https://heinonline.org |holsupport@wshein.com

CITATIONS:

Bluebook 22nd ed.
RJR-MacDonald Inc. v. the Attorney General of Canada and Imperial Tobacco Ltd. v. the Attorney General of Canada and the Attorney General of Quebec and the Attorney General for Ontario et al., 1995 S.C.R. 199 (1995).

ALWD 7th ed.
, RJR-MacDonald Inc. v. the Attorney General of Canada and Imperial Tobacco Ltd. v. the Attorney General of Canada and the Attorney General of Quebec and the Attorney General for Ontario et al., 1995 S.C.R. 199 (1995).

APA 7th ed.
(1995). RJR-MacDonald Inc. v. the Attorney General of Canada and Imperial Tobacco Ltd. v. the Attorney General of Canada and the Attorney General of Quebec and the Attorney General for Ontario et al. Canada Supreme Court Reports, 1995, 199-366.

Chicago 18th ed.
"RJR-MacDonald Inc. v. the Attorney General of Canada and Imperial Tobacco Ltd. v. the Attorney General of Canada and the Attorney General of Quebec and the Attorney General for Ontario et al." Canada Supreme Court Reports 1995: 199-366. HeinOnline.

McGill Guide 10th ed.
"RJR-MacDonald Inc. v. the Attorney General of Canada and Imperial Tobacco Ltd. v. the Attorney General of Canada and the Attorney General of Quebec and the Attorney General for Ontario et al." (1995) 1995 SCR 199.

AGLC 4th ed.
'RJR-MacDonald Inc. v. the Attorney General of Canada and Imperial Tobacco Ltd. v. the Attorney General of Canada and the Attorney General of Quebec and the Attorney General for Ontario et al.' (1995) 1995 Canada Supreme Court Reports 199

MLA 9th ed.
"RJR-MacDonald Inc. v. the Attorney General of Canada and Imperial Tobacco Ltd. v. the Attorney General of Canada and the Attorney General of Quebec and the Attorney General for Ontario et al." Canada Supreme Court Reports, 1995, 1995, pp. 199-366. HeinOnline.

OSCOLA 4th ed.
'RJR-MacDonald Inc. v. the Attorney General of Canada and Imperial Tobacco Ltd. v. the Attorney General of Canada and the Attorney General of Quebec and the Attorney General for Ontario et al.' (1995) 1995 SCR 199

Date Downloaded: Sat May 16 21:55:47 2026

Source: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.cscreports/canadalr0169&id=207

Terms, Conditions & Use of PDF Document:
Please note, citations are provided as a general guideline. Users should consult their preferred citation format's style manual for proper formatting. Your use of this HeinOnline PDF indicates your acceptance of William S. Hein & Co., Inc. and HeinOnline's Terms & Conditions: https://help.heinonline.org/kb/terms-conditions/ . The search text of this PDF is generated from uncorrected OCR text. To obtain permission to use this article beyond the scope of your license, please use: https://www.copyright.com.

Please note: citations are provided as a general guideline. Users should consult their preferred citation format's style manual for proper citation formatting.

HeinOnline is a product of William S. Hein & Co., Inc. | 2350 North Forest Road, Getzville, NY 14068

RJR-MacDonald Inc. *Appellant*

v.

The Attorney General of Canada *Respondent*

and

Imperial Tobacco Ltd. *Appellant*

v.

The Attorney General of Canada *Respondent*

and

The Attorney General of Quebec *Mis-en-cause*

and

The Attorney General for Ontario, the Heart and Stroke Foundation of Canada, the Canadian Cancer Society, the Canadian Council on Smoking and Health, the Canadian Medical Association, and the Canadian Lung Association *Interveners*

INDEXED AS: RJR-MACDONALD INC. *v.* CANADA (ATTORNEY GENERAL)

File Nos.: 23460, 23490.

1994: November 29, 30; 1995: September 21.

Present: Lamer C.J. and La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci and Major JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR QUEBEC

Constitutional law — Division of powers — Charter of Rights — Freedom of expression — Commercial advertising — Cigarette advertising banned — Whether or not legislation validly enacted under criminal law

RJR-MacDonald Inc. *Appelante*

c.

Le procureur général du Canada *Intimé*

et

Imperial Tobacco Ltd. *Appelante*

c.

Le procureur général du Canada *Intimé*

et

Le procureur général du Québec *Mis en cause*

et

Le procureur général de l'Ontario, la Fondation des maladies du cœur du Canada, la Société canadienne du cancer, le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé, l'Association médicale canadienne et l'Association pulmonaire du Canada *Intervenants*

RÉPERTORIÉ: RJR-MACDONALD INC. *c.* CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

Nos du greffe: 23460, 23490.

1994: 29, 30 novembre; 1995: 21 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

Droit constitutionnel — Partage des compétences — Charte des droits — Liberté d'expression — Publicité commerciale — Publicité de la cigarette interdite — Les dispositions législatives ont-elles été validement adop-

power or under peace, order and good government clause — If so, whether or not Act's provisions infringing s. 2(b) Charter right to freedom of expression — If so, whether or not infringements justifiable under s. 1 — Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 1, 2(b) — Constitution Act, 1867, Preamble, s. 91(27) — Tobacco Products Control Act, S.C. 1988, c. 20, ss. 4, 5, 6, 8, 9.

The *Tobacco Products Control Act* (the "Act") broadly prohibited (with specified exceptions) all advertising and promotion of tobacco products and the sale of a tobacco product unless its package includes prescribed unattributed health warnings and a list of toxic constituents. The legislative scheme targeted three distinct categories of commercial activity: advertising, promotion and labelling. The Act, except for a prohibition on the distribution of free samples of tobacco products, did not proscribe the sale, distribution or use of tobacco products.

These proceedings began with two separate motions for declaratory judgments before the Quebec Superior Court. The appellant RJR-MacDonald Inc. sought a declaration that the Act was wholly *ultra vires* Parliament and invalid as an unjustified infringement of freedom of expression guaranteed by s. 2(*b*) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*. The appellant Imperial Tobacco Ltd. sought the same order, but only in respect of ss. 4 and 5 (advertisement of tobacco products), and ss. 6 and 8 (promotion of tobacco products). The two motions were heard together in the Quebec Superior Court which declared the whole of the Act *ultra vires* the Parliament of Canada and as well found it to be of no force or effect as an unjustified infringement of s. 2(*b*) of the *Charter*. The Quebec Court of Appeal reversed this judgment. The constitutional questions considered by this Court queried: (1) whether Parliament had legislative competence to enact the Act under either the peace, order and good government of Canada clause or the criminal law power, and (2) whether the Act infringed the right to freedom of expression protected by s. 2(*b*) of the *Charter* and, if so, whether it was saved under s. 1.

Held (La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier and Cory JJ. dissenting): The appeals should be allowed. The first constitutional question dealing with the legisla-

tées dans le cadre de la compétence en matière de droit criminel ou en vertu de la disposition relative à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement? — Dans l'affirmative, les dispositions de la Loi violent-elles la liberté d'expression garantie à l'art. 2b) de la Charte? — Dans l'affirmative, les violations sont-elles justifiables en vertu de l'article premier? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b) — Loi constitutionnelle de 1867, préambule, art. 91(27) — Loi réglementant les produits du tabac, L.C. 1988, ch. 20, art. 4, 5, 6, 8, 9.

La *Loi réglementant les produits du tabac* (la «Loi») comporte une interdiction générale (sous réserve d'exceptions précises) de toute publicité et promotion en faveur des produits du tabac et de la vente de ces produits à moins que leur emballage ne comporte les mises en garde non attribuées prévues et une liste de leurs substances toxiques. Le régime législatif vise trois catégories distinctes d'activité commerciale: la publicité, la promotion et l'étiquetage. Sauf pour ce qui est de l'interdiction de distribuer des échantillons gratuits, la Loi n'interdit pas la vente, la distribution ou l'usage des produits du tabac.

Les présents litiges ont commencé par deux requêtes distinctes visant à obtenir des jugements déclaratoires devant la Cour supérieure du Québec. L'appelante RJR-MacDonald Inc. a demandé que la Loi soit déclarée complètement *ultra vires* du Parlement du Canada et non valide du fait qu'elle constitue une violation injustifiée de la liberté d'expression garantie à l'al. 2*b*) de la *Charte canadienne des droits et libertés*. L'appelante Imperial Tobacco Ltd. a demandé la même ordonnance, mais seulement relativement aux art. 4 et 5 (publicité en faveur des produits du tabac) et aux art. 6 et 8 (promotion des produits du tabac). Les deux requêtes ont été entendues en même temps par la Cour supérieure du Québec, qui a déclaré l'ensemble de la Loi *ultra vires* du Parlement du Canada et a affirmé que la Loi était inopérante du fait qu'elle constituait une violation injustifiée de l'al. 2*b*) de la *Charte*. La Cour d'appel du Québec a infirmé cette décision. Notre Cour a examiné les questions constitutionnelles visant à déterminer: (1) si le Parlement avait la compétence nécessaire pour adopter la Loi soit pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, soit dans le cadre de sa compétence en matière de droit criminel, et (2) si la Loi porte atteinte à la liberté d'expression garantie à l'al. 2*b*) de la *Charte* et, dans l'affirmative, si elle est sauvegardée par l'article premier.

Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory sont dissidents): Les pourvois sont accueillis. La première question constitutionnelle traitant de la compé-

tive competence of Parliament to enact the legislation under the criminal law power or for the peace, order and good government of Canada should be answered in the positive. With respect to the second constitutional question, ss. 4 (re advertising), 8 (re trade mark use) and 9 (re unattributed health warnings) of the Act are inconsistent with the right of freedom of expression as set out is 2(*b*) of the *Charter* and do not constitute a reasonable limit on that right as can be demonstrably justified pursuant to s. 1 thereof. La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier and Cory JJ. would find that they constitute a reasonable limit. Given that ss. 5 (re retail displays) and 6 (re sponsorships) could not be cleanly severed from ss. 4, 8 and 9, all are of no force or effect pursuant to s. 52 of the *Constitution Act, 1982*.

Division of Powers

(i) *Criminal Law Power*

Per Lamer C.J. and La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin and Iacobucci JJ. (Sopinka and Major JJ. dissenting): The legislation was validly enacted under the criminal law power.

Per Lamer C.J. and La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory and Iacobucci JJ.: The legislation was validly enacted under the criminal law power, and it was accordingly unnecessary to consider whether it fell under the peace, order and good government clause. The criminal law power is plenary in nature, defined broadly, and not frozen in time or confined to a fixed domain of activity. The legislation must not, however, be colourable; some legitimate public purpose must underlie the prohibition.

The *Tobacco Products Control Act* is, in pith and substance, criminal law. Parliament's purpose was to prohibit three categories of acts: advertisement of tobacco products (ss. 4 and 5), promotion of tobacco products (ss. 6 to 8) and sale of tobacco products without printed health warnings (s. 9). The penal sanctions accompanying these prohibitions created a *prima facie* indication that the Act was criminal law. The Act also has an underlying criminal public purpose directed at some injurious effect upon the public — the detrimental health effects caused by tobacco consumption which were clearly demonstrated by the attorney general at trial.

tence du Parlement de légiférer en matière de droit criminel ou pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada reçoit une réponse positive. Pour ce qui est de la seconde question constitutionnelle, les art. 4 (la publicité), 8 (les marques) et 9 (les messages non attribués relatifs à la santé) de la Loi sont incompatibles avec le droit à la liberté d'expression garanti à l'al. 2*b*) de la *Charte* et n'apportent pas une limite raisonnable à l'exercice de ce droit, dont la justification puisse se démontrer au sens de l'article premier. Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory sont d'avis qu'ils apportent une limite raisonnable. Vu que les art. 5 (commerce au détail) et 6 (parrainage) ne peuvent pas nettement être distingués des art. 4, 8 et 9, ils sont tous inopérants aux termes de l'art. 52 de la *Loi constitutionnelle de 1982*.

Partage des compétences

(i) *Compétence en matière de droit criminel*

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci (les juges Sopinka et Major sont dissidents): La loi a été validement adoptée en vertu de la compétence en matière de droit criminel.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: La Loi constitue un exercice valide de la compétence en matière de droit criminel, et il était inutile d'examiner si elle relève de la compétence de légiférer pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement. La compétence en matière de droit criminel est de nature plénière, sa portée est définie largement et sa définition n'est pas gelée à une époque déterminée ni restreinte à un domaine d'activité fixe. La loi ne doit pas être spécieuse; l'interdiction doit se fonder sur un objectif public légitime.

La *Loi réglementant les produits du tabac* est, de par son caractère véritable, une loi en matière de droit criminel. L'objectif du Parlement était d'interdire trois catégories d'actes: la publicité en faveur des produits du tabac (art. 4 et 5), la promotion des produits du tabac (art. 6 à 8) et la vente des produits du tabac dont l'emballage ne comporterait pas de messages relatifs à la santé (art. 9). Les sanctions pénales dont ces interdictions sont assorties créent une indication à première vue que la Loi est de droit criminel. La Loi a également un objectif public sous-jacent du droit criminel dirigé contre un effet nuisible pour le public — les effets nocifs de l'usage du tabac sur la santé, que le procureur général a clairement établis en première instance.

"Health" is not an enumerated head under the *Constitution Act, 1867*, and may be dealt with by valid federal or provincial legislation depending on the circumstances and nature and scope of the problem in question. The protection of health is one of the ordinary ends of the federal criminal law power. The scope of that power includes, for example, the right to legislate with respect to dangerous goods, including health warnings on dangerous goods. This legislation was not colourable. Its purpose is to protect Canadians against the serious health hazards that flow from the consumption of tobacco. Parliament's decision to criminalize tobacco advertisement and promotion is a valid exercise of the criminal law power. The Act has the requisite "criminal public purpose" even though Parliament has not criminalized the "evil" ultimately aimed at but rather an activity ancillary to the "evil". A prohibition upon the sale or consumption of tobacco is not now a practical policy option, given the addictive nature of tobacco products, and the large number of Canadians who smoke. It would be absurd to limit Parliament's power to legislate in this emerging area of public concern simply because it cannot as a practical matter impose a prohibition more specifically aimed at the evil. The constitutionality of such legislation has recently been upheld in other cases.

The legislation, while not serving a "public purpose commonly recognized as being criminal in nature", is nevertheless a valid exercise of the criminal law power. The definition of the criminal law is not "frozen as of some particular time" and the criminal law power includes the power to create new crimes. The existence of exemptions within the legislation does not transform it from criminal to regulatory legislation. Broad status-based exemptions to criminal legislation do not detract from the legislation's criminal nature; they help define the crime by clarifying its contours.

Per McLachlin J.: Parliament may impose advertising bans and require health warnings on tobacco products under its criminal law power.

Per Sopinka and Major JJ.: Section 9 of the *Tobacco Products Control Act* falls within Parliament's power under s. 91(27) of the *Constitution Act, 1867*, but ss. 4, 5, 6, and 8 which prohibit all advertising and promotion

La «santé» n'est pas un chef de compétence énuméré dans la *Loi constitutionnelle de 1867*, et la compétence en cette matière peut validement être exercée dans le cadre de lois fédérales ou provinciales, selon les circonstances et selon la nature et la portée du problème en question. La protection de la santé constitue un des buts habituels de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Cette compétence comprend, par exemple, le droit de légiférer à l'égard des marchandises dangereuses, notamment à l'égard des mises en garde relatives à la santé. La loi en cause n'était pas spécieuse. Elle a pour objet de protéger les Canadiens contre les graves dangers de l'usage du tabac. La décision du Parlement de criminaliser la publicité et la promotion du tabac constitue un exercice valide de sa compétence en matière de droit criminel. La Loi vise un «objectif public du droit criminel» même si le Parlement n'a pas criminalisé le «mal» visé mais plutôt un aspect secondaire du «mal». Une interdiction de vente ou d'usage du tabac ne constitue pas une option politique pratique pour le moment, étant donné la dépendance que suscitent les produits du tabac et le grand nombre de Canadiens qui fument. Il serait absurde de restreindre la compétence du Parlement de légiférer dans ce nouveau domaine d'intérêt public simplement parce qu'il ne peut pas, d'un point de vue pratique, imposer une interdiction visant plus précisément le mal. La constitutionnalité de lois de ce genre a récemment été maintenue.

Bien qu'elle ne serve pas «une fin publique communément reconnue comme étant de nature criminelle» la Loi constitue néanmoins un exercice valide de la compétence en matière de droit criminel. La définition du droit criminel n'est pas «gelé[e] à une époque déterminée», et la compétence de légiférer en matière de droit criminel comprend celle de définir de nouveaux crimes. Le fait qu'il existe des exemptions dans une loi n'en fait pas un texte réglementaire plutôt qu'un texte relevant du droit criminel. La création d'une exemption générale, fondée sur le statut, à l'application d'une loi en matière criminelle n'a pas pour effet d'enlever à la loi son caractère de droit criminel, elle contribue plutôt à définir l'infraction en en clarifiant les particularités.

Le juge McLachlin: En vertu de sa compétence en matière de droit criminel, le Parlement peut imposer des interdictions sur la publicité et exiger l'apposition de mises en garde relatives à la santé sur les produits du tabac.

Les juges Sopinka et Major: L'article 9 de la *Loi réglementant les produits du tabac* relève de la compétence du Parlement en vertu du par. 91(27) de la *Loi constitutionnelle de 1867*, mais les art. 4, 5, 6 et 8, qui

of tobacco products and restrict the use of tobacco trademarks, do not. The criminal law power encompasses the right to legislate against dangerous foods and drugs, including tobacco products. Manufacturers of tobacco products are under a duty to disclose and warn of the dangers inherent in the consumption of tobacco products and failure to do so can validly constitute a crime.

The prohibition of conduct which interferes with the proper functioning of society or which undermines the safety and security of society as a whole lies at the heart of the criminal law. Matters posing a significant and serious risk of harm or causing significant and serious harm to public health, safety or security can be proscribed by Parliament as criminal. Lesser threats to society and its functioning are addressed through non-criminal regulation.

Care must be taken not to overstate the objective because its importance may be exaggerated and the analysis compromised. The objective of the advertising ban and trade mark usage restrictions is to prevent Canadians from being persuaded by advertising and promotion to use tobacco products.

The undesirability of this form of expression does not pose such a grave and serious danger to public health as to make it criminal. The Act lacked a typically criminal public purpose and is too far removed from the injurious or undesirable effects of tobacco use to constitute a valid exercise of the criminal law power. Those areas where ancillary activities have been criminalized, rather than the core activity itself, concern matters which have traditionally been subject to criminal sanctions and pose significant and serious dangers in and of themselves. Parliament could have criminalized tobacco use but chose not to.

Broad-based exemptions are a factor which may lead a court to conclude that the proscribed conduct is not truly criminal. The prohibitions on advertising cannot be upheld as a valid exercise of the criminal law power given the broad-based exemptions allowing for tobacco advertising in imported publications and given that the Act does not engage a typically criminal public purpose.

interdisent toute publicité et promotion en faveur des produits du tabac et restreignent l'utilisation des marques de tabac, n'en relèvent pas. La compétence en matière de droit criminel comprend le droit de légiférer contre les produits dangereux et les drogues, y compris les produits du tabac. Les fabricants de produits du tabac ont l'obligation de mettre en garde contre les dangers inhérents à la consommation du tabac, et l'omission de le faire peut validement constituer un crime

L'interdiction de tout comportement qui entrave le bon fonctionnement de la société ou qui compromet la sécurité de la société dans son ensemble est au cœur du droit criminel. Tout ce qui pose un risque de préjudice grave et important ou qui entraîne pour la sécurité et la santé du public un préjudice grave ou important peut être interdit par le Parlement comme relevant du droit criminel. Les menaces moins graves pour la société et son fonctionnement sont ciblées dans les régimes de réglementation qui ne relèvent pas du droit criminel.

Il faut veiller à ne pas surestimer l'objectif parce qu'on risque d'en exagérer l'importance et d'en compromettre l'analyse. L'objectif de l'interdiction de publicité et des restrictions à l'usage des marques est d'empêcher la population canadienne de se laisser convaincre par la publicité et la promotion de faire usage du tabac.

Le fait que cette forme d'expression soit indésirable ne présente pas un risque grave et important pour la santé publique au point de la rendre criminelle. La Loi est dénuée d'un objectif public habituellement reconnu du droit criminel et est trop éloignée des effets nocifs ou indésirables de l'utilisation du tabac pour constituer un exercice valide de la compétence en matière de droit criminel. Les domaines où les activités secondaires ont été criminalisées, plutôt que l'activité principale même, portent sur des sujets qui ont toujours fait l'objet de sanctions pénales et comportent en soi des dangers graves et importants. Le Parlement aurait pu criminaliser l'usage du tabac, mais il a choisi de ne pas le faire.

L'existence d'exemptions générales est un facteur qui peut mener un tribunal à conclure que le comportement interdit n'est pas véritablement criminel. L'interdiction de publicité ne peut pas être maintenue à titre d'exercice valide de la compétence en matière de droit criminel compte tenu des exemptions générales qui permettent la publicité en faveur du tabac dans les publications importées et du fait que la Loi ne relève pas d'un objectif public habituellement reconnu du droit criminel.

Charter Issues

(i) *Infringement*

Per Lamer C.J. and La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci and Major JJ.: The impugned sections infringed freedom of expression guaranteed in s. 2(b) of the Charter.

Per La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier and Cory JJ.: The prohibition on advertising and promotion under the Act infringed appellants' right to freedom of expression under s. 2(*b*) of the *Charter*.

Per Lamer C.J. and Sopinka, McLachlin, Iacobucci and Major JJ.: The prohibition on advertising and promotion of tobacco products violated the right to free expression. Since freedom of expression necessarily entails the right to say nothing or the right not to say certain things, the requirement that tobacco manufacturers place an unattributed health warning on tobacco packages combined with the prohibition against displaying any writing on their packaging other than the name, brand name, trade mark, and other information required by legislation too infringed this right. Section 7, which prohibits the free distribution of any tobacco product in any form, is closely connected to the law's objective and should stand.

(ii) *Section 1 Analysis*

Per Lamer C.J. and Sopinka, McLachlin, Iacobucci and Major JJ.: The impugned sections were not justified under s. 1 of the Charter. La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier and Cory JJ. would have found the impugned sections justified and therefore saved under s. 1.

Per Sopinka, McLachlin and Major JJ.: The appropriate test in a s. 1 analysis is that found in s. 1 itself: whether the infringement is reasonable and demonstrably justified in a free and democratic society. No conflict exists between the words of s. 1 and the jurisprudence founded upon *Oakes*. The word "demonstrably" in s. 1 is critical: the process is neither one of mere intuition nor of deference to Parliament's choice. While remaining sensitive to the social and political context of the impugned law and allowing for difficulties of proof inherent in that context, the courts must nevertheless insist that, before the state can override constitutional rights, there be a reasoned demonstration of the good

Questions relatives à la *Charte*

(i) *Violation*

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Les dispositions contestées violent la liberté d'expression garantie à l'al. 2b) de la Charte.

Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory: L'interdiction de publicité et de promotion imposée par la Loi viole le droit des appelantes à la liberté d'expression garanti à l'al. 2*b*) de la *Charte*.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin, Iacobucci et Major: L'interdiction imposée sur la publicité et la promotion des produits du tabac constitue une violation du droit à la liberté d'expression. Comme la liberté d'expression comporte nécessairement le droit de ne rien dire ou encore le droit de ne pas dire certaines choses, l'obligation imposée aux fabricants de tabac d'inscrire sur les emballages des produits du tabac des messages non attribués relatifs à la santé, conjuguée à l'interdiction d'apposer sur l'emballage d'un produit des mentions autres que la désignation, le nom, la marque et les renseignements prévus par une loi, constitue une violation de ce droit. L'article 7, qui interdit la distribution gratuite des produits du tabac, sous quelque forme que ce soit, se rattache étroitement à l'objectif de la loi et devrait être déclaré valide.

(ii) *Analyse relative à l'article premier*

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin, Iacobucci et Major: Les dispositions contestées ne sont pas justifiées en vertu de l'article premier de la Charte. Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory auraient conclu que les dispositions contestées étaient justifiées et qu'elles étaient par conséquent sauvegardées par l'article premier.

Les juges Sopinka, McLachlin et Major: Le critère approprié applicable à une analyse fondée sur l'article premier se trouve dans la disposition même et consiste à déterminer si la violation est raisonnable et peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. Il n'existe pas d'incompatibilité entre le libellé de l'article premier et la jurisprudence fondée sur l'arrêt *Oakes*. Les mots «puisse se démontrer» sont importants. En effet, il ne s'agit pas de procéder par simple intuition ou d'affirmer qu'il faut avoir de l'égard pour le choix du Parlement. Bien qu'ils doivent demeurer conscients du contexte socio-politique de la loi attaquée et reconnaître les difficultés qui y sont propres en matière de preuve, les

which the law may achieve in relation to the seriousness of the infringement.

Context, deference and a flexible and realistic standard of proof are essential aspects of the s. 1 analysis. The *Oakes* test must be applied flexibly, having regard to the factual and social context of each case. This contextual approach does not reduce the obligation on the state to demonstrate that the limitation on rights imposed by the law is reasonable and justified. The deference accorded to Parliament may vary with the social context but must not be carried to the point of relieving the government of its *Charter*-based burden of demonstrating the limits it has imposed on guaranteed rights to be reasonable and justifiable. To do so would diminish the role of the courts in the constitutional process and weaken the structure of rights. The civil standard of proof on a balance of probabilities at all stages of the proportionality analysis is more appropriate.

Courts of appeal, as a general rule, decline to interfere with findings of fact by a trial judge unless they are unsupported by the evidence or based on clear error. In the context of the s. 1 analysis, more deference may be required where findings are based on evidence of a purely factual nature whereas a lesser degree of deference may be required where the trial judge has considered social science and other policy-oriented evidence. Appellate courts generally are not as constrained by the trial judge's findings in the context of the s. 1 analysis as they are in the course of non-constitutional litigation because the impact of the infringement on constitutional rights must often be assessed by reference to a broad review of social, economic and political factors in addition to scientific facts.

The objective should not be overstated. The objective relevant to the s. 1 analysis is that of the infringing measure, since only the infringing measure must be justified. If the objective is stated too broadly, its importance may be exaggerated and the analysis compromised. The objective of the impugned measures, however, is somewhat narrower than the objectives of the wider legisla-

tribunaux doivent néanmoins insister pour que, avant qu'il ne supprime un droit protégé par la Constitution, l'État fasse une démonstration raisonnée du bien visé par la loi par rapport à la gravité de la violation.

Les concepts de contexte, de respect et d'application d'une norme de preuve souple et réaliste sont des aspects essentiels de l'analyse fondée sur l'article premier. Le critère formulé dans *Oakes* doit être appliqué avec souplesse, compte tenu du contexte factuel et social de chaque cas particulier. Cette analyse contextuelle n'a pas pour effet de diminuer l'obligation qu'a l'État de démontrer que la restriction des droits est raisonnable et justifiée. Le respect accordé au Parlement peut varier en fonction du contexte social, mais il ne doit pas aller jusqu'au point de libérer le gouvernement de l'obligation que la *Charte* lui impose de démontrer que les restrictions qu'il apporte aux droits garantis sont raisonnables et justifiables. Agir ainsi reviendrait à diminuer le rôle des tribunaux à l'intérieur du processus constitutionnel et à affaiblir la structure des droits. La norme de preuve qui convient, à toutes les étapes de l'analyse de la proportionnalité, est celle qui s'applique en matière civile, c'est-à-dire la preuve selon la prépondérance des probabilités.

En règle générale, une cour d'appel refuse de modifier les conclusions de fait du juge de première instance, sauf si ces conclusions ne s'appuient pas sur la preuve ou sont fondées sur une erreur manifeste. Dans le contexte de l'analyse fondée sur l'article premier, il pourrait bien être nécessaire de faire preuve d'une plus grande retenue à l'égard de conclusions fondées sur une preuve de nature purement factuelle, qu'à l'égard de conclusions que le juge de première instance aurait tirées après l'examen de la preuve en matière de sciences humaines et d'autres questions de principe. En règle générale, dans le contexte d'une analyse fondée sur l'article premier, une cour d'appel n'est pas liée par les conclusions du juge de première instance au même degré qu'elle l'est dans le cadre d'un litige de nature non constitutionnelle, puisque l'incidence de la violation sur les droits constitutionnels doit souvent être évaluée dans le cadre d'un vaste examen de facteurs sociaux, économiques et politiques, qui vient s'ajouter à celui de faits scientifiques.

Il faut veiller à ne pas surestimer l'objectif. Aux fins d'une analyse fondée sur l'article premier, l'objectif pertinent est celui de la mesure attentatoire puisque c'est cette dernière que l'on cherche à justifier. Si l'on formule l'objectif d'une façon trop large, on risque d'en exagérer l'importance et d'en compromettre l'analyse. Cependant, l'objectif des mesures contestées est un peu

tive and policy scheme in which the Act is found. The advertising ban and trade mark usage restrictions are to prevent people in Canada from being persuaded by advertising and promotion to use tobacco products. The mandatory package warning is to discourage people who see the package from tobacco use. Both constitute important objectives. The critical question, however, is not the evil tobacco works generally in our society, but the evil which the legislation addresses.

The extent to which this Court should defer to the trial judge's findings depends on whether the findings relate to purely factual matters or whether they relate to complex social science evidence from which it is difficult to draw firm factual and scientific conclusions. Less deference should be accorded to the trial judge's finding that the complete ban on advertising was not rationally connected to the aim of reducing advertising-induced consumption. Much of the evidence adduced on this point was social science evidence predictive of human behaviour from which it was difficult to draw firm factual conclusions.

The impugned provisions mandating a complete ban and unattributed package warnings do not minimally impair the right to free expression. Under the minimal impairment analysis, the trial judge did not rely on problematic social science data, but on the fact that the government had adduced no evidence to show that less intrusive regulation would not achieve its goals as effectively as an outright ban. Nor had the government adduced evidence to show that attributed health warnings would not be as effective as unattributed warnings on tobacco packaging.

The causal relationship between the infringement of rights and the benefit sought may sometimes be proved by scientific evidence showing that as a matter of repeated observation, one affects the other. Where, however, legislation is directed at changing human behaviour, as in the case of the *Tobacco Products Control Act*, the causal relationship may not be scientifically

plus restreint que les objectifs plus vastes du régime complexe dans lequel s'inscrit la Loi sur le plan législatif et sur celui des principes. L'interdiction de publicité et les restrictions à l'usage des marques visent à empêcher la population canadienne de se laisser convaincre par la publicité et la promotion de faire usage du tabac. L'objectif de la mise en garde obligatoire est de dissuader les gens qui voient l'emballage de faire usage du tabac. Dans les deux cas, il s'agit d'objectifs importants. La question cruciale, toutefois, n'est pas le mal que le tabac cause dans l'ensemble de notre société, mais bien le mal auquel s'attaque la loi.

La mesure dans laquelle notre Cour devrait faire preuve de retenue à l'égard des conclusions du juge de première instance dépend de la réponse à la question de savoir si les conclusions se rapportent à des questions purement factuelles ou à des éléments de preuve complexes en matière de sciences humaines à partir desquels il est difficile de tirer de solides conclusions factuelles et scientifiques. Il y a lieu de faire preuve d'une moins grande retenue à l'égard de la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'interdiction totale de publicité n'avait pas de lien rationnel avec l'objectif de diminution de la consommation provoquée par la publicité. La majeure partie de la preuve présentée sur ce point consistait en des données en matière de sciences humaines concernant le comportement humain prévisible, à partir desquelles il était difficile de tirer de solides conclusions factuelles.

Les dispositions attaquées, qui interdisent toute publicité et exigent l'apposition de mises en garde non attribuées sur les emballages, ne constituent pas une atteinte minimale à la liberté d'expression. Dans le cadre de l'analyse de l'atteinte minimale, le juge de première instance ne s'est pas fié à des données problématiques en matière de sciences humaines mais plutôt au fait que le gouvernement n'avait pas présenté d'éléments de preuve établissant qu'un règlement moins attentatoire n'atteindrait pas ses objectifs aussi efficacement qu'une interdiction totale. Le gouvernement n'avait pas non plus présenté d'éléments de preuve pour établir que des mises en garde attribuées sur les emballages des produits du tabac ne seraient pas aussi efficaces que des mises en garde non attribuées.

Le lien causal entre l'atteinte aux droits et l'avantage recherché peut parfois être établi par une preuve scientifique démontrant, à la suite d'une observation répétée, que l'un influe sur l'autre. Par contre, dans les cas où une loi vise une modification du comportement humain, comme dans le cas de la *Loi réglementant les produits du tabac*, le lien causal pourrait bien ne pas être mesura-

measurable. In such cases, this Court has been prepared to find a causal connection between the infringement and benefit sought on the basis of reason or logic, without insisting on direct proof of a relationship between the infringing measure and the legislative objective. Here, no direct evidence of a scientific nature showed a causal link between advertising bans and decrease in tobacco consumption. A link, established on a balance of probabilities and based on reason, existed between certain forms of advertising, warnings and tobacco consumption. No causal connection existed however, whether based on direct evidence or logic and reason, between the objective of decreasing tobacco consumption and s. 8's absolute prohibition on the use of a tobacco trade mark on articles other than tobacco products. Section 8 failed the rational connection test.

A complete ban on a form of expression is more difficult to justify than a partial ban. The government must show that only a full prohibition will enable it to achieve its objective. Where, as here, no evidence is adduced to show that a partial ban would be less effective than a total ban, the justification required by s. 1 to save the violation of free speech is not established.

As a matter of reason and logic, lifestyle advertising is designed to increase consumption. Purely informational or brand preference advertising, however, has not been shown to have this effect. Several less intrusive alternative measures would be a reasonable impairment of the right to free expression, given the important objective and the legislative context.

Allowing Parliament to choose such measures as it sees fit by contrasting the importance of Parliament's objective with the low value of the expression at issue raises a number of concerns. First, to argue that the importance of the legislative objective justifies more deference to the government at the stage of evaluating minimal impairment, is to engage in the balancing between objective and deleterious effect contemplated by the third stage of the proportionality analysis in *Oakes*. Second, just as care must be taken not to overvalue the legislative objective beyond its actual parameters, so care must be taken not to undervalue the expression at issue. Third, a great deal of reliance is placed on the fact that the appellants are motivated by profit. Motivation to profit is irrelevant to the determination of

ble du point de vue scientifique. Dans ces cas, notre Cour s'est montrée disposée à reconnaître l'existence d'un lien causal entre la violation et l'avantage recherché sur le fondement de la raison ou de la logique, sans insister sur la nécessité d'une preuve directe de lien entre la mesure attentatoire et l'objectif législatif. En l'espèce, il n'existait aucune preuve directe de nature scientifique de l'existence d'un lien causal entre une interdiction de publicité et la diminution de l'usage du tabac. On a établi, suivant la prépondérance des probabilités, l'existence d'un lien fondé sur la raison entre certaines formes de publicité, les mises en garde et l'usage du tabac. Cependant, il n'existait pas de lien causal, fondé sur une preuve directe ou sur la logique ou la raison, entre l'objectif de diminution de l'usage du tabac et l'interdiction absolue, imposée par l'art. 8, quant à l'usage des marques sur des articles autres que les produits du tabac. L'article 8 ne satisfait pas au critère du lien rationnel.

Il est plus difficile de justifier l'interdiction totale d'une forme d'expression que son interdiction partielle. Le gouvernement doit établir que seule une interdiction totale lui permettra d'atteindre son objectif. Si, comme en l'espèce, aucune preuve n'a été présentée pour démontrer qu'une interdiction partielle serait moins efficace qu'une interdiction totale, on n'a pas établi la justification requise en vertu de l'article premier visant à sauvegarder la violation de la liberté d'expression.

D'un point de vue rationnel et logique, la publicité de style de vie vise à accroître la consommation, mais rien n'indique que la publicité purement informative ou de fidélité aux marques a cet effet. Plusieurs autres mesures, par ailleurs moins envahissantes, constitueraient une atteinte raisonnable au droit à la liberté d'expression, étant donné l'importance de l'objectif et du contexte législatif.

Permettre au Parlement de choisir les mesures qu'il juge appropriées en comparant l'importance de l'objectif qu'il vise et la faible valeur de l'expression en cause soulève certaines préoccupations. Premièrement, soutenir que l'importance de l'objectif législatif justifie un plus grand respect envers le gouvernement à l'étape de l'évaluation de l'atteinte minimale, c'est procéder à la pondération des effets objectifs et des effets préjudiciables, prévue à la troisième étape de l'analyse de la proportionnalité dans l'arrêt *Oakes*. Deuxièmement, tout comme il faut prendre soin de ne pas surestimer l'objectif législatif par rapport à ses véritables paramètres, il faut veiller à ne pas sous-estimer l'importance de l'expression en cause. Troisièmement, une grande importance est accordée au fait que les appelantes sont moti-

whether the government has established that the law is reasonable or justified as an infringement of freedom of expression.

The requirement that the warning be unattributed pursuant to s. 9 of the Act fails to meet the minimum impairment requirement of proportionality. The government is clearly justified in requiring the appellants to place warnings on tobacco packaging. For the reasons given with respect to the advertising ban, a lower level of constitutional scrutiny is not justified in deciding whether it was necessary to prohibit the appellants from attributing the message to the government and whether it was necessary to prevent the appellants from placing on their packaging any information other than that allowed by the regulations.

Per Lamer C.J. and Iacobucci J.: The *Tobacco Products Control Act* did not minimally impair the appellants' s. 2(*b*) *Charter* rights. An attenuated minimal impairment analysis could unduly dilute the s. 1 principles as originally cast in *Oakes* and related cases creating the risk that *Charter* violations would be too easily justified, with the result that *Charter* values would be too easily undercut.

The Act was rationally connected to its goal of protecting Canadians from the health risks associated with tobacco use. Rational connection is to be established, upon a civil standard, through reason, logic or common sense. The existence of scientific proof is simply of probative value in demonstrating this reason, logic or common sense but is by no means dispositive or determinative. The Act, however, was not "social engineering". Agreement was expressed with the approach described by La Forest J. relative to appellate court intervention on legislative or social facts found by a trial judge.

Minimal impairment analysis requires consideration of whether or not the legislature turned its mind to alternative and less rights-impairing means to promote its legislative goal. Here, evidence related to the options considered as alternatives to the total ban was withheld from the factual record. In cases like these involving wide public interest constitutional litigation, government should remain non-adversarial and make full disvées par le profit. La volonté de faire un profit ne constitue pas une considération pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si le gouvernement a établi que la loi est raisonnable ou justifiée en tant qu'atteinte à la liberté d'expression.

L'exigence de la non-attribution des mises en garde, prévue à l'art. 9 de la Loi, ne satisfait pas à l'exigence de l'atteinte minimale de la proportionnalité. Le gouvernement est clairement justifié d'exiger des appelantes qu'elles apposent des mises en garde sur les emballages des produits du tabac. Pour les motifs exposés relativement à l'interdiction de publicité, il n'est pas justifié de procéder à une analyse constitutionnelle moins approfondie afin de décider s'il était nécessaire d'interdire aux appelantes d'attribuer le message au gouvernement et s'il était nécessaire de les empêcher d'apposer sur leur emballage des renseignements autres que ceux autorisés par règlement.

Le juge en chef Lamer et le juge Iacobucci: La *Loi réglementant les produits du tabac* ne constitue pas une atteinte minimale aux droits garantis aux appelantes par l'al. 2*b*) de la *Charte*. Une analyse assouplie de l'atteinte minimale risque de trop diluer les principes d'application de l'article premier par rapport à leur formulation initiale dans l'arrêt *Oakes* et les arrêts connexes, créant ainsi un risque que les violations de la *Charte* ne soient trop facilement justifiées et, de ce fait, que les valeurs protégées par la *Charte* ne soient trop facilement contrecarrées.

La Loi a un lien rationnel avec son objectif de protéger les Canadiens contre les méfaits de l'usage du tabac sur la santé. Le lien rationnel doit être établi, selon la norme de preuve en matière civile, par la raison, la logique ou le simple bon sens. L'existence d'une preuve scientifique n'a une valeur probante que lorsqu'il s'agit d'établir la raison, la logique ou le bon sens, mais elle n'est en aucune façon déterminante. Toutefois, la Loi n'est pas une forme d'«ingénierie sociale». La méthode décrite par le juge La Forest relativement à l'intervention des cours d'appel en ce qui concerne les faits législatifs ou sociaux constatés par le juge de première instance est acceptée.

Dans l'analyse de l'atteinte minimale, il faut déterminer si le législateur a examiné d'autres mesures moins attentatoires pour atteindre l'objectif législatif en question. En l'espèce, des éléments de preuve concernant les options envisagées comme solutions de rechange à l'interdiction totale ont été supprimés du dossier de la preuve factuelle. Dans les cas où, comme en l'espèce, il s'agit d'un litige d'un grand intérêt public en matière

closure. The total prohibition on advertising (the full rights-impairing option) is only constitutionally acceptable if information is provided that such a total prohibition is necessary in order for the legislation to achieve a pressing and substantial goal. When the evidence is unclear whether a partial prohibition is as effective as a full prohibition, the *Charter* requires that the legislature enact the partial denial of the implicated *Charter* right. The tailoring required to meet minimal impairment was not significant and yet very necessary to the Act's being constitutional.

Section 9 of the Act, requiring the placing of unattributed health warnings, infringed s. 2(*b*) and was unjustifiable under s. 1 for the reasons of McLachlin J. Sections 4, 5, 6 and 8 should also be struck. Proof might exist for this total and absolute ban on advertising, but without it, there is no justifiable basis for this ban.

Per La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier and Cory JJ.: The infringement was justifiable under s. 1. Protecting Canadians from the health risks associated with tobacco use, and informing them about these risks, is a pressing and substantial objective. It meets the two broad criteria set forth in *Oakes*. First, its objective is of sufficient importance to override a guaranteed right. Second, it meets the proportionality requirements established in *Oakes*. These requirements are not synonymous with nor have they been superseded by those set forth in s. 1 of the *Charter*. The appropriate "test" is that found in s. 1 itself. The courts are to determine whether an infringement is reasonable and can be demonstrably justified in a "free and democratic society" and must strike a delicate balance between individual rights and community needs. This balance cannot be achieved in the abstract, with reference solely to a formalistic "test" uniformly applicable in all circumstances. The section 1 inquiry is an unavoidably normative inquiry, requiring the courts to take into account both the nature of the infringed right and the specific values and principles upon which the state seeks to justify the infringement. An important "synergetic relation" exists between *Charter* rights and the context in which they are claimed. The *Oakes* requirements therefore must be applied flexibly, having regard to the specific factual and social context of each case. A rigid or formalistic approach should be

constitutionnelle, le gouvernement ne devrait pas s'en tenir à un débat contradictoire et devrait faire une pleine divulgation. L'interdiction totale de publicité (l'option pleinement attentatoire aux droits) n'est acceptable du point de vue constitutionnel que s'il existe des renseignements établissant qu'une telle interdiction est nécessaire pour qu'un objectif urgent et réel de la loi soit atteint. Si la preuve ne permet pas d'établir clairement si une interdiction partielle est aussi efficace qu'une interdiction totale, la *Charte* exige que le législateur opte pour la mesure qui constitue une atteinte partielle au droit qui y est garanti. Les adaptations qui s'imposent pour satisfaire au critère de l'atteinte minimale ne sont pas importantes, mais elles sont tout à fait nécessaires pour rendre la loi constitutionnelle.

L'article 9 de la Loi, qui exige l'apposition de messages non attribués, viole l'al. 2*b*) et n'est pas justifiable en vertu de l'article premier pour les motifs formulés par le juge McLachlin. Les articles 4, 5, 6 et 8 devraient aussi être annulés. Il existe peut-être une preuve appuyant cette interdiction totale et absolue de la publicité, mais sans cette preuve, l'interdiction n'est pas justifiable.

Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory: La violation était justifiable en vertu de l'article premier. Protéger les Canadiens contre les conséquences néfastes du tabac sur la santé et les sensibiliser à ces conséquences constitue un objectif urgent et réel. Cette mesure satisfait aux deux critères généraux énoncés dans *Oakes*. Premièrement, son objectif est suffisamment important pour l'emporter sur un droit garanti. Deuxièmement, cet objectif répond aux exigences de la proportionnalité formulées dans *Oakes*. Ces exigences ne sont pas comparables à celles applicables à l'article premier de la *Charte* ni ne les ont remplacées. Le «critère» approprié se trouve dans l'article premier même. Les tribunaux doivent déterminer si la limite est raisonnable et si elle peut se démontrer dans le cadre d'une «société libre et démocratique», et ils doivent établir un équilibre délicat entre les droits individuels et les besoins de la collectivité. Un tel équilibre ne peut être établi dans l'abstrait, à partir seulement d'un «critère» formaliste qui s'appliquerait de façon uniforme dans toutes les circonstances. L'examen fondé sur l'article premier est un examen inévitablement normatif qui exige des tribunaux qu'ils tiennent compte de la nature du droit violé ainsi que des valeurs et des principes spécifiques à partir desquels l'État tente de justifier la violation. Il existe un important «rapport synergique» entre les droits garantis par la *Charte* et le contexte de l'instance particulière. Les exigences formulées dans *Oakes* doivent donc être appliquées avec souplesse en tenant

avoided in order to overcome the risk of losing sight of this relation.

The evidentiary requirements under s. 1 vary substantially depending upon both the nature of the legislation and the nature of the right infringed. Here, both these contextual elements were highly relevant to a proper application of the s. 1 analysis. The application of a "rigorous" civil standard of proof below resulted in a failure to take into account the specific context in which the s. 1 balancing must take place.

The nature and scope of the health problems raised by tobacco consumption are highly relevant to the s. 1 analysis, both in determining the appropriate standard of justification and in weighing the relevant evidence. Despite the lack of definitive scientific explanations of the causes of tobacco addiction, clear evidence does exist of the detrimental social effects of tobacco consumption. Overwhelming evidence was introduced at trial that tobacco consumption is a principal cause of deadly cancers, heart disease and lung disease, and that tobacco is highly addictive. The most distressing aspect of the evidence is that tobacco consumption is most widespread among the most vulnerable, the young and the less educated, at whom much of the advertising is specifically directed.

The significant gap between an understanding of the health effects of tobacco consumption and of the root causes of tobacco consumption raises a fundamental institutional problem that must be taken into account in undertaking the s. 1 balancing. Strictly applying the proportionality analysis in cases of this nature would place an impossible onus on Parliament by requiring it to produce definitive social scientific evidence respecting the root causes of a pressing area of social concern whenever Parliament wished to address its effects. This would have the effect of virtually paralyzing the operation of government in the socio-economic sphere. To require Parliament to await definitive social science conclusions whenever it wishes to make social policy would impose an unjustifiable and unrealistic limit on legislative power.

compte du contexte factuel et social particulier de chaque cas. Il faut éviter d'utiliser une méthode rigide ou formaliste si l'on veut écarter le risque qu'il ne soit pas tenu compte de ce rapport.

Les exigences en matière de preuve sous le régime de l'article premier varient beaucoup en fonction de la nature de la loi et du caractère du droit atteint. En l'espèce, ces deux éléments contextuels sont fort pertinents pour une bonne application de l'analyse fondée sur l'article premier. L'application «rigoureuse» du fardeau de la preuve en matière civile par les instances inférieures a fait en sorte que l'on n'a pas tenu compte du contexte spécifique dans lequel doit se dérouler la pondération en vertu de l'article premier.

La nature et l'étendue des problèmes de santé reliés à l'usage du tabac sont tout à fait pertinents pour l'analyse fondée sur l'article premier, tant aux fins de la détermination du critère approprié de justification que dans l'appréciation de la preuve pertinente. Malgré l'absence d'explications scientifiques concluantes des causes de la dépendance au tabac, il existe des éléments de preuve clairs sur les effets sociaux préjudiciables de l'usage du tabac. On a présenté en première instance une preuve abondante établissant que l'usage du tabac est une cause principale de cancers, de maladies cardiaques et de maladies pulmonaires entraînant la mort, et que le tabac crée une forte dépendance. L'aspect le plus troublant de la preuve est que l'usage du tabac est plus répandu chez les personnes les plus vulnérables, soit les jeunes et les personnes moins instruites, vers qui une grande partie de la publicité est expressément dirigée.

L'écart important entre ce que nous comprenons des effets de l'usage du tabac sur la santé et des principales causes de cet usage soulève un problème institutionnel fondamental dont il faut tenir compte dans la pondération effectuée en application de l'article premier. Une application stricte de l'analyse de la proportionnalité dans les affaires de cette nature imposerait un fardeau impossible au Parlement puisqu'il serait alors tenu de produire des éléments de preuve socio-scientifiques concluants relativement aux causes fondamentales d'un problème urgent d'intérêt social chaque fois qu'il désire s'attaquer à ses effets. Cela aurait pour effet de pratiquement paralyser le fonctionnement de l'appareil gouvernemental dans la sphère socio-économique. Si l'on exigeait du Parlement qu'il attende les données concluantes des études dans le domaine des sciences humaines chaque fois qu'il désire adopter une politique sociale, on restreindrait la compétence législative de façon injustifiable et irréaliste.

The Court has recognized that the *Oakes* standard of justification should be attenuated when institutional constraints analogous to those in the present cases arise. Although courts are specialists in the protection of liberty and the interpretation of legislation and are, accordingly, well placed to subject criminal justice legislation to careful scrutiny — that is not so in the sphere of policy-making. Policy-making is a role properly assigned to elected parliamentarians who have the necessary institutional resources to enable them to compile and assess social science evidence, to mediate between competing social interests and to reach out and protect vulnerable groups. In according a greater degree of deference to social legislation than to ordinary criminal justice legislation, the courts recognize these important institutional differences. The Act in issue is the type of legislation generally accorded a high degree of deference and the considerations addressed in *Irwin Toy* and *McKinney* are applicable.

Expression, depending on its nature, is entitled to varying levels of constitutional protection and requires a contextual, as opposed to an abstract, approach. Although freedom of expression is a fundamental value, other fundamental values are also deserving of protection and consideration by the courts. When these values come into conflict, the courts must make choices based not upon abstract analysis, but upon a concrete weighing of the relative significance of each of the relevant values in our community in the specific context. Freedom of expression claims must be weighed in light of their relative connection to a set of even more fundamental or core values which include the search for political, artistic and scientific truth, the protection of individual autonomy and self-development, and the promotion of public participation in the democratic process. State action placing such values in jeopardy is subject to a searching degree of scrutiny. Where the expression in question is farther from the "core" of freedom of expression values, a lower standard of justification may be applied.

The harm engendered by tobacco and the profit motive underlying its promotion place this form of expression as far from the "core" of freedom of expression values as prostitution, hate-mongering and pornography. Its sole purpose is to promote the use of a product that is harmful and often fatal to the consumer by sophisticated advertising campaigns often specifically

La Cour a reconnu qu'il y aurait lieu d'assouplir le critère de justification formulé dans *Oakes* en présence de contraintes institutionnelles semblables à celles qui existent en l'espèce. Bien que les tribunaux soient des spécialistes de la protection de la liberté et de l'interprétation des lois et que, par conséquent, ils soient bien placés pour faire un examen approfondi des lois en matière de justice criminelle, ce n'est pas le cas dans le domaine de l'élaboration des politiques. Ce dernier rôle incombe aux parlementaires élus, qui disposent des ressources institutionnelles nécessaires pour recueillir et examiner la documentation en matière de sciences humaines, arbitrer entre des intérêts sociaux opposés et assurer la protection des groupes vulnérables. Lorsqu'ils font preuve d'une plus grande retenue à l'égard des lois à caractère social qu'à l'égard des lois ordinaires en matière de justice criminelle, les tribunaux reconnaissent ces différences institutionnelles importantes. La Loi est le type de loi envers laquelle on fait généralement preuve d'une grande retenue, et les considérations examinées dans les arrêts *Irwin Toy* et *McKinney* sont applicables.

L'expression, selon sa nature, pourra bénéficier de divers degrés de protection constitutionnelle et l'on doit recourir à une méthode contextuelle, et non abstraite. Bien que la liberté d'expression soit une valeur fondamentale, il en existe d'autres qui méritent aussi d'être protégées et examinées par les tribunaux. En cas de conflit entre ces valeurs, les tribunaux sont appelés à faire des choix fondés non pas sur une analyse abstraite, mais sur une appréciation concrète de l'importance relative de chacune des valeurs pertinentes dans notre collectivité dans le contexte en question. Les demandes touchant la liberté d'expression doivent être examinées en fonction du lien relatif qu'elles ont avec des valeurs encore plus fondamentales, dont la découverte de la vérité dans les affaires politiques et dans les entreprises scientifiques et artistiques, la protection de l'autonomie et de l'enrichissement personnels et la promotion de la participation du public au processus démocratique. Lorsque les mesures gouvernementales menacent ces valeurs, elles doivent être examinées rigoureusement. Lorsque l'expression en cause s'écarte beaucoup de l'«essence» des valeurs de la liberté d'expression, le critère de justification appliqué peut être moins rigide.

Les maux engendrés par le tabac et la volonté de faire des profits qui en sous-tend la promotion placent cette forme d'expression aussi loin du «cœur» des valeurs de la liberté d'expression que la prostitution, la fomentation de la haine ou la pornographie. Son seul but est de promouvoir, par des campagnes de publicité subtiles visant souvent expressément les jeunes et les plus vulnérables,

aimed at the young and most vulnerable. This form of expression must then be accorded a very low degree of protection under s. 1 and an attenuated level of justification is appropriate. The Attorney General need only demonstrate that Parliament had a rational basis for introducing the measures contained in this Act.

The reliance on the trial judge's finding need not be adopted. An appellate court generally may only interfere with the factual findings of a trial judge where the trial judge made a manifest error and where that error influenced the trial judge's final conclusion or overall appreciation of the evidence. The trial judge's factual findings in these cases, however, were not of the type that fall within the general rule of appellate "non-interference". The privileged position of the trial judge to appreciate and weigh adjudicative facts does not extend to the assessment of "social" or "legislative" facts that arise in the law-making process. The trial judge's factual findings concerning the connection between tobacco advertising and consumption were therefore entitled to minimal deference.

The legislative means chosen under the Act must be rationally connected to the objective of protecting public health by reducing tobacco consumption, not according to a civil standard of proof, but only to the extent that there was a reasonable basis for believing such connection. A rational connection obviously exists between a prohibition on the distribution of free samples of tobacco products under s. 7 and the protection of public health. One also exists between the prohibition on advertising and promotion of tobacco products under ss. 4, 5, 6, and 8 and the objective of reducing tobacco consumption. Notwithstanding the want of a definitive study connecting tobacco advertising and tobacco consumption, sufficient evidence was adduced at trial to conclude that the objective of reducing tobacco consumption is logically furthered by the prohibition on tobacco advertising and promotion under the Act. The large advertising budgets of the tobacco companies of themselves suggest that advertising not only helps to maintain brand loyalty but also to increase consumption and to induce smokers not to quit. The government's concern with the health effects of tobacco can quite reasonably extend to both potential smokers and current smokers who would prefer to quit but cannot. Three categories of evidence capable of substantiating this rational connection were disregarded at trial: internal tobacco marketing documents, expert reports, and international materials. The internal marketing documents

l'usage d'un produit qui est nocif, voire souvent fatal, pour le consommateur. Cette forme d'expression n'a alors droit qu'à une faible protection en vertu de l'article premier et l'on doit faire preuve de souplesse dans la justification au regard de l'article premier. Le procureur général n'a qu'à établir que le Parlement avait un motif rationnel de déposer les mesures contenues dans la Loi.

Il n'y a pas lieu d'adopter les conclusions du juge de première instance. En règle générale, une cour d'appel ne peut modifier les conclusions de fait d'un juge de première instance, sauf si celui-ci a commis une erreur manifeste qui a influencé sa conclusion définitive ou encore son appréciation globale de la preuve. Toutefois, en l'espèce, les conclusions de fait du juge de première instance n'étaient pas du type de celles qui seraient visées par la règle générale de «non-intervention» en appel. La situation privilégiée du juge de première instance lorsqu'il apprécie et pondère les faits en litige ne s'étend pas à l'évaluation des faits «sociaux» ou «législatifs» qui se rattachent au processus législatif. Les conclusions de fait du juge de première instance relativement au lien entre la publicité en faveur des produits du tabac et l'usage du tabac devaient donc faire l'objet d'une retenue minimale.

Les moyens législatifs choisis doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif de protéger la santé publique par la réduction de l'usage du tabac, qui n'a pas à être établi selon les règles de preuve en matière civile, mais seulement dans la mesure où il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence d'un tel lien. Il existe manifestement un lien rationnel entre l'interdiction, en vertu de l'art. 7, de distribuer des échantillons gratuits de produits du tabac et la protection de la santé publique. Il en existe un également entre l'interdiction de publicité et de promotion en faveur des produits du tabac, en vertu des art. 4, 5, 6 et 8, et l'objectif de réduire la consommation du tabac. Malgré l'absence d'une étude concluante sur le lien entre la publicité des produits du tabac et leur usage, une preuve suffisante a été présentée au procès pour conclure que la Loi sert logiquement l'objectif de réduire l'usage des produits du tabac par la prohibition de la publicité et de la promotion. Les budgets de publicité considérables des compagnies de tabac démontrent en soi que la publicité aide non seulement à préserver la fidélité aux marques, mais aussi à accroître la consommation et à inciter les fumeurs à ne pas cesser de fumer. La préoccupation du gouvernement quant aux effets des produits du tabac sur la santé peut très raisonnablement s'étendre non seulement aux fumeurs potentiels, mais aussi aux fumeurs actuels qui voudraient cesser de fumer, mais qui ne le peuvent pas. Trois catégories d'éléments de preuve qui

introduced at trial strongly suggest that the tobacco companies perceive advertising to be a cornerstone of their strategy to reassure current smokers and expand the market by attracting new smokers, primarily among the young. The expert reports introduced at trial attest, at the very least, to the existence of a "body of opinion" supporting the existence of a causal connection between advertising and consumption. It is also significant that by 1990, over 40 countries had adopted measures to restrict or prohibit tobacco advertising.

For the reasons discussed throughout the s. 1 analysis, the legislative means chosen impair the right in question as little as possible, notwithstanding the fact that it imposes a complete prohibition on tobacco advertising and promotion rather than a partial one. The relevance of context is important in s. 1 balancing, particularly at the minimal impairment stage, because it does not require that the least intrusive measures be used but only that the measures employed were the least intrusive in light of both the legislative objective and the infringed right. The measures taken here to control tobacco products, given the legislative context and the fact that this profit-generated type of expression is far from the "core" of the freedom of expression, satisfied the *Oakes* minimal impairment requirement. While a complete prohibition on a type of expression is more difficult to justify than a partial prohibition, ample evidence was adduced at trial to demonstrate the government's decision that a full prohibition on advertising was justified and necessary. The measures were the product of an intensive 20-year period of experimenting with less intrusive measures with the cooperation of the provinces and expensive consultation with an array of national and international health groups. Over the course of this period the government adopted a variety of less intrusive measures before determining a full prohibition on advertising was necessary. Parallel developments in the international community have taken place. There has been overwhelming legislative and judicial acceptance of this type of prohibition by other democratic countries. Where governments have instituted partial prohibitions, tobacco companies have devised ingenious tactics to

auraient pu étayer l'existence de ce lien rationnel ont été écartées en première instance, savoir: les documents internes de commercialisation des produits du tabac, les rapports d'experts et les documents internationaux. Les documents de commercialisation internes déposés lors du procès donnent fortement à entendre que les compagnies de tabac perçoivent la publicité comme la pierre angulaire de leur stratégie visant à rassurer les fumeurs actuels et à étendre le marché en attirant de nouveaux fumeurs, principalement chez les jeunes. Les rapports d'experts attestent, à tout le moins, la présence d'un «corps d'opinions» appuyant l'existence d'un lien causal entre publicité et consommation. Il est également intéressant de constater qu'en 1990, plus de 40 pays avaient adopté des mesures visant à restreindre ou à interdire la publicité en faveur du tabac.

Pour les motifs exprimés tout au long de l'analyse fondée sur l'article premier, les moyens choisis par le législateur portent le moins possible atteinte au droit en question, malgré le fait qu'ils imposent une interdiction complète de la publicité et de la promotion des produits du tabac plutôt qu'une interdiction partielle. La pertinence du contexte dans une pondération en vertu de l'article premier est importante, particulièrement à l'étape du critère de l'atteinte minimale, car cette exigence n'oblige pas à prendre les mesures les moins attentatoires, mais seulement à ce que les mesures utilisées soient les moins attentatoires compte tenu tant de l'objectif législatif que du droit violé. Étant donné le contexte législatif et le fait que ce genre d'expression axé sur la réalisation de profits soit loin du «cœur» de la liberté d'expression, les mesures prises pour réglementer les produits du tabac satisfont à l'exigence de l'atteinte minimale énoncée dans *Oakes*. Bien qu'une interdiction totale d'un type d'expression soit plus difficile à justifier qu'une interdiction partielle, une preuve volumineuse a été déposée en première instance établissant que la décision du gouvernement d'établir une interdiction complète de la publicité était justifiable et nécessaire. Les mesures sont le résultat d'une période intensive de recherche sur des mesures moins attentatoires, qui s'est poursuivie pendant 20 ans, et a demandé la collaboration des provinces et de longues consultations auprès d'une multitude de groupes du domaine de la santé sur les plans tant national qu'international. Au cours de cette période, le gouvernement a adopté toute une gamme de mesures moins attentatoires avant de déterminer qu'il était nécessaire d'interdire complètement la publicité. Des développements parallèles sont survenus dans la communauté internationale. D'autres pays démocratiques ont donné une acceptation générale à ce type d'interdiction sur les plans tant législatifs que

circumvent them. International health organizations support this kind of prohibition.

A proportionality must exist between the deleterious and the salutary effects of the measures. The legislative objective of reducing the number of direct inducements for Canadians to consume these products outweighs the limitation on tobacco companies to advertise inherently dangerous products for profit.

While a legitimate concern was raised with respect to the effect of governmental claims to confidentiality in constitutional cases, the action of the government in these cases was not fatal. The evidence was overwhelming that the prohibition was a reasonable one.

Compelling the tobacco companies to place unattributed health messages on tobacco packages does not infringe their freedom of expression. These messages cannot be taken as being an opinion endorsed by the tobacco companies. They are rather a requirement imposed by government as a condition of participating in a legislated activity. Even if they may infringe a form of expression protected by s. 2(*b*), they were fully justifiable under s. 1. The warnings do nothing more than bring the dangerous nature of these products to the attention of the consumer. They have no political, social or religious content. Any concern arising from the tobacco companies' being prevented from printing on their packaging the opinion that tobacco products are not harmful, even if it is a technical infringement of their rights, was easily outweighed by the pressing health concerns raised by tobacco consumption, especially to children. The *Charter* does not require the elimination of "minuscule" constitutional burdens, and legislative action that increases the costs of exercising a right should not be invalidated if the burden is "trivial". Here, the only cost associated with the unattributed health warning requirement was a potential reduction in profits; manufacturers of dangerous products can reasonably be expected to bear this cost.

Disposition

Per Lamer C.J. and Sopinka, McLachlin, Iacobucci and Major JJ.: Sections 4, 8 and 9, and ss. 5 and 6

judiciaires. Dans les pays où les gouvernements ont imposé des interdictions partielles, les compagnies de tabac ont trouvé d'ingénieuses tactiques pour les contourner. Les organismes internationaux de la santé appuient ce genre d'interdiction.

Il doit y avoir proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques des mesures. L'objet législatif de réduire le nombre d'incitations directes faites aux Canadiens de consommer ces produits l'emporte sur la restriction imposée aux compagnies de tabac de faire de la publicité, à des fins de profit, en faveur de produits intrinsèquement dangereux.

Bien qu'une préoccupation légitime ait été soulevée relativement à l'effet des demandes gouvernementales en matière de confidentialité dans les affaires constitutionnelles, l'activité gouvernementale en l'espèce n'était pas fatale. Il y a une preuve abondante que l'interdiction était raisonnable.

Forcer les compagnies de tabac à placer sur les emballages de produits du tabac des mises en garde non attribuées ne constitue pas une violation de leur liberté d'expression. Ces messages ne peuvent être considérés comme une opinion à laquelle souscrivent les compagnies de tabac. Il s'agit plutôt d'une exigence imposée par le gouvernement comme condition de la participation à une activité réglementée. Même s'ils peuvent porter atteinte à une forme d'expression protégée par l'al. 2*b*), ils étaient tout à fait justifiables au regard de l'article premier. Les mises en garde ne font rien de plus que d'attirer l'attention des consommateurs sur la nature dangereuse de ces produits. Elles n'ont aucun contenu politique, social ou religieux. Toute inquiétude engendrée par l'interdiction imposée aux compagnies de tabac d'imprimer sur leurs emballages leur opinion selon laquelle les produits du tabac ne sont pas dangereux, même s'il s'agit d'une violation de pure forme de leurs droits, ne fait pas le poids devant les préoccupations pour la santé, surtout des enfants, que fait surgir la consommation du tabac. La *Charte* n'exige pas l'élimination des «infimes» inconvénients affectant des droits constitutionnels, et une loi qui accroît le coût de l'exercice d'un droit ne doit pas être invalidée si l'inconvénient est «négligeable». En l'espèce, le seul coût lié à l'exigence d'une mise en garde non attribuée est une possible réduction des bénéfices; on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce coût soit supporté par les fabricants de produits dangereux.

Dispositif

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin, Iacobucci et Major: Les articles 4, 8 et 9, et

which are not severable from them, are of no force or effect under s. 52 of the Constitution Act, 1982. Iacobucci J., while declaring the impugned legislation inoperable, would have made a suspensive declaration of invalidity of one year and Cory J., had he found the impugned legislation inoperable, would have agreed with Iacobucci J. in this respect.

Per Lamer C.J. and Sopinka, McLachlin and Major JJ.: Sections 4, 8 and 9 of the *Tobacco Products Control Act* constitute unjustified infringements on free expression and cannot be severed cleanly from other provisions dealing with promotion and trade mark usage, ss. 5 or 6. Sections 4, 5, 6, 8, and 9 are inconsistent with the *Charter* and hence are of no force or effect by reason of s. 52 of the *Constitution Act, 1982*.

Per Iacobucci J.: A suspensive declaration of invalidity of one year should be made. Immediately striking down the legislation would permit the tobacco companies the untrammelled ability to advertise until minimally impairing legislation is drafted; the suspensive veto would permit the government to design such legislation while the *status quo* remains in force.

Per Cory J.: If the impugned legislation were inoperable, agreement was expressed for the reasons of Iacobucci J. that a suspensive declaration of invalidity of one year be made.

Cases Cited

By McLachlin J.

Referred to: *Ford v. Quebec (Attorney General)*, [1988] 2 S.C.R. 712; *Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927; *Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario*, [1990] 2 S.C.R. 232; *Slaight Communications Inc. v. Davidson*, [1989] 1 S.C.R. 1038; *R. v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103; *Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General)*, [1989] 2 S.C.R. 1326; *Stoffman v. Vancouver General Hospital*, [1990] 3 S.C.R. 483; *Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada*, [1991] 1 S.C.R. 139; *Snell v. Farrell*, [1990] 2 S.C.R. 311; *R. v. Keegstra*, [1990] 3 S.C.R. 697; *R. v. Butler*, [1992] 1 S.C.R. 452; *Reference re ss. 193 and 195.1(1)(c) of the Criminal Code (Man.)*, [1990] 1 S.C.R. 1123; *R. v. Chaulk*, [1990] 3 S.C.R. 1303; *Ramsden v. Peterborough (City)*, [1993] 2 S.C.R. 1084.

les art. 5 et 6 qui ne peuvent en être dissociés, sont inopérants en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Bien qu'il déclare les dispositions contestées inopérantes, le juge Iacobucci, aurait rendu un jugement déclaratoire suspendant l'invalidité pour un an, et le juge Cory, s'il avait conclu que les dispositions contestées étaient inopérantes, aurait été d'accord avec le juge Iacobucci sur ce point.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin et Major: Les articles 4, 8 et 9 de la *Loi réglementant les produits du tabac* constituent des atteintes injustifiées à la liberté d'expression et ne peuvent être nettement dissociés des autres dispositions qui traitent de promotion et d'usage des marques, les art. 5 ou 6. Les articles 4, 5, 6, 8 et 9 sont incompatibles avec la *Charte* et sont, de ce fait, inopérants en application de l'art. 52 de la *Loi constitutionnelle de 1982*.

Le juge Iacobucci: Il y aurait lieu d'ordonner une suspension de l'effet de la déclaration d'invalidité pour une période d'un an. L'annulation immédiate de la loi aurait pour effet de permettre aux compagnies de tabac de mener librement des campagnes publicitaires jusqu'à l'établissement d'une loi satisfaisant au critère de l'atteinte minimale; le veto suspensif permettrait au gouvernement de procéder à l'élaboration d'une telle loi et au statu quo de demeurer en vigueur.

Le juge Cory: Si les dispositions contestées étaient inopérantes, les motifs du juge Iacobucci concernant une suspension de l'effet de l'invalidité pour une période d'un an sont acceptés.

Jurisprudence

Citée par le juge McLachlin

Arrêts mentionnés: *Ford c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 R.C.S. 712; *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927; *Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario*, [1990] 2 R.C.S. 232; *Slaight Communications Inc. c. Davidson*, [1989] 1 R.C.S. 1038; *R. c. Oakes*, [1986] 1 R.C.S. 103; *Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général)*, [1989] 2 R.C.S. 1326; *Stoffman c. Vancouver General Hospital*, [1990] 3 R.C.S. 483; *Comité pour la République du Canada c. Canada*, [1991] 1 R.C.S. 139; *Snell c. Farrell*, [1990] 2 R.C.S. 311; *R. c. Keegstra*, [1990] 3 R.C.S. 697; *R. c. Butler*, [1992] 1 R.C.S. 452; *Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.)*, [1990] 1 R.C.S. 1123; *R. c. Chaulk*, [1990] 3 R.C.S. 1303; *Ramsden c. Peterborough (Ville)*, [1993] 2 R.C.S. 1084.

By Iacobucci J.

Referred to: *Egan v. Canada*, [1995] 2 S.C.R. 513; *R. v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103; *Ford v. Quebec (Attorney General)*, [1988] 2 S.C.R. 712; *Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario*, [1990] 2 S.C.R. 232; *Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927.

By Major J.

Referred to: *R. v. Morgentaler*, [1993] 3 S.C.R. 463; *Labatt Breweries of Canada Ltd. v. Attorney General of Canada*, [1980] 1 S.C.R. 914; *Knox Contracting Ltd. v. Canada*, [1990] 2 S.C.R. 338; *Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act*, [1949] S.C.R. 1; *R. v. Hauser*, [1979] 1 S.C.R. 984; *Boggs v. The Queen*, [1981] 1 S.C.R. 49; *Reference re Alberta Statutes*, [1938] S.C.R. 100; *Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927; *Devine v. Quebec (Attorney General)*, [1988] 2 S.C.R. 790; *Reference re ss. 193 and 195.1(1)(c) of the Criminal Code (Man.)*, [1990] 1 S.C.R. 1123; *Rodriguez v. British Columbia (Attorney General)*, [1993] 3 S.C.R. 519; *Morgentaler v. The Queen*, [1976] 1 S.C.R. 616; *R. v. Furtney*, [1991] 3 S.C.R. 89.

By La Forest J. (dissenting)

R. v. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988]1 S.C.R. 401; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*, [1896] A.C. 348; *Attorney-General for Ontario v. Canada Temperance Federation*, [1946] A.C. 193; *R. v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103; *Scowby v. Glendinning*, [1986] 2 S.C.R. 226; *Attorney-General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co.*, [1903] A.C. 524; *Goodyear Tire and Rubber Co. v. The Queen*, [1956] S.C.R. 303; *R. v. Zelensky*, [1978] 2 S.C.R. 940; *Proprietary Articles Trade Association v. Attorney-General for Canada*, [1931] A.C. 310; *Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act*, [1949] S.C.R. 1; *R. v. Morgentaler*, [1993] 3 S.C.R. 463; *Reference Re Anti-Inflation Act*, [1976] 2 S.C.R. 373; *Re Upper Churchill Water Rights Reversion Act*, [1984] 1 S.C.R. 297; *Schneider v. The Queen*, [1982] 2 S.C.R. 112; *Switzman v. Elbling*, [1957] S.C.R. 285; *R. v. Wetmore*, [1983] 2 S.C.R. 284; *Standard Sausage Co. v. Lee*, [1933] 4 D.L.R. 501, supplemented by addendum at [1934] 1 D.L.R. 706; *R. v. Swain*, [1991] 1 S.C.R. 933; *Labatt Breweries of Canada Ltd. v. Attorney General of Canada*, [1980] 1 S.C.R. 914; *R. v. Cosman's Furniture*

Citée par le juge Iacobucci

Arrêts mentionnés: *Egan c. Canada*, [1995] 2 R.C.S. 513; *R. c. Oakes*, [1986] 1 R.C.S. 103; *Ford c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 R.C.S. 712; *Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario*, [1990] 2 R.C.S. 232; *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927.

Citée par le juge Major

Arrêts mentionnés: *R. c. Morgentaler*, [1993] 3 R.C.S. 463; *Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada*, [1980] 1 R.C.S. 914; *Knox Contracting Ltd. c. Canada*, [1990] 2 R.C.S. 338; *Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act*, [1949] R.C.S. 1; *R. c. Hauser*, [1979] 1 R.C.S. 984; *Boggs c. La Reine*, [1981] 1 R.C.S. 49; *Reference re Alberta Statutes*, [1938] R.C.S. 100; *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927; *Devine c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 R.C.S. 790; *Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.)*, [1990] 1 R.C.S. 1123; *Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)*, [1993] 3 R.C.S. 519; *Morgentaler c. La Reine*, [1976] 1 R.C.S. 616; *R. c. Furtney*, [1991] 3 R.C.S. 89.

Citée par le juge La Forest (dissident)

R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988]1 R.C.S. 401; *Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for the Dominion*, [1896] A.C. 348; *Attorney-General for Ontario c. Canada Temperance Federation*, [1946] A.C. 193; *R. c. Oakes*, [1986] 1 R.C.S. 103; *Scowby c. Glendinning*, [1986] 2 R.C.S. 226; *Attorney-General for Ontario c. Hamilton Street Railway Co.*, [1903] A.C. 524; *Goodyear Tire and Rubber Co. c. The Queen*, [1956] R.C.S. 303; *R. c. Zelensky*, [1978] 2 R.C.S. 940; *Proprietary Articles Trade Association c. Attorney-General for Canada*, [1931] A.C. 310; *Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act*, [1949] R.C.S. 1; *R. c. Morgentaler*, [1993] 3 R.C.S. 463; *Renvoi relatif à la Loi anti-inflation*, [1976] 2 R.C.S. 373; *Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act*, [1984] 1 R.C.S. 297; *Schneider c. La Reine*, [1982] 2 R.C.S. 112; *Switzman c. Elbling*, [1957] R.C.S. 285; *R. c. Wetmore*, [1983] 2 R.C.S. 284; *Standard Sausage Co. c. Lee*, [1933] 4 D.L.R. 501, complété par des motifs additionnels publiés à [1934] 1 D.L.R. 706; *R. c. Swain*, [1991] 1 R.C.S. 933; *Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada*, [1980] 1

(1972) Ltd. (1976), 32 C.C.C. (2d) 345; *R. v. Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 S.C.R. 295; *Attorney-General for British Columbia v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 368; *Campbell v. The Queen*, [1965] S.C.R. vii; *Reference re ss. 193 and 195.1(1)(c) of the Criminal Code (Man.)*, [1990] 1 S.C.R. 1123; *Rodriguez v. British Columbia (Attorney General)*, [1993] 3 S.C.R. 519; *Lord's Day Alliance of Canada v. Attorney General of British Columbia*, [1959] S.C.R. 497; *Morgentaler v. The Queen*, [1976] 1 S.C.R. 616; *R. v. Furtney*, [1991] 3 S.C.R. 89; *Ford v. Quebec (Attorney General)*, [1988] 2 S.C.R. 712; *Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927; *Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario*, [1990] 2 S.C.R. 232; *R. v. Edwards Books and Art Ltd.*, [1986] 2 S.C.R. 713; *R. v. Keegstra*, [1990] 3 S.C.R. 697; *United States of America v. Cotroni*, [1989] 1 S.C.R. 1469; *R. v. Jones*, [1986] 2 S.C.R. 284; *Andrews v. Law Society of British Columbia*, [1989] 1 S.C.R. 143; *Black v. Law Society of Alberta*, [1989] 1 S.C.R. 591; *Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General)*, [1989] 2 S.C.R. 1326; *McKinney v. University of Guelph*, [1990] 3 S.C.R. 229; *Dickason v. University of Alberta*, [1992] 2 S.C.R. 1103; *R. v. Butler*, [1992] 1 S.C.R. 452; *Dorval v. Bouvier*, [1968] S.C.R. 288; *Lapointe v. Hôpital Le Gardeur*, [1992] 1 S.C.R. 351; *Dunagin v. City of Oxford, Mississippi*, 718 F.2d 738 (5th Cir. 1983) (*en banc*), cert. denied, 467 U.S. 1259 (1984); *Lavigne v. Ontario Public Service Employees Union*, [1991] 2 S.C.R. 211; *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission of New York*, 447 U.S. 557 (1980); *Oklahoma Telecasters Ass'n v. Crisp*, 699 F.2d 490 (1983), rev'd on other grounds *sub nom. Capital Cities Cable, Inc. v. Crisp*, 467 U.S. 691 (1984); *Metromedia, Inc. v. City of San Diego*, 453 U.S. 490 (1981); *Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Co. of Puerto Rico*, 478 U.S. 328 (1986); *Canadian Assn. of Regulated Importers v. Canada (Attorney General)*, [1992] 2 F.C. 130; *Canada (Attorney General) v. Central Cartage Co.*, [1990] 2 F.C. 641; *R. v. Schwartz*, [1988] 2 S.C.R. 443; *Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada*, [1991] 1 S.C.R. 139; *Reference re Manitoba Language Rights*, [1985] 1 S.C.R. 721; *Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp.*, [1994] 3 S.C.R. 835; *Slaight Communications Inc. v. Davidson*, [1989] 1 S.C.R. 1038; *Thomson Newspapers Ltd. v. Canada (Director of Investigation and Research, Restrictive Trade Practices Commission)*, [1990] 1 S.C.R. 425.

R.C.S. 914; *R. c. Cosman's Furniture (1972) Ltd.* (1976), 32 C.C.C. (2d) 345; *R. c. Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295; *Attorney-General for British Columbia c. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 368; *Campbell c. The Queen*, [1965] R.C.S. vii; *Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.)*, [1990] 1 R.C.S. 1123; *Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)*, [1993] 3 R.C.S. 519; *Lord's Day Alliance of Canada c. Attorney General of British Columbia*, [1959] R.C.S. 497; *Morgentaler c. La Reine*, [1976] 1 R.C.S. 616; *R. c. Furtney*, [1991] 3 R.C.S. 89; *Ford c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 R.C.S. 712; *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927; *Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario*, [1990] 2 R.C.S. 232; *R. c. Edwards Books and Art Ltd.*, [1986] 2 R.C.S. 713; *R. c. Keegstra*, [1990] 3 R.C.S. 697; *États-Unis d'Amérique c. Cotroni*, [1989] 1 R.C.S. 1469; *R. c. Jones*, [1986] 2 R.C.S. 284; *Andrews c. Law Society of British Columbia*, [1989] 1 R.C.S. 143; *Black c. Law Society of Alberta*, [1989] 1 R.C.S. 591; *Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général)*, [1989] 2 R.C.S. 1326; *McKinney c. Université de Guelph*, [1990] 3 R.C.S. 229; *Dickason c. Université de l'Alberta*, [1992] 2 R.C.S. 1103; *R. c. Butler*, [1992] 1 R.C.S. 452; *Dorval c. Bouvier*, [1968] R.C.S. 288; *Lapointe c. Hôpital Le Gardeur*, [1992] 1 R.C.S. 351; *Dunagin c. City of Oxford, Mississippi*, 718 F.2d 738 (5th Cir. 1983) (*en banc*), cert. refusé, 467 U.S. 1259 (1984); *Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario*, [1991] 2 R.C.S. 211; *Central Hudson Gas & Electric Corp. c. Public Service Commission of New York*, 447 U.S. 557 (1980); *Oklahoma Telecasters Ass'n c. Crisp*, 699 F.2d 490 (1983), inf. pour d'autres motifs *sub nom. Capital Cities Cable, Inc. c. Crisp*, 467 U.S. 691 (1984); *Metromedia, Inc. c. City of San Diego*, 453 U.S. 490 (1981); *Posadas de Puerto Rico Associates c. Tourism Co. of Puerto Rico*, 478 U.S. 328 (1986); *Canadian Assn. of Regulated Importers c. Canada (Procureur général)*, [1992] 2 C.F. 130; *Canada (Procureur général) c. Central Cartage Co.*, [1990] 2 C.F. 641; *R. c. Schwartz*, [1988] 2 R.C.S. 443; *Comité pour la République du Canada c. Canada*, [1991] 1 R.C.S. 139; *Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba*, [1985] 1 R.C.S. 721; *Dagenais c. Société Radio-Canada*, [1994] 3 R.C.S. 835; *Slaight Communications Inc. c. Davidson*, [1989] 1 R.C.S. 1038; *Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce)*, [1990] 1 R.C.S. 425.

Statutes and Regulations Cited

Act Respecting the Protection of Non-Smokers in Certain Public Places, R.S.Q., c. P-38.01.
Act to amend the Excise Act, the Customs Act and the Tobacco Sales to Young Persons Act, S.C. 1994, c. 37.
Act to Protect the Health of Non-smokers, S.M. 1990, c. S125.
Canada Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C-5, s. 39.
Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 1, 2(*b*).
Constitution Act, 1867, Preamble, ss. 91(27), 92(13), (16).
Hazardous Products Act, R.S.C., 1985, c. H-3, ss. 2 [rep. & sub., c. 24 (3rd. Supp.), s. 1], 4 [*idem*], 5 [*idem*], 15 [*idem*].
Medical Services Act, R.S.N.S. 1989, c. 281.
Minors Tobacco Act, R.S.S. 1965, c. 381.
Non-smokers' Health Act, S.C. 1988, c. 21.
Tobacco Access Act, S.N.S. 1993, c. 14.
Tobacco Control Act, S.N. 1993, c. T-4.1.
Tobacco Control Act, 1994, S.O. 1994, c. 10.
Tobacco Product Act, R.S.B.C. 1979, c. 403 [am. S.B.C. 1992, c. 81].
Tobacco Products Control Act, S.C. 1988, c. 20, ss. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19.
Tobacco Products Control Regulations, amendment, SOR/93-389, s. 11.
Tobacco Sales Act, S.N.B. 1993, c. T-6.1.
Tobacco Sales to Minors Act, S.P.E.I. 1991, c. 44.
Tobacco Sales to Young Persons Act, S.C. 1993, c. 5.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2*b*).
Loi constitutionnelle de 1867, préambule, art. 91(27), 92(13), (16).
Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac, L.O. 1994, ch. 10.
Loi modifiant la Loi sur l'accise, la Loi sur les douanes et la Loi sur la vente du tabac aux jeunes, L.C. 1994, ch. 37.
Loi réglementant les produits du tabac, L.C. 1988, ch. 20, art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19.
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 39.
Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs, L.M. 1990, ch. S125.
Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics, L.R.Q., ch. P-38.01.
Loi sur la santé des non-fumeurs, L.C. 1988, ch. 21.
Loi sur la vente du tabac aux jeunes, L.C. 1993, ch. 5.
Loi sur les produits dangereux, L.R.C. (1985), ch. H-3, art. 2 [abr. & rempl., ch. 24 (3e suppl.), art. 1], 4 [*idem*], 5 [*idem*], 15 [*idem*].
Loi sur les ventes de tabac, L.N.-B. 1993, ch. T-6.1.
Medical Services Act, R.S.N.S. 1989, ch. 281.
Minors Tobacco Act, R.S.S. 1965, ch. 381.
Règlement sur les produits du tabac — Modification, DORS/93-389, art. 11.
Tobacco Access Act, S.N.S. 1993, ch. 14.
Tobacco Control Act, S.N. 1993, ch. T-4.1.
Tobacco Product Act, R.S.B.C. 1979, ch. 403 [mod. S.B.C. 1992, ch. 81].
Tobacco Sales to Minors Act, S.P.E.I. 1991, ch. 44.

Authors Cited

Canada. Health and Welfare Canada. *Canadian Initiatives in Smoking and Health*. Ottawa: 1983.
Canada. Health and Welfare Canada. Health Protection Branch. Bureau of Chronic Disease Epidemiology. Surveillance & Risk Assessment Division. Report by Donald T. Wigle. *Illness and Death in Canada by Smoking: An Epidemiological Perspective*. Ottawa: 1989.
Canada. Health and Welfare Canada. National Program to Reduce Tobacco Use. "Directional paper of the national program to reduce tobacco use in Canada".

Doctrine citée

Assemblée mondiale de la santé. Résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé WHA39.14. Mai 1986. WHA39/1986/REC/1, 14.
Assemblée mondiale de la santé. Résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé WHA43.16. Mai 1990. WHA43/1990, 16.
Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales. *Rapport du Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales sur l'usage du tabac et de la cigarette*. Présenté par M. Gaston Isa-

Appendix in *National Program to Reduce Tobacco Use: Orientation Manuals & Historical Perspective.* Ottawa: 1987.

Canada. Health and Welfare Canada. National Program to Reduce Tobacco Use. *National Program to Reduce Tobacco Use: Orientation Manuals & Historical Perspective.* Ottawa: 1987.

Canada. Health and Welfare Canada. Tobacco Products Unit. Report by Roberta G. Ferrence. *Trends in Tobacco Consumption in Canada, 1900-1987.* Ottawa: 1989.

Canada. *House of Commons Debates*, vol. IX, 2nd Sess., 33rd Parl., November 23rd, 1987, p. 11042.

Canada. House of Commons. Standing Committee on Health, Welfare and Social Affairs. *Report of the Standing Committee on Health, Welfare and Social Affairs on Tobacco and Cigarette Smoking.* Presented by M. Gaston Isabelle, Chairman, Session 1969-70. Ottawa: Queen's Printer, 1969.

Chapman, Simon and Bill Fitzgerald. "Brand Preference and Advertising Recall in Adolescent Smokers: Some Implications for Health Promotion" (1982), 72 *Am. J. Pub. Health* 491.

Collinshaw, Neil E., Walter Tostowaryk and Donald T. Wigle. "Mortality Attributable to Tobacco Use in Canada" (1988), 79 *Can. J. Pub. Health* 166.

European Commission. *Official Journal of the European Communities.* Preparatory Acts. Amended proposal for a Council Directive on the authorized advertising of tobacco products in the press and by means of bills and posters. (90/C 116/05).

European Commission. *Official Journal of the European Communities.* Preparatory Acts. Amended proposal for a Council Directive on advertising of tobacco products. (91/C 167/03).

European Commission. *Official Journal of the European Communities.* Preparatory Acts. Amended proposal for a Council Directive on the approximation of Member States' laws, regulations and administrative provisions on advertising for tobacco products. (92/C 129/04).

European Council. *Official Journal of the European Communities.* Council Directive of 3 October 1989. (89/552/EEC).

European Council. *Official Journal of the European Communities.* Council Directive of 13 November 1989. (89/622/EEC). Amended by Council Directive of 15 May 1992. (92/41/EEC).

Gorn, Gerald J. and Renée Florsheim. "The Effects of Commercials for Adult Products on Children" (1985), 11 *J. Consumer Res.* 962.

Hagan, John. "Can Social Science Save Us? The Problems and Prospects of Social Science Evidence belle, président, Session 1969-70. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1969.

Canada. *Débats de la Chambre des communes*, vol. IX, 2e sess., 33e Lég., le 23 novembre 1987, p. 11042.

Canada. Santé et Bien-être social Canada. Document d'orientation du programme national de lutte contre le tabagisme au Canada. Programme national de lutte contre le tabagisme. Annexe du *National Program to Reduce Tobacco Use: Orientation Manuals & Historical Perspective.* Ottawa: 1987.

Canada. Santé et Bien-être social Canada. Direction générale de la protection de la santé. Bureau de l'épidémiologie des maladies chroniques. Division de la surveillance et de l'évaluation des risques. Rapport par Donald T. Wigle. *Illness and Death in Canada by Smoking: An Epidemiological Perspective.* Ottawa: 1989.

Canada. Santé et Bien-être social Canada. *Initiatives canadiennes en matière de santé et de lutte contre l'usage du tabac.* Ottawa: 1983.

Canada. Santé et Bien-être social Canada. National Program to Reduce Tobacco. *National Program to Reduce Tobacco Use: Orientation Manuals & Historical Perspective.* Ottawa: 1987.

Canada. Santé et Bien-être social Canada. Tobacco Products Unit. Rapport par Roberta G. Ferrence. *Trends in Tobacco Consumption in Canada 1900-1987.* Ottawa: 1989.

Chapman, Simon and Bill Fitzgerald. «Brand Preference and Advertising Recall in Adolescent Smokers: Some Implications for Health Promotion» (1982), 72 *Am. J. Pub. Health* 491.

Collinshaw, Neil E., Walter Tostowaryk and Donald T. Wigle. «Mortality Attributable to Tobacco Use in Canada» (1988), 79 *Can. J. Pub. Health* 166.

Commission européenne. *Journal officiel des Communautés européennes.* Actes préparatoires. Proposition modifiée de directive du Conseil en matière de publicité autorisée par voie de presse et d'affiches en faveur des produits du tabac. (90/C 116/05).

Commission européenne. *Journal officiel des Communautés européennes.* Actes préparatoires. Amended proposal for a Council Directive on advertising of tobacco products. (91/C 167/03).

Commission européenne. *Journal officiel des Communautés européennes.* Actes préparatoires. Amended proposal for a Council Directive on the approximation of Member States' laws, regulations and administrative provision on advertising for tobacco products. (92/C 129/04).

Conseil européen. *Journal officiel des Communautés européennes.* Directive du Conseil le 3 octobre 1989. (89/552/CEE).

in Constitutional Litigation". In Robert J. Sharpe, ed., *Charter Litigation*. Toronto: Butterworths, 1987, 213.

Hogg, Peter. *Constitutional Law of Canada*, vol. 1, 3rd ed. (Supplemented). Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (loose-leaf).

Imasco Ltd. *Annual Report 1992*. Montreal: Imasco Ltd., 1992.

Imperial Tobacco Ltd. *Project Viking*, vol. I: *A Behavioural Model of Smoking*. Montreal: Imperial Tobacco Ltd., 1986.

Imperial Tobacco Ltd. *Project Viking*, vol. II: *An Attitudinal Model of Smoking*. Montreal: Imperial Tobacco Ltd., 1986.

Imperial Tobacco Ltd. *Project Viking*, vol. III: *Product Issues*. Montreal: Imperial Tobacco Ltd., 1986.

Joossens, Luc. "Strategy of the Tobacco Industry Concerning Legislation on Tobacco Advertising in some Western European Countries". In *Proceedings of the 5th World Conference on Smoking and Health*. Winnipeg: Canadian Council on Smoking and Health, 1983, 549.

Morgan, Brian G. "Proof of Facts in Charter Litigation". In Robert J. Sharpe, ed., *Charter Litigation*. Toronto: Butterworths, 1987, 159.

New Zealand. Toxic Substances Board. *Health or Tobacco: An End to Tobacco Advertising and Promotion*. Wellington: Publications Division, Government Printing Office, 1989.

Rothschild, Michael L. *Advertising: From Fundamentals to Strategies*. Toronto: D. C. Heath, 1987.

United Nations. Economic and Social Council. Resolution 1993/79. "Multisectoral collaboration on tobacco or health". Geneva, September 7, 1993. *Official Records of the Economic and Social Council, 1993, Supplement No. 1*. (E/1993/93).

United States of America. Department of Health and Human Services. *Reducing the Health Consequences of Smoking — 25 Years of Progress — A report of the Surgeon General*. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. DHHS Publication No. (CDC) 89-8411, Prepublication version, January 11, 1989.

United States of America. Department of Health and Human Services. *The Health Consequences of Smoking — Nicotine Addiction — A report of the Surgeon General*. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, Center for Health Promotion and Education, Office on Smoking and Health. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1988.

Woolhandler, Ann. "Rethinking the Judicial Reception of Legislative Facts" (1988), 41 *Vand. L. Rev.* 111.

Conseil européen. *Journal officiel des Communautés européennes*. Directive du Conseil le 13 Novembre 1989. (89/622/CEE). Modifiée par la directive du Conseil le 15 mai 1992 (92/41/CEE).

Gorn, Gerald J. and Renée Florsheim. «The Effects of Commercials for Adult Products on Children», (1985), 11 *J. Consumer Res.*, 962.

Hagan, John. «Can Social Science Save Us? The Problems and Prospects of Social Science Evidence in Constitutional Litigation». In Robert J. Sharpe, ed., *Charter Litigation*. Toronto: Butterworths, 1987, 213.

Hogg, Peter. *Constitutional Law of Canada*, vol. 1, 3rd ed (Supplemented). Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (loose-leaf).

Imasco Ltd. *Rapport annuel 1992*. Montréal: Imasco, 1992.

Imperial Tobacco Ltd. *Project Viking*, vol. I. *A Behavioural Model of Smoking*. Montreal: Imperial Tobacco Ltd., 1986.

Imperial Tobacco Ltd. *Project Viking*, vol. II. *An Attitudinal Model of Smoking*. Montreal: Imperial Tobacco Ltd., 1986.

Imperial Tobacco Ltd. *Project Viking*, vol. III. *Product Issues*. Montreal: Imperial Tobacco Ltd., 1986.

Joossens. Luc. «Strategy of the Tobacco Industry Concerning Legislation on Tobacco Advertising in some Western European Countries». In *Proceedings of the 5th World Conference on Smoking and Health*. Winnipeg: Canadian Council on Smoking and Health, 1983, 549.

Morgan, Brian G. «Proof of Facts in Charter Litigation». In Robert J. Sharpe, ed., *Charter Litigation*. Toronto: Butterworths, 1987, 159.

Nations Unies. Conseil économique et social. Résolution 1993/79. «Multisectoral collaboration on tabacco or health». Geneva, September 7, 1993. *Official Records of the Economic and Social Council, 1993, Supplement No. 1*. (E/1993/93).

New Zealand. Toxic Substances Board. *Health or Tobacco: An End to Tobacco Advertising and Promotion*. Wellington: Publications Division, Government Printing Office, 1989.

Rothschild, Michael L. *Advertising: From Fundamentals to Strategies*. Toronto: D. C. Heath, 1987.

United States of America. Department of Health and Human Services. *Reducing the Health Consequences of Smoking — 25 Years of Progress — A report of the Surgeon General*. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. DHHS Pubication No. (CDC) 89-8411, Prepublication version, January 11, 1989.

World Health Assembly. World Health Assembly Resolution WHA39.14. May 1986. WHA39/1986/REC/1, 14.

World Health Assembly. World Health Assembly Resolution WHA43.16. May 1990. WHA43/1990, 16.

United States of America. Department of Health and Human Services. *The Health Consequences of Smoking — Nicotine Addiction — A report of the Surgeon General.* U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, Center for Health Promotion and Education, Office on Smoking and Health. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1988.

Woolhandler, Ann. «Rethinking the Judicial Reception of Legislative Facts» (1988), 41 *Vand. L. Rev.* 111.

APPEALS from a judgment of the Quebec Court of Appeal (1993), 102 D.L.R. (4th) 289, [1993] R.J.Q. 375, 53 Q.A.C. 79, 48 C.P.R. (3d) 417, allowing appeals from judgments of Chabot J. (1991), 82 D.L.R. (4th) 449, [1991] R.J.Q. 2260, 37 C.P.R. (3d) 193, granting motions for declaratory judgment. Appeals allowed, La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier and Cory JJ. dissenting. The first constitutional question dealing with the legislative competence of Parliament to enact the legislation under the criminal law power or for the peace, order and good government of Canada should be answered in the positive. With respect to the second constitutional question, ss. 4 (re advertising), 8 (re trade mark use) and 9 (re unattributed health warnings) of the Act are inconsistent with the right of freedom of expression as set out is 2(*b*) of the *Charter* and do not constitute a reasonable limit on that right as can be demonstrably justified pursuant to s. 1 thereof. La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier and Cory JJ. would find that they constitute a reasonable limit. Given that ss. 5 (re retail displays) and 6 (re sponsorships) could not be cleanly severed from ss. 4, 8 and 9, all are of no force or effect pursuant to s. 52 of the *Constitution Act, 1982*.

Colin K. Irving, Georges R. Thibaudeau and *Douglas Mitchell*, for the appellant RJR-MacDonald Inc.

L. Yves Fortier, Q.C., Simon V. Potter, Lyndon A. J. Barnes and *Gregory Bordan*, for the appellant Imperial Tobacco Ltd.

Alain Gingras, for the mis-en-cause the Attorney General of Quebec.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 375, (1993), 102 D.L.R. (4th) 289, 53 Q.A.C. 79, 48 C.P.R. (3d) 417, qui a accueilli des appels contre des décisions du juge Chabot, [1991] R.J.Q. 2260, (1991), 82 D.L.R. (4th) 449, 37 C.P.R. (3d) 193, qui avait accordé des requêtes en jugement déclaratoire. Pourvois accueillis, les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory sont dissidents. La première question constitutionnelle sur la compétence du Parlement de légiférer en matière de droit criminel ou pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada reçoit une réponse positive. Pour ce qui est de la seconde question constitutionnelle, les art. 4 (la publicité), 8 (les marques) et 9 (les messages non attribués relatifs à la santé) de la Loi sont incompatibles avec le droit à la liberté d'expression garanti à l'al. 2*b*) de la *Charte* et n'apportent pas une limite raisonnable à l'exercice de ce droit, dont la justification puisse se démontrer au sens de l'article premier. Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory sont d'avis qu'ils apportent une limite raisonnable. Vu que les art. 5 (commerce au détail) et 6 (parrainage) ne peuvent pas nettement être distingués des art. 4, 8 et 9, ils sont tous inopérants aux termes de l'art. 52 de la *Loi constitutionnelle de 1982*.

Colin K. Irving, Georges R. Thibaudeau et *Douglas Mitchell*, pour l'appelante RJR-MacDonald Inc.

L. Yves Fortier, c.r., Simon V. Potter, Lyndon A. J. Barnes et *Gregory Bordan*, pour l'appelante Imperial Tobacco Ltd.

Alain Gingras, pour le mis en cause le procureur général du Québec.

Claude Joyal, James Mabbutt, Q.C., Paul Évraire, Q.C., Yves Lebœuf and *Johanne Poirier*, for the respondent.

Tanya Lee, for the intervener the Attorney General for Ontario.

Robert W. Cosman, Karl Delwaide and *Richard B. Swan*, for the interveners the Heart and Stroke Foundation of Canada, the Canadian Cancer Society, the Canadian Council on Smoking and Health, the Canadian Medical Association, and the Canadian Lung Association.

The following are the reasons delivered by

1 LAMER C.J. — I have had the benefit of reading the reasons of my colleagues. I am in agreement with the reasons of my colleague, Justice Iacobucci, but agree with my colleague, Justice McLachlin, as to the disposition.

The reasons of La Forest, L'Heureux-Dubé and Gonthier JJ. were delivered by

2 LA FOREST J. (dissenting) — The issues in these appeals are whether the *Tobacco Products Control Act*, S.C. 1988, c. 20 (the "Act"), falls within the legislative competence of the Parliament of Canada under s. 91 of the *Constitution Act, 1867*, either as criminal law or under the peace, order and good government clause, and if so whether it constitutes an infringement of freedom of expression under s. 2(*b*) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* which is not justified under s. 1 of the *Charter*. In broad terms, the Act prohibits, subject to specified exceptions, all advertising and promotion of tobacco products, and prohibits the sale of a tobacco product unless the package containing it sets forth prescribed health warnings and a list of the toxic constituents of the product and of the smoke produced from its combustion.

3 These proceedings began with two separate motions for declaratory judgments before the Quebec Superior Court. The appellant RJR - MacDonald Inc. ("RJR") seeks a declaration that the Act is wholly *ultra vires* the Parliament of Canada and

Claude Joyal, James Mabbutt, c.r., Paul Évraire, c.r., Yves Lebœuf et *Johanne Poirier*, pour l'intimé.

Tanya Lee, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Robert W. Cosman, Karl Delwaide et *Richard B. Swan*, pour les intervenants la Fondation des maladies du cœur du Canada, la Société canadienne du cancer, le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé, l'Association médicale canadienne et l'Association pulmonaire du Canada.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE EN CHEF LAMER — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues. Je suis d'accord avec les motifs de mon collègue, le juge Iacobucci, mais je souscris au dispositif de ma collègue, le juge McLachlin.

Version française des motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier rendus par

LE JUGE LA FOREST (dissident) — Les présents pourvois visent à déterminer si la *Loi réglementant les produits du tabac*, L.C. 1988, ch. 20 (la «Loi»), relève de la compétence du Parlement du Canada, conférée par l'art. 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, de légiférer en matière de droit criminel ou pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement et, dans l'affirmative, si cette loi constitue une violation de la liberté d'expression garantie par l'al. 2*b*) de la *Charte canadienne des droits et libertés*, qui n'est pas justifiée en vertu de l'article premier de la *Charte*. En termes généraux, la Loi interdit, sous réserve de certaines exceptions, toute publicité et promotion en faveur des produits du tabac ainsi que la vente de ces produits, sauf si leur emballage porte les mises en garde réglementaires ainsi qu'une liste des substances toxiques que le produit contient et qui sont dégagées par sa combustion.

La présente instance a commencé par deux requêtes distinctes en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure du Québec. L'appelante RJR-MacDonald Inc. («RJR») demande que la Loi soit déclarée complètement *ultra vires* du Parlement du

invalid as an unjustified infringement of freedom of expression guaranteed by s. 2(*b*) of the *Charter*. The appellant Imperial Tobacco Ltd. ("Imperial") seeks the same order, but only in respect of ss. 4, 5, 6 and 8 of the Act. The two motions were heard together before Chabot J. of the Quebec Superior Court who rejected the Attorney General of Canada's contention that the Act was valid either as criminal law or under the peace, order and good government clause, and declared the whole of the Act *ultra vires* the Parliament of Canada. He further held the Act was of no force or effect as an unjustified infringement of s. 2(*b*) of the *Charter*. The Quebec Court of Appeal reversed this judgment. While upholding the judge's conclusion regarding the criminal law power, it unanimously held that the Act was *intra vires* Parliament as falling within the peace, order and good government clause and, by majority, that the infringement of s. 2(*b*) of the *Charter* was justified by s. 1 of that instrument. The minority judge would have held ss. 4, 5, 6 and 8 invalid under s. 2(*b*) of the *Charter*.

Canada et non valide du fait qu'elle constitue une violation injustifiée de la liberté d'expression garantie par l'al. 2*b*) de la *Charte*. L'appelante Imperial Tobacco Ltd. («Imperial») demande la même ordonnance, mais seulement relativement aux art. 4, 5, 6 et 8 de la Loi. Les deux requêtes ont été entendues en même temps par le juge Chabot de la Cour supérieure du Québec, qui a rejeté la prétention du procureur général du Canada quant à la validité de la Loi, que ce soit sous le chef du droit criminel ou en vertu de la clause pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement, et a déclaré toute la Loi *ultra vires* du Parlement du Canada. Il a par ailleurs affirmé que la Loi était inopérante du fait qu'elle constituait une violation injustifiée de l'al. 2*b*) de la *Charte*. La Cour d'appel du Québec a infirmé cette décision. Elle a confirmé la conclusion du juge de première instance quant à la compétence en matière de droit criminel, mais elle a conclu à l'unanimité que la Loi était *intra vires* du Parlement en tant que loi adoptée pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement et statué à la majorité que la violation de l'al. 2*b*) de la *Charte* pouvait se justifier en vertu de l'article premier. Le juge minoritaire aurait déclaré non valides les art. 4, 5, 6 et 8 au regard de l'al. 2*b*) de la *Charte*.

The appellants sought and were granted leave to appeal to this Court. 4

Les appelantes ont demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour.

The Legislative Scheme

The Act, the long title of which is *An Act to prohibit the advertising and promotion and respecting the labelling and monitoring of tobacco products*, received Royal Assent on June 28, 1988 and came into force on January 1, 1989. The purpose of the Act is set out in s. 3, which reads: 5

3. The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and, in particular,

(*a*) to protect the health of Canadians in the light of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases;

(*b*) to protect young persons and others, to the extent that is reasonable in a free and democratic society,

Le régime législatif

La Loi, dont le titre intégral est *Loi interdisant la publicité en faveur des produits du tabac, réglementant leur étiquetage et prévoyant certaines mesures de contrôle*, a reçu la sanction royale le 28 juin 1988 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Son objet est formulé à l'art. 3:

3. La présente loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave, urgent et d'envergure nationale et, plus particulièrement:

a) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant de façon indiscutable un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;

b) de préserver notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une société libre et démocratique, des

from inducements to use tobacco products and consequent dependence on them; and

(*c*) to enhance public awareness of the hazards of tobacco use by ensuring the effective communication of pertinent information to consumers of tobacco products.

Section 3 thus states that Parliament's purpose in enacting the legislation is to address the "national public health problem of substantial and pressing concern" arising from the use of tobacco, by protecting young persons and others from inducements to use tobacco products, and by enhancing public awareness concerning the hazards of tobacco use. However, it is of significance to these appeals that, with the exception of a prohibition on the distribution of free samples of tobacco products under s. 7, the Act does not purport to proscribe the sale, distribution or use of tobacco products. Rather, as its long title indicates, the Act seeks to attain its purpose through the institution of a prohibition on the advertising and promotion of tobacco products offered for sale in Canada and through the institution of a requirement that manufacturers of tobacco products display health warnings on tobacco product packages.

6 In furtherance of the purpose set out in s. 3, Parliament has created a legislative scheme that targets three distinct categories of commercial activity: advertising, promotion and labelling. Sections 4 and 5 of the Act, which fall under the title "ADVERTISING", deal with the advertisement and display of tobacco products. Section 4 prohibits the advertisement, by publication, broadcast or otherwise, of tobacco products offered for sale in Canada. An exception to this prohibition is created by s. 4(3) and (4), which stipulate that the prohibition does not extend to foreign advertising in foreign publications imported into Canada or foreign broadcasts retransmitted in Canada, as long as those advertisements are not intended primarily for the purpose of promoting the sale of a tobacco product in Canada. Section 5 is directed to the retail display of tobacco products in retail establishments and vending machines. Section 5(1) stipulates that a retailer may expose tobacco products for sale and may post signs that indicate, other than by their brand names or trade marks, the

incitations à la consommation du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

c) de mieux sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux méfaits du tabac par la diffusion efficace de l'information utile aux consommateurs de celui-ci.

Ainsi, l'art. 3 affirme que le législateur vise par cette loi à s'attaquer «à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave, urgent et d'envergure nationale» et qui découle de la consommation du tabac, en préservant notamment les jeunes des incitations à la consommation du tabac et en sensibilisant davantage les Canadiennes et les Canadiens aux méfaits du tabac. Cependant, pour les fins des présents pourvois, il importe de signaler que la Loi, à l'exception de l'interdiction de distribuer des échantillons de produits du tabac prévue à l'art. 7, n'a pas pour but d'interdire la vente, la distribution ou la consommation des produits du tabac. Elle vise plutôt, comme son titre intégral l'indique, à atteindre son objectif en interdisant la publicité et la promotion en faveur des produits du tabac mis en vente au Canada et en exigeant que les fabricants de produits du tabac apposent des mises en garde sur leurs emballages.

Pour atteindre l'objectif visé à l'art. 3, le législateur a créé un régime législatif qui vise trois catégories distinctes d'activité commerciale: la publicité, la promotion et l'étiquetage. Les articles 4 et 5 de la Loi, sous la rubrique «PUBLICITÉ», portent sur la publicité et la présentation des produits du tabac. En vertu de l'art. 4, il est interdit de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, de la publicité en faveur d'un produit du tabac mis en vente au Canada. Les paragraphes 4(3) et (4) créent une exception à cette interdiction et prévoient que l'interdiction ne s'applique pas à la publicité dans des publications étrangères importées au Canada ou à la retransmission d'émissions de l'étranger dans la mesure où cette publicité n'est pas faite dans le but, principalement, de promouvoir la vente d'un produit du tabac au Canada. L'article 5 porte sur la présentation des produits du tabac dans l'établissement du détaillant et dans les distributeurs automatiques. Le paragraphe 5(1) prévoit qu'un détaillant peut exposer des produits du tabac pour la vente et signaler

tobacco products offered for sale on the premises. Section 5(2) permits the operation of tobacco vending machines, and the identification of products and prices on the exterior of the machines.

par des affiches les produits du tabac qui y sont vendus, sans toutefois mentionner leur nom ou leur marque. Le paragraphe 5(2) permet à une personne d'exploiter un distributeur automatique de produits du tabac, et de les nommer et d'en indiquer les prix sur celui-ci.

Sections 6 to 8 of the Act fall under the title "PROMOTION", and deal with various direct and indirect promotional activities involving tobacco products. Section 6(1) stipulates that the full name of a tobacco manufacturer may be used in a representation to the public that promotes a cultural or sporting event, but prohibits the use of brand names in such representations unless the use of a brand name is required by a contract made before January 25, 1988. Section 6(2) stipulates that, where a contract requiring the use of a brand name was in place before January 25, 1988, the value of contributions under that contract are frozen at 1987 levels. Section 7 prohibits the free distribution of tobacco products in any form. Section 8 prohibits the use of a tobacco trade mark on any article other than a tobacco product, and also prohibits the use and distribution of tobacco trade marks in advertising for products other than tobacco products; however, a special exemption from the s. 8 prohibition is created under s. 8(3) for the "Dunhill" trade mark.

7 Les articles 6 à 8 de la Loi figurent sous la rubrique «PROMOTION» et portent sur diverses activités promotionnelles directes et indirectes en faveur des produits du tabac. Le paragraphe 6(1) prévoit qu'il est possible d'utiliser le nom intégral du fabricant d'un produit du tabac dans toute mention au public qui vise à promouvoir une activité ou une manifestation culturelles ou sportives, mais interdit l'utilisation du nom du produit dans ces mentions, sauf si cette utilisation est exigée par un contrat conclu avant le 25 janvier 1988. Le paragraphe 6(2) prévoit que, dans le cas où un contrat conclu avant le 25 janvier 1988 exige l'utilisation du nom du produit, la valeur des concours financiers dans le cadre de ce contrat ne peut dépasser la valeur des concours apportés en 1987. L'article 7 interdit la distribution des produits du tabac à titre gratuit. L'article 8 interdit de faire usage des marques apposées sur les produits du tabac sur des articles autres que ces produits, de distribuer ces marques et d'en faire usage dans toute publicité en faveur d'autres articles que les produits du tabac; cependant, le par. 8(3) crée pour la marque «Dunhill» une exception à l'interdiction prévue à l'art. 8.

Section 9 falls under the title "LABELLING", and prohibits tobacco manufacturers from selling their products unless they display on the package containing the product unattributed messages describing the health effects of the product as well as a list of the product's toxic constituents and the quantities of those constituents present in it. Section 17(*f*) authorizes the Governor in Council to adopt regulations prescribing the content, position, configuration, size and prominence of the health messages. Under the *Tobacco Products Control Regulations, amendment*, SOR/93-389, s. 11 (July 21, 1993), every tobacco package must display one of the following messages:

8 L'article 9, que l'on trouve sous la rubrique «ÉTIQUETAGE», interdit aux fabricants de vendre un produit du tabac qui ne comporte pas sur l'emballage les mises en garde non attribuées décrivant les effets du produit sur la santé ainsi que la liste et la quantité des substances toxiques que celui-ci contient. L'alinéa 17*f*) autorise le gouverneur en conseil à adopter des règlements pour fixer la teneur, la présentation, l'emplacement, les dimensions et la mise en évidence des messages relatifs à la santé. En vertu du *Règlement sur les produits du tabac — Modification*, DORS/93-389, art. 11 (21 juillet 1993), tout emballage contenant des produits du tabac doit porter l'un des messages suivants:

11. (1) . . .

(*a*) . . .

(i) "Cigarettes are addictive" . . .

(ii) "Tobacco smoke can harm your children" . . .

(iii) "Cigarettes cause fatal lung disease" . . .

(iv) "Cigarettes cause cancer" . . .

(v) "Cigarettes cause strokes and heart disease" . . .

(vi) "Smoking during pregnancy can harm your baby" . . .

(vii) "Smoking can kill you" . . .

(viii) "Tobacco smoke causes fatal lung disease in non-smokers" . . .

Section 17(*g*) also authorizes the Governor in Council to require leaflets providing health information to be placed inside packages of a tobacco product and to prescribe their content, form and manner of placement in those packages. Under s. 9(2), tobacco manufacturers are prohibited from displaying on their packages any writing other than the name, brand name, trade mark, and other information required by legislation.

9 One further provision of the Act is of relevance to these appeals. Section 17(*a*) gives the Governor in Council power to make regulations exempting a tobacco product from the application of ss. 4 and 7 where, in the opinion of the Governor in Council, that product is likely to be used as a substitute for other tobacco products and poses less risk to the health of users than those other products.

10 The enforcement provisions of the Act are found in ss. 11 to 16. These provisions confer upon the Minister the power to designate a "tobacco product inspector" with powers of inspection, search and seizure, analysis, detention of things seized, and forfeiture. The "offences and punishments" for contravention of the Act are set out in ss. 18 and 19. Section 18 stipulates that every person who contravenes ss. 4, 6(2), 7, 8, 9 or 10 is guilty of an offence punishable on summary conviction or an indictable offence. The penalties range in seriousness from a fine not exceeding two thousand dol-

11. (1) . . .

a) . . .

(i) «La cigarette crée une dépendance» . . .

(ii) «La fumée du tabac peut nuire à vos enfants» . . .

(iii) «La cigarette cause des maladies pulmonaires mortelles» . . .

(iv) «La cigarette cause le cancer» . . .

(v) «La cigarette cause des maladies du cœur» . . .

(vi) «Fumer durant la grossesse peut nuire à votre bébé» . . .

(vii) «Fumer peut vous tuer» . . .

(viii) «La fumée du tabac cause chez les non-fumeurs des maladies pulmonaires mortelles» . . .

De plus, l'al. 17*g*) autorise le gouverneur en conseil à exiger que des prospectus relatifs aux effets des produits du tabac soient placés à l'intérieur de l'emballage d'un produit du tabac et à en préciser la forme, la teneur et l'emplacement. En vertu du par. 9(2), il est interdit aux fabricants de produits du tabac d'apposer sur leurs emballages des mentions autres que la désignation, le nom et toute marque de celui-ci ainsi que les renseignements prévus par la loi.

Une autre disposition de la Loi est également pertinente en l'espèce. En vertu de l'al. 17*a*), le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l'application des art. 4 et 7 tout produit du tabac qui, à son avis, sera probablement utilisé comme substitut aux autres produits du tabac et fait courir moins de risque à la santé des consommateurs que ces autres produits.

Les dispositions relatives au contrôle d'application se trouvent aux art. 11 à 16. Ces dispositions confèrent au ministre le pouvoir de désigner un «inspecteur des produits du tabac» qui possède des pouvoirs de visite, de perquisition, de saisie, d'analyse, de détention d'objets et de confiscation. Les «infractions et peines» sont prévues aux art. 18 et 19. L'article 18 porte que quiconque contrevient aux art. 4, 6(2), 7, 8, 9 ou 10 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou commet un acte criminel. La gravité des peines varie d'une amende maxi-

lars or six months' imprisonment, or both, for a first offence on summary conviction, to a fine not exceeding three hundred thousand dollars or two years' imprisonment, or both, for a second or subsequent offence pursued by way of indictment.

The Relevant Statutory Provisions

For ease of reference, I set out the relevant provisions of the Act as follows:

4. (1) No person shall advertise any tobacco product offered for sale in Canada.

(2) No person shall, for consideration, publish, broadcast or otherwise disseminate, on behalf of another person, an advertisement for any tobacco product offered for sale in Canada.

(3) For greater certainty, subsection (2) does not apply in respect of the distribution for sale of publications imported into Canada or the retransmission of radio or television broadcasts originating outside Canada.

(4) No person in Canada shall advertise a tobacco product by means of a publication published outside Canada or a radio or television broadcast originating outside Canada primarily for the purpose of promoting the sale in Canada of a tobacco product.

(5) Notwithstanding subsections (1) and (2), the manufacturer or importer of a tobacco product may advertise the product by means of signs at any time before January 1, 1991, if

(*a*) the amount, determined in accordance with the regulations, expended by the manufacturer or importer on the preparation in 1989 of materials for use in signs and on the presentation of signs in that year does not exceed two thirds of the expenses of the manufacturer or importer, determined in accordance with the regulations, incurred during its last financial year ending before January 1, 1988 for such preparation and presentation;

(*b*) the amount, determined in accordance with the regulations, expended by the manufacturer or importer on such preparation and presentation in 1990 does not exceed one third of the expenses of the manufacturer or importer, so determined, incurred there-

male de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, pour une première infraction punissable par voie de procédure sommaire, jusqu'à une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines, s'il s'agit d'un récidiviste poursuivi par acte d'accusation.

Les dispositions législatives pertinentes

Par souci de commodité, je reproduis les dispositions pertinentes de la Loi: 11

4. (1) La publicité en faveur des produits du tabac mis en vente au Canada est interdite.

(2) Il est interdit, à titre onéreux et pour le compte d'une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, la publicité en faveur d'un produit du tabac mis en vente au Canada.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s'applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d'émissions de radio ou de télévision de l'étranger.

(4) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire de la publicité en faveur d'un produit du tabac dans une publication étrangère ou une émission radiodiffusée de l'étranger dans le but, principalement, de promouvoir la vente d'un produit du tabac au Canada.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2) le fabricant ou l'importateur d'un produit du tabac peut, jusqu'au 1er janvier 1991, exclusivement, faire de la publicité en faveur du produit par des affiches à condition que:

a) le montant qu'il dépense pour la préparation, en 1989, de la publicité relative à ces affiches et pour la présentation de ces affiches au public au cours de la même année ne dépasse pas les deux tiers des dépenses engagées pour la préparation et la présentation d'affiches au cours de son dernier exercice clos avant le 1er janvier 1988;

b) le montant qu'il dépense pour la préparation et la présentation d'affiches en 1990 ne dépasse pas le tiers

for during the financial year referred to in paragraph (*a*); and

(*c*) a health warning is provided in accordance with the regulations on any sign put in place after the coming into force of this Act.

(6) In subsection (5), "sign" does not include

(*a*) a sign displayed at the place of business of a retailer; or

(*b*) a representation described in paragraph 6(1)(*a*) or (*b*).

5. (1) Notwithstanding section 4, a retailer may

(*a*) expose tobacco products for sale at the retailer's place of business;

(*b*) post in that place, in the prescribed form, manner and quantity, signs that indicate, otherwise than by their brand names or trade marks, the tobacco products offered for sale and their prices;

(*c*) where the retailer's name or trade name contains any word or expression signifying that tobacco products are sold by the retailer, employ that name or trade name, otherwise than in association with a tobacco product, for the purpose of advertising the retailer's business, except by means of a radio or television transmission; and

(*d*) display at the retailer's place of business, at any time before January 1, 1993, an advertisement or portion thereof

(i) that was displayed in that place before January 25, 1988, or

(ii) that the retailer is obliged to display under the terms of a contract entered into before January 25, 1988, other than a term allowing for the extension or renewal of the contract after that day.

(2) Notwithstanding section 4, a person who operates a vending machine that dispenses tobacco products may identify or depict those products and their prices on the exterior of the vending machine in the prescribed form and manner.

6. (1) Notwithstanding section 4 and subsection 8(1) but subject to subsection (2) of this section, the full name of a manufacturer or importer of tobacco products

des dépenses engagées au cours de l'exercice visé à l'alinéa *a*);

c) les affiches installées après l'entrée en vigueur de la présente loi comportent une mise en garde réglementaire.

Les montants et dépenses visés au présent paragraphe se calculent conformément aux règlements.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), «affiche» ne vise pas:

a) les supports publicitaires se trouvant à l'intérieur ou aux abords de l'établissement d'un détaillant;

b) les mentions visées aux alinéas 6(1)*a*) ou *b*).

5. (1) Malgré l'article 4, le détaillant peut:

a) exposer des produits du tabac pour la vente dans son établissement;

b) signaler dans ce lieu, par des affiches réglementaires quant à leur forme, leur teneur et leur quantité, les produits du tabac qui y sont vendus ainsi que leur prix, sans toutefois mentionner leur nom ou leur marque;

c) faire usage, ailleurs qu'à la radio-télévision, de sa dénomination ou de sa raison sociale à des fins publicitaires — même quand l'un de ses éléments indique qu'il vend des produits du tabac — sans toutefois y associer un produit du tabac;

d) jusqu'au 1er janvier 1993, exclusivement, conserver, à l'intérieur ou aux abords de son établissement, les supports publicitaires — ou parties de ceux-ci:

(i) soit dont il avait déjà fait usage avant le 25 janvier 1988,

(ii) soit dont il est tenu de faire usage conformément aux stipulations d'un contrat conclu avant le 25 janvier 1988, à l'exclusion de toute stipulation autorisant le renouvellement ou la prorogation du contrat après cette date.

(2) Malgré l'article 4, l'exploitant d'un distributeur automatique de produits du tabac peut les représenter ou les nommer et en indiquer les prix sur celui-ci selon les modalités réglementaires.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est possible, malgré l'article 4 et le paragraphe 8(1), d'utiliser le nom intégral du fabricant ou de l'importateur d'un produit du

and, where required by the terms of a contract entered into before January 25, 1988, the brand name of a tobacco product, may be used, otherwise than in association with a tobacco product, in a representation to the public

(*a*) that promotes a cultural or sporting activity or event; or

(*b*) that acknowledges financial or other contributions made by the manufacturer or importer of the tobacco product toward such an activity or event.

(2) Where, in any calendar year, a manufacturer or importer of tobacco products makes financial or other contributions toward cultural or sporting activities or events in respect of which brand names of those products are used, the value of such contributions, determined in accordance with the regulations, shall not exceed the value, so determined, of the contributions made by the manufacturer or importer toward cultural or sporting activities and events in 1987.

7. (1) No distributor shall distribute tobacco products in the absence of consideration therefor, or furnish tobacco products to any person for the purpose of their subsequent distribution without consideration.

(2) No person shall offer any gift or cash rebate or the right to participate in any contest, lottery or game to the purchaser of a tobacco product in consideration of the purchase thereof, or to any person in consideration of the furnishing of evidence of such a purchase.

8. (1) No manufacturer or importer of tobacco products who is entitled to use any trade mark in association with those products, and no person acting with the concurrence or acquiescence of such a manufacturer or importer, shall

(*a*) apply the trade mark, in any form in which it appears on packages of the product that are sold in Canada, to any article other than a tobacco product or a package or container in which a tobacco product is sold or shipped, or

(*b*) use the trade mark in any such form for the purpose of advertising any article other than a tobacco product or any service, activity or event,

notwithstanding that the manufacturer or importer is,

tabac et, dans les cas où l'exige un contrat conclu avant le 25 janvier 1988, le nom du produit, sans toutefois y associer un produit du tabac, dans toute mention au public:

a) qui vise à promouvoir une activité ou une manifestation culturelles ou sportives;

b) qui fait état des concours financiers ou autres apportés par le fabricant ou l'importateur à la réalisation de cette activité ou manifestation.

(2) La valeur, calculée conformément aux règlements, des concours financiers ou autres apportés par le fabricant ou l'importateur de produits du tabac à la réalisation d'activités ou manifestations culturelles ou sportives dans le cadre desquelles est mentionné le nom des produits ne peut dépasser, pour une année civile donnée, la valeur, ainsi calculée, des concours qu'il a apportés en 1987 à la réalisation de telles activités ou manifestations.

7. (1) Il est interdit aux négociants de distribuer des produits du tabac à titre gratuit ou d'en fournir à cette fin.

(2) Il est interdit d'offrir un cadeau ou une remise, ou la possibilité de participer à un concours, une loterie ou un jeu, en contrepartie de l'achat d'un produit du tabac ou de la production d'une preuve d'achat de celui-ci.

8. (1) Il est interdit aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac:

a) d'apposer des marques qu'ils sont habilités à utiliser à l'égard de ces produits sur des articles, autres que les produits du tabac et les emballages servant à vendre ou expédier ceux-ci, sous une forme reprenant celle qui figure sur les emballages de ces produits alors vendus au Canada;

b) de faire usage de ces marques et sous cette forme dans toute publicité en faveur d'autres articles que les produits du tabac ou de services, manifestations ou activités.

La présente interdiction s'applique même si les fabricants ou les importateurs sont par ailleurs habilités à utiliser ces marques à l'égard de ces autres articles ou de ces services, manifestations ou activités et vise égale-

but for this Act, entitled to use the trade mark in association with that article, service, activity or event.

(2) No person shall distribute, sell, offer for sale or expose for sale any article, other than a tobacco product or a package or container in which a tobacco product is sold or shipped, that bears a trade mark of a tobacco product in any form in which it appears on packages of the tobacco product that are sold in Canada.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a trade mark if in 1986 tobacco products and other articles bearing that trade mark were sold at retail in Canada and the retail value of those other articles estimated in accordance with the regulations was greater than one-quarter of the retail value of those tobacco products so estimated.

(4) Subsection (2) does not apply in respect of the distribution or sale before January 1, 1993 of an article manufactured before April 30, 1987, or ordered before that date from the manufacturer or supplier of the article otherwise than by the placing of a standing order that requires confirmation or is subject to cancellation after that date.

9. (1) No distributor shall sell or offer for sale a tobacco product unless

(*a*) the package containing the product displays, in accordance with the regulations, messages pertaining to the health effects of the product and a list of toxic constituents of the product and, where applicable, of the smoke produced from its combustion indicating the quantities of those constituents present therein; and

(*b*) if and as required by the regulations, a leaflet furnishing information relative to the health effects of the product has been placed inside the package containing the product.

(2) No distributor shall sell or offer for sale a tobacco product if the package in which it is contained displays any writing other than the name, brand name and any trade marks of the tobacco product, the messages and list referred to in subsection (1), the label required by the *Consumer Packaging and Labelling Act* and the stamp and information required by sections 203 and 204 of the *Excise Act*.

(3) This section does not affect any obligation of a distributor, at common law or under any Act of Parliament or of a provincial legislature, to warn purchasers

ment quiconque agit avec le consentement, exprès ou tacite, de ces fabricants ou ces importateurs.

(2) Il est interdit de distribuer, de vendre, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des articles, autres que les produits du tabac et les emballages servant à vendre ou expédier ceux-ci, s'ils portent la marque d'un produit du tabac sous une forme reprenant celle qui figure sur les emballages de ce produit vendus au Canada.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si, en 1986 et au Canada, la valeur estimative, calculée conformément aux règlements, des ventes au détail d'articles autres que les produits du tabac portant la marque en question était supérieure au quart de celle, ainsi calculée, des produits du tabac portant également cette marque.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la vente ou à la distribution, avant le 1er janvier 1993, d'articles fabriqués avant le 30 avril 1987 ou commandés à leur fabricant ou fournisseur avant cette date, sauf s'il s'agit d'une commande permanente qui doit être confirmée ou peut prendre fin après cette date.

9. (1) Il est interdit aux négociants de vendre ou mettre en vente un produit du tabac qui ne comporte pas, sur ou dans l'emballage respectivement, les éléments suivants:

a) les messages soulignant, conformément aux règlements, les effets du produit sur la santé, ainsi que la liste et la quantité des substances toxiques, que celui-ci contient et, le cas échéant, qui sont dégagées par sa combustion;

b) s'il y a lieu, le prospectus réglementaire contenant l'information sur les effets du produit sur la santé.

(2) Les seules autres mentions que peut comporter l'emballage d'un produit du tabac sont la désignation, le nom et toute marque de celui-ci, ainsi que les indications exigées par la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* et le timbre et les renseignements prévus aux articles 203 et 204 de la *Loi sur l'accise*.

(3) Le présent article n'a pas pour effet de libérer le négociant de toute obligation qu'il aurait, aux termes d'une loi fédérale ou provinciale ou en *common law*,

of tobacco products of the health effects of those products.

17. The Governor in Council may make regulations

(*a*) exempting a tobacco product from the application of sections 4 and 7 where, in the opinion of the Governor in Council, that product is likely to be used as a substitute for other tobacco products and poses less risk to the health of users than those other products;

. . .

(*f*) prescribing, in respect of any tobacco product, the content, position, configuration, size and prominence of the messages and list of toxic constituents referred to in paragraph 9(1)(*a*);

(*g*) requiring leaflets furnishing information referred to in paragraph 9(1)(*b*) to be placed inside packages of a tobacco product and prescribing their content, form and manner of placement in those packages;

. . .

18. (1) Every person who contravenes section 4, 7, 8, 9 or 10

(*a*) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

(i) for a first offence under any of those sections, to a fine not exceeding two thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, and

(ii) where the person has previously been convicted of an offence under any of those sections, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or

(*b*) is guilty of an indictable offence and liable

(i) for a first offence under any of those sections, to a fine not exceeding one hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both, and

(ii) where the person has previously been convicted of an offence under any of those sections, to a fine not exceeding three hundred thousand dollars or to imprisonment for two years, or to both.

(2) Every person who contravenes subsection 6(2) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

d'avertir les acheteurs de produits du tabac des effets de ceux-ci sur la santé.

17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) exempter de l'application des articles 4 et 7 tout produit du tabac qui, à son avis, sera probablement utilisé comme substitut aux autres produits du tabac et fait courir moins de risque à la santé des consommateurs que ces autres produits;

. . .

f) fixer, pour tout produit du tabac, la teneur, la présentation, l'emplacement, les dimensions et la mise en évidence des mentions — messages et liste des substances toxiques — visées à l'alinéa 9(1)*a*);

g) exiger la présence, à l'intérieur de l'emballage d'un produit du tabac, du prospectus visé à l'alinéa 9(1)*b*) et préciser la forme de celui-ci, sa teneur ainsi que son emplacement;

. . .

18. (1) Quiconque contrevient aux articles 4, 7, 8, 9 ou 10:

a) soit commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt:

(i) pour une première infraction, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

(ii) s'il a déjà été déclaré coupable de n'importe laquelle des infractions prévues à ces articles, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) soit commet un acte criminel et encourt:

(i) pour une première infraction, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines,

(ii) s'il a déjà été déclaré coupable de n'importe laquelle des infractions prévues à ces articles, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 6(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire:

(*a*) for a first offence, to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or

(*b*) for a second or subsequent offence, to a fine not exceeding fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

(3) Every person who contravenes section 14 or any regulations made under paragraph 17(*i*) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding ten thousand dollars.

19. (1) A prosecution in respect of an offence under this Act, other than a prosecution under paragraph 18(1)(*b*), may not be instituted later than twelve months after the time when the subject-matter of the prosecution arose.

(2) A prosecution for an offence under this Act may be instituted, heard, tried and determined by a court in any territorial jurisdiction in which the accused carries on business regardless of where the subject-matter of the prosecution arose.

(3) No exception, exemption, excuse or qualification prescribed by law is required to be set out or negatived, as the case may be, in an information or indictment for an offence under this Act or under section 421, 422 or 423 [now section 463, 464 or 465] of the *Criminal Code* in respect of an offence under this Act.

(4) In any prosecution for an offence referred to in subsection (3), the burden of proving that an exception, exemption, excuse or qualification prescribed by law operates in favour of the accused is on the accused and the prosecutor is not required, except by way of rebuttal, to prove that the exception, exemption, excuse or qualification does not operate in favour of the accused, whether or not it is set out in the information or indictment.

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) en cas de récidive, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(3) Quiconque contrevient à l'article 14 et aux règlements d'application de l'alinéa 17*i*) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

19. (1) Les poursuites, autres que celles prévues à l'alinéa 18(1)*b*), visant les infractions à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la perpétration de celles-ci.

(2) Le tribunal dans le ressort duquel l'accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d'infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

(3) Dans les poursuites visant toute infraction à la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 421, 422 ou 423 [maintenant les articles 463, 464 ou 465] du *Code criminel* et relatives à une telle infraction, il n'est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.

(4) Dans les poursuites visées au paragraphe (3), il incombe à l'accusé de prouver qu'une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n'est pas tenu, si ce n'est à titre de réfutation, de prouver que l'exception, l'exemption, l'excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l'accusé, qu'elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Judgments of the Courts Below

Quebec Superior Court (1991), 82 D.L.R. (4th) 449 (Chabot J.) (translation)

12 Chabot J. found the Act invalid in its entirety, both as being *ultra vires* the Parliament of Canada under the *Constitution Act, 1867* and as constitut-

Les décisions des instances inférieures

La Cour supérieure du Québec, [1991] R.J.Q. 2260 (le juge Chabot)

Comme nous l'avons vu, le juge Chabot a déclaré la Loi non valide dans son intégralité, à la fois parce qu'elle était *ultra vires* du Parlement du

ing an unjustifiable infringement of s. 2(*b*) of the *Charter*.

In his analysis of the Act under the *Constitution Act, 1867*, Chabot J., at pp. 467-68, characterized it as legislation that is, in pith and substance, in relation to the regulation of advertising and promotion carried on by a particular industry. Having thus characterized the Act, Chabot J. then determined that it was not a valid exercise of the federal Parliament's criminal law power under s. 91(27) of the *Constitution Act, 1867* or Parliament's power to legislate for the peace, order and good government of Canada under s. 91 of the *Constitution Act, 1867*.

With respect to the criminal law power, Chabot J. reasoned that the Act was not valid criminal law because it was not addressed directly to the "evil" against which it was purportedly aimed, i.e., tobacco consumption. He observed, at p. 470, that "advertising in itself does not cause harm, any more than the advertising of tobacco products is by itself harmful to health" and, at p. 468, that "[t]he objective of protecting public health, if it exists, can only be an indirect and remote objective [of the Act]".

Turning to the peace, order and good government clause, Chabot J. concluded that the Act did not satisfy the criteria for the "national dimensions" branch of that clause set forth in *R. v. Crown Zellerbach Canada Ltd.*, [1988] 1 S.C.R. 401. The present cases were, in his view, distinguishable from the Privy Council's decisions in the "temperance cases" (*Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*, [1896] A.C. 348 (the *Local Prohibition Case*), and *Attorney-General for Ontario v. Canada Temperance Federation*, [1946] A.C. 193) because, in contrast with those cases, there was "no evidence that the advertisement of tobacco products has attained a stage of pestilence in Canada which would give it the required character and degree of singleness, distinctiveness and indivisibility which would distinguish it clearly from matters of provincial interest"

Canada en vertu de la *Loi constitutionnelle de 1867* et qu'elle constituait une violation injustifiable de l'al. 2*b*) de la *Charte*.

Dans son analyse de la Loi en vertu de la *Loi constitutionnelle de 1867*, le juge Chabot a dit, aux pp. 2275 et 2276, qu'il s'agissait d'une loi qui, de par son caractère véritable, cherche à réglementer la publicité et la promotion effectuées par une industrie donnée. Après avoir ainsi qualifié la Loi, il a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un exercice valide de la compétence du Parlement fédéral en matière de droit criminel en vertu du par. 91(27) de la *Loi constitutionnelle de 1867* ou de sa compétence de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada en vertu de l'art. 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*. 13

En ce qui concerne la compétence en matière de droit criminel, le juge Chabot a conclu que la Loi n'est pas une règle de droit criminel valide parce qu'elle ne traite pas directement du «mal» qu'elle prétend régler, soit la consommation des produits du tabac. Il a fait remarquer, à la p. 2278, que «la publicité ne cause pas de dommages comme tels, pas plus que la publicité des produits du tabac comme telle ne cause pas d'atteinte à la santé» et, à la p. 2276, que «[l]'objectif de protection de la santé publique, s'il existe, ne peut être qu'un objectif indirect et lointain [de la Loi]». 14

Examinant ensuite la compétence relative à la paix, l'ordre et le bon gouvernement, le juge Chabot a conclu que la Loi ne satisfaisait pas aux critères du volet «dimension nationale» de cette compétence, formulés dans l'arrêt *R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd.*, [1988] 1 R.C.S. 401. À son avis, les présents pourvois se distinguent des arrêts du Conseil privé sur la «tempérance» (*Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for the Dominion*, [1896] A.C. 348 (*l'arrêt sur la prohibition locale*), et *Attorney-General for Ontario c. Canada Temperance Federation*, [1946] A.C. 193) parce que, contrairement à ce qui existait dans ces arrêts, «il n'y a aucune preuve que la publicité des produits du tabac aurait atteint ce stade de pestilence au Canada qui lui donnerait ce caractère et ce degré requis d'unicité, de particularité et d'indivisibilité qui la distinguerait claire- 15

(p. 475). Chabot J. also decided that there was no evidence of a "provincial inability" to control tobacco advertising. He observed, at p. 478, that "the evidence clearly shows the will and the capacity of the provinces to cooperate with each other and with the federal government with respect to the advertising and promotion of tobacco products".

16 Proceeding to an analysis of the Act's validity under the *Charter*, Chabot J. found the Act to be in violation of the appellants' right to freedom of expression under s. 2(*b*). He concluded, first (at pp. 484-85), that tobacco advertising has a sufficient expressive content to constitute a protected activity under s. 2(*b*) and, second (at p. 486), that the unattributed health message requirement under s. 9 of the Act infringed the appellants' s. 2(*b*) rights on the ground that "freedom of expression includes the freedom to remain silent".

17 Chabot J. then found, applying the test established by this Court in *R. v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103, that the s. 2(*b*) infringement was not justified under s. 1 of the *Charter*. After considering the uncontradicted evidence adduced by the Attorney General concerning the dire health consequences of tobacco use, Chabot J., at p. 492, concluded that the Attorney General had satisfied the first branch of the *Oakes* test by demonstrating a "substantial and pressing concern". However, he concluded that the Act did not survive the "proportionality" branch of that test. He began his proportionality analysis by holding, at p. 515, that the Attorney General had failed to establish, on the balance of probabilities, that a rational connection exists between a full prohibition on advertising and the objective of reducing tobacco consumption. He also observed, at p. 513, that "[t]he virtual totality of the scientific documents in the state's possession at the time the Act was passed do not demonstrate that a ban on advertising would affect consumption". He then decided that the complete prohibition on advertising under the Act did not meet the test of minimal impairment of the appel-

ment des matières d'intérêt provincial» (p. 2281). Le juge Chabot a décidé qu'il n'y avait aucune preuve de «l'incapacité provinciale» de contrôler la publicité des produits du tabac. Il a fait remarquer, à la p. 2283, que «la preuve a révélé abondamment la volonté et la capacité des provinces de coopérer entre elles et avec le fédéral en regard de la publicité et de la promotion des produits du tabac».

Passant ensuite à une analyse de la validité de la Loi au regard de la *Charte*, le juge Chabot a déterminé que la Loi viole le droit à la liberté d'expression garanti aux appelantes par l'al. 2*b*). Il a conclu dans un premier temps que la publicité des produits du tabac a un contenu expressif suffisant pour constituer une activité protégée au sens de l'al. 2*b*) (aux pp. 2288 et 2289), et dans un deuxième temps, que l'exigence des messages de santé non attribués prévue à l'art. 9 de la Loi contrevient aux droits garantis aux appelantes par l'al. 2*b*) pour le motif que «la liberté d'expression inclut la liberté de ne pas s'exprimer» (p. 2289).

Lorsqu'il a appliqué le critère formulé par notre Cour dans l'arrêt *R. c. Oakes*, [1986] 1 R.C.S. 103, le juge Chabot a ensuite affirmé que la violation de l'al. 2*b*) ne se justifiait pas en vertu de l'article premier de la *Charte*. Après avoir examiné la preuve non contredite déposée par le procureur général relativement aux conséquences graves du tabagisme, le juge Chabot a conclu, à la p. 2294, que le ministère public avait satisfait au premier critère de l'arrêt *Oakes* en établissant une «préoccupation réelle et urgente». Cependant, il a conclu que la Loi ne satisfait pas au volet «proportionnalité» de ce critère. Il a commencé son analyse de la proportionnalité en affirmant, à la p. 2310, que le procureur général n'avait pas fait, suivant la prépondérance des probabilités, la preuve d'un lien rationnel entre une interdiction totale de publicité et l'objectif de diminution de la consommation des produits du tabac. Il a aussi fait remarquer, à la p. 2309, que «[l]a presque totalité de la documentation scientifique en possession de l'État lors de l'adoption de la loi ne démontrait pas que le bannissement de la publicité aurait un effet sur la consommation». Il a alors décidé que le bannissement total de la publi-

lants' s. 2(*b*) rights. He observed, at pp. 515-16, that no evidence had been adduced at trial demonstrating that a complete prohibition on tobacco advertisements would reduce tobacco consumption more effectively than a partial ban, or that unattributed health warnings would be more effective than attributed health warnings. Finally, with respect to the proportionality between effects and objectives, Chabot J. concluded, at p. 517, that the Act constitutes "social engineering" and "an extremely serious impairment of the principles inherent in a free and democratic society which is disproportionate to the objective of the [Act]".

cité en vertu de la Loi ne satisfaisait pas au critère de l'atteinte minimale aux droits garantis aux appelantes par l'al. 2*b*). Il a ajouté, à la p. 2311, que l'on n'avait pas présenté de preuve en première instance établissant qu'un bannissement total de la publicité relative aux produits du tabac réduirait la consommation de façon plus efficace qu'un bannissement partiel, ou que des messages non attribués seraient plus efficaces que des messages attribués. Enfin, en ce qui concerne la proportionnalité entre les effets et les objectifs, le juge Chabot a conclu, à la p. 2312, que la Loi constitue un genre d'«ingénierie sociale» et «une atteinte extrêmement grave aux principes inhérents d'une société libre et démocratique, incommensurable avec l'objectif de la [Loi]».

Quebec Court of Appeal (1993), 102 D.L.R. (4th) 289 (LeBel and Rothman JJ.A., Brossard J.A. dissenting in part) (translation)

La Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 375 (les juges LeBel et Rothman; le juge Brossard étant dissident en partie)

The Court of Appeal allowed the appeals from the decision of Chabot J. and upheld the constitutional validity of the Act in its entirety. It was unanimous in deciding that the Act was not beyond the legislative competence of the Parliament of Canada under s. 91 of the *Constitution Act, 1867* and, although the Attorney General had conceded that the Act constituted an infringement of the appellants' rights under s. 2(*b*), a majority (Brossard J.A. dissenting) decided that the infringement was justifiable under s. 1 of the *Charter*.

18 La Cour d'appel a accueilli les appels contre la décision du juge Chabot et confirmé la constitutionnalité de l'ensemble de la Loi. La cour, à l'unanimité, a statué que la Loi n'outrepassait pas la compétence législative du Parlement du Canada prévue à l'art. 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*; en outre, même si le procureur général avait admis que la Loi constituait une violation des droits garantis aux appelantes par l'al. 2*b*), la cour à la majorité (le juge Brossard étant dissident) a décidé que cette violation était justifiable en vertu de l'article premier de la *Charte*.

Writing for a unanimous Court of Appeal with respect to the constitutionality of the Act under the *Constitution Act, 1867*, Brossard J.A. began his analysis by characterizing the Act as legislation, in pith and substance, in relation to the protection of public health (at p. 339). Brossard J.A. criticized, at pp. 338-39, the trial judge's pith and substance analysis on two grounds. First, he decided that the trial judge had confined himself to an excessively literal interpretation of the Act by failing to explore a possible connection between the Act's statement of purpose in s. 3 and its legal effect on tobacco advertising and promotion. Second, he held that the trial judge had confused the evidentiary requirements for the application of s. 1 of the

19 S'exprimant au nom de la Cour d'appel à l'unanimité relativement à la constitutionnalité de la Loi en vertu de la *Loi constitutionnelle de 1867*, le juge Brossard a commencé son analyse en affirmant, à la p. 408, que la Loi visait, de par son caractère véritable, la protection de la santé publique. Le juge Brossard, aux pp. 407 et 408, a trouvé deux lacunes dans l'analyse du caractère véritable de la loi faite par le juge de première instance. Premièrement, il a décidé que le juge de première instance s'était restreint à une interprétation trop littérale de la Loi, en omettant de rechercher un lien possible entre l'objet de la Loi mentionné à l'art. 3 et son effet juridique sur la publicité et la promotion des produits du tabac. Deuxièmement, il a statué que le

Charter, under which the effectiveness of the legislation is a relevant criterion, with the requirements for ascertaining pith and substance in a division of powers analysis, where it is not.

juge de première instance avait confondu les exigences de la preuve relative à l'application de l'article premier de la *Charte*, en vertu duquel l'efficacité de la loi est un critère pertinent, et ce qui est requis pour la détermination du caractère véritable de la loi, dans le cadre d'une analyse sur le partage des pouvoirs, dans laquelle cette efficacité n'est pas un critère pertinent.

20 Brossard J.A. then proceeded to consider whether the Act was a valid exercise of the federal criminal law power under s. 91(27) of the *Constitution Act, 1867* or the peace, order and good government clause under s. 91 of the *Constitution Act, 1867*. He began by deciding that the Act did not fall under the criminal law power. He found it significant, at pp. 341-42, that neither tobacco consumption nor tobacco advertising are activities that have an "affinity with some traditional criminal law concern" (p. 342) and observed that, although the Act makes the advertising and promotion of tobacco products illegal, the "real evil" the Act is designed to combat, tobacco consumption, continues to be legal in Canada. Parliament, he reasoned, at pp. 340-41, cannot criminalize the ancillary activities relating to a principal activity when it has not criminalized the principal activity itself. Brossard J.A. decided, however, that the Act fell within the federal Parliament's power to legislate for the peace, order and good government of Canada because it satisfied the test for the "national dimensions" branch of that power developed in *Crown Zellerbach*, *supra*. He observed, at p. 348, that the problem of tobacco consumption has developed into a matter of national concern comparable in scope to that of alcohol consumption addressed in the temperance cases. He also noted, at p. 350, that the health problems resulting from tobacco consumption have a "singleness, distinctiveness and indivisibility that distinguish them clearly from matters that are of strictly provincial interest". Finally, he concluded that the Act met the "provincial inability test" because "[t]he fact is that communications, whether radio or television broadcasting, or even newspaper publishing, do not

Le juge Brossard a ensuite examiné si la Loi constituait un exercice valide de la compétence fédérale en matière de droit criminel en vertu du par. 91(27) de la *Loi constitutionnelle de 1867* ou de la compétence de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement en vertu de l'art. 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Il a commencé par affirmer qu'il ne s'agissait pas d'une loi relevant de la compétence en matière de droit criminel. À son avis (aux pp. 409 et 410), il importe de préciser que ni la consommation des produits du tabac ni la publicité de ces produits ne constituent des activités qui ont [TRADUCTION] «une affinité avec une préoccupation traditionnelle en matière de droit criminel» (p. 410); il a aussi fait remarquer que, bien que la Loi rende illégale la publicité et la promotion des produits du tabac, le «véritable mal» que vise à combattre la Loi — la consommation des produits du tabac — demeure légitime au Canada. Le Parlement, raisonne-t-il, aux pp. 408 et 409, ne peut rendre criminels les aspects secondaires de l'activité principale s'il n'a pas criminalisé cette activité. Cependant, le juge Brossard a décidé que la Loi relève de la compétence du fédéral de légiférer pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada parce qu'elle satisfait aux critères du volet «dimension nationale» de cette compétence formulés dans l'arrêt *Crown Zellerbach*, précité. Il a fait observer, à la p. 414, que le tabagisme est devenu un problème d'intérêt national d'une envergure comparable à celui de la consommation de l'alcool dont il était question dans les arrêts sur la tempérance. Il a aussi fait remarquer, à la p. 415, que les problèmes de santé reliés au tabagisme comportent ce «degré d'unicité, de particularité et d'indivisibilité qui les distingue clairement des matières d'intérêt strictement provincial». Enfin, il a conclu que la Loi satisfaisait au «critère de l'incapacité provinciale» parce que

recognize frontiers, still less provincial borders" (pp. 350-51).

«le domaine des communications, qu'il s'agisse de radio, de télévision, de publication même de journaux, ne connaît plus de frontières et encore moins de frontières provinciales» (p. 415).

The Court of Appeal was divided on the validity of the Act under the *Charter*. LeBel J.A., writing for the majority, accepted that the Act infringed the appellants s. 2(*b*) rights, but held that the infringement was justified under s. 1 of the *Charter*. LeBel J.A., at pp. 311-12, first noted that the trial judge had erred in applying a civil standard of justification in his application of the *Oakes* analysis. He observed, at p. 313, that, in cases involving socio-economic legislation such as the Act, this Court has "recognized the need for an attitude of deference with regard to legislative choices", and has required the state to meet an attenuated standard of justification under the *Oakes* analysis.

21 La Cour d'appel était partagée sur la question de la validité de la Loi en vertu de la *Charte*. Le juge LeBel, s'exprimant au nom de la majorité, a reconnu que la Loi violait les droits garantis aux appelantes par l'al. 2*b*), mais a conclu que cette violation pouvait se justifier en vertu de l'article premier de la *Charte*. Il a tout d'abord fait remarquer, à la p. 391, que le juge de première instance avait commis une erreur en appliquant un critère de justification assimilable à celui appliqué dans un procès civil lorsqu'il a procédé à l'analyse élaborée dans l'arrêt *Oakes*. Il a fait observer, à la p. 392, que, dans les cas de lois socio-économiques comme en l'espèce, notre Cour «reconnaît la nécessité d'une attitude de déférence à l'égard des choix législatifs en ce domaine» et exige du ministère public qu'il satisfasse à un critère assoupli de justification en vertu de l'analyse élaborée dans l'arrêt *Oakes*.

Applying the attenuated *Oakes* standard, LeBel J.A. held that the Act was a justifiable infringement under s. 1 of the *Charter*. He first observed that "there does not appear to be a serious debate" that the objective of reducing the number of smokers in Canada is pressing and substantial (p. 321), and then proceeded to an application of the proportionality test. There was, he held, at p. 323, sufficient evidence adduced at trial to establish a rational connection between a prohibition of tobacco advertising and the goal of reducing tobacco consumption. He conceded that there was no evidence on the record demonstrating, on the criterion of the civil balance of proof, that the prohibition of these forms of advertising would attain that objective. However, he noted that there was sufficient expert testimony and documentation adduced at trial to "attest, at the very least, to the existence of a body of opinion favourable to the adoption of a legislative measure such as the restriction of tobacco advertising in order to diminish consumption over time" (p. 323). LeBel J.A. also observed, at p. 324, that, in Imperial's

22 Le juge LeBel a appliqué une forme assouplie du critère formulé dans l'arrêt *Oakes* et conclu que la Loi constituait une violation justifiable en vertu de l'article premier de la *Charte*. Il a tout d'abord précisé qu'«il ne semble pas y avoir de débat sérieux» que l'objectif de réduire le nombre de fumeurs au Canada est important et urgent (p. 397), et il a ensuite appliqué le critère de la proportionnalité. À son avis, suffisamment d'éléments de preuve ont été présentés au procès pour établir un lien rationnel entre une interdiction de la publicité des produits du tabac et l'objectif de diminuer le tabagisme (p. 398). Il a reconnu qu'il n'existe pas, dans le dossier, de preuve démontrant que, suivant le critère civil de la prépondérance de la preuve, l'interdiction de ces formes de publicité réussirait à atteindre cet objectif. Toutefois, il a affirmé que l'on avait présenté au procès suffisamment de témoignages d'expert et d'études qui «attestent, à tout le moins, de l'existence d'un corps d'opinions favorables à l'adoption d'une mesure législative comme la limitation de la publicité du tabac, pour diminuer éventuellement la consommation de

internal documentation, "there are commentaries suggesting that the objective of tobacco advertising is either promotion, recruitment of new smokers, or consolidation of market share by reassuring current smokers".

23 Second, LeBel J.A. held, at pp. 326-27, that the Act satisfied the minimal impairment test because the measures adopted under the Act did not prohibit consumption of tobacco, did not allow for the control of foreign advertising, and permitted the continued availability of tobacco product information at retail establishments. Finally, he found it significant that the legislative objective, addressing a serious health problem, outweighed the adverse effects of the legislation on the appellants' right to commercial expression which, he noted, at p. 326, "seeks exclusively to advance the respondents' interests in marketing, distributing and selling a product recognized as harmful".

24 Brossard J.A., in dissent, agreed with LeBel J.A. that the Act's objective was pressing and substantial, and that ss. 7 and 9 met the requirements of the *Oakes* test but, in his view, ss. 4, 5, 6 and 8 did not satisfy either the rational connection or the minimal impairment branches of the *Oakes* proportionality test.

25 With respect to the rational connection test, Brossard J.A. distinguished between three different types of advertising (at pp. 383-84): informative advertising (which disseminates information concerning product content), brand loyalty advertising (which is aimed solely at promoting one brand over another based on the colour, design and appearance of the packaging), and lifestyle advertising (which creates an image by associating the product's consumption with a particular lifestyle). Brossard J.A. found, at p. 384, that the prohibition on informative advertising and brand preference advertising was not rationally connected to the goal of reducing consumption of tobacco because "there is not a single piece of evidence in the record with any probative value to the effect that it

celui-ci» (p. 398). Le juge LeBel a aussi fait observer, à la p. 399, que, dans la documentation interne obtenue d'Imperial, «l'on retrouve aussi des commentaires suggérant que la publicité du tabac aurait un objectif soit de promotion, soit de recrutement de nouveaux fumeurs, soit de consolidation de la clientèle, en rassurant les fumeurs actuels».

Deuxièmement, le juge LeBel a conclu, aux pp. 400 et 401, que la Loi satisfait au critère de l'atteinte minimale parce que les mesures adoptées en vertu de la Loi n'interdisent pas la consommation des produits du tabac, ne permettent pas de contrôler la publicité étrangère et permettent de continuer de fournir de l'information sur les produits du tabac aux points de vente. Enfin, il a jugé important que l'objectif législatif, qui vise un problème grave de santé, l'emporte sur les effets négatifs qu'a la loi sur la garantie de l'expression commerciale des appelantes, lequel, estime-t-il, à la p. 400, «recherche uniquement la promotion de l'intérêt des intimés à commercialiser, distribuer et vendre un produit reconnu comme nocif».

Le juge Brossard, dissident, était d'accord avec le juge LeBel pour dire que l'objectif de la Loi était urgent et réel, et que les art. 7 et 9 répondaient aux exigences du critère formulé dans l'arrêt *Oakes*; cependant, à son avis, les art. 4, 5, 6 et 8 ne satisfont ni au volet du lien rationnel ni à celui de l'atteinte minimale du critère de la proportionnalité formulé dans *Oakes*.

En ce qui concerne le critère du lien rationnel, le juge Brossard a établi une distinction entre trois différents types de publicité (aux pp. 437 et 438): la publicité informative (celle qui contient de l'information quant au contenu du produit), la publicité de fidélité à une marque (qui vise uniquement à promouvoir une marque plutôt qu'une autre par l'effet de la couleur, du design de l'emballage et de sa présentation) et la publicité de style de vie (qui crée une image en associant un style de vie à la consommation du produit). Le juge Brossard a conclu, aux pp. 437 et 438, que l'interdiction de la publicité informative et de la publicité de fidélité à une marque n'a pas de lien rationnel avec l'objectif de diminuer l'usage du tabac parce qu'il «n'existe au dossier aucun élément de preuve ayant quelque

encourages non-smokers to become smokers . . . or smokers to increase their consumption, or that it prevents smokers from reducing their consumption or quitting if they want to". However, he found, at p. 385, that the prohibitions respecting lifestyle advertising met the rational connection test owing to the testimony adduced at trial concerning the stimulative effect of such advertising upon the consumer behaviour of young persons.

Proceeding to the minimal impairment requirement, Brossard J.A. held, at p. 387, that, with the exception of the prohibition upon lifestyle advertising, ss. 4, 5, 6 and 8 of the Act did not minimally impair the appellants' rights because "it would easily have been possible to exclude from the general ban any advertising which is purely informative, there being no proof even on the level of possibility that such advertising has any impact on consumption". Thus, Brossard J.A. concluded, at p. 392, that ss. 4, 5, 6 and 8 of the Act could not be justified under s. 1 of the *Charter*, but that ss. 7 and 9 could be justified under s. 1 of the *Charter*. Brossard J.A. did not uphold the prohibition on lifestyle advertising, even though he decided it was theoretically justifiable under s. 1, because Parliament made no distinction between types of advertising in the legislation.

Issues Before This Court

The argument before this Court was conducted on the basis of two constitutional questions, stated by Chief Justice Lamer on November 4, 1993:

1. Is the *Tobacco Products Control Act*, S.C. 1988, c. 20, wholly or in part within the legislative competence of the Parliament of Canada as being a law enacted for the peace, order and good government of Canada pursuant to s. 91 of the *Constitution Act, 1867*; as being enacted pursuant to the criminal law power in s. 91(27) thereof; or otherwise?

2. Is the *Tobacco Products Control Act* wholly or in part inconsistent with the right of freedom of expression as set out in s. 2(*b*) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* and, if so, does it constitute a

valeur probante à l'effet qu'elle inciterait un non-consommateur à le devenir [. . .] ou un consommateur à augmenter sa consommation ou à l'empêcher de diminuer ou d'arrêter cette consommation s'il le désire». Cependant, il a conclu, à la p. 438, que l'interdiction de publicité de style de vie satisfaisait au critère du lien rationnel compte tenu des témoignages présentés au procès relativement à l'effet incitatif de cette publicité sur le comportement des jeunes consommateurs.

26 Pour ce qui est de l'exigence de l'atteinte minimale, le juge Brossard a conclu, à la p. 439, que, sous réserve de l'exception de l'interdiction de publicité de style de vie, les art. 4, 5, 6 et 8 de la Loi ne constituent pas une atteinte minimale aux droits des appelantes parce qu'il «eût été facilement possible de soustraire toute publicité de nature strictement informative, n'ayant aucune incidence prouvée, même au niveau des possibilités, sur la consommation, de la suppression générale». En conséquence, le juge Brossard a conclu, à la p. 442, que les art. 4, 5, 6 et 8 de la Loi ne pouvaient se justifier en vertu de l'article premier de la *Charte*, mais que les art. 7 et 9 le pouvaient. Il n'a pas confirmé l'interdiction de publicité de style de vie, même s'il a décidé que ce type de publicité était théoriquement justifiable en vertu de l'article premier, parce que le législateur n'avait pas fait dans la loi de distinction entre les types de publicité.

Les questions devant notre Cour

27 Les arguments présentés devant notre Cour ont porté sur deux questions constitutionnelles formulées par le juge en chef Lamer le 4 novembre 1993:

1. La *Loi réglementant les produits du tabac*, L.C. 1988, ch. 20, relève-t-elle, en tout ou en partie, de la compétence du Parlement du Canada de légiférer pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada en vertu de l'art. 91, ou en matière de droit criminel suivant le par. 91(27), de la *Loi constitutionnelle de 1867*, ou autrement?

2. La *Loi réglementant les produits du tabac* est-elle, en tout ou en partie, incompatible avec la liberté d'expression garantie à l'al. 2*b*) de la *Charte canadienne des droits et libertés* et, dans l'affirmative, apporte-

reasonable limit on that right as can be demonstrably justified pursuant to s. 1 thereof?

t-elle une limite raisonnable à l'exercice de ce droit, dont la justification puisse se démontrer au sens de l'article premier de la *Charte*?

Analysis

Analyse

1. *Jurisdiction under the Constitution Act, 1867*

1. *Compétence en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867*

The Criminal Law Power

La compétence en matière de droit criminel

28 The first question arising on these appeals is whether the Act constitutes a valid exercise of the federal criminal law power and is therefore *intra vires* the federal Parliament. Section 91(27) of the *Constitution Act, 1867* confers on the federal Parliament the exclusive power to legislate in relation to the criminal law. The criminal law power is plenary in nature and this Court has always defined its scope broadly. As Estey J. observed in *Scowby v. Glendinning*, [1986] 2 S.C.R. 226, at p. 238, "[t]he terms of s. 91(27) of the Constitution must be read as assigning to Parliament exclusive jurisdiction over criminal law in the widest sense of the term"; see also *Attorney-General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co.*, [1903] A.C. 524 (P.C.), at pp. 528-29. In developing a definition of the criminal law, this Court has been careful not to freeze the definition in time or confine it to a fixed domain of activity; see *Goodyear Tire and Rubber Co. v. The Queen*, [1956] S.C.R. 303, at p. 311 (*per* Rand J.); *R. v. Zelensky*, [1978] 2 S.C.R. 940, at pp. 950-51 (*per* Laskin C.J.). In *Proprietary Articles Trade Association v. Attorney-General for Canada*, [1931] A.C. 310 (*PATA*), at p. 324, the Privy Council defined the federal criminal law power in the widest possible terms to include any prohibited act with penal consequences. Subsequent to that decision, this Court recognized that the Privy Council's definition was too broad in that it would allow Parliament to invade areas of provincial legislative competence colourably simply by legislating in the proper form; see *Scowby*, *supra*, at p. 237. So, as Estey J. put it in *Scowby*, at p. 237, "it was accepted that some legitimate public purpose must underlie the prohibition". This necessary adjustment was introduced in *Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act*, [1949] S.C.R. 1 (the *Margarine Reference*). Rand J. drew

La première question soulevée dans les présents pourvois vise à déterminer si la Loi constitue un exercice valide de la compétence fédérale en matière de droit criminel et est en conséquence *intra vires* du Parlement. Le paragraphe 91(27) de la *Loi constitutionnelle de 1867* confère au Parlement la compétence exclusive de légiférer relativement au droit criminel. Cette compétence est de nature plénière et notre Cour en a toujours défini largement la portée. Comme le juge Estey l'a fait remarquer dans l'arrêt *Scowby c. Glendinning*, [1986] 2 R.C.S. 226, à la p. 238, «[l]es termes du par. 91(27) de la Constitution doivent être interprétés comme attribuant au Parlement la compétence exclusive en matière de droit criminel dans le sens plus large du terme»; voir aussi *Attorney-General for Ontario c. Hamilton Street Railway Co.*, [1903] A.C. 524 (C.P.), aux pp. 528 et 529. Dans l'élaboration d'une définition du droit criminel, notre Cour a pris soin de ne pas geler la définition à une époque déterminée ni de la restreindre à un domaine d'activité fixe; voir *Goodyear Tire and Rubber Co. c. The Queen*, [1956] R.C.S. 303, à la p. 311 (le juge Rand); *R. c. Zelensky*, [1978] 2 R.C.S. 940, aux pp. 950 et 951 (le juge en chef Laskin). Dans l'arrêt *Proprietary Articles Trade Association c. Attorney-General for Canada*, [1931] A.C. 310 (*PATA*), à la p. 324, le Conseil privé a défini la compétence fédérale en matière de droit criminel dans le sens le plus large possible de façon à inclure tout acte interdit assorti de sanctions pénales. À la suite de cette décision, notre Cour a reconnu que la définition du Conseil privé était trop large car elle permettrait au Parlement, simplement en légiférant de la manière appropriée, d'empiéter spécieusement sur des domaines de compétence législative provinciale; voir *Scowby*, précité, à la p. 237. Comme l'affirme le juge Estey

attention, at pp. 49-50, to the need to identify the evil or injurious effect at which a penal prohibition was directed. He stated:

> A crime is an act which the law, with appropriate penal sanctions, forbids; but as prohibitions are not enacted in a vacuum, we can properly look for some evil or injurious or undesirable effect upon the public against which the law is directed. That effect may be in relation to social, economic or political interests; and the legislature has had in mind to suppress the evil or to safeguard the interest threatened.
>
> . . .
>
> Is the prohibition . . . enacted with a view to a public purpose which can support it as being in relation to criminal law? Public peace, order, security, health, morality: these are the ordinary though not exclusive ends served by that law . . . . [Emphasis added.]

See also *R. v. Morgentaler*, [1993] 3 S.C.R. 463, at p. 489.

Taking into account the broad definition of the criminal law developed by this Court, I am satisfied that the Act is, in pith and substance, criminal law. A law's pith and substance, or "matter", is best described as its dominant purpose or true character; see *Morgentaler*, *supra*, at pp. 481-82. From a plain reading of the Act, it seems clear that Parliament's purpose in enacting this legislation was to prohibit three categories of acts: advertisement of tobacco products (ss. 4 and 5), promotion of tobacco products (ss. 6 to 8) and sale of tobacco products without printed health warnings (s. 9). These prohibitions are accompanied by penal sanctions under s. 18 of the Act, which, as Lord Atkin noted in *PATA*, *supra*, at p. 324, creates at least a *prima facie* indication that the Act is criminal law. However, the crucial further question is whether the Act also has an underlying criminal public purpose in the sense described by Rand J. in the *Margarine Reference*, *supra*. The question, as Rand J.

dans *Scowby*, à la p. 237, «on a accepté que l'interdiction doit se fonder sur un objectif public légitime». Cet ajustement nécessaire a été introduit dans *Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act*, [1949] R.C.S. 1 (le *Renvoi sur la margarine*). Aux pages 49 et 50, le juge Rand a attiré l'attention sur la nécessité d'identifier le mal ou l'effet nuisible ou indésirable contre lequel la loi est dirigée. Il affirme:

> [TRADUCTION] Un crime est un acte que la loi interdit, avec des sanctions pénales appropriées; mais comme les prohibitions ne sont pas édictées dans le vide, nous sommes justifiés de chercher contre quel mal ou effet nuisible ou indésirable pour le public la loi est dirigée. Cet effet peut être relié à des intérêts sociaux, économiques ou politiques; et la législature avait à l'esprit de supprimer le mal ou de protéger l'intérêt menacé.
>
> . . .
>
> La prohibition est-elle [. . .] adoptée en vue d'un objectif public qui peut la faire considérer comme relative au droit criminel? La paix publique, l'ordre, la sécurité, la santé, la moralité: ce sont là des buts habituels, bien que non exclusifs, que poursuit ce droit . . . [Je souligne.]

Voir aussi *R. c. Morgentaler*, [1993] 3 R.C.S. 463, à la p. 489.

29 Si l'on tient compte de la définition large du droit criminel établie par notre Cour, je suis convaincu que la Loi est, de par son caractère véritable, une loi en matière de droit criminel. La meilleure façon de décrire le caractère véritable d'une loi, ou la «matière» qu'elle vise, consiste à partir de son objet principal ou de son idée maîtresse; voir *Morgentaler*, précité, aux pp. 481 et 482. Si l'on interprète la Loi dans son sens ordinaire, il semble évident qu'elle avait pour objet d'interdire trois catégories d'actes: la publicité en faveur des produits du tabac (art. 4 et 5), la promotion des produits du tabac (art. 6 à 8) et la vente des produits du tabac dont l'emballage ne comporterait pas les messages relatifs à la santé (art. 9). Ces interdictions sont assorties de sanctions pénales en vertu de l'art. 18 de la Loi, lesquelles, comme le précise lord Atkin dans l'arrêt *PATA*, précité, à la p. 324, créent une indication du moins à première vue que la loi est de droit criminel. Cependant, l'autre

framed it, is whether the prohibition with penal consequences is directed at an "evil" or injurious effect upon the public.

30 In these cases, the evil targeted by Parliament is the detrimental health effects caused by tobacco consumption. This is apparent from s. 3, the Act's "purpose" clause, which bears repeating here:

> **3.** The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and, in particular,
>
> (*a*) to protect the health of Canadians in the light of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases;
>
> (*b*) to protect young persons and others, to the extent that is reasonable in a free and democratic society, from inducements to use tobacco products and consequent dependence on them; and
>
> (*c*) to enhance public awareness of the hazards of tobacco use by ensuring the effective communication of pertinent information to consumers of tobacco products.

Quite clearly, the common thread running throughout the three enumerated purposes in paras. 3(*a*) to (*c*) is a concern for public health and, more specifically, a concern with protecting Canadians from the hazards of tobacco consumption. This is a valid concern. A copious body of evidence was introduced at trial demonstrating convincingly, and this was not disputed by the appellants, that tobacco consumption is widespread in Canadian society and that it poses serious risks to the health of a great number of Canadians. I note in passing the well-established principle that a court is entitled, in a pith and substance analysis, to refer to extrinsic materials, such as related legislation, Parliamentary debates and evidence of the "mischief" at which the legislation is directed; see *Morgentaler*, *supra*, at pp. 483-84; *Reference Re Anti-Inflation Act*, [1976] 2 S.C.R. 373, at p. 437; *Re Upper Churchill Water Rights Reversion Act*, [1984] 1

question importante est de savoir si la Loi a également un objectif public sous-jacent du droit criminel au sens où le décrit le juge Rand dans le *Renvoi sur la margarine*, précité. Comme le précise le juge Rand, la question est de savoir si l'interdiction assortie de sanctions pénales est dirigée contre un «mal» ou un effet nuisible pour le public.

Dans les présents pourvois, le mal visé par le Parlement est l'effet nocif de l'usage du tabac sur la santé. Ceci ressort clairement de l'art. 3, la clause «objet» de la Loi, qu'il vaut la peine de reproduire ici:

> **3.** La présente loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave, urgent et d'envergure nationale et, plus particulièrement:
>
> *a*) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant de façon indiscutable un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;
>
> *b*) de préserver notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une société libre et démocratique, des incitations à la consommation du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;
>
> *c*) de mieux sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux méfaits du tabac par la diffusion efficace de l'information utile aux consommateurs de celui-ci.

Il est tout à fait évident que les trois objets énumérés aux al. 3*a*) à *c*) ont en commun un souci pour la santé publique, et plus particulièrement, un souci de protéger les Canadiens contre les méfaits du tabac. C'est un souci valide. On a présenté en première instance une preuve abondante établissant de façon convaincante (ce qui n'a pas été contesté par les appelantes) que l'usage du tabac est répandu dans la société canadienne et qu'il présente de graves dangers pour la santé d'un grand nombre de Canadiens. En passant, je tiens à mentionner le principe bien établi selon lequel un tribunal a le droit, dans le cadre d'une analyse du caractère véritable, de se reporter à une preuve extrinsèque, comme les textes législatifs connexes, les débats parlementaires et la preuve du «mal» que le texte vise à corriger; voir *Morgentaler*, précité, aux pp. 483 et 484; *Renvoi relatif à la Loi anti-inflation*, [1976] 2 R.C.S. 373, à la p. 437;

S.C.R. 297, at pp. 317-19. An appropriate starting point in an examination of these extrinsic materials is the speech given by Jake Epp, the Minister of National Health and Welfare, on November 23, 1987 before second reading of Bill C-51, which was later given Royal Assent to the Act. He stated (*House of Commons Debates*, vol. IX, at p. 11042):

The federal Government has taken an active role in addressing the issue of cigarette smoking. It is important for people to understand why smoking, which was thought of as merely a personal habit, has become a legitimate public concern. There is overwhelming evidence that tobacco smoke is the largest preventable cause of illness, disability and premature death in Canada. Moreover, it has also become evident that Canadians who are consistently exposed to smoke in the environment may suffer from adverse health effects. Not surprisingly, the public is increasingly asking for an environment that protects non-smokers from tobacco smoke.

As Minister of National Health and Welfare, my primary concern is the health of Canadians. Therefore, I must do all that I can to protect their health by discouraging the advertising and promotion of tobacco, and by increasing public health knowledge of the health hazards of smoking.

This is not a moral crusade. It is not a case of some overzealous individuals attempting to force their lifestyle on others. It is responsible government action in reaction to overwhelming evidence that tobacco, despite its widespread use by a third of the adult population, is actually responsible for 100 deaths a day in Canada.

Apart from shedding light upon the government's intent in introducing this legislation, this speech also gives some indication of the nature and scope of the societal problem posed by tobacco consumption. Statistics show that approximately 6.7 million Canadians, or 28 percent of Canadians over the age of 15, consume tobacco products; see expert report prepared for Health and Welfare Canada by Dr. Roberta G. Ferrence, *Trends in Tobacco Consumption in Canada, 1900-1987* (1989). The harm tobacco consumption causes

Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297, aux pp. 317 à 319. Comme point de départ de l'examen de ces documents extrinsèques, il convient d'examiner le discours prononcé par Jake Epp, ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, le 23 novembre 1987, avant la deuxième lecture du projet de loi C-51, qui a plus tard reçu la sanction royale. Il affirme (*Débats de la Chambre des communes*, vol. IX, à la p. 11042):

Le gouvernement fédéral s'attaque activement à la question de l'usage du tabac. Il est important que les gens comprennent pourquoi cet usage que l'on considérait simplement comme une habitude personnelle est devenu avec raison un sujet d'inquiétude publique. En effet, des preuves irréfutables démontrent que la fumée du tabac est la plus importante cause évitable de maladies, d'incapacités et de décès prématurés au Canada. De plus, il est devenu évident que les Canadiens qui sont exposés régulièrement à un environnement enfumé peuvent souffrir de conséquences nuisibles à leur santé. Il n'est donc pas étonnant que le public exige de plus en plus un environnement où les non-fumeurs sont protégés de la fumée du tabac.

En tant que ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, je me préoccupe avant tout de la santé des Canadiens. Je dois donc faire tout ce que je peux pour protéger leur santé en décourageant la publicité en faveur du tabac et en informant davantage le public sur les dangers que l'usage du tabac fait courir à la santé.

Il ne s'agit pas d'une croisade morale. Il ne s'agit pas de quelques personnes zélées qui tentent d'imposer leur style de vie aux autres. Il s'agit d'une mesure responsable que le gouvernement prend en réponse à des preuves irréfutables qui démontrent que le tabac cause effectivement près de 100 décès par jour au Canada même si le tiers de la population adulte fume.

31 En plus de clarifier l'intention du gouvernement au moment du dépôt de ce projet de loi, ce discours donne également une indication de la nature et de l'étendue du problème social posé par l'usage du tabac. Les statistiques révèlent qu'approximativement 6,7 millions de Canadiens, ou 28 pour 100 de la population canadienne de plus de 15 ans, consomment des produits du tabac; voir le rapport d'expert de Roberta G. Ferrence, rédigé pour Santé et Bien-être social Canada, *Trends in Tobacco Consumption in Canada, 1900-1987* (1989). Le

each year to individual Canadians, and to the community as a whole, is tragic. Indeed, it has been estimated that smoking causes the premature death of over 30,000 Canadians annually; see Neil E. Collinshaw, Walter Tostowaryk, Donald T. Wigle, "Mortality Attributable to Tobacco Use in Canada" (1988), 79 *Can. J. Pub. Health* 166; expert report prepared for Health and Welfare Canada by Dr. Donald T. Wigle, *Illness and Death in Canada by Smoking: An Epidemiological Perspective* (1989). Overwhelming evidence was introduced at trial that tobacco use is a principal cause of deadly cancers, heart disease and lung disease. In our day and age this conclusion has become almost a truism. Nonetheless, it is instructive to review a small sampling of some of the vast body of medical evidence adduced at trial attesting to the devastating health consequences that arise from tobacco consumption. The expert report of Dr. Anthony B. Miller, for example, contains the following statement, at p. 24 ("Tobacco Use and Cancer" (1989)):

> The scientific evidence summarised in this statement shows that tobacco smoking causes lung, oral, larynx, esophagus, bladder, kidney and pancreas cancer, while oral use of tobacco causes oral cancer. Tobacco use causes 29% of the deaths that occur in Canada from cancer each year, i.e. an estimated excess of 15,300 deaths in 1989. Evidence is accumulating that passive smoking (exposure to environmental tobacco smoke) increases the risk of lung cancer in non-smokers.

Similarly, in the report of Dr. Donald T. Wigle, *supra*, one finds the following conclusion:

> Tobacco smoke contains over 4,000 known chemicals many of which are toxic. Over 50 chemicals present in tobacco smoke and tobacco smoke *per se*, are known to cause cancer in animals, humans or both.

. . .

> Smoking causes about 30% of all cancer deaths, 30% of all coronary heart disease deaths and about 85% of all chronic bronchitis/emphysema deaths in Canada and United States. In addition, smoking is a major cause of

mal que l'usage du tabac cause chaque année aux Canadiens, de façon individuelle ou globale, est tragique. En fait, on a estimé que la cigarette cause le décès prématuré de plus de 30 000 Canadiens chaque année; voir Neil E. Collinshaw, Walter Tostowaryk et Donald T. Wigle, «Mortality Attributable to Tobacco Use in Canada» (1988), 79 *Can. J. Pub. Health* 166; rapport d'expert de Donald T. Wigle, rédigé pour Santé et Bien-être social Canada, *Illness and Death in Canada by Smoking: An Epidemiological Perspective* (1989). On a déposé en première instance une preuve abondante établissant que l'usage du tabac est une cause principale de cancer, ainsi que de maladies cardiaques et pulmonaires causant la mort. De nos jours, cette conclusion est devenue presque un truisme. Néanmoins, il est instructif d'examiner quelques extraits de la vaste preuve médicale présentée en première instance relativement aux conséquences dévastatrices de l'usage du tabac sur la santé. Par exemple, le rapport d'expert d'Anthony B. Miller, renferme l'affirmation suivante, à la p. 24. («Tobacco Use and Cancer» (1989)):

> [TRADUCTION] La preuve scientifique résumée dans le présent énoncé révèle que l'habitude de fumer cause le cancer des poumons, de la bouche, du larynx, de l'œsophage, de la vessie, des reins et du pancréas, et que l'usage oral du tabac cause le cancer de la bouche. L'usage du tabac est la cause de 29 pour 100 des décès attribuables au cancer chaque année, soit environ plus de 15 300 décès en 1989. Il y a de plus en plus de données qui établissent que le tabagisme passif (inhalation involontaire de fumée de tabac) accroît le risque de cancer des poumons chez les non-fumeurs.

De même, dans le rapport de Donald T. Wigle, *op. cit.*, on trouve la conclusion suivante:

> [TRADUCTION] La fumée de tabac contient plus de 4 000 substances chimiques connues, dont beaucoup sont toxiques. Plus de 50 substances chimiques présentes dans la fumée de tabac, et la fumée de tabac elle-même, sont une cause connue du cancer chez les animaux et les humains.

. . .

> L'usage du tabac cause environ 30 pour 100 de tous les décès attribuables au cancer, 30 pour 100 de tous les décès attribuables à l'insuffisance coronarienne et environ 85 pour 100 de tous les décès attribuables à la

deaths due to aortic aneurysms, peripheral artery disease and fires. There is growing evidence that smoking is also an important cause of deaths due to stroke.

In terms of the scientific evidence available, the causal role of smoking in the major diseases described above is firmly established beyond all reasonable doubt. This conclusion is accepted by all leading health professional organizations and by many governments and international agencies including:

- Canadian Medical Association
- Canadian Public Health Association
- Health and Welfare Canada
- Canadian Cancer Society
- Canadian Lung Association
- Canadian Heart Foundation
- Canadian Council on Smoking and Health
- U.S. Surgeon General/U.S. Department of Health and Human Services
- World Health Organization
- International Agency for Research on Cancer.

It appears, then, that the detrimental health effects of tobacco consumption are both dramatic and substantial. Put bluntly, tobacco kills. Given this fact, can Parliament validly employ the criminal law to prohibit tobacco manufacturers from inducing Canadians to consume these products, and to increase public awareness concerning the hazards of their use? In my view, there is no question that it can. "Health", of course, is not an enumerated head under the *Constitution Act, 1867*. As Estey J. observed in *Schneider v. The Queen*, [1982] 2 S.C.R. 112, at p. 142:

> . . . "health" is not a matter which is subject to specific constitutional assignment but instead is an amorphous topic which can be addressed by valid federal or provincial legislation, depending in the circumstances of each case on the nature or scope of the health problem in question.

bronchite/emphysème chronique au Canada et aux États-Unis. De plus, l'habitude de fumer est une cause importante des décès attribuables aux anévrismes aortiques, aux maladies artérielles périphériques et aux incendies. Il existe de plus en plus de données que l'usage du tabac est également une importante cause des décès résultant d'accidents cérébrovasculaires.

La documentation scientifique établit bien hors de tout doute raisonnable le rôle de l'usage du tabac comme cause des principales maladies qui viennent d'être décrites. Cette conclusion est acceptée par toutes les grandes organisations professionnelles de la santé ainsi que par de nombreux gouvernements et organismes internationaux, dont:

- Association médicale canadienne
- Association canadienne de santé publique
- Santé et Bien-être social Canada
- Société canadienne du cancer
- Association pulmonaire du Canada
- Fondation canadienne des maladies du cœur
- Conseil canadien sur le tabagisme et la santé
- Surgeon General et Department of Health and Human Services des États-Unis
- Organisation mondiale de la santé
- Centre international de recherche sur le cancer.

Il appert donc que les effets nocifs de l'usage du tabac sur la santé sont à la fois saisissants et importants. En deux mots, le tabac tue. Compte tenu de ce fait, le Parlement peut-il validement se servir du droit criminel pour interdire aux fabricants des produits du tabac d'inciter la population canadienne à consommer ces produits et pour mieux la sensibiliser aux méfaits du tabac? À mon avis, il ne fait aucun doute qu'il peut le faire. De toute évidence, la «santé» n'est pas un chef de compétence énuméré dans la *Loi constitutionnelle de 1867*. Comme le fait observer le juge Estey dans l'arrêt *Schneider c. La Reine*, [1982] 2 R.C.S. 112, à la p. 142:

> . . . la «santé» n'est pas l'objet d'une attribution constitutionnelle spécifique, mais constitue plutôt un sujet indéterminé que les lois fédérales ou provinciales valides peuvent aborder selon la nature ou la portée du problème de santé en cause dans chaque cas.

32

Given the "amorphous" nature of health as a constitutional matter, and the resulting fact that Parliament and the provincial legislatures may both validly legislate in this area, it is important to emphasize once again the plenary nature of the criminal law power. In the *Margarine Reference*, *supra*, at pp. 49-50, Rand J. made it clear that the protection of "health" is one of the "ordinary ends" served by the criminal law, and that the criminal law power may validly be used to safeguard the public from any "injurious or undesirable effect". The scope of the federal power to create criminal legislation with respect to health matters is broad, and is circumscribed only by the requirements that the legislation must contain a prohibition accompanied by a penal sanction and must be directed at a legitimate public health evil. If a given piece of federal legislation contains these features, and if that legislation is not otherwise a "colourable" intrusion upon provincial jurisdiction, then it is valid as criminal law; see *Scowby*, *supra*, at pp. 237-38.

Vu que la santé comme matière constitutionnelle présente un caractère «informe» et qu'il s'ensuit que tant le Parlement que les législatures provinciales peuvent validement légiférer dans ce domaine, il importe de faire ressortir de nouveau la nature plénière de la compétence en matière de droit criminel. Dans le *Renvoi sur la margarine*, précité, aux pp. 49 et 50, le juge Rand établit clairement que la protection de la «santé» constitue un des «buts habituels» du droit criminel, et que la compétence en matière de droit criminel peut validement être exercée pour protéger le public contre un «effet nuisible ou indésirable». Le fédéral possède une vaste compétence pour ce qui est de l'adoption de lois en matière criminelle relativement à des questions de santé, et cette compétence n'est circonscrite que par les exigences voulant qu'elles comportent une interdiction accompagnée d'une sanction pénale, et qu'elles visent un mal légitime pour la santé publique. Si une loi fédérale donnée possède ces caractéristiques et ne constitue pas par ailleurs un empiétement «spécieux» sur la compétence provinciale, c'est alors une loi valide en matière criminelle; voir *Scowby*, précité, aux pp. 237 et 238.

33 As I have indicated, it is clear that this legislation is directed at a public health evil and that it contains prohibitions accompanied by penal sanctions. Is it colourable? In my view, it is not. Indeed, it is difficult to conceive what Parliament's purpose could have been in enacting this legislation apart from the reduction of tobacco consumption and the protection of public health. If Parliament's underlying purpose or intent had been to encroach specifically upon the provincial power to regulate advertising, it would surely have enacted legislation applying to advertising in more than one industry. Similarly, if Parliament's intent had been to regulate the tobacco industry as an industry, and not merely to combat the ancillary health effects resulting from tobacco consumption, then it would surely have enacted provisions that relate to such matters as product quality, pricing and labour relations. In this respect, the present cases must be distinguished from cases such as *Morgentaler*, *supra*, where there was evidence that Nova Scotia's major purpose in enacting the *Medical Ser-*

Comme je l'ai indiqué, il est clair que la loi est dirigée contre un mal touchant la santé publique et qu'elle renferme des interdictions assorties de sanctions pénales. Est-elle spécieuse? À mon avis, elle ne l'est pas. En fait, outre la diminution de l'usage du tabac et la protection de la santé publique, il est difficile de concevoir quel aurait pu être l'objectif du Parlement lorsqu'il a adopté cette loi. Si l'objet ou l'intention sous-jacents du Parlement avaient été d'empiéter spécifiquement sur la compétence provinciale en matière de réglementation de la publicité, il aurait certainement adopté une loi applicable à la publicité dans plus d'une industrie. De même, si l'intention du Parlement avait été de réglementer l'industrie du tabac en tant qu'industrie, et non simplement de lutter contre les effets indirects de l'usage du tabac sur la santé, il aurait sûrement adopté des dispositions se rapportant à des questions comme la qualité du produit, la fixation des prix et les relations du travail. À cet égard, les présents pourvois se distinguent notamment de l'arrêt *Morgentaler*, précité, dans lequel il

vices Act, R.S.N.S. 1989, c. 281, which purported to be for the control of private health care facilities, was in fact the elimination of free-standing abortion clinics, or *Switzman v. Elbling*, [1957] S.C.R. 285, where it was clear that Quebec's intention in enacting the *Act Respecting Communistic Propaganda*, R.S.Q. 1941, c. 52, was not to control the use of property but to suppress freedom of speech, a federal matter. In both these cases, it was clear that the provincial legislature was attempting to intrude indirectly upon federal powers when it could not do so directly; see also *Re Upper Churchill Water Rights Reversion Act*, *supra*. By contrast, there is no evidence in the present cases that Parliament had an ulterior motive in enacting this legislation, or that it was attempting to intrude unjustifiably upon provincial powers under ss. 92(13) and (16). They thus differ from the *Margarine Reference*, *supra*, where the prohibition was not really directed at curtailing a public evil, but was in reality, in pith and substance, aimed at regulating the dairy industry.

existait une preuve que la Nouvelle-Écosse visait avant tout l'élimination des cliniques d'avortement autonomes, lorsqu'elle a adopté la *Medical Services Act*, R.S.N.S. 1989, ch. 281, dont l'objet était supposément de contrôler les établissements de santé privés, et de l'arrêt *Switzman c. Elbling*, [1957] R.C.S. 285, dans lequel il était évident que le Québec, en adoptant la *Loi concernant la propagande communiste*, S.R.Q. 1941, ch. 52, ne visait pas à contrôler l'utilisation des biens mais plutôt à supprimer la liberté d'expression, matière de compétence fédérale. Dans ces deux affaires, il est clair que la législature provinciale tentait d'empiéter indirectement sur les compétences fédérales parce qu'elle ne pouvait le faire directement; voir aussi le *Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act*, précité. Par contre, il n'existe dans les présents pourvois aucune preuve que le Parlement avait une arrière-pensée lorsqu'il a adopté cette loi, ou encore qu'il tentait d'empiéter de façon injustifiable sur les compétences attribuées aux provinces en vertu des par. 92(13) et (16). Les présents pourvois diffèrent donc du *Renvoi sur la margarine*, précité, dans lequel l'interdiction ne visait pas vraiment à s'attaquer à un mal public, mais en fait, compte tenu du caractère véritable de la loi en cause, à réglementer l'industrie laitière.

Why, then, has Parliament chosen to prohibit tobacco advertising, and not tobacco consumption itself? In my view, there is a compelling explanation for this choice. It is not that Parliament was attempting to intrude colourably upon provincial jurisdiction but that a prohibition upon the sale or consumption of tobacco is not a practical policy option at this time. It must be kept in mind that the very nature of tobacco consumption makes government action problematic. Many scientists agree that the nicotine found in tobacco is a powerfully addictive drug. For example, the United States Surgeon General has concluded that "[c]igarettes and other forms of tobacco are addicting" and that "the processes that determine tobacco addiction are similar to those that determine addiction to other drugs, including illegal drugs"; see *The Health Consequences of Smoking — Nicotine Addiction — A report of the Surgeon General* (1988). Given the addictive nature of tobacco

Pourquoi, alors, le Parlement a-t-il choisi d'interdire la publicité en faveur des produits du tabac et non leur usage? À mon avis, ce choix repose sur une justification impérative. En fait, ce n'est pas que le Parlement tentait d'empiéter de façon déguisée sur une compétence provinciale, mais bien qu'une interdiction de vente ou d'usage du tabac ne constitue pas pour lui une option politique pratique pour le moment. Il faut se rappeler que la nature même de l'usage du tabac rend l'action gouvernementale problématique. De nombreux scientifiques conviennent que la nicotine que l'on trouve dans le tabac constitue une drogue qui crée une forte dépendance. Par exemple, le Surgeon General des États-Unis a conclu que [TRADUCTION] «[l]es cigarettes et les autres types de produits du tabac créent une dépendance» et que «les méthodes de détermination de la dépendance au tabac sont semblables à celles utilisées pour d'autres drogues, y compris les drogues illicites»; 34

products, and the fact that over one-third of Canadians smoke, it is clear that a legislative prohibition on the sale and use of tobacco products would be highly impractical. Indeed a prohibition on the manufacture and sale of tobacco products would likely lead many smokers to resort to alternative, and illegal, sources of supply. As legislators in this country discovered earlier in the century, the prohibition of a social drug such as tobacco or alcohol leads almost inevitably to an increase in smuggling and crime.

35 However, the mere fact that it is not practical or realistic to implement a prohibition on the use or manufacture of tobacco products does not mean that Parliament cannot, or should not, resort to other intermediate policy options. As Sheila Copps, then an opposition MP, commented during the debate concerning Bill C-51, *House of Commons Debates*, *supra*, at p. 11047:

> We realize that tobacco has been a part of our culture for many hundreds of years. We realize that the negative health effects of tobacco have become evident only in the last number of years. Yet frankly, from a strict political point of view, I do not think any political party would want to go into the next election trumpeting itself as the party which will introduce prohibition on tobacco. That is a fact.
>
> If we are stopping short of actually banning the sale of this hazardous product, what steps are we prepared to take to cut down on its use over the next number of years? Certainly, a ban on tobacco advertising is one strategy which is supportable in the move to cut down on the consumption of tobacco.

Jake Epp, the Minister of National Health and Welfare, made a similar observation during the debate, at p. 11045:

> Prohibiting the sale of a social drug like tobacco is not feasible, but prohibiting the advertising and promotion of this toxic substance is both feasible and desirable . . . .

voir *The Health Consequences of Smoking — Nicotine Addiction — A report of the Surgeon General* (1988). Vu que les produits du tabac créent une dépendance et que plus d'un tiers de la population canadienne fume, il est clair qu'une interdiction législative de vente et d'usage des produits du tabac est tout à fait inconcevable en pratique. En effet, interdire la fabrication et la vente des produits du tabac inciterait vraisemblablement de nombreux fumeurs à s'approvisionner autrement et illégalement. Comme les législateurs de notre pays l'ont découvert au début du siècle, l'interdiction d'une drogue sociale comme le tabac ou l'alcool mène presque inévitablement à un accroissement de la contrebande et du crime.

Cependant, le simple fait qu'il n'est ni pratique ni réaliste de mettre en œuvre une interdiction d'usage ou de fabrication des produits du tabac ne signifie pas que le Parlement ne peut ni ne devrait avoir recours à d'autres options intermédiaires. Comme l'a affirmé Mme Sheila Copps, alors députée de l'opposition, au cours du débat sur le projet de loi C-51, *Débats de la Chambre des communes*, *op. cit.*, à la p. 11047:

> Nous savons que le tabac fait partie de notre culture depuis des siècles, et que ses effets nocifs ne sont connus que depuis quelques années. Pourtant, il faut bien admettre qu'aucun parti politique, à mon avis, mènerait une campagne électorale tambour battant sur l'interdiction du tabac. Voilà la réalité.
>
> Or, si nous sommes encore bien loin d'interdire la vente de ce produit dangereux, jusqu'où accepterions-nous d'aller pour en réduire progressivement la consommation? Certes, interdire la publicité sur le tabac est une politique acceptable comme mesure progressive.

Jake Epp, ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, a fait une observation similaire au cours du débat, à la p. 11045:

> Il n'est pas possible d'interdire la vente d'une drogue aussi répandue dans notre société que le tabac peut l'être, mais il est à la fois possible et souhaitable d'en interdire la publicité et la promotion . . .

The advertising ban is but only a part, although a key part, of a long term comprehensive health oriented policy on tobacco and smoking. The long term objective is to bring about a significant decline in smoking and tobacco consumption. An essential tool for meeting this objective is the national program to reduce tobacco use, a joint effort of provincial, territorial, and the federal Governments plus major health organizations. In the short term, the Government's objectives are to strengthen the existing trend against the social acceptability of smoking and to enhance the credibility of the health message.

L'interdiction de la publicité n'est qu'un aspect, même s'il est important, d'une vaste politique à long terme, en matière de santé, concernant le tabac et son usage. L'objectif à long terme est d'abaisser notablement la consommation de tabac. L'outil essentiel pour y parvenir est le programme national de réduction de l'usage du tabac, effort conjoint des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral et des principales organisations du domaine de la santé. À court terme, les objectifs du gouvernement sont de renforcer la tendance actuelle contre l'acceptabilité sociale de l'usage du tabac et d'améliorer la crédibilité du message dénonçant le coût pour la santé.

It is apparent from these comments that the social problems created by tobacco consumption are complex and that innovative legislative solutions are required to address them effectively. Faced with the insurmountable difficulties a complete prohibition upon tobacco consumption would create, the federal Parliament has undertaken the task of devising such solutions. Indeed, the Act forms only one part of a comprehensive and multifaceted federal and provincial program to control and reduce the consumption of tobacco. This program has been in development for over 25 years. As early as 1969, the Standing Committee on Health, Welfare and Social Affairs produced a report entitled *Report of the Standing Committee on Health, Welfare and Social Affairs on Tobacco and Cigarette Smoking* (1969). In that report, the Committee advocated the progressive elimination of tobacco consumption through the introduction of intermediate measures. The Committee stated, at p. 30:

Ces commentaires indiquent clairement que les problèmes sociaux créés par l'usage du tabac sont complexes et qu'il faut de nouvelles solutions législatives pour les résoudre efficacement. Aux prises avec les difficultés insurmontables que créerait l'interdiction complète de l'usage du tabac, le Parlement a entrepris de concevoir ces solutions. En fait, la Loi ne constitue qu'une facette d'un programme fédéral et provincial exhaustif destiné à contrôler et à réduire l'usage du tabac. Ce programme évolue depuis plus de 25 ans. En effet, dès 1969, le Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales a produit un rapport intitulé: *Rapport du Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales sur l'usage du tabac et de la cigarette* (1969). Dans ce rapport, le Comité préconise l'élimination progressive de l'usage du tabac par l'établissement de mesures intermédiaires. Il affirme à la p. 30: 36

While it is clear that cigarette sales cannot be banned at this time, it is equally clear that the production, distribution and sale of cigarettes should no longer be considered in the same light as the production, distribution and sale of other products. It seems reasonable to introduce whatever steps are feasible to progressively eliminate the promotion of cigarette sales and preparations should be made to assist growers and others affected by reductions in cigarette sales. It is also desirable to increase educational efforts to discourage cigarette smoking and to expand activities to make cigarette smoking less hazardous for those who continue to smoke.

Bien qu'il soit évident que la vente des cigarettes ne peut pas être interdite en ce moment, il est également manifeste que la production, la distribution et la vente de ces produits ne peuvent plus être envisagées dans la même perspective que la production, la distribution et la vente d'autres produits. Il semble raisonnable, au présent stade, de recourir à toute mesure pratique en vue d'éliminer progressivement la promotion des ventes de cigarettes et il faut en même temps établir des projets destinés à aider les producteurs et les autres personnes qui seront lésées par la mévente des cigarettes. Il serait en outre souhaitable d'intensifier les mesures d'éducation populaire en vue de décourager les fumeurs et de déployer des efforts en vue de rendre la cigarette moins dangereuse pour les fumeurs invétérés.

In this regard, the Committee recommended, at p. 32, that "cigarette advertising and all other promotion of cigarette sales be progressively eliminated" and suggested, at pp. 52-53, a complete elimination of all cigarette promotional activities within four years from enactment of any legislation. Since 1969, the Department of National Health and Welfare has introduced a variety of educational programmes and has supported research and health promotion organizations in the battle against tobacco consumption. In 1983, for example, Health and Welfare Canada published *Canadian Initiatives in Smoking and Health* in which it stated, at pp. 79 and 81:

A major initiative toward concerted action with the ten provinces and the two territories began in 1980, when smoking and health was identified as a high priority area for joint action. In November 1980, a federal-provincial working group was established.

When this task force reported back a year later, both federal and provincial governments were involved in a variety of smoking prevention, cessation, and research projects. The scale of these activities had grown apace and presented many opportunities for mutual assistance and cooperation.

For its part, the federal government was engaged in support, research, and program development and implementation in several critical areas.

. . .

The Health Promotion Directorate, responsible for the overall smoking and health program, was engaged in research and data base development projects; a major national prevention project, "Toward a Generation of Non-Smoking Canadians"; a cessation project with community pharmacists; and a mass media, community-linked cessation campaign, "Time to Quit", aimed at the general public.

À cet égard, le Comité a recommandé à la p. 32 que «la publicité sur la cigarette et toute autre forme de promotion des ventes de cigarettes soient progressivement éliminées», et il a proposé aux pp. 52 et 53 une élimination complète de toute publicité sur la cigarette dans les quatre années suivant l'adoption d'une loi. Depuis 1969, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social a présenté toute une gamme de programmes éducatifs et a appuyé les organismes de recherche et de promotion de la santé dans la lutte contre l'usage du tabac. Par exemple, en 1983, Santé et Bien-être social Canada a publié un document intitulé *Initiatives canadiennes en matière de santé et de lutte contre l'usage du tabac* dans lequel il affirme aux pp. 80 et 82:

Une initiative d'envergure visant à favoriser la prise de mesures concertée par les provinces et les deux territoires du Canada débuta en 1980, lorsque la santé et la lutte contre le tabagisme furent définis comme étant des secteurs prioritaires à l'égard desquels il convenait de prendre des mesures conjointes. En novembre 1980, un groupe de travail fédéral-provincial fut créé.

Lorsque ce groupe de travail présenta son rapport un an plus tard, les autorités tant fédérales que provinciales étaient engagées dans toute une gamme de projets axés sur la prévention du tabagisme, sur la cessation et sur la recherche. L'envergure de ces activités avait connu une expansion rapide et offrait de nombreuses possibilités d'aide et de collaboration.

Pour sa part, le gouvernement fédéral s'occupait de financement, de recherche ainsi que d'élaboration et de mise sur pied de programmes dans plusieurs secteurs critiques.

. . .

La Direction de la promotion de la santé, chargée de l'administration de l'ensemble du Programme canadien sur le tabac et la santé, exécutait les projets de recherche et de création de banques de données, un projet national d'envergure en matière de prévention, «Vers une génération de non-fumeurs», un projet de lutte contre le tabagisme conjointement avec les pharmaciens communautaires, ainsi qu'une campagne de lutte contre le tabagisme administrée dans les collectivités et diffusée dans les médias à l'intention du grand public qui s'intitulait «Moi aussi, j'écrase».

In 1985, "federal, provincial and territorial ministers of health agreed to work jointly with non-governmental organizations in the development and implementation of a National Program to Reduce Tobacco Use" ("Break free — For a new generation of non-smokers"); see Health and Welfare Canada, *National Program to Reduce Tobacco Use: Orientation Manuals & Historical Perspective* (1987). In June 1987, Health and Welfare Canada released a "Directional paper of the national program to reduce tobacco use in Canada", where, at p. 4, seven "strategic directions" were recommended to "achieve a non-smoking program that will assist in producing a generation of non-smokers by the year 2000":

1. Legislation
2. Access to Information
3. Availability of Services/Programs
4. Message Promotion
5. Support for Citizen Action
6. Intersectoral Policy Coordination
7. Research/Knowledge Development

Among the legislative measures recommended in that Paper were the identification of tobacco products as hazardous products and the "prohibition of direct or indirect advertising, promotion and sponsorship of tobacco products or requirement of large health warnings to make promotion less attractive" (p. 20). In 1988, the legislative committee responsible for studying Bill C-51, which was subsequently adopted by Parliament as the Act, held hearings and heard from 104 organizations representing a variety of interests, including medicine, transport, advertising, smokers' rights, non-smokers' rights, and tobacco production.

Subsequent to the passage of the Act, Parliament has also introduced an array of legislative measures as part of its larger initiative to curb tobacco consumption. These include a law prohibiting the sale of tobacco to minors (*Tobacco Sales to Young Persons Act*, S.C. 1993, c. 5.), a law eliminating

En 1985, [TRADUCTION] «les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la santé ont accepté de travailler conjointement avec les organismes non gouvernementaux à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme national de lutte contre le tabagisme» («Pour une nouvelle génération de non-fumeurs»); voir Santé et Bien-être social Canada, *National Program to Reduce Tobacco Use: Orientation Manuals & Historical Perspective* (1987). En juin 1987, Santé et Bien-être social Canada a publié un «Document d'orientation du programme national de lutte contre le tabagisme au Canada», dans lequel, à la p. 4, on recommandait sept «orientations stratégiques» pour «favoriser le non-usage du tabac en vue de créer une génération de non-fumeurs d'ici l'an 2000»: 37

1. Législation
2. Accès à l'information
3. Accessibilité des services et des programmes
4. Diffusion de messages anti-tabac
5. Appui des initiatives communautaires
6. Coordination intersectorielle
7. Expansion des connaissances et des recherches

Parmi les mesures législatives recommandées dans ce document, on note entre autres qu'il faut indiquer que les produits du tabac sont des substances toxiques et qu'il faut «interdire la publicité, la promotion et le parrainage directs ou indirects des produits du tabac; rendre la promotion de ces produits moins attrayante ou exiger que l'emballage de tous les produits du tabac porte des mises en garde bien en évidence» (p. 20). En 1988, le comité législatif responsable de l'étude du projet de loi C-51, qui est par la suite devenu la Loi, a tenu des auditions au cours desquelles il a obtenu le point de vue de 104 organisations représentatives de tout un éventail d'intérêts: médecine, transports, publicité, groupes de fumeurs, groupes de non-fumeurs et producteurs de tabac.

À la suite de l'adoption de la Loi, le Parlement a aussi déposé toute une gamme de mesures législatives dans le cadre de son vaste programme de lutte contre l'usage du tabac. Mentionnons notamment une loi interdisant la vente de produits du tabac à des mineurs (*Loi sur la vente du tabac aux* 38

smoking in federal government work environments (*Non-smokers' Health Act*, S.C. 1988, c. 21), and the prohibition of the sale of cigarettes in the small package formats often purchased by children (so-called "kiddie packs" of less than 20 cigarettes); see *An Act to amend the Excise Act, the Customs Act and the Tobacco Sales to Young Persons Act*, S.C. 1994, c. 37. Parliament has also sought to reduce smoking through major tax increases in 1985, 1989 and 1991, although taxes were partially rolled back in 1994 due to a large contraband problem. Also relevant is that nine provinces have introduced legislation respecting the sale of tobacco to young persons and smoking in public places (*Tobacco Control Act, 1994*, S.O. 1994, c. 10; *Tobacco Control Act*, S.N. 1993, c. T-4.1; *Tobacco Access Act*, S.N.S. 1993, c. 14; *Tobacco Sales Act*, S.N.B. 1993, c. T-6.1; *Tobacco Sales to Minors Act*, S.P.E.I. 1991, c. 44; *The Minors Tobacco Act*, R.S.S. 1965, c. 381; *An Act to Protect the Health of Non-smokers*, S.M. 1990, c. S125; *Tobacco Product Act*, R.S.B.C. 1979, c. 403, as amended, S.B.C. 1992, c. 81; *An Act Respecting the Protection of Non-smokers in Certain Public Places*, R.S.Q., c. P-38.01).

39 Quite clearly, then, Parliament has been innovative in seeking to find alternatives to a prohibition on the sale or use of tobacco. In light of the practical difficulties entailed in prohibiting the sale or consumption of tobacco, and the resulting need for innovative legislative solutions, Parliament's decision to criminalize tobacco advertisement and promotion is, in my view, a valid exercise of the criminal law power. This Court has long recognized that Parliament may validly employ the criminal law power to prohibit or control the manufacture, sale and distribution of products that present a danger to public health, and that Parliament may also validly impose labelling and packaging requirements on dangerous products with a view to protecting public health. This was recognized as early as the *Margarine Reference*, *supra*. There, it is true, this Court decided that s. 5(*a*) of the *Dairy Industry Act*, R.S.C. 1927, c. 45, which prohibited

jeunes, L.C. 1993, ch. 5), une loi éliminant l'usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux (*Loi sur la santé des non-fumeurs*, L.C. 1988, ch. 21) et une loi interdisant la vente de cigarettes dans des petits paquets souvent achetés par des enfants (contenant moins de 20 cigarettes); voir la *Loi modifiant la Loi sur l'accise, la Loi sur les douanes et la Loi sur la vente du tabac aux jeunes*, L.C. 1994, ch. 37. Le Parlement a également cherché à réduire l'usage du tabac par d'importantes majorations de taxes en 1985, 1989 et 1991; cependant, ces taxes ont été partiellement éliminées en 1994 à cause d'un grave problème de contrebande. Il est également pertinent de mentionner que neuf provinces ont adopté des lois relatives à la vente de tabac aux jeunes et à l'usage du tabac dans les endroits publics (*Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac*, L.O. 1994, ch. 10; *Tobacco Control Act*, S.N. 1993, ch. T-4.1; *Tobacco Access Act*, S.N.S. 1993, ch. 14; *Loi sur les ventes de tabac*, L.N.-B. 1993, ch. T-6.1; *Tobacco Sales to Minors Act*, S.P.E.I. 1991, ch. 44; *The Minors Tobacco Act*, R.S.S. 1965, ch. 381; *Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs*, L.M. 1990, ch. S125; *Tobacco Product Act*, R.S.B.C. 1979, ch. 403, modifiée, S.B.C. 1992, ch. 81; *Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics*, L.R.Q., ch. P-38.01).

Il est très clair que le Parlement a été innovateur en cherchant à trouver des solutions de rechange à une interdiction de vente ou d'usage du tabac. Compte tenu des difficultés pratiques liées à une telle interdiction et de la nécessité qui s'ensuit de trouver des solutions législatives innovatrices, la décision du Parlement de rendre criminelles la publicité et la promotion du tabac constitue, à mon avis, un exercice valide de sa compétence en matière de droit criminel. Notre Cour a depuis longtemps reconnu que le Parlement peut validement utiliser cette compétence pour interdire ou contrôler la fabrication, la vente et la distribution de produits qui présentent un danger pour la santé publique, et qu'il peut aussi validement imposer des exigences en matière d'étiquetage et d'emballage de produits dangereux dans le but de protéger la santé publique. Cela a été reconnu dès le *Renvoi sur la margarine*, précité. Certes, dans ce renvoi,

the importation of margarine into Canada, was *ultra vires* the federal Parliament, but this decision was based on the holding that margarine was not a threat to the health of Canadians and, accordingly, that s. 5(*a*) was an invalid intrusion upon the provincial power to regulate local trade. However, in so deciding, the Court also made clear that the federal Parliament could validly legislate under the criminal law power with respect to health and product safety. In his concurring reasons, *supra*, at pp. 82-83, Locke J. stated:

> It cannot, in my opinion, be successfully contended that if the real purpose of the prohibition of the importation, manufacture or sale of these products was the protection of the general health of the public the Dominion might not properly legislate.

Later, in *R. v. Wetmore*, [1983] 2 S.C.R. 284, this Court addressed the question whether ss. 8 and 9 of the *Food and Drugs Act*, R.S.C. 1970, c. F-27, which prohibited the sale of drugs prepared under unsanitary conditions and false or misleading advertisement of drugs, were a valid exercise of the federal criminal law power. Those provisions read as follows:

> **8.** No person shall sell any drug that
>
> (*a*) was manufactured, prepared, preserved, packed or stored under unsanitary conditions; . . .
>
> **9.** (1) No person shall label, package, treat, process, sell or advertise any drug in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character, value, quantity, composition, merit or safety.

In upholding the constitutionality of these provisions under s. 91(27), Laskin C.J., writing for the majority, stated, at pp. 288-89:

> An examination of the various provisions of the *Food and Drugs Act* shows that it goes beyond mere prohibi-

notre Cour a décidé que l'al. 5*a*) de la *Loi de l'industrie laitière*, S.R.C. 1927, ch. 45, qui interdisait l'importation de margarine au Canada, était *ultra vires* du Parlement; cependant, en prenant cette décision, notre Cour est partie de la prémisse que la margarine ne constituait pas un danger pour la santé des Canadiens et elle a en conséquence statué que l'al. 5*a*) constituait un empiétement non valide sur la compétence provinciale de réglementer le commerce local. Toutefois, dans sa décision, notre Cour a clairement établi que le Parlement pouvait validement légiférer en vertu de sa compétence en matière de droit criminel relativement à la santé et à la sécurité des produits. Dans des motifs concordants, aux pp. 82 et 83, le juge Locke affirme:

> [TRADUCTION] À mon avis, on ne peut avoir gain de cause en soutenant que le Dominion ne peut légiférer si l'objet réel de l'interdiction d'importation, de fabrication ou de vente de ces produits est la protection de la santé du public.

Plus tard, dans l'arrêt *R. c. Wetmore*, [1983] 2 R.C.S. 284, notre Cour a examiné la question de savoir si les art. 8 et 9 de la *Loi des aliments et drogues*, S.R.C. 1970, ch. F-27, qui interdisaient la vente de drogues préparées dans des conditions non hygiéniques et l'annonce de manière fausse et trompeuse de drogues, constituaient un exercice valide de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Voici le libellé des dispositions en question:

> **8.** Nul ne doit vendre quelque drogue
>
> *a*) qui a été fabriquée, préparée, conservée, empaquetée ou emmagasinée dans des conditions non hygiéniques; . . .
>
> **9.** (1) Nul ne doit étiqueter, empaqueter, traiter, préparer, vendre ou annoncer quelque drogue de manière fausse, trompeuse ou mensongère, ou qui peut créer une fausse impression quant à la nature, valeur, quantité, composition, ou quant aux avantages ou à la sûreté de la drogue.

Lorsqu'il a confirmé la constitutionnalité de ces dispositions en vertu du par. 91(27), le juge en chef Laskin, s'exprimant au nom de la majorité, affirme aux pp. 288 et 289:

> Il ressort d'un examen des différentes dispositions de la *Loi des aliments et drogues* que cette loi va au delà de

tion to bring it solely within s. 91(27) but that it also involves a prescription of standards, including labelling and packaging as well as control of manufacture. The ramifications of the legislation, encompassing food, drugs, cosmetics and devices and the emphasis on marketing standards seem to me to subjoin a trade and commerce aspect beyond mere criminal law alone. There appear to be three categories of provisions in the *Food and Drugs Act*. Those that are in s. 8 are aimed at protecting the physical health and safety of the public. Those that are in s. 9 are aimed at marketing and those dealing with controlled drugs in Part III of the Act are aimed at protecting the moral health of the public. One may properly characterize the first and third categories as falling under the criminal law power but the second category certainly invites the application of the trade and commerce power.

However, it is unnecessary to pursue this issue and it has been well understood over many years that protection of food and other products against adulteration and to enforce standards of purity are properly assigned to the criminal law. [Emphasis added.]

It is clear from Laskin C.J.'s analysis that legislation with respect to food and drugs that is aimed at protecting the "physical health and safety of the public" is a valid exercise of the federal criminal law power. This was also the view of the British Columbia Court of Appeal in *Standard Sausage Co. v. Lee*, [1933] 4 D.L.R. 501, supplemented by addendum at [1934] 1 D.L.R. 706, affirmed in *Wetmore*, *supra*, at pp. 292-93, where it upheld the constitutionality under the criminal law power of a prohibition against the adulteration of foods under ss. 3, 4 and 23 of the *Food and Drugs Act*, R.S.C. 1927, c. 76. In reaching this decision, Macdonald J.A. stated, at pp. 506-7:

. . . if the Federal Parliament, to protect the public health against actual or threatened danger, places restrictions on, and limits the number of preservatives that may be used, it may do so under s. 91 (27) of the B.N.A. Act. This is not in essence an interference with property and civil rights. That may follow as an incident but the real purpose (not colourable and not merely to aid what in

la simple prohibition et qu'elle fixe des normes notamment en ce qui concerne l'étiquetage, l'empaquetage et la fabrication, de sorte qu'elle ne relève pas exclusivement du par. 91(27). Les ramifications de la Loi, qui porte sur les aliments, les drogues, les cosmétiques et les instruments, et l'accent qu'elle met sur les normes de commercialisation me semblent lui prêter un aspect commercial qui transcende le simple droit criminel. La *Loi des aliments et drogues* semble comprendre trois catégories de dispositions. Celles de l'art. 8 visent à protéger la santé et la sécurité physiques du public. Les dispositions de l'art. 9 portent sur la commercialisation et celles relatives aux drogues contrôlées, qui figurent dans la partie III de la Loi, ont pour objet la protection de la santé morale du public. Les première et troisième catégories peuvent à juste titre être considérées comme relevant de la compétence en matière de droit criminel, mais la seconde emporte certainement l'application de la compétence en matière d'échanges et de commerce.

Toutefois, il n'est pas nécessaire d'examiner davantage cette question, car il est bien établi depuis fort longtemps que la protection des aliments et d'autres produits contre la falsification et l'application des normes de pureté ressortissent légitimement au droit criminel. [Je souligne.]

L'analyse du juge en chef Laskin indique clairement qu'une loi portant sur les aliments et les drogues qui vise à protéger «la santé et la sécurité physiques du public» constitue un exercice valide de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Tel était également le point de vue de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt *Standard Sausage Co. c. Lee*, [1933] 4 D.L.R. 501, complété par des motifs additionnels publiés à [1934] 1 D.L.R. 706, confirmé dans *Wetmore*, précité, aux pp. 292 et 293, et dans lequel on a déclaré constitutionnelle, comme relevant du droit criminel, une interdiction de falsification d'aliments prévue aux art. 3, 4 et 23 de la *Loi des aliments et drogues*, S.R.C. 1927, ch. 76. Lorsqu'il a rendu cette décision, le juge Macdonald a affirmé aux pp. 506 et 507:

[TRADUCTION] . . . si le Parlement fédéral, pour protéger la santé publique contre un danger réel ou appréhendé, apporte des restrictions aux agents de conservation qui peuvent être utilisés et en limite le nombre, il peut le faire en vertu du par. 91(27) de l'A.A.N.B. Ce n'est pas par essence une intrusion dans la propriété et les droits civils. Cela peut en découler accessoirement mais le vrai

substance is an encroachment) is to prevent actual, or threatened injury or the likelihood of injury of the most serious kind to all inhabitants of the Dominion.

. . .

The primary object of this legislation is the public safety — protecting it from threatened injury. If that is its main purpose — and not a mere pretence for the invasion of civil rights — it is none the less valid . . . .

Moreover, in my view, the necessary implication of the reasoning in *Wetmore* and the *Margarine Reference* is that the federal criminal law power to legislate with respect to dangerous goods also encompasses the power to legislate with respect to health warnings on dangerous goods. Since health warnings serve to alert Canadians to the potentially harmful consequences of the use of dangerous products, the power to prohibit sales without these warnings is simply a logical extension of the federal power to protect public health by prohibiting the sale of the products themselves. As noted by Lamer C.J. in *R. v. Swain*, [1991] 1 S.C.R. 933, at p. 999, "it has long been recognized that there also exists a preventative branch of the criminal law power". This is also the implication of this Court's decision in *Labatt Breweries of Canada Ltd. v. Attorney General of Canada*, [1980] 1 S.C.R. 914, where Estey J., although finding a detailed regulatory scheme with respect to production and content standards for malt liquor under the *Food and Drugs Act*, R.S.C. 1970, c. F-27, to be *ultra vires* Parliament, observed, at pp. 933-34:

That there is an area of legitimate regulations in respect of trade practices contrary to the interest of the community such as misleading, false or deceptive advertising and misbranding, is not under debate.

In this respect, it is significant that Parliament has already enacted numerous prohibitions against

but (qui n'est pas déguisé, ni seulement un appui à ce qui est en substance un empiétement) est de prévenir un dommage réel ou appréhendé ou la probabilité d'un dommage de la plus grande gravité pour tous les habitants du Dominion.

. . .

L'objet premier de cette loi est la sécurité du public, en protégeant celui-ci contre un dommage appréhendé. Si c'est là son but principal — et non un simple prétexte pour s'ingérer dans le domaine des droits civils — sa validité n'est pas amoindrie . . .

41 En outre, à mon avis, il découle nécessairement du raisonnement dans l'arrêt *Wetmore* et dans le *Renvoi sur la margarine* que, dans le domaine du droit criminel, la compétence fédérale de légiférer relativement aux produits dangereux englobe également celle de légiférer quant aux mises en garde à apposer sur les produits dangereux. Puisque ces mises en garde servent à sensibiliser les Canadiens aux conséquences potentiellement nocives de l'utilisation de produits dangereux, le pouvoir d'interdire la vente de produits sur lesquels n'a pas été apposée cette mise en garde ne constitue qu'une extension logique de la compétence fédérale de protéger la santé publique par l'interdiction même de la vente de ces produits. Comme l'a fait remarquer le juge en chef Lamer dans l'arrêt *R. c. Swain*, [1991] 1 R.C.S. 933, à la p. 999, «[i]l est [. . .] reconnu depuis longtemps que le pouvoir en matière de droit criminel comporte aussi un aspect préventif». C'est également ce que sous-entend l'arrêt de notre Cour *Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada*, [1980] 1 R.C.S. 914, dans lequel le juge Estey, après avoir conclu qu'un règlement détaillé concernant les normes de production et de contenu d'une liqueur de malt pris en vertu de la *Loi des aliments et drogues*, S.R.C. 1970, ch. F-27, était *ultra vires* du Parlement, a cependant fait remarquer aux pp. 933 et 934:

L'existence d'un secteur de réglementation légitime des pratiques commerciales contraires aux intérêts de la collectivité, tels que l'annonce et l'étiquetage trompeurs, faux ou mensongers, n'est pas en cause.

42 À cet égard, il importe de signaler que le Parlement a déjà adopté de nombreuses interdictions de

the manufacture, sale, advertisement and use of a great variety of products that Parliament deems, from time to time, to be dangerous or harmful. For example, the *Hazardous Products Act*, R.S.C., 1985, c. H-3, amended R.S.C., 1985, c. 24 (3rd. Supp.), s. 1, which has been found to be a valid exercise of the criminal law power by the Manitoba Court of Appeal in *R. v. Cosman's Furniture (1972) Ltd.* (1976), 32 C.C.C. (2d) 345, contains the following provisions:

2. In this Act,

"advertise", in relation to a prohibited product or restricted product, includes any representation by any means whatever for the purpose of promoting directly or indirectly the sale or other disposition of the product;

. . .

"controlled product" means any product, material or substance specified by the regulations made pursuant to paragraph 15(1)(*a*) to be included in any of the classes listed in Schedule II;

"hazardous product" means any prohibited product, restricted product or controlled product;

. . .

"prohibited product" means any product, material or substance included in Part I of Schedule I;

"restricted product" means any product, material or substance included in Part II of Schedule I;

. . .

4. (1) No person shall advertise, sell or import a prohibited product.

(2) No person shall advertise, sell or import a restricted product except as authorized by the regulations made under section 5.

5. The Governor in Council may make regulations

(*a*) authorizing the advertising, sale or importation of any restricted product and prescribing the circumstances and conditions under which and the persons by whom the restricted product may be advertised, sold or imported;

. . .

fabrication, de vente, de publicité et d'utilisation d'un grand nombre de produits qu'il considère à l'occasion comme dangereux ou nocifs. Par exemple, la *Loi sur les produits dangereux*, L.R.C. (1985), ch. H-3, modifiée, L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1, que la Cour d'appel du Manitoba a jugé un exercice valide de la compétence en matière de droit criminel, dans l'arrêt *R. c. Cosman's Furniture (1972) Ltd.* (1976), 32 C.C.C. (2d) 345, renferme les dispositions suivantes:

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

. . .

«produit contrôlé» Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d'application de l'alinéa 15(1)*a*) dans une des catégories inscrites à l'annexe II.

«produit dangereux» Produit interdit, limité ou contrôlé.

«produit interdit» Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l'annexe I.

«produit limité» Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l'annexe I.

«publicité» S'entend notamment de la présentation, par tout moyen d'un produit interdit ou d'un produit limité en vue d'en promouvoir directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente.

. . .

4. (1) La vente, l'importation et la publicité des produits interdits sont interdites.

(2) Sauf autorisation contraire des règlements d'application de l'article 5, la vente, l'importation et la publicité des produits limités sont interdites.

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) autoriser la vente, l'importation ou la publicité de tout produit limité et prévoir les cas et conditions dans lesquels l'autorisation peut être donnée et à qui elle peut l'être;

. . .

15. (1) Subject to section 19, the Governor in Council may make regulations

. . .

(*d*) prescribing the form and manner in which information shall be disclosed on a label and the manner in which a label shall be applied to a controlled product or container in which a controlled product is packaged;

(*e*) prescribing hazard symbols and the manner in which hazard symbols shall be displayed on a controlled product or container in which a controlled product is packaged;

From the foregoing, it is clear that Parliament could, if it chose, validly prohibit the manufacture and sale of tobacco products under the criminal law power on the ground that these products constitute a danger to public health. Such a prohibition would be directly analogous to the prohibitions on dangerous drugs and unsanitary foods or poisons mentioned earlier, which quite clearly fall within the federal criminal law power. In my view, once it is accepted that Parliament may validly legislate under the criminal law power with respect to the manufacture and sale of tobacco products, it logically follows that Parliament may also validly legislate under that power to prohibit the advertisement of tobacco products and sales of products without health warnings. In either case, Parliament is legislating to effect the same underlying criminal public purpose: protecting Canadians from harmful and dangerous products.

Seen in this light, the only true distinction that can be drawn between the measures adopted under the Act and an outright prohibition on the sale or consumption of tobacco is with respect to the form employed by Parliament to combat the "evil" of tobacco consumption. However, such a distinction, unaccompanied by any evidence of colourability, is not constitutionally significant. Once it is conceded, as I believe it must be, that tobacco consumption has detrimental health effects and that Parliament's intent in enacting this legislation was

15. (1) Sous réserve de l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement:

. . .

d) fixer les modalités de la divulgation de renseignements sur une étiquette et de l'apposition de celle-ci sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;

e) fixer les signaux de danger et les modalités de leur affichage sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;

Il découle clairement de ce qui précède que le Parlement pourrait, s'il le désire, interdire validement la fabrication et la vente des produits du tabac en vertu de sa compétence en matière de droit criminel pour le motif que ces produits constituent un danger pour la santé publique. Une telle interdiction serait tout à fait analogue aux interdictions relatives aux drogues dangereuses et produits préparés dans des conditions non hygiéniques ou aux poisons, dont j'ai déjà parlé, lesquelles relèvent manifestement de la compétence fédérale en matière de droit criminel. À mon avis, lorsque l'on accepte que, en vertu de sa compétence en matière de droit criminel, le Parlement peut validement légiférer relativement à la fabrication et à la vente des produits du tabac, il s'ensuit logiquement qu'il peut aussi validement légiférer en vertu de cette compétence pour interdire la publicité des produits du tabac et la vente des produits ne comportant pas de mise en garde. Dans les deux cas, le Parlement se trouve à légiférer pour le même objectif public du droit criminel: protéger la population canadienne contre les produits nocifs et dangereux. 43

Vu sous cet angle, la seule véritable distinction susceptible d'être établie entre les mesures adoptées en vertu de la Loi et une interdiction absolue de vente ou d'usage des produits du tabac a trait au moyen employé par le Parlement pour lutter contre le «mal» que présente l'usage du tabac. Cependant, si elle n'est pas accompagnée d'une preuve de son caractère déguisé, une telle distinction n'est pas importante du point de vue constitutionnel. Lorsqu'il est admis, comme cela doit l'être à mon avis, que l'usage du tabac a des effets nocifs sur la santé 44

to combat these effects, then the wisdom of Parliament's choice of method cannot be determinative with respect to Parliament's power to legislate. The goal in a pith and substance analysis is to determine Parliament's underlying purpose in enacting a particular piece of legislation; it is not to determine whether Parliament has chosen that purpose wisely or whether Parliament would have achieved that purpose more effectively by legislating in other ways; see *R. v. Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 S.C.R. 295, at p. 358 (*per* Wilson J.) and *Morgentaler*, *supra*, at p. 487:

> Only when the effects of the legislation so directly impinge on some other subject matter as to reflect some alternative or ulterior purpose do the effects themselves take on analytic significance.

There is no evidence that the practical effect of the Act, or the lack thereof, reflects any "alternative or ulterior purpose".

et que, lors de l'adoption de la loi en question, le Parlement souhaitait lutter contre ces effets, alors la sagesse de la méthode qu'il a choisie ne peut être déterminante relativement à sa compétence de légiférer. L'analyse du caractère véritable d'une loi a pour but de déterminer l'objet sous-jacent que visait le Parlement au moment de l'adoption de cette loi; il ne s'agit pas de déterminer s'il a choisi cet objet judicieusement ou s'il l'aurait atteint plus efficacement en légiférant autrement; voir *R. c. Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 358 (le juge Wilson), et *Morgentaler*, précité, à la p. 487:

> Ce n'est que lorsqu'une loi a des effets qui empiètent si directement sur un autre domaine qu'elle doit avoir un objet dissimulé que lesdits effets prennent eux-mêmes de l'importance aux fins de l'analyse . . .

Il n'existe aucune preuve que l'effet pratique de la Loi, ou l'absence d'effet, est l'indice d'un quelconque «objet dissimulé».

The Appellants' Principal Arguments

45 The foregoing considerations, it seems to me, are sufficient to establish that the pith and substance of the Act is criminal law for the purpose of protecting public health and that Parliament accordingly has the legislative authority under s. 91(27) of the *Constitution Act, 1867* to enact this legislation. However, I think it right to address directly the three principal arguments raised by the appellants in support of their submission that the Act is not valid as criminal law: first, that the conduct prohibited by the Act does not have an "affinity with a traditional criminal law concern"; second, that Parliament cannot criminalize an activity ancillary to an "evil" if it does not criminalize the "evil" itself; and, third, that the Act is more properly characterized as regulatory, not criminal, legislation. I will now address each of these arguments in turn.

Les principaux arguments des appelantes

Il me semble que les considérations qui précèdent suffisent à établir que la Loi, de par son caractère véritable, est une loi en matière de droit criminel visant à protéger la santé publique et que, par conséquent, le Parlement a la compétence législative, en vertu du par. 91(27) de la *Loi constitutionnelle de 1867*, de l'adopter. Cependant, j'estime opportun d'examiner directement les trois principaux arguments soulevés par les appelantes pour soutenir que la Loi n'est pas une loi valide en matière de droit criminel: premièrement, que la conduite interdite par la Loi n'a pas d'[TRADUCTION] «affinité avec une préoccupation traditionnelle en matière de droit criminel»; deuxièmement, que le Parlement ne peut rendre criminelle une activité accessoire à un «mal» s'il n'a pas donné un caractère criminel au «mal» lui-même, et troisièmement, qu'il convient davantage de qualifier la Loi de texte de nature réglementaire plutôt que de texte relevant du droit criminel. J'examinerai séparément chacun de ces arguments.

i. *Affinity of the Act with a Traditional Criminal Law Concern*

The appellants' first argument is that the Act is not a valid exercise of the criminal law power because it does not involve conduct having an affinity with a traditional criminal law concern. The appellants observe that both tobacco consumption and tobacco advertising have always been legal in this country and, on this basis, argue that this legislation does not serve a "public purpose commonly recognized as being criminal in nature"; see *Swain*, *supra*, at p. 998.

In my view, this argument fails because it neglects the well-established principle that the definition of the criminal law is not "frozen as of some particular time"; see *Zelensky*, *supra*, at p. 951 (*per* Laskin C.J.). It has long been recognized that Parliament's power to legislate with respect to the criminal law must, of necessity, include the power to create new crimes. This was made clear as early as 1931, when the Privy Council upheld the validity of the *Combines Investigation Act*, R.S.C. 1927, c. 26, in *PATA*, *supra*. That legislation criminalized a wide array of commercial activities not hitherto perceived to have an affinity with criminal law concerns. However, Lord Atkin explained that this fact alone was not sufficient to preclude the application of the criminal law power. He stated, at pp. 323-24:

In their Lordships' opinion s. 498 of the Criminal Code and the greater part of the provisions of the Combines Investigation Act fall within the power of the Dominion Parliament to legislate as to matters falling within the class of subjects, "the criminal law including the procedure in criminal matters" (s. 91, head 27). The substance of the Act is by s. 2 to define, and by s. 32 to make criminal, combines which the legislature in the public interest intends to prohibit. The definition is wide, and may cover activities which have not hitherto been considered to be criminal. But only those combines are affected "which have operated or are likely to operate to the detriment or against the interest of the public, whether consumers, producers, or others"; and if Parliament genuinely determines that commercial activities

i. *Affinité de la Loi avec une préoccupation traditionnelle en matière de droit criminel*

Le premier argument des appelantes est que la Loi ne constitue pas un exercice valide de la compétence en matière de droit criminel parce qu'elle ne touche pas une conduite ayant une affinité avec une préoccupation traditionnelle en matière de droit criminel. Les appelantes font remarquer que l'usage du tabac et la publicité en sa faveur ont toujours été légales au Canada et, pour ce motif, elles soutiennent que la loi ne sert pas «une fin publique communément reconnue comme étant de nature criminelle»; voir *Swain*, précité, à la p. 998. 46

À mon avis, cet argument échoue parce qu'il ne tient pas compte du principe bien établi selon lequel la définition du droit criminel n'est pas «gelé[e] à une époque déterminée»; voir *Zelensky*, précité, à la p. 951 (le juge en chef Laskin). On a depuis longtemps reconnu que la compétence fédérale de légiférer en matière de droit criminel comprend nécessairement celle de définir de nouveaux crimes. Cela a été établi clairement dès 1931 lorsque le Conseil privé a confirmé la validité de la *Loi des enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. 1927, ch. 26, dans l'arrêt *PATA*, précité. Cette loi rendait criminelles une vaste gamme d'activités commerciales que l'on ne considérait pas jusque là comme ayant une affinité avec les préoccupations en matière de droit criminel. Cependant, lord Atkin a expliqué que ce seul fait ne suffit pas à empêcher l'application de la compétence en matière de droit criminel. Il a affirmé, aux pp. 323 et 324: 47

[TRADUCTION] De l'avis de leurs Seigneuries, l'art. 498 du Code criminel et la plus grande partie des dispositions de la Loi des enquêtes sur les coalitions entrent dans le pouvoir qu'a le Parlement du Dominion de faire des lois en ce qui concerne les matières entrant dans la catégorie de sujets «le droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle» (art. 91, par. 27). En substance, le but de la Loi est, dans son art. 2, de définir et, dans son art. 32, de rendre criminelles les coalitions que le législateur entend prohiber dans l'intérêt public. Cette définition est large et peut couvrir des activités que l'on ne considérait pas jusque-là comme criminelles. Mais seules sont touchées les coalitions «qui ont opéré ou sont de nature à opérer au détriment de l'intérêt du public, soit des consommateurs, des producteurs ou

which can be so described are to be suppressed in the public interest, their Lordships see no reason why Parliament should not make them crimes. "Criminal law" means "the criminal law in its widest sense": *Attorney-General for Ontario* v. *Hamilton Street Ry. Co.*, [1903] A.C. 524. It certainly is not confined to what was criminal by the law of England or of any Province in 1867. The power must extend to legislation to make new crimes .... It appears to their Lordships to be of little value to seek to confine crimes to a category of acts which by their very nature belong to the domain of "criminal jurisprudence"; for the domain of criminal jurisprudence can only be ascertained by examining what acts at any particular period are declared by the State to be crimes .... [Emphasis added.]

Soon after that decision, in *Attorney-General for British Columbia v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 368, the Privy Council adopted similar reasoning to uphold a prohibition on price discrimination under the criminal law power. Later, this Court, following in large part the reasoning employed by the Privy Council in *PATA*, *supra*, sustained a prohibition of resale price maintenance under the criminal law power (*Campbell v. The Queen*, [1965] S.C.R. vii) and a federal law authorizing the courts to make orders prohibiting the continuation of illegal practices or to dissolve illegal mergers; see *Goodyear Tire*, *supra*. In the *Goodyear Tire* case, at p. 311, Rand J. reaffirmed the reasoning in the *PATA* case and made the following observation:

It is accepted that head 27 of s. 91 of the Confederation statute is to be interpreted in the widest sense, but that breadth of scope contemplates neither a static catalogue of offences nor order of sanctions. The evolving and transforming types and patterns of social and economic activities are constantly calling for new penal controls and limitations and that new modes of enforcement and punishment adapted to the changing conditions are not to be taken as being equally within the ambit of parliamentary power is, in my opinion, not seriously arguable.

48 In my view, the reasoning in *PATA* and *Goodyear Tire* is directly applicable here. The simple

autres»; et si le Parlement décide à bon droit que lesdites activités commerciales doivent être réprimées dans l'intérêt public, leurs Seigneuries ne voient pas pourquoi le Parlement ne pourrait pas en faire des crimes. Le «droit criminel» signifie «le droit criminel dans son sens le plus large» (*Attorney-General for Ontario* c. *Hamilton Street Ry. Co.*, [1903] A.C. 524). Il ne se confine certainement pas à ce que le droit anglais ou celui d'une province quelconque considéraient comme des actes criminels en 1867. Ce pouvoir doit permettre de légiférer pour définir de nouveaux crimes. [...] Il apparaît assez vain à leurs Seigneuries de chercher à confiner les crimes à une catégorie d'actes qui, de par leur nature véritable, appartiennent au domaine du «droit criminel», car on ne peut fixer le domaine du droit criminel qu'en examinant quels actes l'État qualifie de crimes à chaque période en cause ... [Je souligne.]

Peu de temps après cette décision, dans l'arrêt *Attorney-General for British Columbia c. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 368, le Conseil privé a adopté un raisonnement similaire pour maintenir, en vertu de la compétence en matière de droit criminel, une prohibition de discrimination relative aux prix. Plus tard, notre Cour, se fondant en grande partie sur le raisonnement du Conseil privé dans l'arrêt *PATA*, précité, a confirmé une interdiction de maintien du prix de revente en vertu de la compétence en matière de droit criminel (*Campbell c. The Queen*, [1965] R.C.S. vii), ainsi qu'une loi fédérale autorisant les tribunaux à interdire par ordonnance la continuation de pratiques illégales ou à dissoudre des fusions illégales; voir *Goodyear Tire*, précité. Dans cet arrêt, à la p. 311, le juge Rand a de nouveau confirmé le raisonnement de l'arrêt *PATA* et fait l'observation suivante:

[TRADUCTION] Il est reconnu que le par. 91(27) de la loi sur la Confédération doit être interprété dans son sens le plus large, mais il ne s'agit pas pour autant d'établir un éventail fixe d'infractions ni de sanctions. L'évolution des types et des modèles d'activités sociales et économiques fait constamment appel à de nouveaux contrôles et restrictions de nature pénale, et, selon moi, on ne peut sérieusement soutenir que les nouveaux modes d'exécution et de sanction, adaptés à l'évolution des conditions, ne doivent pas être considérés comme faisant également partie de la compétence du Parlement.

À mon avis, les arrêts *PATA* et *Goodyear Tire* sont directement applicables en l'espèce. Le sim-

fact that neither tobacco consumption nor tobacco advertising have been illegal in the past in no way precludes Parliament from criminalizing either of those activities today. Indeed, given the fact that the first medical reports linking cigarette smoking to disease did not emerge until the 1950s, and that governments have only recently been made aware of the truly devastating health consequences of tobacco consumption, it is clear that Parliament had no reason, before that time, to criminalize this activity. The evolution in medical knowledge since the 1950s has radically altered the social and political landscape, producing a growing consensus, both nationally and internationally, that tobacco consumption is a *sui generis* problem that can only be properly addressed with an array of innovative and multifaceted legislative responses. In Canada, the decision to criminalize tobacco advertising was made incrementally, as part of a 25-year public policy process, and only after Parliament had determined that there was compelling evidence concerning the health effects of tobacco consumption and that the variety of non-criminal measures then in place were not sufficiently effective in reducing consumption. It would be artificial, if not absurd, to limit Parliament's power to legislate in this emerging area of public health concern simply because it did not, and logically could not, legislate at an earlier time.

ple fait que l'usage et la publicité du tabac n'étaient pas illégaux dans le passé n'empêche aucunement le Parlement de criminaliser l'une ou l'autre de ces activités aujourd'hui. En fait, puisque ce n'est que dans les années 50 qu'ont paru les premiers rapports médicaux reliant l'habitude de fumer à la maladie et que ce n'est que récemment que les gouvernements ont été mis au courant des conséquences véritablement nocives de l'usage du tabac pour la santé, il est clair que le Parlement n'avait auparavant aucune raison de criminaliser cette activité. L'évolution de la médecine depuis les années 50 a radicalement modifié le cadre social et politique, donnant lieu, sur les plans tant national qu'international, à un consensus de plus en plus grand selon lequel l'usage du tabac est un problème en soi auquel on ne peut s'attaquer efficacement que par une série de mesures législatives innovatrices et diversifiées. Au Canada, la décision de criminaliser la publicité du tabac a été prise progressivement dans le cadre d'un processus de politique gouvernementale échelonné sur une période de 25 ans et seulement après que le Parlement eut déterminé qu'il existait des données impératives sur les effets de l'usage du tabac sur la santé et que la gamme de mesures non criminelles alors en place n'étaient pas suffisamment efficaces pour réduire la consommation. Il serait artificiel, voire absurde, de restreindre la compétence du Parlement de légiférer dans ce nouveau domaine d'intérêt pour la santé publique simplement parce qu'il ne l'a pas fait, et ne pouvait logiquement pas le faire, auparavant.

ii. *The Ancillary Nature of the Prohibited Act*

The appellants' second argument is that the Act lacks the requisite "criminal public purpose" because Parliament cannot criminalize an activity ancillary to an "evil" (the advertisement and promotion of tobacco), when the underlying activity the legislation is designed to combat (the manufacture, sale and consumption of tobacco) is itself legal.

In my view, this argument fails because it cannot be reconciled with the recent jurisprudence of this Court. In both *Reference re ss. 193 and 195.1(1)(c) of the Criminal Code (Man.)*, [1990] 1

ii. *L'aspect secondaire de l'acte interdit*

Le deuxième argument des appelantes est que la Loi ne vise pas un «objectif public du droit criminel» parce que le Parlement ne peut criminaliser une activité portant sur un aspect secondaire d'un «mal» (la publicité et la promotion des produits du tabac) si l'activité sous-jacente à laquelle s'attaque la loi (la fabrication, la vente et l'usage du tabac) est elle-même légale. 49

À mon avis, cet argument échoue parce qu'il n'est pas compatible avec la jurisprudence récente de notre Cour. Tant dans le *Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.)*, 50

S.C.R. 1123 (the *Prostitution Reference*), and *Rodriguez v. British Columbia (Attorney General)*, [1993] 3 S.C.R. 519, this Court upheld the constitutionality of legislation that criminalized an ancillary activity without also criminalizing the underlying activity or "evil". In the *Prostitution Reference*, for example, this Court upheld the constitutionality of ss. 193 and 195.1(1)(*c*) of the *Criminal Code*, R.S.C. 1970, c. C-34, which prohibited the solicitation of clients for prostitution and the operation of bawdy houses, but did not, at the same time, prohibit prostitution itself. In reaching the conclusion that these provisions were constitutionally valid, Dickson C.J. reasoned as follows, at p. 1142:

> While I recognize that Parliament has chosen a circuitous path, I find it difficult to say that Parliament cannot take this route. The issue is not whether the legislative scheme is frustrating or unwise but whether the scheme offends the basic tenets of our legal system. The fact that the sale of sex for money is not a criminal act under Canadian law does not mean that Parliament must refrain from using the criminal law to express society's disapprobation of street solicitation. Unless or until this Court is faced with the direct question of Parliament's competence to criminalize prostitution, it is difficult to say that Parliament cannot criminalize and thereby indirectly control some element of prostitution — that is, street solicitation. [Emphasis in original.]

In that case, Lamer J. (as he then was) also made the following observation, at p. 1191:

> As I have noted above, prostitution itself is not a crime in Canada. Our legislators have instead, chosen to attack prostitution indirectly. The *Criminal Code* contains many prohibitions relating to the act of taking money in return for sexual services. Among the offences that relate to prostitution are the bawdy-house provisions, the procuring and pimping provisions, as well as other more general offences that indirectly have an impact on prostitution related activities; for example provisions such as disturbing the peace. In my view, these laws indicate that while on the face of the legislation the act

[1990] 1 R.C.S. 1123 (le *Renvoi sur la prostitution)* que dans l'arrêt *Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)*, [1993] 3 R.C.S. 519, notre Cour a maintenu la constitutionnalité de lois qui criminalisaient une activité secondaire sans rendre criminelle l'activité ou le «mal» sous-jacents. Par exemple, dans le *Renvoi sur la prostitution*, notre Cour a confirmé la constitutionnalité de l'art. 193 et de l'al. 195.1(1)*c*) du *Code criminel*, S.R.C. 1970, ch. C-34, qui interdisaient la sollicitation de clients à des fins de prostitution et la tenue de maisons de débauche, sans toutefois interdire la prostitution même. Pour conclure à la validité constitutionnelle de ces dispositions, le juge en chef Dickson a fait le raisonnement suivant, à la p. 1142:

> Bien que j'admette que le Parlement a choisi un moyen détourné, il m'est difficile d'affirmer que le Parlement ne peut emprunter cette voie. La question n'est pas de savoir si le régime législatif est insatisfaisant ou peu judicieux mais si le régime porte atteinte aux préceptes fondamentaux de notre système juridique. Le fait que la vente de services sexuels en échange d'argent ne soit pas un acte criminel en droit canadien ne signifie pas que le Parlement ne peut utiliser le droit criminel pour manifester la désapprobation de la société à l'égard de la sollicitation de rue. Tant qu'on ne demandera pas directement à notre Cour de se prononcer sur la compétence du Parlement pour criminaliser la prostitution, il est difficile d'affirmer que le Parlement ne peut pas criminaliser et ainsi contrôler indirectement certains éléments de la prostitution, c'est-à-dire la sollicitation de rue. [Souligné dans l'original.]

Dans cet arrêt, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a également fait l'observation suivante, à la p. 1191:

> Comme je l'ai déjà dit, la prostitution en soi n'est pas un crime au Canada. Notre législateur a préféré s'attaquer indirectement à la prostitution. Le *Code criminel* contient plusieurs interdictions relatives à l'action d'accepter de l'argent en contrepartie de services sexuels. On retrouve parmi les infractions qui se rapportent à la prostitution les dispositions sur les maisons de débauche, les dispositions sur les souteneurs ainsi que d'autres infractions plus générales qui ont des répercussions indirectes sur les activités accessoires de la prostitution; par exemple, des dispositions sur le fait de troubler la paix. À mon avis, ces dispositions législatives indiquent que, bien que selon la lettre de la loi la prostitution elle-

of prostitution is not illegal, our legislators are indeed aiming at eradicating the practice.

A similar line of reasoning was employed by this Court in *Rodriguez*, *supra*, where the constitutionality of a prohibition against assisted suicide under s. 214(*b*) of the *Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, was upheld despite the fact that suicide itself was, and is at present, not illegal in this country.

In my view, the reasoning in the *Prostitution Reference* and *Rodriguez* is directly applicable to the present cases. Although the manufacture, sale and consumption of tobacco has not been criminalized under the Act, it is clear that Parliament's underlying purpose in criminalizing tobacco advertising and promotion is to eradicate the practice. The fact that Parliament has chosen a "circuitous path" to accomplish this goal does not in any way lessen the constitutional validity of the goal. I emphasize once again that it is the pith and substance of the legislation, not Parliament's wisdom in choosing the legislative method, that is the touchstone in a division of powers analysis.

iii. *The Creation of Exemptions Under the Criminal Law Power*

The appellants' third argument is that the Act is fundamentally regulatory, not criminal, in nature. In support of this argument, they observe that the Act contains exemptions for publications and broadcasts originating outside Canada (s. 4(3)), for the Dunhill trademark (s. 8(3)), and for tobacco product substitutes exempted by the Governor in Council on the ground that they pose less risk to the health of users (s. 17(*a*)). The practical effect of these exemptions, the appellants argue, is that the very same act can be legal when committed by one party in Canada but illegal when committed by another.

In my view, this argument fails because it disregards the long-established principle that the criminal law may validly contain exemptions for certain

même ne soit pas illégale, notre législateur vise effectivement à supprimer la pratique.

Notre Cour a appliqué un raisonnement similaire dans l'arrêt *Rodriguez*, précité, dans lequel elle a confirmé la constitutionnalité d'une interdiction d'aide au suicide en vertu de l'al. 214*b*) du *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, même si le suicide n'était, et n'est toujours pas, illégal au Canada.

À mon avis, le raisonnement appliqué dans le *Renvoi sur la prostitution* et dans l'arrêt *Rodriguez* est directement applicable en l'espèce. Bien que la fabrication, la vente et l'usage du tabac n'aient pas été criminalisés en vertu de la Loi, de toute évidence, en rendant criminelles la publicité et la promotion en faveur du tabac, le législateur fédéral avait comme objectif sous-jacent de supprimer cette pratique. Le fait qu'il a choisi «un moyen détourné» pour atteindre cet objectif n'en change aucunement la validité constitutionnelle. Je voudrais souligner de nouveau que c'est le caractère véritable de la loi, non la sagesse du choix de la mesure législative, qui est la pierre angulaire dans une analyse du partage des pouvoirs. 51

iii. *La création d'exemptions dans le cadre de la compétence en matière de droit criminel*

Le troisième argument des appelantes est que la Loi est fondamentalement un texte réglementaire et non un texte relevant du droit criminel. À l'appui de cet argument, elles soutiennent que la Loi renferme des exemptions concernant les publications et les émissions en provenance de l'étranger (par. 4(3)), la marque Dunhill (par. 8(3)), et les substituts aux produits du tabac exemptés par le gouverneur en conseil pour le motif qu'ils font courir moins de risques pour la santé des consommateurs (al. 17*a*)). En pratique, ces exemptions ont pour effet, selon les appelantes, qu'un acte peut être légal s'il est commis par une partie au Canada, mais illégal lorsqu'il est commis par une autre partie. 52

À mon avis, cet argument échoue parce qu'il ne tient pas compte du principe depuis longtemps reconnu que le droit criminel peut validement 53

conduct without losing its status as criminal law. As early as 1959, in *Lord's Day Alliance of Canada v. Attorney General of British Columbia*, [1959] S.C.R. 497, this Court held that the *Lord's Day Act*, R.S.C. 1952, c. 171, which prohibited gambling on Sunday, was a valid exercise of the criminal law power despite the fact that s. 6 of that Act created an exemption for provinces which had passed legislation to the contrary. In upholding the validity of the Act, Rand J. explained, at pp. 509-10, that this exemption did not detract from the criminal nature of the legislation:

> The legislative efficacy in prohibiting the activity named is that solely of Parliament; the effect of the exception is to declare that in the presence of a provincial enactment of the appropriate character the scope of s. 6 automatically ceases to extend to the provincial area covered by that enactment. The latter is a condition of fact in relation to which Parliament itself has provided a limitation for its own legislative act. That Parliament can so limit the operation of its own legislation and that it may do so upon any such event or condition is not open to serious debate.

54 This principle was reiterated in *Morgentaler v. The Queen*, [1976] 1 S.C.R. 616, where this Court addressed the constitutionality of s. 251 of the *Criminal Code*, R.S.C. 1970, c. C-34. Under s. 251(1) of the *Code*, the intentional procurement of a miscarriage was declared to be unlawful. However, under s. 251(4) and (5), Parliament had also created an exemption for miscarriages carried out by qualified medical practitioners where the life of the woman was in danger. Laskin C.J., dissenting in the result but not on this issue, made it clear that the creation of such an exemption did not detract from the validity of the provision as criminal law, at p. 627:

> I need cite no authority for the proposition that Parliament may determine what is not criminal as well as what is, and may hence introduce dispensations or exemptions in its criminal legislation. It has done this in respect of gaming and betting by prescribing for lawful operation of pari-mutuel systems . . ., by exempting agricultural fairs or exhibitions from certain of the

comporter des exemptions relativement à certaines conduites sans pour autant perdre son caractère. Dès 1959, dans l'arrêt *Lord's Day Alliance of Canada c. Attorney General of British Columbia*, [1959] R.C.S. 497, notre Cour a statué que la *Loi sur le dimanche*, S.R.C. 1952, ch. 171, qui interdisait les jeux de hasard le dimanche, était un exercice valide de compétence en matière de droit criminel, même si l'art. 6 de cette loi créait une exemption pour les provinces qui avaient adopté une loi à l'effet contraire. En confirmant la validité de la loi, le juge Rand a expliqué, aux pp. 509 et 510, que cette exemption n'enlève pas à la loi son caractère de droit criminel:

> [TRADUCTION] L'action législative, en interdisant l'activité indiquée, correspond uniquement à celle du Parlement: l'exception a pour effet de déclarer qu'en présence d'une disposition provinciale de nature appropriée, l'art. 6 cesse immédiatement de s'appliquer au territoire provincial visé par cette disposition. Il s'agit d'une condition de fait au sujet de laquelle le Parlement lui-même a prévu des limites à sa propre action législative. Le fait que le Parlement peut ainsi limiter l'application de ses propres lois et le faire dans n'importe quelles circonstances ou sous n'importe quelles conditions ne prête pas vraiment à discussion.

Ce principe a été repris dans *Morgentaler c. La Reine*, [1976] 1 R.C.S. 616, où notre Cour a examiné la constitutionnalité de l'art. 251 du *Code criminel*, S.R.C. 1970, ch. C-34. En vertu du par. 251(1) du *Code*, le fait de procurer intentionnellement un avortement a été déclaré illégal. Cependant, en vertu des par. 251(4) et (5), le législateur a créé une exemption dans le cas des avortements effectués par des médecins qualifiés si la santé de la femme est en danger. Le juge en chef Laskin, dissident quant au résultat mais pas relativement à cette question, a clairement établi que la formulation d'une telle exemption ne porte pas atteinte à la validité de la disposition en tant que règle de droit criminel, à la p. 627:

> Je n'ai pas besoin de citer de précédents pour affirmer que le Parlement peut déterminer ce qui n'est pas criminel aussi bien que ce qui l'est, et qu'il peut par conséquent introduire dans ses lois pénales des dispenses ou des immunités. Il l'a fait dans le domaine des jeux et paris en permettant l'exploitation légale du pari mutuel [. . .], en exemptant les foires ou expositions agricoles

prohibitions against lotteries and games of chance . . . and by expressly permitting lotteries under stated conditions. . . .

Most recently, in *R. v. Furtney*, [1991] 3 S.C.R. 89, this Court reaffirmed Laskin C.J.'s conclusion. In *Furtney*, the Court addressed a challenge to s. 207 of the *Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, which prohibited lotteries but created an exemption for provincial lotteries conducted in accordance with terms and conditions of licences issued by the Lieutenant Governor. The Court held that the *Code* provision was valid criminal law, even though it delegated regulatory power to the provincial Lieutenant Governors in Council to create exemptions. In reaching the conclusion that s. 207 was a valid exercise of the criminal law power, Stevenson J. stated, at p. 105:

I note that these very provisions were referred to as valid by Laskin C.J. in his dissenting judgment (the majority not addressing the matter) in *Morgentaler v. The Queen*, [1976] 1 S.C.R. 616. The Chief Justice (at p. 627) referred to Parliament's authority to introduce dispensations or exemptions from criminal law in determining what is and what is not criminal.

Stevenson J. expressed his agreement with Laskin C.J.'s view and gave the following rationale for his conclusion, at pp. 106-7:

The appellants question whether the criminal law power will sustain the establishment of a regulatory scheme in which an administrative agency or official exercises discretionary authority. In so doing they ask the question "referred to by Professor Hogg" in his *Constitutional Law of Canada* . . . at p. 415. Hogg suggests that the question is really one of colourability. . . . In my view the decriminalization of lotteries licensed under prescribed conditions is not colourable. It constitutes a definition of the crime, defining the reach of the offence, a constitutionally permissive exercise of the criminal law power, reducing the area subject to criminal law prohibition where certain conditions exist. I cannot characterize it as an invasion of provincial powers

de certaines interdictions qui frappent les loteries et jeux de hasard [. . .] et en permettant expressément des loteries sous certaines conditions. . .

Plus récemment, dans *R. c. Furtney*, [1991] 3 R.C.S. 89, notre Cour a de nouveau confirmé la conclusion du juge en chef Laskin. Dans cet arrêt, notre Cour s'est prononcée sur une contestation de l'art. 207 du *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, qui interdisait les loteries, sauf celles d'une province tenues conformément aux modalités d'une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur. Notre Cour a statué que la disposition du *Code* énonçait une règle de droit criminel valide, même si elle déléguait un pouvoir de réglementation aux lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces leur permettant de créer certaines exceptions. En arrivant à la conclusion que l'art. 207 constituait un exercice valide de compétence en matière de droit criminel, le juge Stevenson affirme à la p. 105: 55

Je constate que ces dispositions mêmes ont été considérées comme valides par le juge en chef Laskin dans l'opinion dissidente (les juges formant la majorité n'ayant pas abordé la question) qu'il a rédigée dans l'arrêt *Morgentaler c. La Reine*, [1976] 1 R.C.S. 616. Le Juge en chef a mentionné, à la p. 627, le pouvoir du Parlement d'introduire, dans ses lois criminelles, des dispenses ou des immunités en déterminant ce qui est et ce qui n'est pas criminel.

Le juge Stevenson a exprimé son assentiment avec le juge en chef Laskin et a justifié ainsi sa conclusion, aux pp. 106 et 107:

Les appelants mettent en doute que le pouvoir en matière de droit criminel puisse étayer l'instauration d'un régime de réglementation dans lequel un organisme ou un agent administratif exerce un pouvoir discrétionnaire. Ce faisant, ils posent la question [TRADUCTION] «mentionnée par le professeur Hogg» dans *Constitutional Law of Canada*, [. . .] à la p. 415. Hogg dit qu'il s'agit vraiment d'une question de législation déguisée. [. . .] À mon avis, la décriminalisation des loteries exploitées en vertu de licences assorties de certaines conditions précises n'est pas une tentative déguisée de légiférer. Elle constitue une définition de l'acte criminel, qui fixe la portée de l'infraction, un exercice constitutionnellement acceptable du pouvoir en matière de droit criminel, qui réduit le champ de l'interdiction du droit criminel lorsqu'il existe certaines conditions. Je

any more than the appellants were themselves able to do. [Emphasis added.]

56 The clear implication of this Court's decisions in *Lord's Day Alliance*, *Morgentaler* and *Furtney*, is that the creation of a broad status-based exemption to criminal legislation does not detract from the criminal nature of the legislation. On the contrary, the exemption helps to define the crime by clarifying its contours. In my view, this is precisely what Parliament has done in creating exemptions under the Act. The crime created by Parliament is the advertisement and promotion of tobacco products offered for sale in Canada. Rather than diluting the criminality of these acts, the exemptions to which the appellants refer serve merely to delineate the logical and practical limits to Parliament's exercise of the criminal law power in this context. For example, it is clear that the exemption for foreign media under s. 4(3) was created to avoid both the extraterritorial application of Canadian legislation and the page-by-page censorship of foreign publications at the border. It must also be kept in mind that the exemption thereby created extends only to foreign publications imported into Canada or the retransmission of broadcasts originating outside Canada. Section 4(4) limits this exemption by prohibiting persons in Canada from advertising products for sale in Canada by way of foreign publications of broadcasts. Given the fact that foreign tobacco products comprise less than 1 percent of the Canadian market, it is apparent that the exemption has an extremely limited scope. There is an equally logical and practical explanation for the exemptions created under ss. 17(*a*) and 8(3). With respect to the exemption under s. 17(*a*), which permits the Governor in Council to make regulations exempting substitute tobacco products from the application of ss. 4 and 7 where they pose less risk to the health of users, it is clear that Parliament was seeking to encourage the development of alternatives to tobacco. Such an exemption is, of course, completely consistent with the Act's underlying purpose of protecting public health. With respect to the exemption for Dunhill products under s. 8(3), it is clear that Parliament was addressing the legitimate concern that this trademark is unique because

ne puis qualifier cela d'empiétement sur les pouvoirs des provinces, pas plus que les appelants n'ont eux-mêmes été en mesure de le faire. [Je souligne.]

Il résulte de toute évidence des arrêts de notre Cour *Lord's Day Alliance*, *Morgentaler* et *Furtney* que la création d'une exemption générale, fondée sur le statut, à l'application d'une loi en matière criminelle n'a pas pour effet d'enlever à la loi son caractère de droit criminel. Au contraire, l'exemption contribue à définir l'infraction en en clarifiant les particularités. À mon avis, c'est précisément ce que le Parlement a fait par la constitution d'exemptions dans la Loi. L'infraction créée par le Parlement est la publicité et la promotion des produits du tabac mis en vente au Canada. Plutôt que d'atténuer la nature criminelle de ces actes, les exemptions que mentionnent les appelantes servent tout simplement à cerner les restrictions logiques et pratiques de l'exercice de la compétence fédérale en matière de droit criminel dans ce contexte. Par exemple, il est clair que le législateur a créé l'exemption applicable aux médias étrangers visée au par. 4(3) pour éviter à la fois l'application extraterritoriale de la loi canadienne et l'examen page par page des publications étrangères à la frontière. On doit également se rappeler que l'exemption en question ne s'applique qu'aux publications étrangères importées au Canada ou qu'à la retransmission d'émissions de radio ou de télévision de l'étranger. Le paragraphe 4(4) restreint cette exemption en interdisant à toute personne se trouvant au Canada de faire de la publicité dans une publication étrangère ou une émission radiodiffusée de l'étranger en faveur d'un produit du tabac vendu au Canada. Puisque les produits du tabac étrangers représentent moins d'un pour cent du marché canadien, il est évident que l'exemption a une portée extrêmement limitée. Il y a également une explication tout aussi logique et pratique pour les exemptions créées en vertu de l'al. 17*a*) et du par. 8(3). Pour ce qui est de l'exemption prévue à l'al. 17*a*), qui permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour exempter de l'application des art. 4 et 7 les produits du tabac utilisés comme substituts s'ils font courir moins de risque pour la santé des consommateurs que ces autres produits, il est évident que le Parlement cherchait à encourager la mise au point de nouveaux produits

it has a marketing existence quite independent from tobacco. Thus, none of these exemptions serves in any way to confuse, or detract from, the category of acts Parliament has validly criminalized under the Act.

comme substituts du tabac. Une telle exemption est, bien entendu, tout à fait compatible avec l'objet sous-jacent de la Loi, qui est de protéger la santé publique. En ce qui concerne l'exemption pour les produits Dunhill établie au par. 8(3), il est évident que le Parlement tenait compte de la préoccupation légitime selon laquelle cette marque est unique parce qu'elle a une existence commerciale tout à fait indépendante du tabac. En conséquence, aucune de ces exemptions ne sert à embrouiller la catégorie des actes que le Parlement a validement criminalisés en vertu de la Loi ni à y porter atteinte.

For all the foregoing reasons, I am of the view that the Act is a valid exercise of the federal criminal law power. Having reached this conclusion, I do not find it necessary to address the Attorney General's further submission that the Act falls under the federal power to legislate for the peace, order and good government of Canada. Accordingly, I now proceed directly to a consideration of the Act's validity under the *Charter*.

Pour tous les motifs qui précèdent, je suis d'avis que la Loi constitue un exercice valide de la compétence fédérale en matière de droit criminel. C'est pourquoi j'estime inutile d'examiner l'autre argument du procureur général selon lequel la Loi relève de la compétence fédérale de légiférer pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada. Par conséquent, je passerai immédiatement à un examen de la validité de la Loi sous le régime de la *Charte*. 57

2. *The Canadian Charter of Rights and Freedoms*

2. *La Charte canadienne des droits et libertés*

Introductory

The Attorney General conceded that the prohibition on advertising and promotion under the Act constitutes an infringement of the appellants' right to freedom of expression under s. 2(*b*) of the *Charter*, and directed his submissions solely to justifying the infringement under s. 1 of the *Charter*. In my view, the Attorney General was correct in making this concession. This Court has, on a number of occasions, held that prohibitions against engaging in commercial expression by advertising infringe upon the freedom of expression in s. 2(*b*) of the *Charter*; see *Ford v. Quebec (Attorney General)*, [1988] 2 S.C.R. 712, at pp. 766-67; *Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927, at pp. 976-78; *Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario*, [1990] 2 S.C.R. 232, at pp. 241-45. On this general issue, then, there only remains the question whether this

Introduction

Le procureur général a admis que l'interdiction de publicité et de promotion prévue dans la Loi constitue une violation du droit à la liberté d'expression garanti aux appelantes par l'al. 2*b*) de la *Charte*, et il a orienté ses arguments seulement vers la justification de cette violation en vertu de l'article premier de la *Charte*. À mon avis, le procureur général a eu raison d'admettre ce fait. À plusieurs reprises, notre Cour a statué que les interdictions relatives à l'expression commerciale par la publicité portent atteinte à la liberté d'expression prévue à l'al. 2*b*) de la *Charte*; voir *Ford c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 R.C.S. 712, aux pp. 766 et 767; *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927, aux pp. 976 à 978; *Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario*, [1990] 2 R.C.S. 232, aux pp. 241 à 245. Relativement à cette question générale, il ne 58

infringement is justified under s. 1, a matter to which I shall turn in a moment.

59 Before doing so, however, it is appropriate to draw attention to the fact that the Attorney General did not concede that s. 9 of the Act, which requires tobacco manufacturers to place an unattributed health warning on packages of these products, constitutes an infringement of the appellants' right to freedom of expression. In my view, the Attorney General was correct in not making this concession. However, since there is considerable overlap between my discussion of this issue and my discussion of s. 1, I shall for convenience address this distinct issue separately at the conclusion of my general s. 1 analysis.

Section 1 of the *Charter*

The Legislative Objective and Context

60 Section 1 of the *Charter* guarantees the rights and freedoms set out therein "subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society". It is well established that the onus of justifying the limitation of a *Charter* right rests on the party seeking to have that limitation upheld, in this case the Attorney General. In *Oakes*, *supra*, this Court set out two broad criteria as a framework to guide courts in determining whether a limitation is demonstrably justified in a free and democratic society. The first is that the objective the limit is designed to achieve must be of sufficient importance to warrant overriding the constitutionally protected right or freedom. The second is that the measures chosen to achieve the objective must be proportional to the objective. The proportionality requirement has three aspects: the measures chosen must be rationally connected to the objective; they must impair the guaranteed right or freedom as little as possible; and there must be proportionality between the deleterious effects of the measures and their salutary effects.

reste alors qu'à déterminer si cette atteinte peut se justifier en vertu de l'article premier, question que j'examinerai dans un instant.

Cependant, j'aimerais auparavant faire ressortir que le procureur général n'a pas admis que l'art. 9 de la Loi, qui exige des fabricants du tabac qu'ils apposent une mise en garde non attribuée sur les emballages de ces produits, constitue une violation du droit à la liberté d'expression des appelantes. À mon avis, le procureur général a eu raison de ne pas admettre ce fait. Cependant, puisqu'il existe un chevauchement considérable entre mon analyse de cette question et celle fondée sur l'article premier, par souci de commodité, j'examinerai cette question distincte séparément à la fin de mon analyse générale fondée sur l'article premier.

L'article premier de la *Charte*

L'objectif et le contexte de la loi

L'article premier de la *Charte* garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. «Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.» Il est bien établi qu'il incombe à la partie qui recherche la justification de la restriction, en l'espèce le procureur général, d'en faire la justification. Dans *Oakes*, précité, notre Cour a établi deux critères généraux pour guider les tribunaux lorsqu'ils doivent déterminer si la justification d'une restriction peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. En premier lieu, l'objectif que la restriction vise à promouvoir doit être suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution. En second lieu, les moyens choisis pour atteindre l'objectif doivent être proportionnels à cet objectif. L'exigence de la proportionnalité comporte trois aspects: les mesures choisies doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif; elles doivent porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté en question, et il doit exister une proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets salutaires.

The appellants have conceded that the objective of protecting Canadians from the health risks associated with tobacco use, and informing them about these risks, is pressing and substantial. Rather than focusing upon the objective, the appellants submit that the measures employed under the Act are not proportional to the objective. In adopting this strategy, they rely heavily upon Chabot J.'s rigorous application of the proportionality requirement at trial. There, Chabot J. equated the burden of proof under the s. 1 analysis to the burden in a civil trial, stating, at p. 515:

> . . . the burden of proof of justification under s. 1 of the Charter rests on the party who seeks to uphold the limitation of a guaranteed right. This burden is the civil burden of proof, the balance of probabilities. However, this balance of probabilities must be applied rigorously and the evidence must be cogent and persuasive. . . .

Applying this standard, Chabot J. decided that the Attorney General had not demonstrated that the prohibition of tobacco advertising and promotion under ss. 4 to 8 of the Act, and the s. 9 requirement that tobacco manufacturers print unattributed health warnings on tobacco products, are proportional to the objective of reducing tobacco consumption. The appellants submit that Chabot J.'s approach was correct and argue that this Court should defer to his factual findings.

It is my view that Chabot J.'s approach was not the correct one in the circumstances of these cases, and that he erred in deciding that the civil burden of proof must be "applied rigorously". As I will show, it is also my view that the Attorney General adduced sufficient evidence at trial to justify the limitation on freedom of expression entailed by this legislation, and that the appellants' argument accordingly fails. However, before I proceed to reexamine the evidence, I find it necessary to clarify in more detail the nature of Chabot J.'s error. Throughout his judgment, Chabot J. referred to the requirements set forth in *Oakes* as a "test". In so doing, he adopted the view, unfortunately still held

Les appelantes ont reconnu le caractère urgent et réel de l'objectif visant à protéger les Canadiens contre les conséquences néfastes du tabac sur la santé et à les sensibiliser à ces conséquences. Plutôt que de s'attarder à cet objectif, les appelantes soutiennent que les mesures employées en vertu de la Loi ne sont pas proportionnelles à l'objectif. En adoptant cette stratégie, les appelantes s'appuient fortement sur l'application rigoureuse de l'exigence de la proportionnalité qu'a faite le juge de première instance. En effet, le juge Chabot a assimilé le fardeau de la preuve applicable lors d'une analyse fondée sur l'article premier au fardeau de la preuve applicable en matière civile; il affirme à la p. 2310: 61

> . . . le fardeau de la preuve en matière de justification en vertu de l'article premier de la charte repose sur celui qui soutient la restriction à un droit garanti. C'est le fardeau de preuve civile, la balance des probabilités. Toutefois, cette balance des probabilités doit être appliquée rigoureusement et la preuve doit être forte et persuasive.

À partir de ce critère, le juge Chabot a décidé que le procureur général n'avait pas démontré la proportionnalité entre d'une part, l'interdiction de publicité et de promotion du tabac en vertu des art. 4 à 8 de la Loi et la nécessité pour les fabricants des produits du tabac d'apposer, en vertu de l'art. 9, des mises en garde non attribuées sur les emballages, et d'autre part, l'objectif de réduire l'usage du tabac. Les appelantes soutiennent que l'analyse du juge Chabot était correcte et que notre Cour doit faire preuve de retenue à l'égard des conclusions de fait auxquelles il est arrivé.

Je suis d'avis que l'analyse du juge Chabot n'était pas correcte dans les circonstances et qu'il a commis une erreur en décidant que le fardeau de preuve civile doit être «appliqué rigoureusement». Comme je vais l'illustrer, je suis également d'avis que le procureur général a déposé une preuve suffisante en première instance pour justifier la restriction à la liberté d'expression qu'entraîne cette loi, et que l'argument des appelantes doit donc échouer. Cependant, avant de procéder au réexamen de la preuve, j'estime nécessaire de clarifier la nature de l'erreur du juge Chabot. Tout au long de sa décision, il parle des exigences formulées dans l'arrêt *Oakes* comme d'un «critère». Ce faisant, il a 62

by some commentators, that the proportionality requirements established in *Oakes* are synonymous with, or have even superseded, the requirements set forth in s. 1. This view is based upon a misperception of this Court's jurisprudence. The appropriate "test" to be applied in a s. 1 analysis is that found in s. 1 itself, which makes it clear that the court's role in applying that provision is to determine whether an infringement is reasonable and can be demonstrably justified in a "free and democratic society". In *Oakes*, this Court established a set of principles, or guidelines, intended to serve as a framework for making this determination. However, these guidelines should not be interpreted as a substitute for s. 1 itself. It is implicit in the wording of s. 1 that the courts must, in every application of that provision, strike a delicate balance between individual rights and community needs. Such a balance cannot be achieved in the abstract, with reference solely to a formalistic "test" uniformly applicable in all circumstances. The s. 1 inquiry is an unavoidably normative inquiry, requiring the courts to take into account both the nature of the infringed right and the specific values and principles upon which the state seeks to justify the infringement.

63 This Court has on many occasions affirmed that the *Oakes* requirements must be applied flexibly, having regard to the specific factual and social context of each case. The word "reasonable" in s. 1 necessarily imports flexibility. In a significant, but often neglected, passage from *Oakes* itself, Dickson C.J. warned against an overly formalistic approach to s. 1 justification, stating, at p. 139, that "[a]lthough the nature of the proportionality test will vary depending on the circumstances, in each case the courts will be required to balance the interests of society with those of individuals and groups". Shortly thereafter, he reaffirmed this warning in *R. v. Edwards Books and Art Ltd.*,

adopté le point de vue, que partagent malheureusement certains auteurs, que les exigences en matière de proportionnalité formulées dans l'arrêt *Oakes* sont comparables à celles applicables à l'article premier ou les ont même remplacées. Ce point de vue se fonde sur une interprétation erronée de la jurisprudence de notre Cour. Le «critère» approprié applicable à une analyse fondée sur l'article premier se trouve dans la disposition même, laquelle établit clairement que le rôle du tribunal lorsqu'il l'applique est de déterminer si la limite est raisonnable et peut se démontrer dans le cadre d'une «société libre et démocratique». Dans l'arrêt *Oakes*, notre Cour a établi une série de principes ou directives destinés à servir de cadre analytique à cette fin. Toutefois, ces directives ne devraient pas être interprétées comme si elles remplaçaient l'article premier. Le libellé de l'article premier indique implicitement que les tribunaux doivent, chaque fois qu'ils l'appliquent, établir un équilibre délicat entre les droits individuels et les besoins de la collectivité. Un tel équilibre ne peut être établi dans l'abstrait, à partir seulement d'un «critère» formaliste qui s'appliquerait de façon uniforme dans toutes les circonstances. L'examen fondé sur l'article premier est un examen inévitablement normatif qui exige des tribunaux qu'ils tiennent compte de la nature du droit violé ainsi que des valeurs et des principes spécifiques à partir desquels le ministère public tente de justifier la violation.

Notre Cour a confirmé à maintes reprises que les exigences formulées dans l'arrêt *Oakes* doivent être appliquées avec souplesse en tenant compte du contexte factuel et social particulier de chaque cas. Le terme «raisonnables» employé à l'article premier est nécessairement une indication qu'il y a lieu de faire preuve de souplesse. Dans un passage important, mais souvent oublié, de l'arrêt *Oakes*, le juge en chef Dickson fait une mise en garde contre un examen trop formaliste de la justification en vertu de l'article premier, affirmant à la p. 139, que «[m]ême si la nature du critère de proportionnalité pourra varier selon les circonstances, les tribunaux devront, dans chaque cas, soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes». Peu après, il a répété cette mise en garde dans l'arrêt *R. c. Edwards Books and Art Ltd.*, [1986] 2

[1986] 2 S.C.R. 713, at pp. 768-69, where, referring to the Court's decision in *Oakes*, he stated:

> The Court stated that the nature of the proportionality test would vary depending on the circumstances. Both in articulating the standard of proof and in describing the criteria comprising the proportionality requirement the Court has been careful to avoid rigid and inflexible standards.

Later, in *R. v. Keegstra*, [1990] 3 S.C.R. 697, at p. 735, Dickson C.J. had occasion to elaborate more fully upon the nature of the *Oakes* inquiry, stating that it was "dangerously misleading to conceive of s. 1 as a rigid and technical provision". He noted at p. 735 that,

> [f]rom a crudely practical standpoint, *Charter* litigants sometimes may perceive s. 1 in this manner, but in the body of our nation's constitutional law it plays an immeasurably richer role, one of great magnitude and sophistication.

The role played by s. 1, he observed, at pp. 735-36, is to bring "together the fundamental values and aspirations of Canadian society" through the "dual function" of activating *Charter* rights and permitting such reasonable limits as a free and democratic society may have occasion to place upon them. In applying a "rigid or formalistic approach to the application of s. 1", he cautioned, at p. 737, the courts risk losing sight of the "synergetic relation" that exists between *Charter* rights and the context in which they are claimed. In *United States of America v. Cotroni*, [1989] 1 S.C.R. 1469, at pp. 1489-90, I also stressed the importance of this "synergetic relation", and the resulting need to avoid what I called a "mechanistic approach" in the application of the s. 1 analysis:

> In the performance of the balancing task under s. 1, it seems to me, a mechanistic approach must be avoided. While the rights guaranteed by the *Charter* must be given priority in the equation, the underlying values must be sensitively weighed in a particular context

R.C.S. 713, aux pp. 768 et 769, où il dit relativement à l'arrêt *Oakes*:

> La Cour a affirmé que la nature du critère de proportionnalité pourrait varier en fonction des circonstances. Tant dans son élaboration de la norme de preuve que dans sa description des critères qui comprennent l'exigence de proportionnalité, la Cour a pris soin d'éviter de fixer des normes strictes et rigides.

Plus tard, dans l'arrêt *R. c. Keegstra*, [1990] 3 R.C.S. 697, à la p. 735, le juge en chef Dickson a eu l'occasion de clarifier davantage la nature de l'examen dont il est question dans l'arrêt *Oakes*, affirmant que l'«on s'induit dangereusement en erreur si l'on voit dans l'article premier une disposition rigide et empreinte de formalisme». Il souligne, à la p. 735:

> D'un point de vue purement pratique, les plaideurs qui invoquent la *Charte* peuvent parfois percevoir ainsi l'article premier mais, dans le droit constitutionnel de notre nation, cet article joue un rôle infiniment plus riche, un rôle de grande envergure et d'extrême raffinement.

Le juge en chef Dickson précise aux pp. 735 et 736 que le rôle de l'article premier est de réunir «les valeurs et les aspirations fondamentales de la société canadienne», ayant comme «double fonction» de rendre effectifs les droits et libertés garantis par la *Charte* et de permettre toute limite raisonnable qu'une société libre et démocratique peut avoir à y imposer. S'ils font preuve de «rigidité et [de] formalisme [. . .] dans l'application de l'article premier», précise-t-il, à la p. 737, les tribunaux risquent de ne pas tenir compte du «rapport synergique» qui existe entre les droits garantis par la *Charte* et le contexte de l'instance particulière. Dans *États-Unis d'Amérique c. Cotroni*, [1989] 1 R.C.S. 1469, aux pp. 1489 et 1490, j'ai également fait ressortir l'importance du «rapport synergique» et de la nécessité d'éviter ce que j'ai appelé une «méthode mécaniste» dans l'application de l'analyse fondée sur l'article premier:

> Il me semble qu'en effectuant cette évaluation en vertu de l'article premier il faut éviter de recourir à une méthode mécaniste. Bien qu'il faille accorder priorité dans l'équation aux droits garantis par la *Charte*, les valeurs sous-jacentes doivent être, dans un contexte par-

against other values of a free and democratic society sought to be promoted by the legislature.

For a similar contextual approach to the s. 1 analysis, see *R. v. Jones*, [1986] 2 S.C.R. 284, at p. 300; *Andrews v. Law Society of British Columbia*, [1989] 1 S.C.R. 143, at pp. 184-85; *Black v. Law Society of Alberta*, [1989] 1 S.C.R. 591, at pp. 627-28; *Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General)*, [1989] 2 S.C.R. 1326, at pp. 1355-56, 1380; *McKinney v. University of Guelph*, [1990] 3 S.C.R. 229, at pp. 280-81; and *Dickason v. University of Alberta*, [1992] 2 S.C.R. 1103, at p. 1122.

64 It appears, then, that Chabot J.'s principal error in applying a "rigorous" civil standard of proof was his failure to take into account the specific context in which the s. 1 balancing must take place. This Court has on many occasions stated that the evidentiary requirements under s. 1 will vary substantially depending upon both the nature of the legislation and the nature of the right infringed. In the present cases, both these contextual elements are highly relevant to a proper application of the s. 1 analysis. Accordingly, before proceeding to an analysis of the evidence submitted at trial, I find it necessary to explore in more detail both the nature of the legislation and the nature of the right it infringes.

65 I turn first to the nature of the legislation. In my discussion of the criminal law power, I concluded that the Act is, in pith and substance, criminal law aimed at the protection of public health. In enacting this legislation, Parliament clearly intended to protect public health by reducing the number of inducements for Canadians to consume tobacco, and by educating Canadians about the health risks entailed in its consumption. The appellants concede, and in my view there is no doubt, that this goal is pressing and substantial. At trial and before this Court the Attorney General adduced copious evidence, some of which is set forth in the criminal law power discussion, demonstrating that tobacco consumption is one of the leading causes of illness

ticulier, évaluées délicatement en fonction d'autres valeurs propres à une société libre et démocratique que le législateur cherche à promouvoir.

Pour une démarche contextuelle similaire relativement à l'analyse fondée sur l'article premier, voir *R. c. Jones*, [1986] 2 R.C.S. 284, à la 300; *Andrews c. Law Society of British Columbia*, [1989] 1 R.C.S. 143, aux pp. 184 et 185; *Black c. Law Society of Alberta*, [1989] 1 R.C.S. 591, aux pp. 627 et 628; *Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général)*, [1989] 2 R.C.S. 1326, aux pp. 1355, 1356 et 1380; *McKinney c. Université de Guelph*, [1990] 3 R.C.S. 229, aux pp. 280 et 281, et *Dickason c. Université de l'Alberta*, [1992] 2 R.C.S. 1103, à la p. 1122.

Il appert alors que la principale erreur du juge Chabot lorsqu'il a appliqué «rigoureusement» le fardeau de preuve civile est qu'il a omis de tenir compte du contexte spécifique dans lequel doit se dérouler la pondération en vertu de l'article premier. Notre Cour a à maintes reprises affirmé que les exigences en matière de preuve sous le régime de l'article premier varieront beaucoup en fonction de la nature de la loi et du caractère du droit atteint. Ces éléments contextuels sont fort pertinents en l'espèce pour une bonne application de l'analyse fondée sur l'article premier. En conséquence, avant de procéder à une analyse de la preuve déposée au procès, j'estime nécessaire d'examiner plus en détail la nature de la loi et celle du droit auquel elle porte atteinte.

J'examinerai tout d'abord la nature de la loi. Dans mon examen de la compétence en matière de droit criminel, j'ai conclu que la Loi constitue, de par son caractère véritable, du droit criminel visant la protection de la santé publique. Lorsqu'il a adopté cette loi, le Parlement visait de toute évidence à protéger la santé publique en diminuant le nombre des incitations à la consommation du tabac et à sensibiliser les Canadiens aux méfaits du tabac. Les appelantes admettent que cet objectif est urgent et réel, ce qui ne fait aucun doute à mon avis. En première instance et devant notre Cour, le procureur général a déposé de nombreux éléments de preuve, dont certains ont été exposés au cours de l'analyse de la compétence en matière de droit

and death in our society. It is noteworthy that the detrimental effects of tobacco consumption impact not only upon the estimated 30,000 Canadians who die from related diseases each year, but also upon every member of our community. Apart from the apparent danger posed to nonsmoking members of the community by secondary smoke, all Canadians, and not merely tobacco consumers, must shoulder the heightened tax burden arising from the high cost of medical care for tobacco users who become ill.

criminel, établissant que l'usage du tabac est l'une des principales causes de maladie et de décès dans notre société. Il importe de signaler que les effets préjudiciables de l'usage du tabac ont une incidence non seulement sur les quelque 30 000 Canadiens qui décèdent chaque année de maladies connexes, mais aussi sur l'ensemble de la collectivité. En effet, outre le risque apparent que le tabagisme passif cause aux non-fumeurs dans la société, tous les Canadiens, et non seulement les fumeurs, doivent assumer le fardeau fiscal accru qu'entraînent les frais médicaux élevés des fumeurs qui contractent des maladies.

Having conceded that the objective of protecting public health from the detrimental effects of tobacco consumption is pressing and substantial, the appellants submit, and Chabot J. agreed, that the facts respecting the harmful effect of tobacco are irrelevant to the application of the proportionality analysis. Chabot J. stated, at p. 491:

> . . . much of the expert scientific evidence relating to the effects of tobacco on health, however voluminous and instructive, was nevertheless, with respect, irrelevant to the case and, in the humble view of the court, served merely to colour the debate unnecessarily.

Comme ils ont admis que l'objectif de protection de la santé publique contre les effets préjudiciables du tabac est urgent et réel, les appelantes soutiennent, ce avec quoi était d'accord le juge Chabot, que les faits relatifs à l'effet nocif du tabac ne sont pas pertinents relativement à l'application de la proportionnalité. Le juge Chabot affirme, à la p. 2293: 66

> . . . une grande partie de cette preuve d'expertise scientifique relativement aux effets du tabac sur la santé, toute colossale et instructive fut-elle, n'en était pas moins, avec respect, non pertinente en l'espèce et ne servait, de l'humble opinion du Tribunal, qu'à colorer inutilement le débat.

With respect, I disagree. In my view, the nature and scope of the health problems raised by tobacco consumption are highly relevant to the s. 1 analysis, both in determining the appropriate standard of justification and in weighing the relevant evidence. In this respect, it is essential to keep in mind that tobacco addiction is a unique, and somewhat perplexing, phenomenon. Despite the growing recognition of the detrimental health effects of tobacco use, close to a third of the population continues to use tobacco products on a regular basis. At this point, there is no definitive scientific explanation for tobacco addiction, nor is there a clearly understood causal connection between advertising, or any other environmental factor, and tobacco consumption. This is not surprising. One cannot understand the causal connection between advertising and consumption, or between tobacco and addiction, without probing deeply into the mysteries of human psychology. Many of the workings of

En toute déférence, je ne suis pas d'accord. À mon avis, la nature et l'étendue des problèmes de santé reliés à l'usage du tabac sont tout à fait pertinents relativement à l'analyse fondée sur l'article premier, tant aux fins de la détermination du critère approprié de justification que dans l'appréciation de la preuve pertinente. À cet égard, il est essentiel de se rappeler que la dépendance au tabac est un phénomène unique et assez compliqué. Même si les effets nocifs du tabac sont de plus en plus connus, près du tiers de la population continue de fumer de façon régulière. On ne peut actuellement pas donner d'explication scientifique concluante de la dépendance au tabac, ni établir un lien causal bien compris entre la publicité, ou tout autre facteur environnemental, et l'usage du tabac. Cela n'est pas étonnant. En effet, on ne saurait comprendre le lien causal entre la publicité et la consommation ou entre le tabac et la dépendance sans procéder à une analyse approfondie des mystères

the human mind, and the causes of human behaviour, remain hidden to our understanding and will no doubt remain so for quite some time. In this respect, it is instructive to consider the view of the Surgeon General of the United States, who observed in his 1989 report entitled *Reducing the Health Consequences of Smoking — 25 Years of Progress — A report of the Surgeon General*, at pp. 512-13:

> There is no scientifically rigorous study available to the public that provides a definitive answer to the basic question of whether advertising and promotion increase the level of tobacco consumption. Given the complexity of the issue, none is likely to be forthcoming in the foreseeable future.

However, despite the lack of definitive scientific explanations of the causes of tobacco addiction, clear evidence does exist of the detrimental social effects of tobacco consumption. As I discussed earlier, overwhelming evidence was introduced at trial that tobacco use is a principal cause of deadly cancers, heart disease and lung disease, and that tobacco is highly addictive. Perhaps the most distressing aspect of the evidence introduced at trial is that tobacco consumption is most widespread among the young and the less educated — those segments of the population who are least able to inform themselves about, and to protect themselves against, its hazards. The majority of Canadian tobacco smokers start smoking regularly in their teens, and approximately one in five begin smoking regularly as early as 13; see expert report of Dr. Roberta G. Ferrence, *supra*; "Project Plus/Minus", prepared for Imperial Tobacco Ltd. (1982). Indeed, it has been estimated that, among young Canadians who continue to use tobacco, six times more will die prematurely of disease caused by smoking than from car accidents, suicide, murder and AIDS combined; see expert report of Dr. Donald T. Wigle, *supra*. Moreover there are more smokers among people with less formal education. While, in 1986, 60 percent of those with no high school education smoked on a daily basis, only 8 percent of those with a university degree did so;

de la psychologie humaine. Un grand nombre des rouages du cerveau humain et des causes du comportement humain demeurent un mystère pour nous, et le demeureront sans doute pendant encore longtemps. Sur ce point, il est intéressant d'examiner le point de vue du Surgeon General des États-Unis qui a fait remarquer dans son rapport de 1989 intitulé: *Reducing the Health Consequences of Smoking — 25 Years of Progress — A report of the Surgeon General*, aux pp. 512 et 513:

> [TRADUCTION] Il n'existe pas d'étude publique scientifiquement rigoureuse qui donne une réponse concluante à la question fondamentale de savoir si la publicité et la promotion accroissent la consommation du tabac. Compte tenu de la complexité de la question, il y a peu de chance qu'une telle étude soit menée à brève échéance.

Cependant, malgré l'absence d'explications scientifiques concluantes des causes de la dépendance au tabac, il existe des éléments de preuve clairs sur les effets sociaux préjudiciables de l'usage du tabac. Comme je l'ai mentionné, on a présenté en première instance une preuve abondante établissant d'une part, que l'usage du tabac est une cause principale de cancers, de maladies cardiaques et de maladies pulmonaires entraînant la mort, et d'autre part, que le tabac crée une forte dépendance. L'aspect le plus troublant de la preuve déposée au procès est peut-être que l'usage du tabac est plus répandu chez les jeunes et les personnes moins instruites — les groupes qui sont le moins en mesure de se renseigner sur les méfaits du tabac et de s'en protéger. La majorité des fumeurs au Canada commencent à fumer régulièrement à l'adolescence, et environ un fumeur sur cinq commence à fumer régulièrement dès l'âge de 13 ans; voir le rapport d'expert de Roberta G. Ferrence, *op. cit.*; «Project Plus/Minus», préparé pour Imperial Tobacco Ltd. (1982). En fait, on a estimé que les maladies causées par le tabac entraîneront six fois plus de décès prématurés chez les jeunes fumeurs canadiens que les accidents de voiture, le suicide, le meurtre et le SIDA confondus; voir le rapport d'expert de Donald T. Wigle, *op. cit.* Par ailleurs, il y a davantage de fumeurs chez les gens qui ont moins d'instruction. En 1986, 60 pour 100 des personnes n'ayant fait aucune étude secondaire fumaient à tous les jours, contre seulement 8 pour 100 dans le

see expert report of Dr. Roberta G. Ferrence, *supra*, at p. 32.

It appears, then, that there is a significant gap between our understanding of the health effects of tobacco consumption and of the root causes of tobacco consumption. In my view, this gap raises a fundamental institutional problem that must be taken into account in undertaking the s. 1 balancing. Simply put, a strict application of the proportionality analysis in cases of this nature would place an impossible onus on Parliament by requiring it to produce definitive social scientific evidence respecting the root causes of a pressing area of social concern every time it wishes to address its effects. This could have the effect of virtually paralyzing the operation of government in the socio-economic sphere. As I noted in *McKinney*, *supra*, at pp. 304-5, predictions respecting the ramifications of legal rules upon the social and economic order are not matters capable of precise measurement, and are often "the product of a mix of conjecture, fragmentary knowledge, general experience and knowledge of the needs, aspirations and resources of society, and other components". To require Parliament to wait for definitive social science conclusions every time it wishes to make social policy would impose an unjustifiable limit on legislative power by attributing a degree of scientific accuracy to the art of government which, in my view, is simply not consonant with reality. As LeBel J.A. observed in the Court of Appeal (at pp. 311-12):

> Interpreted literally, mechanically, without nuance, the *Oakes* test and the burden of proof which it imposes on the state would most often negate its ability to legislate.

Moreover, such an approach misconceives the nature of a constitutional case such as this. It cannot be dealt with as if it were an ordinary civil trial. We are not dealing with a matter in which, for example, a particular litigant seeks to demonstrate that his tobacco consumption and the advertising of a manufacturer whose cigarettes

cas des diplômés d'université; voir le rapport d'expert de Roberta G. Ferrence, *op. cit.*, à la p. 32.

Il paraît alors y avoir un important écart entre ce 67
que nous comprenons des effets de l'usage du tabac sur la santé et des principales causes de cet usage. À mon avis, cet écart soulève un problème institutionnel fondamental dont il faut tenir compte dans la pondération effectuée en application de l'article premier. Bref, une application stricte de l'analyse de la proportionnalité dans les affaires de cette nature imposerait un fardeau impossible au Parlement puisqu'il serait alors tenu de produire des éléments de preuve socio-scientifiques concluants relativement aux causes fondamentales d'un problème urgent d'intérêt social chaque fois qu'il désire s'attaquer à ses effets. Cela aurait pour effet de pratiquement paralyser le fonctionnement de l'appareil gouvernemental dans la sphère socio-économique. Comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt *McKinney*, précité, aux pp. 304 et 305, les prévisions relatives aux incidences des règles juridiques sur l'ordre socio-économique ne sont pas des questions susceptibles d'être évaluées précisément, et découlent souvent «de la combinaison d'hypothèses, de connaissances fragmentaires, de l'expérience générale et de la connaissance des besoins, des aspirations et des ressources de la société ainsi que d'autres éléments». Si l'on exigeait du Parlement qu'il attende les données concluantes des études dans le domaine des sciences humaines chaque fois qu'il désire adopter une politique sociale, on restreindrait de façon injustifiable la compétence législative en attribuant un degré de précision scientifique à l'art de gouverner, ce qui, à mon avis, n'est tout simplement pas conforme à la réalité. Comme le juge LeBel de la Cour d'appel l'a fait remarquer (à la p. 391):

> Interprétés littéralement, mécaniquement, sans nuances, le test d'*Oakes* et le fardeau de preuve imposé ainsi à l'État nieraient, le plus souvent, à celui-ci la faculté de légiférer.

Par ailleurs, une telle approche se méprend sur la nature d'une affaire constitutionnelle comme celle-ci. Elle ne s'assimile pas à un simple procès civil. Nous ne sommes pas placés devant un dossier où un plaideur particulier tenterait, par hypothèse, de démontrer que, dans son cas, sa consommation de tabac et la publicité

he consumed caused his lung cancer or his emphysema. It is rather a question of determining the basis on which a legislator may choose to act, where the outcome is uncertain.

It is necessary to understand the limits and the nature of policy choices. It is often difficult to forecast the future and to anticipate the beneficial or negative consequences of government policy. A well-conceived policy may be poorly applied. The necessary institutional resources may fail; unforeseen obstacles may intervene. If one is to apply rigorously the criterion of civil proof on the balance of probabilities it will be impossible to govern. On this basis, it would not be possible to make difficult but sometimes necessary legislative choices. There would be conferred on the courts a supervisory role over a state itself essentially inactive.

68 In several recent cases, this Court has recognized the need to attenuate the *Oakes* standard of justification when institutional constraints analogous to those in the present cases arise. In *Irwin Toy*, *supra*, at pp. 993-94, this Court stated:

> . . . in matching means to ends and asking whether rights or freedoms are impaired as little as possible, a legislature mediating between the claims of competing groups will be forced to strike a balance without the benefit of absolute certainty concerning how that balance is best struck. Vulnerable groups will claim the need for protection by the government whereas other groups and individuals will assert that the government should not intrude.
>
> . . .
>
> When striking a balance between the claims of competing groups, the choice of means, like the choice of ends, frequently will require an assessment of conflicting scientific evidence and differing justified demands on scarce resources. Democratic institutions are meant to let us all share in the responsibility for these difficult choices. Thus, as courts review the results of the legislature's deliberations, particularly with respect to the protection of vulnerable groups, they must be mindful of the legislature's representative function. . . .
>
> In other cases, however, rather than mediating between different groups, the government is best characterized as the singular antagonist of the individual whose right has been infringed. For example, in justify-

faite par tel manufacturier dont il consommait les cigarettes ont causé son cancer du poumon ou son emphysème. Il s'agit plutôt de déterminer sur quelle base un législateur peut choisir d'agir, dans des perspectives incertaines.

Il faut comprendre les limites et la nature des choix politiques. Il est souvent difficile de prévoir l'avenir et d'anticiper les conséquences bénéfiques ou néfastes d'une politique gouvernementale. Bien conçue, une politique peut être mal appliquée. Les ressources institutionnelles nécessaires peuvent faire défaut, des obstacles imprévus survenir. Si l'on applique rigoureusement le critère de la preuve civile, selon la balance des probabilités, on ne gouvernera pas. L'on ne saura faire les choix législatifs difficiles, mais parfois nécessaires. L'on confiera à la magistrature la surveillance d'un état essentiellement passif.

Dans plusieurs arrêts récents, notre Cour a reconnu la nécessité d'assouplir le critère de justification formulé dans *Oakes* en présence de contraintes institutionnelles semblables à celles qui existent en l'espèce. Dans *Irwin Toy*, précité, aux pp. 993 et 994, notre Cour affirme:

> . . . en faisant correspondre les moyens et les fins, et en se demandant s'il a été porté le moins possible atteinte aux droits ou aux libertés, le législateur en arbitrant entre les revendications de groupes concurrents, sera encore obligé de trouver le point d'équilibre sans pouvoir être absolument certain d'où il se trouve. Les groupes vulnérables vont revendiquer la protection du gouvernement alors que les autres groupes et individus affirmeront que le gouvernement ne doit pas intervenir.
>
> . . .
>
> Pour trouver le point d'équilibre entre des groupes concurrents, le choix des moyens, comme celui des fins, exige souvent l'évaluation de preuves scientifiques contradictoires et de demandes légitimes mais contraires quant à la répartition de ressources limitées. Les institutions démocratiques visent à ce que nous partagions tous la responsabilité de ces choix difficiles. Ainsi, lorsque les tribunaux sont appelés à contrôler les résultats des délibérations du législateur, surtout en matière de protection de groupes vulnérables, ils doivent garder à l'esprit la fonction représentative du pouvoir législatif. . .
>
> Il arrive parfois qu'au lieu d'arbitrer entre des groupes différents, le gouvernement devienne plutôt ce qu'on pourrait appeler l'adversaire singulier de l'individu dont le droit a été violé. Par exemple, pour justifier

ing an infringement of legal rights enshrined in ss. 7 to 14 of the *Charter*, the state, on behalf of the whole community, typically will assert its responsibility for prosecuting crime whereas the individual will assert the paramountcy of principles of fundamental justice. There might not be any further competing claims among different groups. In such circumstances, and indeed whenever the government's purpose relates to maintaining the authority and impartiality of the judicial system, the courts can assess with some certainty whether the "least drastic means" for achieving the purpose have been chosen, especially given their accumulated experience in dealing with such questions. . . .

In drawing a distinction between legislation aimed at "mediating between different groups", where a lower standard of s. 1 justification may be appropriate, and legislation where the state acts as the "singular antagonist of the individual", where a higher standard of justification is necessary, the Court in *Irwin Toy* was drawing upon the more fundamental institutional distinction between the legislative and judicial functions that lies at the very heart of our political and constitutional system. Courts are specialists in the protection of liberty and the interpretation of legislation and are, accordingly, well placed to subject criminal justice legislation to careful scrutiny. However, courts are not specialists in the realm of policy-making, nor should they be. This is a role properly assigned to the elected representatives of the people, who have at their disposal the necessary institutional resources to enable them to compile and assess social science evidence, to mediate between competing social interests and to reach out and protect vulnerable groups. In according a greater degree of deference to social legislation than to legislation in the criminal justice context, this Court has recognized these important institutional differences between legislatures and the judiciary.

In my view, the considerations addressed by this Court in *Irwin Toy* and *McKinney*, *supra*, are applicable to the present cases. In enacting this legisla-

une atteinte à des droits consacrés par les art. 7 à 14 de la *Charte*, l'État fera valoir, au nom de toute la société, sa responsabilité de poursuivre les criminels alors que la personne fera valoir le caractère prépondérant des principes de justice fondamentale. Il est possible qu'il n'y ait pas de demandes contradictoires venant de différents groupes. Dans de tels cas, et d'ailleurs chaque fois que l'objet du gouvernement se rapporte au maintien de l'autorité et de l'impartialité du système judiciaire, les tribunaux peuvent décider avec un certain degré de certitude si les [TRADUCTION] «moyens les moins radicaux» ont été choisis pour parvenir à l'objectif compte tenu de la somme d'expérience acquise dans le règlement de ces questions . . .

En établissant une distinction entre une loi visant à «arbitrer entre des groupes différents», auquel cas un critère moins sévère pourrait être approprié relativement à la justification en vertu de l'article premier, et une loi dans laquelle l'État agit à titre d'«adversaire singulier de l'individu», auquel cas il faut appliquer un critère plus sévère, notre Cour, dans l'arrêt *Irwin Toy*, faisait appel à la distinction institutionnelle plus fondamentale entre les fonctions législatives et judiciaires, qui est à la base même de notre régime politique et constitutionnel. Les tribunaux sont des spécialistes de la protection de la liberté et de l'interprétation des lois et sont, en conséquence, bien placés pour faire un examen approfondi des lois en matière de justice criminelle. Cependant, ils ne sont pas des spécialistes de l'élaboration des politiques et ils ne devraient pas l'être. Ce rôle est celui des représentants élus de la population, qui disposent des ressources institutionnelles nécessaires pour recueillir et examiner la documentation en matière de sciences humaines, arbitrer entre des intérêts sociaux opposés et assurer la protection des groupes vulnérables. Lorsqu'elle fait preuve d'une plus grande retenue à l'égard des lois à caractère social qu'à l'égard des lois en matière de justice criminelle, notre Cour reconnaît ces différences institutionnelles importantes entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

À mon avis, les considérations que notre Cour a examinées dans les arrêts *Irwin Toy* et *McKinney*, précités, sont applicables en l'espèce. Lorsqu'il a 69

tion, Parliament was facing a difficult policy dilemma. On the one hand, Parliament is aware of the detrimental health effects of tobacco use, and has a legitimate interest in protecting Canadians from, and in informing them about, the dangers of tobacco use. Health underlies many of our most cherished rights and values, and the protection of public health is one of the fundamental responsibilities of Parliament. On the other hand, however, it is clear that a prohibition on the manufacture, sale or use of tobacco products is unrealistic. Nearly seven million Canadians use tobacco products, which are highly addictive. Undoubtedly, a prohibition of this nature would lead to an increase in illegal activity, smuggling and, quite possibly, civil disobedience. Well aware of these difficulties, Parliament chose a less drastic, and more incremental, response to the tobacco health problem. In prohibiting the advertising and promotion of tobacco products, as opposed to their manufacture or sale, Parliament has sought to achieve a compromise among the competing interests of smokers, non-smokers and manufacturers, with an eye to protecting vulnerable groups in society. Given the fact that advertising, by its very nature, is intended to influence consumers and create demand, this was a reasonable policy decision. Moreover, as I discussed above, the Act is the product of a legislative process dating back to 1969, when the first report recommending a full prohibition on tobacco advertising was published; see *Report of the Standing Committee on Health, Welfare and Social Affairs on Tobacco and Cigarette Smoking*, *supra*. In drafting this legislation, Parliament took into account the views of Canadians from many different sectors of society, representing many different interests. Indeed, the legislative committee responsible for drafting Bill C-51, which was subsequently adopted by Parliament as the Act, heard from 104 organizations during hearings in 1988 representing a variety of interests, including medicine, transport, advertising, smokers' rights, non-smokers' rights, and tobacco production.

adopté cette loi, le Parlement était aux prises avec un dilemme difficile. D'une part, il est bien au courant des effets nocifs de l'usage du tabac sur la santé et est légitimement fondé à protéger les Canadiens contre ses méfaits et à les y sensibiliser. La santé est à la base des droits et valeurs qui nous tiennent le plus à cœur, et la protection de la santé publique est l'une des responsabilités fondamentales du Parlement. D'autre part, cependant, il est clair qu'il n'est pas réaliste d'interdire la fabrication, la vente ou l'usage des produits du tabac. Presque sept millions de Canadiens font usage des produits du tabac, lesquels créent une forte dépendance. De toute évidence, une telle interdiction donnerait lieu à un accroissement des activités illégales, de la contrebande, voire même de la désobéissance civile. Fort conscient de ces difficultés, le Parlement a choisi des mesures moins radicales et plus graduelles pour répondre au problème du tabagisme. En interdisant la publicité et la promotion des produits du tabac, par opposition à leur fabrication ou à leur vente, il a tenté de parvenir à un compromis entre les intérêts opposés des fumeurs, des non-fumeurs et des fabricants, dans le but de protéger les groupes vulnérables de la société. Puisque la publicité vise intrinsèquement à influencer les consommateurs et à susciter la demande, la mesure prise constituait une décision de principe raisonnable. Par ailleurs, comme je l'ai déjà mentionné, la Loi est l'aboutissement du processus législatif commencé en 1969 au moment où était rendu public le premier rapport recommandant un bannissement total de la publicité des produits du tabac; voir le *Rapport du Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales sur l'usage du tabac et de la cigarette*, *op. cit.* Dans la rédaction de la Loi, le législateur a tenu compte du point de vue des Canadiens provenant de divers secteurs de la société, représentant tout un éventail d'intérêts. En effet, lors des audiences tenues en 1988, le comité responsable de la rédaction du projet de loi C-51, aujourd'hui devenu la Loi, a entendu les commentaires de 104 organisations représentant divers intérêts, notamment, médecine, transport, publicité, groupes de fumeurs, groupes de non-fumeurs et producteurs de tabac.

Seen in this way, it is clear that the Act is the very type of legislation to which this Court has generally accorded a high degree of deference. In drafting this legislation, which is directed toward a laudable social goal and is designed to protect vulnerable groups, Parliament was required to compile and assess complex social science evidence and to mediate between competing social interests. Decisions such as these are properly assigned to our elected representatives, who have at their disposal the necessary resources to undertake them, and who are ultimately accountable to the electorate. As I observed in *McKinney*, *supra*, at p. 305:

They are decisions of a kind where those engaged in the political and legislative activities of Canadian democracy have evident advantages over members of the judicial branch, as *Irwin Toy*, *supra*, at pp. 993-94, has reminded us. This does not absolve the judiciary of its constitutional obligation to scrutinize legislative action to ensure reasonable compliance with constitutional standards, but it does import greater circumspection than in areas such as the criminal justice system where the courts' knowledge and understanding affords it a much higher degree of certainty.

Turning now to the nature of the right infringed under the Act, it is once again necessary to place the appellants' claim in context. This Court has recognized, in a line of freedom of expression cases dating back to *Edmonton Journal*, *supra*, that, depending on its nature, expression will be entitled to varying levels of constitutional protection. In *Edmonton Journal*, Wilson J. outlined the need for a contextual, as opposed to an abstract, approach to freedom of expression cases. She stated, at pp. 1355-56:

. . . a particular right or freedom may have a different value depending on the context. It may be, for example, that freedom of expression has greater value in a political context than it does in the context of disclosure of the details of a matrimonial dispute. The contextual approach attempts to bring into sharp relief the aspect of the right or freedom which is truly at stake in the case as well as the relevant aspects of any values in competition

Vue sous cet angle, il est clair que la Loi est précisément le type de loi envers laquelle notre Cour a généralement fait preuve d'une grande retenue. Dans le cadre de la rédaction de cette loi, qui vise à atteindre un objectif social louable et à protéger les groupes vulnérables, le Parlement a dû recueillir et examiner des données sociales complexes et trancher entre des intérêts sociaux opposés. Le soin de prendre de telles décisions est confié comme il se doit à nos représentants élus, qui disposent des ressources nécessaires à cette fin et qui sont en dernier ressort responsables envers l'électorat. Comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt *McKinney*, précité, à la p. 305: 70

Ce sont des décisions où ceux qui participent aux activités politiques et législatives de la démocratie canadienne possèdent des avantages manifestes sur les membres du pouvoir judiciaire, comme nous l'a rappelé l'arrêt *Irwin Toy*, précité, aux pp. 993 et 994. Cela ne libère pas le pouvoir judiciaire de son obligation constitutionnelle d'examiner minutieusement les mesures législatives pour veiller à ce qu'elles se conforment raisonnablement aux normes constitutionnelles, mais cela entraîne une plus grande circonspection que dans des domaines comme le système de justice criminelle où le savoir et le discernement de la cour lui permettent de se prononcer de façon beaucoup plus sûre.

Je passe maintenant à l'examen de la nature du droit auquel il a été porté atteinte; de nouveau, il est nécessaire de placer dans son contexte la demande des appelantes. Dans une série d'arrêts sur la liberté d'expression rendus depuis *Edmonton Journal*, précité, notre Cour a reconnu que, selon sa nature, l'expression pourra bénéficier de divers degrés de protection constitutionnelle. Dans l'arrêt *Edmonton Journal*, le juge Wilson a exposé la nécessité du recours à une méthode contextuelle, et non abstraite, dans l'examen des questions de liberté d'expression. Elle affirme aux pp. 1355 et 1356: 71

. . . une liberté ou un droit particuliers peuvent avoir une valeur différente selon le contexte. Par exemple, il se peut que la liberté d'expression ait une importance plus grande dans un contexte politique que dans le contexte de la divulgation des détails d'une affaire matrimoniale. La méthode contextuelle tente de mettre clairement en évidence l'aspect du droit ou de la liberté qui est véritablement en cause dans l'instance ainsi que les aspects

with it. It seems to be more sensitive to the reality of the dilemma posed by the particular facts and therefore more conducive to finding a fair and just compromise between the two competing values under s. 1.

In *Rocket*, *supra*, at pp. 246-47, McLachlin J. affirmed Wilson J.'s contextual approach:

> While the Canadian approach does not apply special tests to restrictions on commercial expression, our method of analysis does permit a sensitive, case-oriented approach to the determination of their constitutionality. Placing the conflicting values in their factual and social context when performing the s. 1 analysis permits the courts to have regard to special features of the expression in question. As Wilson J. notes in *Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General)*, [1989] 2 S.C.R. 1326, not all expression is equally worthy of protection. Nor are all infringements of free expression equally serious.

72 The source of the "sensitive, case-oriented approach" referred to by McLachlin J. in *Rocket* is this Court's more fundamental recognition that the right to freedom of expression is not absolute and cannot, in all cases, override other rights and values. Although freedom of expression is undoubtedly a fundamental value, there are other fundamental values that are also deserving of protection and consideration by the courts. When these values come into conflict, as they often do, it is necessary for the courts to make choices based not upon an abstract, platonic analysis, but upon a concrete weighing of the relative significance of each of the relevant values in our community in the specific context. This the Court has done by weighing freedom of expression claims in light of their relative connection to a set of even more fundamental values. In *Keegstra*, *supra*, at pp. 762-63, Dickson C.J. identified these fundamental or "core" values as including the search for political, artistic and scientific truth, the protection of individual autonomy and self-development, and the promotion of public participation in the democratic process. When state action places such values in jeopardy,

pertinents des valeurs qui entrent en conflit avec ce droit ou cette liberté. Elle semble mieux saisir la réalité du litige soulevé par les faits particuliers et être donc plus propice à la recherche d'un compromis juste et équitable entre les deux valeurs en conflit en vertu de l'article premier.

Dans l'arrêt *Rocket*, précité, aux pp. 246 et 247, le juge McLachlin a confirmé la méthode contextuelle formulée par le juge Wilson:

> Bien que la méthode canadienne ne consiste pas à appliquer des critères spéciaux aux restrictions imposées à l'expression commerciale, notre méthode d'analyse permet d'aborder la détermination de leur constitutionnalité avec sensibilité et en fonction de chaque cas particulier. En situant les valeurs contradictoires dans leur contexte factuel et social au moment de procéder à l'analyse fondée sur l'article premier, les tribunaux ont la possibilité de tenir compte des caractéristiques spéciales de l'expression en question. Comme le juge Wilson le fait remarquer dans *Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général)*, [1989] 2 R.C.S. 1326, ce ne sont pas toutes les expressions qui méritent la même protection. Toutes les violations de la liberté d'expression ne sont pas également graves.

La source de l'examen à faire «avec sensibilité et en fonction de chaque cas particulier», dont parle le juge McLachlin dans l'arrêt *Rocket*, est la reconnaissance plus fondamentale par notre Cour que le droit à la liberté d'expression n'est pas absolu et ne peut, dans tous les cas, l'emporter sur les autres droits et libertés. Bien que la liberté d'expression constitue indubitablement une valeur fondamentale, il existe d'autres valeurs fondamentales qui méritent aussi d'être protégées et examinées par les tribunaux. En cas de conflit entre ces valeurs, comme cela se produit souvent, les tribunaux sont appelés à faire des choix fondés non pas sur une analyse abstraite, platonicienne, mais sur une appréciation concrète de l'importance relative de chacune des valeurs pertinentes dans notre collectivité dans le contexte en question. C'est ce que notre Cour a fait en examinant les demandes touchant le droit à la liberté d'expression en fonction du lien relatif qu'elles ont avec des valeurs encore plus fondamentales. Dans l'arrêt *Keegstra*, précité, aux pp. 762 et 763, le juge en chef Dickson a identifié ces valeurs fondamentales ou se trouvant au «cœur» d'une garantie comme incluant la décou-

this Court has been careful to subject it to a searching degree of scrutiny. However, when the form of expression placed in jeopardy falls farther from the "centre core of the spirit", this Court has ruled restrictions on such expression less difficult to justify. As Dickson C.J. observed in *Keegstra*, *supra*, at p. 760:

> In my opinion, however, the s. 1 analysis of a limit upon s. 2(*b*) cannot ignore the nature of the expressive activity which the state seeks to restrict. While we must guard carefully against judging expression according to its popularity, it is equally destructive of free expression values, as well as the other values which underlie a free and democratic society, to treat all expression as equally crucial to those principles at the core of s. 2(*b*).

In cases where the expression in question is farther from the "core" of freedom of expression values, this Court has applied a lower standard of justification. For example, in *Keegstra*, where a majority of this Court ruled that a prohibition on hate speech under s. 319(2) of the *Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, was a justifiable limitation on freedom of expression, Dickson C.J. found that this limited infringement was justified because hate propaganda was a form of expression that was only remotely related to "core" free expression values. He noted, at p. 766:

> . . . I am of the opinion that hate propaganda contributes little to the aspirations of Canadians or Canada in either the quest for truth, the promotion of individual self-development or the protection and fostering of a vibrant democracy where the participation of all individuals is accepted and encouraged. While I cannot conclude that hate propaganda deserves only marginal protection under the s. 1 analysis, I can take cognizance of the fact that limitations upon hate propaganda are directed at a

verte de la vérité dans les affaires politiques et dans les entreprises scientifiques et artistiques, la protection de l'autonomie et de l'enrichissement personnels et la promotion de la participation du public au processus démocratique. Lorsque les mesures gouvernementales menacent ces valeurs, notre Cour a pris soin d'en faire un examen rigoureux. Toutefois, lorsque la forme d'expression menacée s'écarte beaucoup de l'«esprit même» de la garantie, notre Cour a statué que les restrictions à cette expression sont moins difficiles à justifier. Comme le juge en chef Dickson l'a fait remarquer dans *Keegstra*, précité, à la p. 760:

> À mon avis, toutefois, l'analyse en vertu de l'article premier d'une restriction imposée à l'al. 2*b*) doit tenir compte de la nature de l'activité expressive que l'État cherche à restreindre. Si nous devons veiller à ne pas juger l'expression en fonction de sa popularité, il est tout aussi néfaste pour les valeurs inhérentes à la liberté d'expression, et pour les autres valeurs sous-jacentes à une société libre et démocratique, de considérer que toutes les sortes d'expressions revêtent la même importance au regard des principes qui sont au cœur de l'al. 2*b*).

Dans les cas où l'expression en question s'écarte 73
beaucoup des valeurs au «cœur» de la liberté d'expression, notre Cour a appliqué une norme de justification moins sévère. Par exemple, dans l'arrêt *Keegstra*, dans lequel notre Cour à la majorité a statué qu'une interdiction de fomentation de la haine fondée sur le par. 319(2) du *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, constituait une restriction justifiable de la liberté d'expression, le juge en chef Dickson a statué que cette atteinte limitée était justifiée parce que la propagande haineuse constituait une forme d'expression qui ne se rattachait que vaguement au «cœur» des valeurs de la liberté d'expression. Il a fait remarquer, à la p. 766:

> . . . je suis d'avis que la propagande haineuse apporte peu aux aspirations des Canadiens ou du Canada, que ce soit dans la recherche de la vérité, dans la promotion de l'épanouissement personnel ou dans la protection et le développement d'une démocratie dynamique qui accepte et encourage la participation de tous. Si je ne puis conclure que la propagande haineuse ne mérite qu'une protection minimale dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier, je peux néanmoins recon-

special category of expression which strays some distance from the spirit of s. 2(*b*), and hence conclude that "restrictions on expression of this kind might be easier to justify than other infringements of s. 2(*b*)". . . .

74 This Court adopted a similar approach in *R. v. Butler*, [1992] 1 S.C.R. 452, where it found a prohibition upon publications whose dominant characteristic was the "undue exploitation of sex" under s. 163(8) of the *Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, to be a justifiable infringement upon freedom of expression. In so ruling, this Court found it significant, at p. 500, that "the kind of expression which is sought to be advanced does not stand on an equal footing with other kinds of expression which directly engage the 'core' of the freedom of expression values". The expression targeted by s. 163(8) was pornography, which is designed to promote sex for profit, and thus fell far from the "core" of freedom of expression values discussed by Dickson C.J. in *Keegstra*. The Court has adopted a similar approach with respect to prostitution, which was also accorded a lower level of protection in the *Prostitution Reference*, *supra*. In that case, Dickson C.J. stated, at p. 1136:

> When a *Charter* freedom has been infringed by state action that takes the form of criminalization, the Crown bears the heavy burden of justifying that infringement. Yet, the expressive activity, as with any infringed *Charter* right, should also be analyzed in the particular context of the case. Here, the activity to which the impugned legislation is directed is expression with an economic purpose. It can hardly be said that communications regarding an economic transaction of sex for money lie at, or even near, the core of the guarantee of freedom of expression.

75 In my view, the harm engendered by tobacco, and the profit motive underlying its promotion, place this form of expression as far from the "core" of freedom of expression values as prostitu-

naître le fait que les restrictions imposées à la propagande haineuse visent une catégorie particulière d'expression qui s'écarte beaucoup de l'esprit même de l'al. 2*b*). Je conclus donc qu'«il se pourrait que des restrictions imposées à des expressions de ce genre soient plus faciles à justifier que d'autres atteintes à l'al. 2*b*)». . .

Notre Cour a adopté une analyse similaire dans l'arrêt *R. c. Butler*, [1992] 1 R.C.S. 452, dans lequel elle a statué qu'une interdiction touchant des publications dont une caractéristique dominante était «l'exploitation indue des choses sexuelles» en contravention du par. 163(8) du *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, constituait une atteinte justifiable à la liberté d'expression. Ce faisant, notre Cour a considéré comme important, à la p. 500, que «le genre d'expression que l'on cherche à promouvoir n'est pas du même calibre que les autres genres d'expression qui touchent directement à l'«essence» des valeurs relatives à la liberté d'expression». L'expression visée par le par. 163(8) était la pornographie, laquelle vise à promouvoir le sexe contre un profit, ce qui s'écarte des valeurs au «cœur» de la liberté d'expression analysées par le juge en chef Dickson dans l'arrêt *Keegstra*. Notre Cour a adopté une analyse similaire relativement à la prostitution, à laquelle elle a également accordé une protection moindre dans le *Renvoi sur la prostitution*, précité. Dans cette affaire, le juge en chef Dickson affirme aux pp. 1135 et 1136:

> Lorsqu'une liberté garantie par la *Charte* a été violée par une mesure prise par l'État, en l'occurrence la criminalisation, le ministère public doit s'acquitter du lourd fardeau de justifier cette violation. Néanmoins, comme dans le cas de toute violation d'un droit reconnu par la *Charte*, l'activité d'expression devrait également être analysée dans le contexte particulier de l'affaire. En l'espèce, l'activité visée par la disposition législative contestée est une expression ayant un but économique. On peut difficilement affirmer que les communications relatives à l'opération économique d'échange de services sexuels pour de l'argent relèvent, ou même se rapprochent, de l'essence de la garantie de la liberté d'expression.

À mon avis, le préjudice engendré par le tabac, et la volonté de faire des profits qui en sous-tend la promotion, placent cette forme d'expression aussi loin du «cœur» des valeurs de la liberté d'expres-

tion, hate mongering, or pornography, and thus entitle it to a very low degree of protection under s. 1. It must be kept in mind that tobacco advertising serves no political, scientific or artistic ends; nor does it promote participation in the political process. Rather, its sole purpose is to inform consumers about, and promote the use of, a product that is harmful, and often fatal, to the consumers who use it. The main, if not sole, motivation for this advertising is, of course, profit. The sale of tobacco products in Canada generates enormous profits for the three companies who dominate the market (RJR, Imperial and Rothmans, Benson & Hedges Inc.). In 1992, for example, earnings from Imperial's operations alone reached $432,000,000 (Earnings from operations (Tobacco) in Note 31 (Segmented financial information) in "Notes to the Consolidated Financial Statements", at p. 48 of Imasco *Annual Report 1992* and "Six Year Review" in Imasco *Annual Report 1992*, at pp. 52-53).

sion que la prostitution, la fomentation de la haine ou la pornographie, ce qui fait qu'elle n'a droit qu'à une faible protection en vertu de l'article premier. Il faut se rappeler que la publicité du tabac ne sert aucune fin politique, scientifique ou artistique et qu'elle ne favorise pas la participation au processus politique. Son seul but est plutôt de renseigner les consommateurs sur un produit qui est nocif, voire souvent fatal, pour ceux qui en font usage, et d'en faire la promotion. Le principal, sinon le seul motif de la publicité est, bien entendu, le profit. La vente des produits du tabac au Canada génère d'énormes profits pour les trois compagnies qui dominent le marché (RJR, Imperial et Rothmans, Benson & Hedges Inc.). Par exemple, en 1992, les revenus d'exploitation d'Imperial seulement se sont élevés à 432 000 000 $ (Bénéfice des activités d'exploitation (Tabac), dans Note 31 (Information financière sectorielle) dans «Notes complémentaires des exercices», à la p. 48, Imasco, *Rapport annuel 1992*, et «Revue des six dernières années» dans Imasco, *Rapport annuel 1992*, aux pp. 52 et 53).

The appellants, both of whom are large multinational corporations, spend millions of dollars every year to promote their products (in 1987 alone, RJR and Imperial spent over $75 million dollars on advertising and promotion); see RJR-MacDonald Inc., "Advertising and Promotion Spending (CND$)" (1976-1987); Imperial Tobacco Ltd., "Domestic Advertising Expense Summary" (1982-1987). The large sums these companies spend on advertising allow them to employ the most advanced advertising and social psychology techniques to convince potential buyers to buy their products. The sophistication of the advertising campaigns employed by these corporations, in my view, undermines their claim to freedom of expression protection because it creates an enormous power differential between these companies and tobacco consumers in the "marketplace of ideas". As noted by M. L. Rothschild in *Advertising: From Fundamentals to Strategies* (1987), at p. 8, and cited in Dr. Richard W. Pollay, "The

76

Les appelantes, toutes deux d'importantes multinationales, dépensent des millions de dollars chaque année pour faire la promotion de leurs produits (en 1987 seulement, RJR et Imperial ont dépensé plus de 75 millions de dollars au titre de la publicité et de la promotion); voir RJR-MacDonald Inc., «Advertising and Promotion Spending CND$» (1976-1987); Imperial Tobacco Ltd., «Domestic Advertising Expense Summary» (1982-1987). Vu les sommes importantes que ces compagnies consacrent à la publicité, elles sont en mesure de recourir aux techniques les plus avancées dans le domaine de la publicité et des sciences psychosociales pour convaincre d'éventuels acheteurs. À mon avis, la complexité même des campagnes publicitaires menées par ces compagnies ne les aide pas lorsqu'elles demandent que soit protégée leur liberté d'expression, du fait que ces campagnes créent un important déséquilibre des forces entre ces sociétés et les consommateurs des produits du tabac dans le «marché des idées». Comme l'a fait remarquer M. L. Rothschild dans *Advertising: From Fundamentals to Strategies* (1987), à la p. 8, et cité dans l'ouvrage de Richard W. Pollay,

Functions and Management of Cigarette Advertising", Report, prepared July 27, 1989, at p. 2:

Advertising is salesmanship, and is paid for by a firm, a person or a group with a particular point of view. The message advocates that point of view, and its goal is to create awareness, attitude, or behaviour that is favorable to that advocacy position. The message attempts to inform and to persuade; it is intentionally biased, and there is no intent to present a balanced point of view.

The power differential between advertiser and consumer is even more pronounced with respect to children who, as this Court observed in *Irwin Toy*, at p. 987, are "particularly vulnerable to the techniques of seduction and manipulation abundant in advertising"; see, e.g., expert report of Dr. Michael J. Chandler, "A Report on the Special Vulnerabilities of Children and Adolescents" (1989), at p. 19; expert report of Simon Chapman and Bill Fitzgerald, "Brand Preference and Advertising Recall in Adolescent Smokers: Some Implications for Health Promotion" (1982), 72 *Am. J. Pub. Health* 491; Gerald J. Gorn and Renée Florsheim, "The Effects of Commercials for Adult Products on Children" (1985), 11 *J. Consumer Res.* 962. In this respect, it is critical to keep in mind Dickson C.J.'s reminder in *Edwards Books*, *supra*, at p. 779:

In interpreting and applying the *Charter* I believe that the courts must be cautious to ensure that it does not simply become an instrument of better situated individuals to roll back legislation which has as its object the improvement of the condition of less advantaged persons.

77 I conclude, therefore, that an attenuated level of s. 1 justification is appropriate in these cases. Taking into account both the nature of the right and the nature of the legislation in issue, I am satisfied that LeBel J.A. was correct in deciding that the Attorney General need only demonstrate that Parliament had a rational basis for introducing the measures contained in this Act. With these observations firmly in mind, I now proceed to an application of the proportionality test.

«The Functions and Management of Cigarette Advertising», Rapport, 27 juillet 1989, à la p. 2:

[TRADUCTION] La publicité est l'art de vendre; elle est financée par une firme, une personne ou un groupe ayant un point de vue particulier. Le message prône ce point de vue et son objectif est de sensibiliser, de créer un intérêt ou d'établir un comportement qui est favorable à la position avancée. Le message tente d'informer et de persuader, il est intentionnellement partial; il ne s'agit aucunement de présenter un point de vue équilibré.

Le déséquilibre des forces entre le publicitaire et le consommateur est encore plus marqué dans le cas des enfants qui, comme l'a affirmé notre Cour dans l'arrêt *Irwin Toy*, à la p. 987, sont «particulièrement vulnérable[s] aux nombreuses techniques de séduction et de manipulation de la publicité»; voir le rapport d'expert de Michael J. Chandler, «A Report on the Special Vulnerabilities of Children and Adolescents» (1989), à la p. 19; le rapport d'expert de Simon Chapman et Bill Fitzgerald, «Brand Preference and Advertising Recall in Adolescent Smokers: Some Implications for Health Promotion» (1982), 72 *Am. J. Pub. Health* 491, et Gerald J. Gorn et Renée Florsheim, «The Effects of Commercials for Adult Products on Children» (1985), 11 *J. Consumer Res.* 962. À cet égard, il est essentiel de se rappeler la mise en garde du juge en chef Dickson dans *Edwards Books*, précité, à la p. 779:

Je crois que lorsqu'ils interprètent et appliquent la *Charte*, les tribunaux doivent veiller à ce qu'elle ne devienne pas simplement l'instrument dont se serviront les plus favorisés pour écarter des lois dont l'objet est d'améliorer le sort des moins favorisés.

Par conséquent, je conclus qu'il convient en l'espèce de faire preuve de souplesse dans la justification au regard de l'article premier. Compte tenu de la nature du droit et de celle de la loi en cause, je suis convaincu que le juge LeBel de la Cour d'appel a eu raison de décider que le procureur général n'avait qu'à établir que le Parlement avait un motif rationnel de déposer les mesures contenues dans la Loi. En gardant fermement ces observations à l'esprit, je procède maintenant à une application du critère de la proportionnalité.

Proportionality

As I mentioned at the outset of my *Charter* discussion, the appellants rely heavily on Chabot J.'s factual findings in support of their argument that the measures employed under the Act are not proportional to the objective of reducing tobacco consumption. Briefly, Chabot J.'s principal factual findings at trial were as follows. With respect to a rational connection between the measures adopted under the Act and the objective of reducing tobacco consumption, he found, at p. 512, that "the connection which the state seeks to establish between health protection and tobacco advertising is tenuous and speculative" and, at p. 513, that "[t]he virtual totality of the scientific documents in the state's possession at the time the Act was passed do not demonstrate that a ban on advertising would affect consumption". With respect to whether the measures impair rights as little as possible, Chabot J. concluded, at pp. 515-16, as follows:

> To the extent that the purpose of the law is to eliminate any message constituting an inducement addressed to any Canadian citizen, the only means to achieve this is necessarily a total ban on such messages. To the extent that the purpose is to protect young people from inducements to smoke, a total ban on all advertising of any kind, directed at any audience, goes far beyond that purpose. Likewise, if the objective is to enhance Canadians' awareness of the harmful effects of cigarettes, the total ban on advertising is out of all proportion to the objective, while the imposition of unattributed messages goes beyond what was necessary to achieve the objective, all the more so as there is no impact study on the effectiveness of these unattributed messages as compared to messages attributed to the Department of National Health and Welfare.

Finally, with respect to the proportionality between effects and objectives, Chabot J. found, at p. 517, that the Act constituted "social engineering" which was an "extremely serious impairment of the principles inherent in a free and democratic society which is disproportionate to the objective of the [Act]".

In my view, Chabot J. erred in finding that there was insufficient evidence to satisfy the proportionality requirement, and the majority of the Court of

Proportionnalité

78 Comme je l'ai mentionné au début de mon analyse fondée sur la *Charte*, les appelantes s'appuient fortement sur les conclusions de fait du juge Chabot pour soutenir que les mesures employées en vertu de la Loi ne sont pas proportionnelles à l'objectif de réduire l'usage du tabac. Voici un bref résumé des principales conclusions de fait du juge Chabot. En ce qui concerne l'existence d'un lien rationnel entre les mesures adoptées en vertu de la Loi et l'objectif de réduire l'usage du tabac, il a conclu, à la p. 2308, que «le lien que l'État cherche à établir entre la protection de la santé et la publicité des produits du tabac est ténu et aléatoire» et que «[l]a presque totalité de la documentation scientifique en possession de l'État lors de l'adoption de la loi ne démontrait pas que le bannissement de la publicité aurait un effet sur la consommation» (p. 2309). Quant à savoir si les mesures constituent une atteinte minimale aux droits, le juge Chabot a ajouté, à la p. 2311:

> Dans la mesure où l'objectif de la loi est d'éliminer tout message incitatif auprès de tout citoyen canadien, la seule manière d'y arriver, c'est nécessairement d'interdire en totalité ces messages. Dans la mesure où l'objectif est de protéger les jeunes contre les incitatifs à fumer, l'interdiction totale de toute forme et de toute publicité dirigée à tout auditoire dépasse largement l'objectif. Pareillement, si l'objectif est de sensibiliser les Canadiens aux méfaits de la cigarette, l'interdiction totale de la publicité est sans commune mesure avec l'objectif, alors que l'imposition de messages non attribués dépasse ce qui était nécessaire pour atteindre l'objectif, d'autant plus qu'il n'y a aucune étude d'impact sur la valeur de ces messages non attribués par rapport aux messages attribués au ministère de la Santé.

Enfin, relativement au critère de la proportionnalité entre les effets et les objectifs, le juge Chabot a estimé à la p. 2312 que la Loi était un genre «d'ingénierie sociale» qui constitue «une atteinte extrêmement grave aux principes inhérents d'une société libre et démocratique, incommensurable avec l'objectif de la [Loi]».

79 À mon avis, le juge Chabot a commis une erreur lorsqu'il a décidé que la preuve n'était pas suffisante pour satisfaire au critère de la proportionna-

Appeal was correct to interfere with his findings and reevaluate the evidence. It is, of course, well-established that an appellate court may only interfere with the factual findings of a trial judge where the trial judge made a manifest error and where that error influenced the trial judge's final conclusion or overall appreciation of the evidence; see *Dorval v. Bouvier*, [1968] S.C.R. 288; *Lapointe v. Hôpital Le Gardeur*, [1992] 1 S.C.R. 351, at p. 358. However, it is important to emphasize that the trial findings on which the appellants rely are not the type of factual findings that fall within the general rule of appellate "non-interference" discussed in these cases. The appellate "non-interference" rule reflects the traditional recognition that a trial judge is better placed than an appellate court to assess and weigh so-called "adjudicative" facts or, in John Hagan's terms, "who did what, where, when, how and with what motive or intent"; see John Hagan, "Can Social Science Save Us? The Problems and Prospects of Social Science Evidence in Constitutional Litigation" in Robert J. Sharpe, ed., *Charter Litigation* (1987), at p. 215. Fauteux J. explained the rationale for the non-interference rule in *Dorval*, *supra*, at p. 293, as follows:

[TRANSLATION] Because of the privileged position of the judge who presides at the trial, who sees and hears the parties and witnesses and who assesses their evidence, it is an established principle that his opinion is to be treated with the utmost deference by the appellate court, whose duty it is not to retry the case nor to interfere by substituting its own assessment of the evidence for that of the trial judge, except in the case of a clear error on the face of the reasons of the judgment appealed from.

However, the privileged position of the trial judge does not extend to the assessment of "social" or "legislative" facts that arise in the law-making process and require the legislature or a court to assess complex social science evidence and to draw general conclusions concerning the effect of legal rules on human behaviour. As Ann Woolhandler observes in "Rethinking the Judicial Reception of

lité, et la Cour d'appel à la majorité a eu raison de modifier les déterminations du juge Chabot et de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve. Il est, évidemment, bien établi qu'une cour d'appel ne peut modifier les conclusions de fait d'un juge de première instance, sauf si celui-ci a commis une erreur manifeste qui a influencé sa conclusion définitive ou encore son appréciation globale de la preuve; voir *Dorval c. Bouvier*, [1968] R.C.S. 288; *Lapointe c. Hôpital Le Gardeur*, [1992] 1 R.C.S. 351, à la p. 358. Cependant, il est important de souligner que les conclusions de fait du juge de première instance, que font valoir les appelantes, ne sont pas du type de celles qui seraient visées par la règle générale de «non-intervention» en appel examinée dans les arrêts que je viens de mentionner. La règle de «non-intervention» en appel reflète la règle traditionnelle selon laquelle un juge de première instance est en meilleure position qu'une cour d'appel pour évaluer et pondérer des faits dits «en litige» ou pour déterminer, selon les termes employés par John Hagan, [TRADUCTION] «qui a fait quoi, où, quand, comment et pour quel motif ou dans quelle intention»; voir John Hagan, «Can Social Science Save Us? The Problems and Prospects of Social Science Evidence in Constitutional Litigation» dans Robert J. Sharpe, dir., *Charter Litigation* (1987), à la p. 215. Le juge Fauteux a expliqué la raison d'être de la règle de non-intervention dans l'arrêt *Dorval*, précité à la p. 293:

En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l'opinion de celui-ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d'appel et que le devoir de celle-ci n'est pas de refaire le procès, ni d'intervenir pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu'une erreur manifeste n'apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d'appel.

Cependant, la situation privilégiée du juge de première instance ne va pas jusqu'à faire l'appréciation des faits «sociaux» ou «législatifs» qui se rattachent au processus législatif et obligent une législature ou un tribunal à procéder à l'appréciation de données complexes en sciences humaines et à tirer des conclusions générales sur l'effet des règles de droit sur le comportement humain.

Legislative Facts" (1988), 41 *Vand. L. Rev.* 111, at pp. 114 and 123, conclusions of this nature are most accurately characterized as social or legislative facts because they involve predictions about the social effects of legal rules, which are invariably subject to dispute:

> In contrast to adjudicative facts, legislative facts do not presume a pre-existing legal norm because by definition such facts are used to create law. A paradigmatic legislative fact is one that shows the general effect a legal rule will have, and is presented to encourage the decisionmaker to make a particular legal rule. There is less a sense that legislative facts are true or knowable because such facts are predictions, and, moreover, typically predictions about the relative importance of one factor in causing a complex phenomenon.
>
> . . .
>
> Legislative facts are predictions about the effects of legal rules and are by their nature disputable. The creation and reception of legislative facts will be governed by pre-existing presumptions about desirable effects and their causes. Legislative facts, moreover, cannot neutrally provide answers to legal questions because by definition legislative facts are used to make the rules that pose the questions. Although legislative facts provide information for the pragmatic balancing of desirable effects, these "facts" cannot tell us what effects are desirable, or how to weigh them.

In my view, the causal connection between tobacco advertising and consumption, or the lack thereof, is a paradigm example of a legislative or social fact. While a trial judge is in a privileged position with respect to adjudicative fact-finding, this is not the case with legislative or social fact-finding, where appellate courts and legislatures are as well placed as trial judges to make findings. Certainly, one does not have to be a trial judge to come to general conclusions about the effect of legal rules on human behaviour. Moreover, given the intimate relation that exists between legislative facts and the creation of legal rules, there is also a strong policy reason for suspending the non-interference rule with respect to legislative or social

Comme Ann Woolhandler le fait remarquer dans «Rethinking the Judicial Reception of Legislative Facts» (1988), 41 *Vand. L. Rev.* 111, aux pp. 114 et 123, de telles conclusions peuvent être plus précisément qualifiées de faits sociaux ou législatifs parce qu'elles portent sur des prédictions quant aux effets sociaux des règles de droit, lesquelles font immanquablement l'objet de débats:

> [TRADUCTION] Contrairement aux faits en litige, les faits législatifs ne supposent pas une norme juridique préexistante parce que, par définition, ces faits servent à l'établissement de lois. Un fait législatif de nature paradigmatique est un fait qui établit l'effet général d'une règle de droit, et qui vise à inciter le décideur à adopter une règle de droit particulière. On a moins l'impression que les faits législatifs sont exacts ou connaissables parce que ces faits sont des prédictions et, plus précisément, des prédictions qui portent généralement sur l'importance relative d'un facteur à l'intérieur d'un phénomène complexe.
>
> . . .
>
> Les faits législatifs sont des prédictions sur les effets des règles de droit et sont, de par leur nature, contestables. La constitution et l'admission des faits législatifs seront régies par les présomptions existantes sur les effets souhaitables et leurs causes. Par ailleurs, les faits législatifs ne peuvent fournir de réponses objectives aux questions de droit parce que, par définition, ces faits sont utilisés aux fins de l'adoption des règles qui suscitent les questions. Bien que les faits législatifs renseignent sur la pondération pragmatique des effets souhaitables, ces «faits» ne peuvent nous dire quels sont les effets souhaitables ou comment il faut en faire l'appréciation.

À mon avis, l'existence ou l'inexistence d'un lien causal entre la publicité et l'usage du tabac est un exemple paradigmatique d'un fait législatif ou social. Bien qu'un juge de première instance soit dans une situation privilégiée relativement à l'appréciation des faits en litige, il ne l'est pas dans le cas de faits législatifs ou sociaux, dont l'appréciation peut être aussi bien faite par une cour d'appel ou une législature que par un juge de première instance. De toute évidence, il n'est pas nécessaire d'être juge de première instance pour tirer des conclusions générales sur l'incidence des règles de droit sur le comportement humain. Par ailleurs, compte tenu de la relation étroite entre les faits législatifs et la création des règles de droit, il existe

80

facts. As Brian G. Morgan notes in "Proof of Facts in Charter Litigation" in *Charter Litigation*, *supra*, at p. 186, the rigid application of that rule would deny appellate courts their proper role in developing legal principles of general application:

> . . . where legislative and constitutional facts are considered and determined at the trial court level, it is important that reference to the traditional division between fact and law in fixing the scope of appellate review not lead the appellate court to treat as conclusive the findings of the trial judge. First, the traditional and accepted expertise of the trial court in determining adjudicative facts does not extend to the less familiar and inherently less certain task of determining legislative or constitutional facts. Secondly, unless the appellate courts retain sufficient discretion to review findings of the trial court on matters of legislative or constitutional facts, the appellate courts will be denied their proper role of developing principles in this area of the law to be applied in the multitude of individual cases which come before trial judges.

The United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, in *Dunagin v. City of Oxford, Mississippi*, 718 F.2d 738 (1983) (*en banc*), cert. denied, 467 U.S. 1259 (1984), a case involving the constitutionality of a ban on liquor advertising, made the same point, at pp. 748-49, n. 8, in slightly more colourful terms:

> There are limits to which important constitutional questions should hinge on the views of social scientists who testify as experts at trial. Suppose one trial judge sitting in one state believes a sociologist who has found no link between alcohol abuse and advertising, while another trial judge sitting in another state believes a psychiatrist who has reached the opposite conclusion. A similar situation actually occurred here. Should identical conduct be constitutionally protected in one jurisdiction

également un solide motif de principe de suspendre l'application de la règle de non-intervention relativement aux faits législatifs ou sociaux. Comme Brian G. Morgan le fait remarquer dans «Proof of Facts in Charter Litigation» dans *Charter Litigation*, *op. cit.*, à la p. 186, l'application rigide de cette règle empêcherait les cours d'appel de s'acquitter du rôle qui leur incombe d'élaborer des principes de droit d'application générale:

> [TRADUCTION] . . . lorsque des faits législatifs et des faits de nature constitutionnelle sont examinés et tranchés en première instance, il est important que la mention de la distinction traditionnelle entre un fait et une règle de droit, aux fins de la détermination de l'étendue de l'examen en appel, ne mène pas la cour d'appel à considérer comme définitives les conclusions du juge de première instance. Premièrement, l'expertise traditionnelle et reconnue du tribunal de première instance dans l'appréciation des faits en litige n'englobe pas la tâche moins connue et moins certaine en soi de l'appréciation des faits législatifs ou de nature constitutionnelle. Deuxièmement, à moins qu'une cour d'appel conserve un pouvoir discrétionnaire suffisant pour réviser les conclusions prononcées en première instance sur des questions relatives à des faits législatifs ou de nature constitutionnelle, elle ne pourra s'acquitter du rôle qu'elle a d'élaborer dans ce domaine du droit des principes qui devront être appliqués dans les nombreux dossiers dont sont saisis les juges de première instance.

Dans l'arrêt *Dunagin c. City of Oxford, Mississippi*, 718 F.2d 738 (1983) (*en banc*), cert. refusé, 467 U.S. 1259 (1984), affaire portant sur la constitutionnalité d'une interdiction de publicité de boissons alcoolisées, la Court of Appeals for the Fifth Circuit des États-Unis a formulé la même observation, aux pp. 748 et 749, note 8, mais en des termes légèrement plus colorés:

> [TRADUCTION] Il y a une limite au règlement de questions constitutionnelles importantes en fonction des idées des spécialistes en sciences humaines qui témoignent comme expert en première instance. Supposons qu'un juge de première instance dans un État donne foi au témoignage d'un sociologue qui n'a pas établi de lien entre l'abus d'alcool et la publicité, alors qu'un autre juge dans un autre État donne foi au témoignage d'un psychiatre qui est arrivé à la conclusion contraire. Une

and illegal in another? Should the fundamental principles of equal protection delivered in *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483, 74 S.Ct. 686, 96 L.Ed. 873 (1954), be questioned if the sociological studies regarding racial segregation set out in the opinion's footnote 11 are shown to be methodologically flawed? Should the constitutionality of the property tax as a means of financing public education, resolved in *San Antonio Independent School District v. Rodriguez*, 411 U.S. 1, 93 S.Ct. 1278, 36 L.Ed.2d 16 (1973), depend on the prevailing views of educators and sociologists as to the existence of a cost-quality relationship in education? Does capital punishment become cruel and unusual when the latest regression models demonstrate a lack of deterrence? The social sciences play an important role in many fields, including the law, but other unscientific values, interests and beliefs are transcendent.

situation similaire s'est produite en l'espèce. Une conduite identique devrait-elle bénéficier d'une protection constitutionnelle dans un ressort et être illégale dans un autre? Les principes fondamentaux en matière d'égalité de protection formulés dans *Brown c. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483, 74 S.Ct. 686, 96 L.Ed. 873 (1954) devraient-ils être remis en question si les études sociologiques sur la ségrégation raciale, mentionnées au renvoi 11 de la décision, se révèlent incorrectes du point de vue méthodologique? La constitutionnalité de la taxe foncière comme moyen de financement de l'enseignement public, prononcée dans l'affaire *San Antonio Independent School District c. Rodriguez*, 411 U.S. 1, 93 S.Ct. 1278, 36 L.Ed.2d 16 (1973), devrait-elle dépendre des opinions courantes des éducateurs et des sociologues quant à l'existence d'un rapport coût-qualité dans l'enseignement? La peine capitale devient-elle un châtiment cruel et inusité dans le cas où les derniers modèles de régression établissent qu'elle n'a pas d'effet de dissuasion? Les sciences humaines jouent un rôle important dans de nombreux domaines, y compris le droit, mais d'autres valeurs, intérêts et croyances non scientifiques ont un rôle transcendant.

Perhaps for these reasons, the Supreme Court's recent commercial speech and other relevant speech cases indicate that appellate courts have considerable leeway in deciding whether restrictions on speech are justified. In none of them did the Court rely heavily on fact findings of the trial court.

C'est peut-être pour ces motifs que la Cour suprême, dans ses récents arrêts sur l'expression commerciale et dans ses décisions pertinentes sur la liberté d'expression, indique que les tribunaux d'appel jouissent d'une grande latitude lorsqu'ils décident si les restrictions à l'expression sont justifiées. La Cour suprême n'accorde d'ailleurs dans ces arrêts aucune grande importance aux conclusions de fait du juge de première instance.

For the foregoing reasons, I conclude that an appellate court may interfere with a finding of a trial judge respecting a legislative or social fact in issue in a determination of constitutionality whenever it finds that the trial judge erred in the consideration or appreciation of the matter. As applied to these cases, I find that, apart from his specific findings with respect to the credibility of witnesses and the probative value of reports, Chabot J.'s factual findings concerning the connection between tobacco advertising and consumption are entitled to minimal deference by this Court. With this in mind, I proceed to the proportionality analysis.

Pour les motifs qui précèdent, je conclus qu'une cour d'appel peut modifier une conclusion d'un juge de première instance concernant un fait législatif ou social en cause dans une détermination de la constitutionnalité lorsqu'elle décide que le juge de première instance a commis une erreur dans son examen ou son évaluation de la question. Si l'on applique cette conclusion aux présents pourvois, je suis d'avis que les conclusions de fait du juge Chabot relativement au lien entre la publicité en faveur des produits du tabac et l'usage du tabac, à l'exception toutefois de ses conclusions spécifiques sur la crédibilité des témoins et la valeur probante des rapports, donnent lieu à une retenue minimale de la part de notre Cour. Gardant ces considérations à l'esprit, je passe maintenant à l'analyse de la question de la proportionnalité. 81

Rational Connection

82 The first step in the proportionality analysis requires the government to demonstrate that the legislative means chosen under the Act are rationally connected to the objective of protecting public health by reducing tobacco consumption. As I explained in discussing the contextual nature of the s. 1 analysis, it is unnecessary in these cases for the government to demonstrate a rational connection according to a civil standard of proof. Rather, it is sufficient for the government to demonstrate that it had a reasonable basis for believing such a rational connection exists; see *McKinney*, *supra*, at pp. 282-85; *Irwin Toy*, *supra*, at p. 994; *Butler*, *supra*, at p. 502. Wilson J. summarized the standard of justification under the rational connection analysis in *Lavigne v. Ontario Public Service Employees Union*, [1991] 2 S.C.R. 211, at p. 291, as follows:

> The *Oakes* inquiry into "rational connection" between objectives and means to attain them requires nothing more than a showing that the legitimate and important goals of the legislature are logically furthered by the means government has chosen to adopt.

83 I note at the outset that there is, without question, a rational connection between a prohibition on the distribution of free samples of tobacco products under s. 7 and the protection of public health. Given the close correlation between price and demand in a free market economy, and the addictive nature of tobacco, it is self-evident that the availability of free tobacco will tend to increase consumption of that product. The appellants, however, base their argument principally upon the claim that there is no rational connection between the prohibition on advertising and promotion of tobacco products under ss. 4, 5, 6, and 8 and the objective of reducing tobacco consumption. In my view, the appellants' argument fails. Although the appellants observe, quite correctly, that there has not to date been a definitive study conducted with respect to the connection between tobacco advertising and tobacco consumption, I believe there was sufficient evidence adduced at trial to con-

Le lien rationnel

La première étape dans l'analyse de la proportionnalité exige que le gouvernement fasse la preuve que les moyens législatifs choisis ont un lien rationnel avec l'objectif de protéger la santé publique par la réduction de l'usage du tabac. Comme je l'ai expliqué dans mes motifs sur la nature contextuelle de l'analyse fondée sur l'article premier, il n'est pas nécessaire en l'espèce que le gouvernement fasse la preuve d'un lien rationnel selon les règles de preuve en matière civile. Il lui suffit plutôt de démontrer qu'il avait des motifs raisonnables de croire à l'existence d'un tel lien; voir *McKinney*, précité, aux pp. 282 à 285; *Irwin Toy*, précité, à la p. 994, et *Butler*, précité, à la p. 502. Dans *Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario*, [1991] 2 R.C.S. 211, le juge Wilson a résumé, à la p. 291, ce en quoi la justification doit consister dans l'analyse du lien rationnel:

> L'examen, proposé dans *Oakes*, du «lien rationnel» entre les objectifs et les moyens choisis pour les atteindre n'exige rien de plus que la démonstration que les moyens retenus par le gouvernement favorisent logiquement la réalisation des objectifs légitimes et importants du législateur.

Je constate, dès le départ, qu'il existe assurément un lien rationnel entre l'interdiction, en vertu de l'art. 7, de distribuer des échantillons gratuits de produits du tabac et la protection de la santé publique. Étant donné le rapport étroit entre le prix et la demande dans une économie de libre marché, de même que la nature toxicomanogène du tabac, il est tout à fait évident que la disponibilité de produits du tabac gratuits induira à une augmentation de leur consommation. Pour leur part, les appelantes, appuient leur argumentation principalement sur l'allégation qu'il n'y a aucun lien rationnel entre l'interdiction de la publicité et de la promotion des produits du tabac, en vertu des art. 4, 5, 6 et 8, et l'objectif de réduire la consommation du tabac. À mon avis, l'argumentation des appelantes ne peut être retenue. Bien que jusqu'à maintenant, comme le font remarquer avec raison les appelantes, il n'y ait jamais eu d'étude concluante sur le lien entre la publicité des produits du tabac et leur

clude that the objective of reducing tobacco consumption is logically furthered by the prohibition under the Act on both tobacco advertising and promotion.

I begin with what I consider to be a powerful common sense observation. Simply put, it is difficult to believe that Canadian tobacco companies would spend over 75 million dollars every year on advertising if they did not know that advertising increases the consumption of their product. In response to this observation, the appellants insist that their advertising is directed solely toward preserving and expanding brand loyalty among smokers, and not toward expanding the tobacco market by inducing non-smokers to start. In my view, the appellants' claim is untenable for two principal reasons. First, brand loyalty alone will not, and logically cannot, maintain the profit levels of these companies if the overall number of smokers declines. A proportionate piece of a smaller pie is still a smaller piece. As the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, observed in *Dunagin*, *supra*, at p. 749:

> It is beyond our ability to understand why huge sums of money would be devoted to the promotion of sales of liquor without expected results, or continue without realized results. No doubt competitors want to retain and expand their share of the market, but what businessperson stops short with competitive comparisons? It is total sales, profits, that pay the advertiser; and dollars go into advertising only if they produce sales.

Second, even if this Court were to accept the appellants' brand loyalty argument, the appellants have not adequately addressed the further problem that even commercials targeted solely at brand loyalty may also serve as inducements for smokers not to quit. The government's concern with the health effects of tobacco can quite reasonably extend not only to potential smokers who are con-

usage, je crois qu'on a présenté suffisamment d'éléments de preuve au procès pour conclure que la Loi sert logiquement l'objectif de réduire l'usage des produits du tabac par la prohibition tant de la publicité que de la promotion.

Je commence par ce que je considère être une observation relevant du plus gros bon sens. Il est tout simplement difficile de croire que les compagnies de tabac canadiennes dépenseraient plus de 75 000 000 $ chaque année pour la publicité si elles ne savaient pas qu'il en résultera une augmentation de l'usage de leurs produits. En réponse à cette observation, les appelantes insistent pour dire que leur publicité ne vise qu'à préserver et renforcer la fidélité des fumeurs à des marques, et qu'elle ne vise pas à étendre le marché des produits du tabac en incitant les non-fumeurs à commencer à fumer. À mon avis, l'allégation des appelantes ne peut être retenue, pour deux raisons principales. Premièrement, la seule fidélité aux marques ne maintiendra pas les bénéfices de ces compagnies, car, logiquement elle ne le peut pas, si le nombre total de fumeurs diminue. La même part d'une plus petite tarte n'en demeure pas moins une plus petite part. Comme l'a fait remarquer la Court of Appeals for the Fifth Circuit des États-Unis dans *Dunagin*, précité, à la p. 749: 84

> [TRADUCTION] Il est au-delà de notre capacité de comprendre pourquoi de fortes sommes d'argent seraient affectées à la promotion de la vente de spiritueux sans attente de résultats, ou continueraient de l'être si aucun résultat n'en découle. Il ne fait aucun doute que les compétiteurs souhaitent maintenir et augmenter leur part du marché, mais quel commerçant s'interdit toute comparaison avec ses compétiteurs? C'est l'ensemble des ventes, les bénéfices, qui payent la publicité; et des dollars ne sont consacrés à la publicité que s'ils rapportent des ventes.

Deuxièmement, même si notre Cour acceptait l'argument des appelantes quant à la fidélité à une marque, les appelantes n'auraient pas apporté de solution au problème soulevé par le fait que même la publicité orientée seulement vers la fidélité à une marque peut aussi servir à inciter les fumeurs à ne pas cesser de fumer. La préoccupation du gouvernement quant aux effets des produits du tabac

sidering starting, but also to current smokers who would prefer to quit but cannot.

85 I observe in passing, based upon the recent jurisprudence of this Court, that the foregoing common sense observation is sufficient in itself to establish a rational connection in these cases. In this respect, there is a direct analogy between the present case and *Butler*, *supra*. In *Butler*, where this Court addressed the constitutionality of a prohibition on "obscene" material under the *Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, the critical question raised at the rational connection stage was whether a rational connection existed between "obscene" material and violence against women. There was little or no evidence adduced to establish such a causal connection in a definitive manner. Indeed, in reviewing the evidence in that case, which consisted largely of two conflicting government reports, Sopinka J. observed, at p. 501, that "the literature of the social sciences remains subject to controversy" and that the social science evidence was "inconclusive". Nonetheless, Sopinka J. decided, at p. 502, that a common sense analysis was sufficient to satisfy the rational connection requirement:

> While a direct link between obscenity and harm to society may be difficult, if not impossible, to establish, it is reasonable to presume that exposure to images bears a causal relationship to changes in attitudes and beliefs.

In reaching this conclusion, Sopinka J., at p. 502, relied heavily on the following statement by the Meese Commission in its report (Attorney General's Commission on Pornography, *Final Report* (1986), vol. 1, at p. 326), regarding the effects of pornography:

> Although we rely for this conclusion on significant scientific empirical evidence, we feel it worthwhile to note the underlying logic of the conclusion. The evidence says simply that the images that people are exposed to bear a causal relationship to their behavior. This is hardly surprising. What would be surprising

sur la santé peut très raisonnablement s'étendre non seulement aux fumeurs potentiels qui envisagent la possibilité de commencer à fumer, mais aussi aux fumeurs actuels qui voudraient cesser de fumer, mais qui ne le peuvent pas.

Je note en passant que, selon la jurisprudence récente de notre Cour, l'observation de gros bon sens qui précède est suffisante en soi pour établir un lien rationnel en l'espèce. À cet égard, il y a une analogie directe entre la présente affaire et l'arrêt *Butler*, précité. Dans cet arrêt, où notre Cour s'est penchée sur la constitutionnalité d'une interdiction édictée par le *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, contre le matériel «obscène», la question en litige qui se posait à l'étape du lien rationnel était de savoir si un lien rationnel existait entre le matériel «obscène» et la violence contre les femmes. Il n'y avait que peu ou pas de preuve établissant de façon certaine un lien causal. En fait, en examinant la preuve déposée dans ce pourvoi, qui consistait principalement en deux rapports gouvernementaux contradictoires, le juge Sopinka a fait observer, à la p. 501, que: «les ouvrages dans le domaine des sciences humaines peuvent toujours faire l'objet d'une controverse» et que la preuve en matière de sciences humaines était «non concluante». Néanmoins, le juge Sopinka a décidé, à la p. 502, qu'une analyse fondée sur le bon sens suffisait pour satisfaire au critère du lien rationnel:

> Bien qu'il puisse être difficile, voire impossible, d'établir l'existence d'un lien direct entre l'obscénité et le préjudice causé à la société, il est raisonnable de supposer qu'il existe un lien causal entre le fait d'être exposé à des images et les changements d'attitude et de croyance.

Pour arriver à cette conclusion, le juge Sopinka, à la p. 502, s'est appuyé en grande partie sur une affirmation tirée du rapport de la commission Meese (Attorney General's Commission on Pornography, *Final Report* (1986), vol. 1, à la p. 326) portant sur les effets de la pornographie:

> [TRADUCTION] Bien que nous nous soyons fondés sur d'importantes données scientifiques empiriques pour en arriver à cette conclusion, nous croyons qu'il vaut la peine d'en faire ressortir la logique sous-jacente. Les données démontrent simplement qu'il existe un lien causal entre les images auxquelles les gens sont exposés et

would be to find otherwise, and we have not so found. We have not, of course, found that the images people are exposed to are a greater cause of sexual violence than all or even many other possible causes the investigation of which has been beyond our mandate. Nevertheless, it would be strange indeed if graphic representations of a form of behaviour, especially in a form that almost exclusively portrays such behavior as desirable, did not have at least some effect on patterns of behavior.

leur comportement. Cela n'est guère étonnant. Le contraire le serait, mais ce n'est pas là notre conclusion. Nous ne sommes pas, de toute évidence, arrivés à la conclusion que les images auxquelles sont exposés les gens contribuent davantage à la violence sexuelle que toutes les nombreuses autres causes possibles, dont l'examen dépassait le cadre de notre mandat. Néanmoins, il serait vraiment étrange que les représentations détaillées d'une forme de comportement, qui est presque toujours représenté comme désirable, n'aient pas au moins une certaine incidence sur les types de comportement.

In my view, a similar type of analysis is applicable here. In his 1989 report, *Reducing the Health Consequences of Smoking — 25 Years of Progress — A report of the Surgeon General*, *supra*, at p. 512, the Surgeon General of the United States conceded that there have been no "scientifically rigorous" studies that prove a causal link between advertising and promotion of tobacco products and consumption, and observed that "[g]iven the complexity of the issue, none is likely to be forthcoming in the foreseeable future" (pp. 512-13). However, he went on to make the following observation, at p. 513:

The most comprehensive review of both the direct and indirect mechanisms concluded that the collective empirical, experiential, and logical evidence makes it more likely than not that advertising and promotional activities do stimulate cigarette consumption. However, that analysis also concluded that the extent of influence of advertising and promotion on the level of consumption is unknown and possibly unknowable (Warner 1986b). This influence relative to other influences on tobacco use, such as peer pressure and role models, is uncertain. Although its effects are not wholly predictable, regulation of advertising and promotion is likely to be a prominent arena for tobacco policy debate in the 1990s. In part this reflects the high visibility of advertising and promotion; in part it reflects the perception that these activities constitute an influence on tobacco consumption that is amenable to government action. [Emphasis added.]

86 À mon avis, un type similaire d'analyse est applicable en l'espèce. Dans son rapport de 1989, intitulé *Reducing the Health Consequences of Smoking — 25 Years of Progress — A report of the Surgeon General*, *op. cit.*, à la p. 512, le Surgeon General des États-Unis a admis, qu'il n'y avait pas d'étude [TRADUCTION] «scientifiquement rigoureuse» qui établissait un lien causal entre d'une part, la publicité et la promotion des produits du tabac et d'autre part, la consommation, et il a fait observer que [TRADUCTION] «[c]ompte tenu de la complexité de la question, il y a peu de chance qu'une telle étude soit menée à brève échéance» (pp. 512 et 513). Il a toutefois fait l'observation suivante, à la p. 513:

[TRADUCTION] L'étude la plus complète quant aux mécanismes tant directs qu'indirects a conclu que l'ensemble de la preuve, empirique, expérimentale et logique, indique qu'il est plus vraisemblable, plutôt que le contraire, que la publicité et les activités de promotion stimulent la consommation de cigarettes. Toutefois, l'analyse a aussi conclu que la portée de l'influence de la publicité et de la promotion sur l'ampleur de la consommation est inconnue et peut-être inconnaissable (Warner 1986b). On ne peut mesurer avec certitude cette influence par rapport à d'autres influences sur la consommation des produits du tabac telles que la pression des pairs et les modèles de comportement. Bien que ses effets ne soient pas entièrement prévisibles, la réglementation de la publicité et de la promotion sera vraisemblablement un point chaud des discussions portant sur les politiques en matière de produits du tabac dans les années 1990. Cela reflète en partie la présence importante de la publicité et de la promotion, mais aussi, en partie, la perception que ces activités constituent une influence sur la consommation des produits du tabac, qui est du ressort du gouvernement. [Je souligne.]

Thus, following the reasoning adopted by this Court in *Butler*, the power of the common-sense connection between advertising and consumption is sufficient to satisfy the rational connection requirement.

87 However, it is not necessary to rely solely upon common sense to reach this conclusion because there was, in any event, sufficient evidence adduced at trial to bear out the rational connection between advertising and consumption. In this respect, I find it significant that Chabot J. made specific reference in his reasons to only two pieces of evidence. First, he considered at length a 1989 report of the New Zealand Toxic Substances Board entitled *Health or Tobacco: An End to Tobacco Advertising and Promotion* (1989), where the Board had reviewed the effect of advertising restrictions in 33 countries, and had concluded that there was a correlation between the degree of restrictions imposed in each of these countries and the relative decline in tobacco consumption. Chabot J. found the Report to be of no probative value on the following grounds, at p. 513:

> With respect to the T.S.B. report, the court can only note that it contains serious methodological errors and a lack of scientific rigour which renders it for all intents and purposes devoid of any probative value. It is a report with an obvious point of view and its conclusions reflect that point of view. In this regard, the court agrees entirely with the analysis of the report made by RJR's counsel in his argument . . . and concludes that the T.S.B. report, as an extrinsic document, is of no probative value.

Chabot J. also rejected the evidence of Dr. Jeffrey Harris, a Crown witness, who had affirmed the accuracy of the Report's conclusions in his own report and in testimony at trial. In Chabot J.'s view, at p. 514, "the input data used by Dr. Harris were unreliable and . . . his methodology led necessarily to the desired result". As a result, Chabot J. held, at p. 514, that Dr. Harris's testimony and his report (also adduced as evidence) had "no probative value". However, apart from these two findings, Chabot J. made no other findings respecting the credibility of expert witnesses who testified at

Par conséquent, conformément au raisonnement adopté par notre Cour dans l'arrêt *Butler*, le pouvoir du lien établi par le bon sens entre publicité et consommation est suffisant pour satisfaire à l'exigence d'un lien rationnel.

Il n'est cependant pas nécessaire de s'en remettre exclusivement au bon sens pour en arriver à cette conclusion, parce que, de toute façon, une preuve suffisante a été déposée en première instance pour confirmer l'existence du lien rationnel entre la publicité et la consommation. À cet égard, je trouve pertinent de noter que le juge Chabot n'a fait référence dans ses motifs qu'à deux documents. Il a d'abord examiné à fond un rapport présenté en 1989 par le Toxic Substances Board de la Nouvelle-Zélande, intitulé *Health or Tobacco: An End to Tobacco Advertising and Promotion* (1989), dans lequel, après avoir examiné les effets de restrictions imposées à la publicité dans 33 pays, cet organisme est arrivé à la conclusion qu'il y avait corrélation entre le degré des restrictions imposées dans chaque pays et le déclin relatif de l'usage des produits du tabac. Le juge Chabot a conclu, à la p. 2309, que ce rapport n'avait pas de valeur probante pour les motifs suivants:

> En ce qui a trait au *T.S.B. Report*, le Tribunal ne peut que noter que celui-ci comporte des erreurs graves de méthodologie et un manque de rigueur scientifique qui le rendent à toutes fins utiles sans valeur probante. C'est un rapport avec un point de vue manifeste et le résultat du rapport est conforme à ce point de vue. À cet égard, le Tribunal partage entièrement l'analyse de ce rapport effectuée par le procureur de R.J.R. dans son argumentation et conclut que le *T.S.B. Report*, à titre de document extrinsèque, n'a aucune valeur probante.

Le juge Chabot a aussi rejeté le témoignage de Jeffrey Harris, un témoin du procureur général, qui a déclaré dans son propre rapport et dans son témoignage au procès que les conclusions du rapport étaient exactes. Selon le juge Chabot, à la p. 2309, «les données de base utilisées par le Dr Harris sont aléatoires et [. . .] sa méthodologie conduit nécessairement au résultat recherché». Par conséquent, le juge Chabot a jugé, à la p. 2310, que le témoignage et le rapport de Harris (aussi déposé en preuve) n'avaient «aucune valeur probante». Cependant, à part ces deux conclusions, le juge

trial or the accuracy of the many reports adduced by the Attorney General. As such, it is apparent that Chabot J. disregarded a substantial amount of evidence that might otherwise have substantiated the government's belief in a rational connection. This evidence can be conveniently subdivided into three categories: internal tobacco marketing documents, expert reports, and international materials. I will review each of these in turn.

Perhaps the most compelling evidence concerning the connection between advertising and consumption can be found in the internal marketing documents prepared by the tobacco manufacturers themselves. Although the appellants steadfastly argue that their marketing efforts are directed solely at maintaining and expanding brand loyalty among adult smokers, these documents show otherwise. In particular, the following general conclusions can be drawn from these documents: the tobacco companies are concerned about a shrinking tobacco market and recognize that an "advocacy thrust" is necessary to maintain the size of the overall market; the companies understand that, in order to maintain the overall numbers of smokers, they must reassure current smokers and make their product attractive to the young and to non-smokers; they also recognize that advertising is critical to maintaining the size of the market because it serves to reinforce the social acceptability of smoking by identifying it with glamour, affluence, youthfulness and vitality.

Many of these conclusions are borne out by a simple reading of an extensive marketing research study commissioned by Imperial Tobacco Ltd. in 1986, entitled *Project Viking*. In the introduction to the study, the authors refer to the fact that increasing numbers of smokers are quitting as a "problem". They also observe that, in light of these declining numbers, the tobacco companies must direct their marketing efforts towards "expanding the market, or at very least forestalling its

Chabot n'a tiré aucune autre conclusion sur la crédibilité des témoins experts au procès, ou sur l'exactitude des nombreux rapports déposés en preuve par le procureur général. Il apparaît donc que le juge Chabot a écarté une grande partie de la preuve qui aurait pu autrement appuyer l'opinion du gouvernement quant à l'existence d'un lien rationnel. Cette preuve peut commodément se diviser en trois catégories: les documents internes de commercialisation des produits du tabac, les rapports d'experts et les documents internationaux. J'examinerai à tour de rôle chaque catégorie.

88 L'élément de preuve peut-être le plus convaincant au sujet du lien entre la publicité et la consommation se trouve dans les documents internes de commercialisation préparés par les fabricants de produits de tabac eux-mêmes. Bien que les appelantes affirment résolument que leurs efforts de commercialisation sont orientés seulement vers la préservation et le renforcement de la fidélité des fumeurs adultes à des marques, ces documents témoignent du contraire. En particulier, on peut tirer de ces documents les conclusions générales suivantes: les compagnies de tabac s'inquiètent du rétrécissement du marché et reconnaissent qu'une [TRADUCTION] «initiative de promotion» est nécessaire pour maintenir la taille de l'ensemble du marché; les compagnies comprennent que, pour maintenir le nombre total des fumeurs, elles doivent rassurer les fumeurs actuels et rendre leurs produits attirants pour les jeunes et les non-fumeurs; elles reconnaissent aussi que la publicité est essentielle au maintien de la taille du marché parce qu'elle sert à renforcer l'acceptabilité sociale de l'usage du tabac en l'identifiant au prestige, à la richesse, à la jeunesse et à la vitalité.

89 Nombre de ces conclusions découlent de la seule lecture d'une importante étude de commercialisation commandée par Imperial Tobacco Ltd. en 1986 et intitulée *Project Viking*. En introduction, les auteurs de l'étude décrivent comme étant un «problème» le fait qu'un nombre croissant de fumeurs cessent de fumer. Ils font aussi observer que, compte tenu de la décroissance du nombre des fumeurs, les compagnies de tabac doivent consacrer leurs activités de commercialisation à [TRA-

decline". They then indicate the objectives of *Project Viking*, vol. I: *A Behavioural Model of Smoking*, which they describe as follows:

Background and Objectives

It is no exaggeration to suggest that the tobacco industry is under siege. The smoker base is declining, primarily as a function of successful quitting. And the characteristics of new smokers are changing such that the future starting level may be in question. There is a constant stream of anti-smoking publicity in the media. Not all of this is soundly supported, but it gains legitimacy in the fact that there have been no responses from the tobacco industry in counterpoint.

Within this somewhat alarming view of the mid-term future, Imperial Tobacco is embarking on a proactive program. Perhaps for the first time, the mandate under consideration is not limited simply to maximizing the ITL franchises; it is now to include as well serious attempts to combat those forces aligned in an attempt to significantly diminish the size of the tobacco market in Canada.

This is the underpinning of Project Viking. There are, in fact, two components to the program, each having its own purposes, but also overlapping with the other in informational areas:

- Project Pearl is directed at expanding the market, or at very least forestalling its decline. It examines attitudes and issues with the potential to be addressed via advocacy. It also looks at the needs of smokers specifically.
- Project Day represents the tactical end by which ITL may achieve competitive gains within the market of today and in the future. Unmet needs of smokers that could be satisfied by new or modified products, products which could delay the quitting process, are pursued. [Emphasis added.]

As LeBel J.A. noted in the Court of Appeal, at p. 324, this document "indicates the objectives of the program: if not to expand the market, then at least to retain it, and also to preserve the company's market share". In *Project Viking*, vol. III: *Product Issues*, the need for an "advocacy thrust" is emphasized:

DUCTION] «faire croître la taille du marché ou, tout au moins, à prévenir son déclin». Ils indiquent ensuite quels sont les objectifs du *Project Viking*, vol. I: *A Behavioural Model of Smoking*, dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Historique et objectifs

Ce n'est pas exagérer que d'affirmer que l'industrie du tabac est assiégée. Le nombre des fumeurs diminue, principalement en raison de ceux qui réussissent à cesser de fumer. Et les caractéristiques des nouveaux fumeurs changent de telle façon que le futur seuil de ceux qui commencent pourrait être remis en question. Il existe un courant continu de publicité anti-tabac dans les médias. Cette publicité n'est pas en tout point bien étayée, mais elle gagne en légitimité du fait que l'industrie du tabac n'y a donné aucune réponse en contrepartie.

Compte tenu de cette perspective plutôt alarmante à moyen terme, Imperial Tobacco lance un programme proactif. Peut-être pour la première fois, le mandat pris en considération n'est pas limité simplement à la maximisation des franchises d'ITL; il doit maintenant inclure aussi des tentatives sérieuses de contrer les forces mises en place dans le but de faire sensiblement diminuer la taille du marché des produits du tabac au Canada.

C'est là le principe du projet Viking. Le programme comporte en fait deux volets, chacun ayant ses propres objectifs, mais se combinant toutefois dans le domaine de l'information:

- Le projet Pearl vise à faire croître la taille du marché ou, tout au moins, à prévenir son déclin. Il examine les attitudes et les questions qui ont le potentiel de faire l'objet d'activités de promotion. Il examine aussi les besoins spécifiques des fumeurs.
- Le projet Day constitue le moyen tactique par lequel ITL pourrait augmenter sa part du marché actuel et futur. On envisage des produits nouveaux ou modifiés qui pourraient satisfaire les besoins des fumeurs auxquels on n'a pas encore répondu, et des produits qui pourraient retarder le moment où un fumeur cesse de fumer. [Je souligne.]

Comme le juge LeBel de la Cour d'appel l'a fait remarquer, à la p. 399, ce document «indique les objectifs du programme: sinon étendre le marché, du moins le conserver, et préserver aussi la part de celui-ci que détient la compagnie». Dans *Project Viking*, vol. III: *Product Issues*, on insiste sur la nécessité d'entreprendre une «initiative de promotion»:

Unsuccessful Quitters are moved disproportionately by physical reactions and social forces to stop smoking (but health remains the most often specified reason). Short-term Quitters very often point to expense, which often will be a transient reason itself, not compelling enough to keep them out of the tobacco market. Health is also of major concern to them.

Strategically, it would seem that reducing quitting is the most viable approach. But it would also seem that a product solution may not be sufficient on its own. An advocacy thrust may be necessary; disaffected smokers do need some reassurance that they are not social pariahs. [Emphasis added.]

The report then goes on to refer to persons contemplating quitting, and states that "[t]he extent to which they can be reassured and satisfied has a major impact on the extension of a viable tobacco industry". Smokers are segmented into five groups (*Project Viking*, vol. II: *An Attitudinal Model of Smoking*, at pp. 31-35): "Smokers With a Disease Concern", "Leave Me Alone", "Pressured", "Seriously Like to Quit", "Not Enjoying Smoking/Smoking Less Now". With respect to the "Pressured" group, the report states, at p. 33, that they "deserve particular attention" as they are "most vulnerable to quitting and . . . in urgent need of reassurance and stroking".

It is, therefore, clear from this report that a central aspect of the "advocacy thrust" suggested in *Project Viking* is advertising. It is difficult to see how companies could "reassure" smokers that they are not "social pariahs" or "stroke" them merely by reducing the price or content of their products. To reassure smokers effectively, it is also necessary to convince them that smoking is socially acceptable or even admirable. Advertising is a proven and effective method for achieving this result.

Apart from the emphasis on "reassuring" smokers, it is also possible to discern from these marketing documents a recognition that tobacco compa-

[TRADUCTION] Les fumeurs qui ont tenté sans succès d'arrêter de fumer sont motivés de façon disproportionnée par des réactions physiques et des influences sociales qui les incitent à cesser de fumer (mais la santé demeure la raison la plus souvent invoquée). Ceux qui ont cessé de fumer depuis peu invoquent souvent le coût, ce qui est souvent une raison transitoire qui n'a pas assez de poids pour les exclure définitivement du marché du tabac. La santé les préoccupe aussi beaucoup.

Sur le plan stratégique, il semble que réduire le nombre des fumeurs qui cessent de fumer est la méthode la plus prometteuse. Mais il semble aussi qu'une solution portant sur les produits ne serait pas suffisante en soi. Une initiative de promotion peut être nécessaire; les fumeurs rebelles ont besoin de se faire rappeler qu'ils ne sont pas des parias. [Je souligne.]

Le rapport traite ensuite des personnes qui envisagent de cesser de fumer, et il y est affirmé que [TRADUCTION] «[l]e plus ils seront rassurés et satisfaits, meilleur sera l'incidence sur la viabilité de l'industrie du tabac». Les fumeurs sont répartis en cinq groupes (*Project Viking*, vol. II: *An Attitudinal Model of Smoking*, aux pp. 31 à 35): [TRADUCTION] «Fumeurs inquiets pour leur santé», «Laissez-moi tranquille», «Sujets à des pressions», «Aimeraient sérieusement cesser de fumer», «Aucun plaisir à fumer/Consommation réduite». En ce qui concerne le groupe «Sujets à des pressions», il est affirmé, à la p. 33, qu'ils [TRADUCTION] «méritent une attention particulière» parce qu'ils sont «les plus susceptibles de cesser de fumer et ont un urgent besoin d'être rassurés et encouragés».

90 Il ressort par conséquent clairement de ce rapport que la publicité est un aspect central de l'«initiative de promotion» proposée dans *Project Viking*. Il est difficile de voir comment les compagnies pourraient «rassurer» les fumeurs qu'ils ne sont pas des «parias», ou les «encourager», simplement par la réduction du prix ou du contenu de leurs produits. Pour rassurer les fumeurs de façon efficace, il est aussi nécessaire de les convaincre que fumer est acceptable sur le plan social, ou même admirable. La publicité a fait la preuve de son efficacité en ce domaine.

91 À part l'insistance quant à la nécessité de «rassurer» les fumeurs, il est possible également de dégager de ces documents de commercialisation la

nies must target the young in order to ensure the continued maintenance of the tobacco market at its current size. I find it significant that, in these documents, strategies to attract the young are usually accompanied by extensive discussions concerning the "image" of the product. For example, the 1978 "Business Plans of RJR-MacDonald Inc. and International Plans" identified as "Prime Prospects" new smokers entering the cigarette market who want the positive, masculine image of this product. Later, in a 1987 RJR-MacDonald Inc. document entitled "Export "A" Brand Long-Term Strategy", reference is made under the title "Whose Behaviour Are We Trying to Affect?" to "18-34; Emphasis 18-24 (new users)" and to "High school — some post secondary education". It continues:

reconnaissance que les compagnies de tabac doivent cibler les jeunes si elles souhaitent garder le marché des produits du tabac à sa taille actuelle. Je trouve révélateur que, dans ces documents, les stratégies visant à attirer les jeunes sont habituellement accompagnées par de longues discussions sur l'«image» du produit. Par exemple, le document «Business Plans of RJR-MacDonald Inc. and International Plans», publié en 1978, a qualifié d'[TRADUCTION] «espoirs de premier plan» les nouveaux fumeurs abordant le marché de la cigarette qui sont à la recherche de l'image positive et masculine que reflète ce produit. Puis, en 1987, dans un document de RJR-MacDonald Inc. intitulé «Export «A» Brand Long-Term Strategy», il est question, sous le titre [TRADUCTION] «Quel comportement cherchons-nous à modifier?», des [TRADUCTION] «18 à 34 ans: particulièrement 18 à 24 ans (nouveaux consommateurs)» et d'[TRADUCTION] «études secondaires — certaines études postsecondaires». Le rapport se poursuit de la façon suivante:

Psychographics:

Young adults who are currently in the process of establishing their independence and their position in society. They look for peer group acceptance in their brand selection, and may often be moderate or conservative in their choices. As young adults they look for symbols that will help to reinforce their independence and individuality.

[TRADUCTION] Psychographie:

Les jeunes adultes qui sont actuellement en voie d'établir leur indépendance et leur place dans la société. Ils recherchent l'acceptation de leurs pairs lorsqu'ils choisissent leur marque, et ils peuvent souvent se montrer modérés ou conservateurs dans leur choix. Comme jeunes adultes, ils sont à la recherche de symboles qui les aideront à affirmer leur indépendance et leur individualité.

Mr. P. Hoult, ex-CEO of Imperial, testified at trial that lifestyle advertising is designed to create certain associations in the minds of consumers, and in the case of EXPORT cigarettes, an association with enjoyment, outdoors and youth. Similarly, in "Overview 1988", an internal document prepared by Imperial, it was stated that one of the philosophies governing its marketing activities was to

Monsieur P. Hoult, ancien directeur général d'Imperial, a affirmé au procès que la publicité dite de style de vie cherche à faire établir des associations dans l'esprit des consommateurs et, dans le cas des cigarettes EXPORT, une association avec plaisir, activités extérieures et jeunesse. Il a aussi été affirmé dans «Overview 1988», un document interne préparé par Imperial, que l'un des principes régissant les activités de publicité était le suivant:

[s]upport the continued social acceptability of smoking through industry and/or corporate action (e.g. product quality, positive lifestyle advertising, selective field activities and marketing public relations programs).

[TRADUCTION] Affirmer qu'il est toujours acceptable socialement de fumer, par des mesures de l'industrie ou des compagnies (p. ex. qualité des produits, publicité positive dite de style de vie, certaines activités de terrain et programmes de relations publiques axés sur la commercialisation).

One of the other stated objectives, "Overall Marketing Objectives" in "Overall Market Conditions 1988", was as follows:

> RE-ESTABLISH clear distinct images for ITL brands with particular emphasis on relevance to younger smokers. Shift resources substantially in favour of avenues that allow for the expression and reinforcement of these image characteristics. [Emphasis in original.]

That these companies are aware of the need to attract the young is also reinforced by the fact that, in 1977, Imperial commissioned a marketing research study entitled "Project 16" which focused on the smoking patterns of adolescents under the age of 17, and traced the manner in which adolescents are influenced by peer pressure and other societal factors to start smoking. A similar focus can be discerned from Imperial's "Fiscal '80 Media Plans" which outlines the target groups in 1980 for each of the company's brands. A weight was assigned to each target group to determine, by means of a computer, which magazines would be selected to place advertisements. This method maximized the advertising exposure for the desired target groups. Importantly, for some brands, not only do target groups include adolescents as young as 12, but youth aged 12-17 are weighted far more heavily than older age groups.

The internal marketing documents introduced at trial strongly suggest that the tobacco companies perceive advertising to be a cornerstone of their strategy to reassure current smokers and expand the market by attracting new smokers, primarily among the young. This conclusion is given added force by a number of reports introduced at trial, to which Chabot J. made no reference, which attest to the causal connection between tobacco advertising and consumption. In a report entitled "The Functions and Management of Cigarette Advertising", Dr. Richard W. Pollay, an historian and marketing professor at the University of British Columbia, concluded that advertising and promotional activi-

Un des autres objectifs mentionnés «Overall Marketing Objectives» dans «Overall Market Conditions 1988» était le suivant:

> [TRADUCTION] RÉTABLIR des images claires et distinctes des marques d'ITL et montrer tout particulièrement leur à-propos pour les jeunes. Réaffecter les ressources en bonne partie vers les avenues qui favorisent l'expression et le renforcement des caractéristiques de ces images. [Souligné dans l'original.]

Il est encore plus évident que ces compagnies sont conscientes de la nécessité d'attirer les jeunes si l'on considère le fait que, en 1977, Imperial a commandé une étude de commercialisation intitulée «Project 16», qui était centrée sur les habitudes d'utilisation du tabac des adolescents âgés de moins de 17 ans, et qui montrait de quelle façon les adolescents sont incités par la pression des pairs et d'autres facteurs sociaux à commencer à fumer. Les mêmes constatations peuvent être faites à partir du document d'Imperial intitulé «Fiscal '80 Media Plans», qui décrit les groupes cibles de chaque marque de la compagnie pour 1980. Une pondération a été effectuée tenant compte de chaque groupe cible afin de déterminer, au moyen d'un ordinateur, dans quels magazines les messages publicitaires seraient placés. Cette méthode maximisait la présence du message en fonction du groupe cible désiré. Fait important, pour certaines marques, non seulement les groupes cibles comprennent les adolescents qui n'ont que 12 ans, mais, dans la pondération, les jeunes de 12 à 17 ans ont une importance beaucoup plus grande que les groupes de personnes plus âgées.

Les documents de commercialisation internes déposés lors du procès donnent fortement à entendre que les compagnies de tabac perçoivent la publicité comme la pierre angulaire de leur stratégie visant à rassurer les fumeurs actuels et à étendre le marché en attirant de nouveaux fumeurs, principalement chez les jeunes. Cette conclusion a encore plus de poids si l'on considère les nombreux rapports déposés lors du procès, auxquels le juge Chabot n'a fait aucune référence et qui attestent un lien causal entre la publicité des produits du tabac et leur consommation. Dans un rapport intitulé «The Functions and Management of Cigarette Advertising», Richard W. Pollay, historien et

92

ties serve to change people's perceptions, creating more positive attitudes and serve as a reinforcement for smokers and a temptation and teacher of tolerance for non-smokers. He stated:

> The research and strategic thinking identifies the psychological needs, wants and interests of target, and leads to the creation of a strategic "positioning" of the products to offer them in ways that promise satisfactions relevant to the targets' personalities and preferences. For starter brands, images are created to communicate independence, freedom and peer acceptance to young targets. The advertising images portray smokers as attractive and autonomous, accepted and admired, athletic and at home in nature. For 'lighter' brands directed at smokers with health concerns, ads image a sense of well being, harmony with nature, and a consumer's self image as intelligent.
>
> . . .
>
> Advertising and promotional activities and communication serve to induce many changes in the public's perceptions, creating: more positive attitudes toward smoking and smokers; less consciousness and fear of any unhealthy consequences of smoking; a stronger self-image among smokers; more confidence of some social support for smoking; and perceptions that smoking is a cultural commonplace to be taken for granted. To smokers it is a reminder and reinforcer, while to non-smokers it is a temptation and a teacher of tolerance. [Emphasis added.]

Similarly, in a report entitled "Effects of Cigarette Advertising on Consumer Behavior", Dr. Joel B. Cohen, a professor of marketing at the University of Florida, observed, at p. 44, that tobacco advertising targets both non-smokers and the young, who are particularly vulnerable to advertising techniques:

> There is ample documentation as to the effectiveness of cigarette advertising. Cigarette advertising achieves essential communications goals that are almost univer-

professeur de commercialisation à l'Université de la Colombie-Britannique, a conclu que la publicité et les activités de promotion servent à changer les perceptions des gens, à créer des attitudes plus positives, et qu'elles servent de renforcement chez les fumeurs, et de tentation et de leçon de tolérance pour les non-fumeurs. Il a affirmé:

> [TRADUCTION] La recherche et la pensée stratégique identifient les besoins psychologiques, les désirs et les intérêts de la cible, et mènent à la création d'un «positionnement» stratégique des produits pour qu'ils soient offerts de façon à promettre les satisfactions auxquelles les cibles s'attendent en raison de leurs personnalités et de leurs préférences. Pour les marques de débutants, des images sont créées pour induire chez les jeunes cibles l'idée d'indépendance, de liberté et d'acceptation des pairs. La publicité représente les fumeurs comme étant à la fois attirants et autonomes, acceptés et admirés, athlétiques et sûrs d'eux-mêmes dans la nature. Pour les marques plus «légères» destinées aux fumeurs qui sont préoccupés par leur santé, la publicité donne l'image d'une sensation de bien-être, d'une harmonie avec la nature et d'un consommateur avisé.
>
> . . .
>
> La publicité, les activités de promotion et les communications servent à provoquer de nombreux changements dans les perceptions du public, à savoir: créer des attitudes plus positives envers l'usage du tabac et les fumeurs; diminuer les interrogations et les craintes quant aux conséquences de l'usage du tabac pour la santé; renforcer l'image de soi parmi les fumeurs; augmenter le sentiment de l'acceptabilité sociale de l'usage du tabac; créer l'impression que fumer est un lieu commun culturel qui doit être tenu pour acquis. Pour les fumeurs, c'est un rappel et un renforcement, alors que pour les non-fumeurs, c'est une tentation et une leçon de tolérance. [Je souligne.]

De façon similaire, dans un rapport intitulé «Effects of Cigarette Advertising on Consumer Behavior», Joel B. Cohen, professeur de commercialisation à l'Université de la Floride, fait observer, à la p. 44, que la publicité des produits du tabac cible à la fois les non-fumeurs et les jeunes, qui sont particulièrement vulnérables face aux techniques de la publicité:

> [TRADUCTION] Il existe une vaste documentation sur l'efficacité de la publicité de la cigarette. Cette publicité atteint des buts de communications essentiels sur les-

sally agreed to increase the likelihood of purchase, and it does so for deliberately targeted groups including adolescent males and females and health concerned smokers. Both of these groups are particularly vulnerable to the types of appeals used.

Cigarette advertising cannot be created so that it is only effective for brand switching. The ads are developed (and researched) to insure that they are maximally effective against targeted segments. Nonsmokers in those segments (e.g., young males) have similar motivations and concerns, and there is no way to lower a "magic curtain" around them in order to shield them from the enticement of such advertising. ["Only" emphasized in original; other emphasis added.]

In yet another report, entitled "A Report on the Special Vulnerabilities of Children and Adolescents", *supra*, at pp. 17-18, Dr. Michael J. Chandler, a psychologist, concluded that the cognitive and socio-emotional immaturities of both children and adolescents makes them vulnerable to the influence of cigarette advertising because they lack the ability to evaluate the messages being presented:

. . . it is an essential truism that tobacco companies cannot maintain their current levels of profit unless they can successfully entice new generations to smoke cigarettes. Whether by accident or design, existing cigarette advertising practices appear strategically tailored to accomplish this questionable initiation process.

It is too early, of course, to calculate the real effects of eliminating the public advertising and promotion of tobacco products. Such a ban can be expected, however, to reduce the numbers of young persons who eventually do choose to smoke.

The views expressed in these reports are not, of course, definitive or conclusive. Indeed, there is currently a lively debate in the social sciences respecting the connection between advertising and consumption, a debate that has been carried on for years and will no doubt persist well into the near future. However, these reports attest, at the very least, to the existence of what LeBel J.A. called a "body of opinion" supporting the existence of a

quels on s'entend presque universellement pour dire qu'ils accroissent la probabilité d'achat; et elle le fait à l'endroit de groupes délibérément ciblés, entre autres celui des adolescents, garçons et filles, et celui des fumeurs préoccupés par leur santé. Ces deux groupes sont particulièrement sensibles aux types d'attraits utilisés.

La publicité de la cigarette ne peut pas être créée de manière à avoir une efficacité seulement sur les changements de marques. Les messages publicitaires sont créés — à la suite de recherches — dans le but d'avoir un effet maximal sur une couche de population ciblée. Les non-fumeurs de ces couches (p. ex. les jeunes hommes) ont des goûts et des préoccupations similaires, et il n'y a pas de façon de tirer autour d'eux un «écran magique» de manière à les protéger de la tentation provoquée par cette publicité. [«Seulement» souligné dans l'original; je souligne le reste.]

Dans encore un autre rapport, intitulé «A Report on the Special Vulnerabilities of Children and Adolescents», *op. cit.*, aux pp. 17 et 18, Michael J. Chandler, psychologue, a conclu que l'immaturité des enfants et des adolescents sur les plans cognitif et socio-affectif les rend vulnérables à l'influence de la publicité de la cigarette parce qu'ils ne sont pas capables d'évaluer les messages qui leur sont présentés:

[TRADUCTION] . . . il relève d'un truisme essentiel que les compagnies de tabac ne peuvent pas maintenir les bénéfices actuels à moins qu'elles puissent réussir à attirer les jeunes à fumer la cigarette. Que ce soit par accident ou à dessein, les pratiques actuelles de la publicité de la cigarette paraissent opportunément conçues pour accomplir ce discutable processus d'initiation.

Il est trop tôt, évidemment, pour faire le bilan des effets réels de l'élimination de la publicité et de la promotion des produits du tabac auprès du public. Cette interdiction devrait cependant réduire le nombre de jeunes qui, tôt ou tard, choisissent de fumer.

Les opinions exprimées dans ces rapports ne sont évidemment pas définitives ni concluantes. En fait, il y a actuellement un débat animé en sciences humaines quant au lien entre publicité et consommation, un débat qui se poursuit depuis des années et qui, sans doute, se poursuivra encore un certain temps. Toutefois, ces rapports attestent à tout le moins la présence de ce que le juge LeBel, de la Cour d'appel, a appelé un «corps d'opinions» 93

causal connection between advertising and consumption. Included in this "body of opinion" are a significant number of international health organizations, which support prohibitions on advertising as a viable strategy in the battle against tobacco consumption. In May 1986, for example, the Thirty-ninth World Health Assembly adopted Resolution WHA39.14, urging member states to fight tobacco consumption through a variety of measures including "the progressive elimination of those socio-economic, behavioural, and other incentives which maintain and promote the use of tobacco" and "prominent health warnings which might include the statement that tobacco is addictive, on cigarette packets and containers of all types of tobacco products". In May 1990, the Forty-third World Health Assembly adopted Resolution WHA43.16 urging "progressive restrictions and concerted action to eliminate eventually all direct and indirect advertising, promotion and sponsorship concerning tobacco" and stating that it was "encouraged" by "recent information demonstrating the effectiveness of tobacco control strategies, and in particular . . . comprehensive bans and other legislative restrictive measures to control effectively direct and indirect advertising, promotion and sponsorship concerning tobacco". In July 1993, the Economic and Social Council of the United Nations adopted Resolution 1993/79 expressly urging governments to maximize their efforts to reduce tobacco consumption through the adoption of multifaceted approaches. In 1989, the European Council adopted Directive 89/552/EEC banning broadcast advertising of tobacco products. One month later, the Council adopted Directive 89/622/EEC (amended 92/41/EEC) requiring health warnings on tobacco products packaging. From 1990 to 1992, the European Commission submitted proposals for Council Directives which would ban all direct and indirect advertising of tobacco products (90\C 116\05; 91/C 167/03; 92/C 129/04). It is also significant that by 1990, over 40 countries had adopted measures to restrict or prohibit tobacco advertising. Tobacco advertising is fully prohibited by law in Australia, New Zealand, France, Portugal, Norway, Finland, Iceland, Singapore and Thailand, among other countries. Among those countries that have instituted substantial

appuyant l'existence d'un lien causal entre publicité et consommation. Ce «corps d'opinions» comprend celles de nombreux organismes internationaux de la santé qui appuient l'interdiction de la publicité comme stratégie viable dans la lutte engagée contre l'usage du tabac. En mai 1986, par exemple, la Trente-neuvième Assemblée mondiale de la santé a adopté la résolution WHA39.14, par laquelle elle demandait instamment aux États membres de lutter contre l'usage des produits du tabac en utilisant diverses mesures, dont l'«élimination progressive des incitations socio-économiques, comportementales et autres qui entretiennent et favorisent l'usage du tabac» et «l'apposition, bien en évidence, de mises en garde pouvant préciser que le tabac engendre la dépendance, sur les paquets de cigarettes et les emballages de tous les types de produits du tabac». En mai 1990, la Quarante-troisième Assemblée mondiale de la santé a adopté la résolution WHA43.16, par laquelle elle demandait instamment d'imposer «des restrictions progressives et des actions concertées visant à éliminer à terme toute publicité directe et indirecte et toutes les activités de promotion et de parrainage concernant le tabac» et affirmait qu'elle était «encouragée» par «les informations récentes montrant l'efficacité des stratégies de lutte antitabac, et en particulier [. . .] des interdictions générales et d'autres mesures législatives restrictives visant à lutter efficacement contre la publicité directe et indirecte, ainsi que contre les activités de promotion et de parrainage concernant le tabac». En juillet 1993, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté la résolution 1993/79, par laquelle il demandait instamment aux gouvernements de maximiser leurs efforts afin de réduire la consommation du tabac par l'adoption de mesures à plusieurs facettes. En 1989, le Conseil européen a adopté la directive 89/552/CEE, par laquelle il interdisait la diffusion de messages publicitaires sur les produits du tabac. Un mois plus tard, le Conseil a adopté la directive 89/622/CEE (modifiée par 92/41/CEE), par laquelle il exigeait l'inscription de mises en garde sur l'emballage des produits du tabac. De 1990 à 1992, la Commission européenne a présenté au Conseil des projets de directives qui avaient pour but d'interdire toute publicité directe et indirecte

restrictions on tobacco advertising are Austria, Belgium, West Germany, Ireland, the Netherlands, Spain and Sweden.

des produits du tabac (90/C 116/05; 91/C 167/03; 92/C 129/04). Il est également intéressant de constater qu'en 1990, plus de 40 pays avaient adopté des mesures visant à restreindre ou à interdire la publicité du tabac. Les lois de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la France, du Portugal, de la Norvège, de la Finlande, de l'Islande, de Singapour et de la Thaïlande, entre autres, interdisent toute publicité des produits du tabac. L'Autriche, la Belgique, l'Allemagne de l'Ouest, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède, entre autres, ont imposé d'importantes restrictions à la publicité du tabac.

On the basis of the foregoing evidence, I conclude that there is a rational connection between the prohibition on advertising and consumption under ss. 4, 5, 6 and 8 of the Act and the reduction of tobacco consumption. I am comforted in this conclusion by the fact that a number of American courts have also recognized the existence of a rational connection between advertising and consumption. I note that in *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission of New York*, 447 U.S. 557 (1980), at p. 569, the Supreme Court of the United States found an "immediate connection between advertising and demand for electricity" and therefore a direct link between the ban on advertising and the state interest in conservation. The court continued:

Compte tenu de la preuve mentionnée précédemment, je conclus qu'il existe un lien rationnel entre l'interdiction de la publicité en vertu des art. 4, 5, 6 et 8 de la Loi et la réduction de la consommation du tabac. Je suis d'autant plus convaincu de la justesse de cette conclusion que de nombreuses décisions judiciaires américaines ont aussi constaté l'existence d'un lien rationnel entre la publicité et la consommation. Je remarque que dans l'arrêt *Central Hudson Gas & Electric Corp. c. Public Service Commission of New York*, 447 U.S. 557 (1980), à la p. 569, la Cour suprême des États-Unis a conclu à l'existence d'un [TRADUCTION] «lien direct entre la publicité et la demande d'électricité» et, par conséquent, d'un lien direct entre l'interdiction de la publicité et l'intérêt de l'État pour la conservation. La cour a affirmé: 94

> Central Hudson would not contest the advertising ban unless it believed that promotion would increase its sales. Thus, we find a direct link between the state interest in conservation and the Commission's order.

> [TRADUCTION] Central Hudson ne contesterait pas l'interdiction de la publicité si elle ne croyait pas que la promotion fait augmenter ses ventes. Par conséquent, nous trouvons qu'il y a un lien direct entre l'intérêt de l'État pour la conservation et l'ordonnance de la Commission.

Similarly, in *Oklahoma Telecasters Ass'n v. Crisp*, 699 F.2d 490 (1983), at p. 501, (rev'd on other grounds *sub nom. Capital Cities Cable, Inc. v. Crisp*, 467 U.S. 691 (1984)), the Court of Appeals for the Tenth Circuit observed that "the record does not demonstrate that Oklahoma's laws have any direct effect on the consumption of alcohol" but concluded:

De même, dans l'arrêt *Oklahoma Telecasters Ass'n c. Crisp*, 699 F.2d 490 (1983), à la p. 501 (infirmé pour d'autres motifs *sub nom. Capital Cities Cable, Inc. c. Crisp*, 467 U.S. 691 (1984)), la Court of Appeals for the Tenth Circuit a fait observer que [TRADUCTION] «le dossier ne démontre pas que les lois de l'Oklahoma ont un effet direct sur la consommation de boissons alcoolisées», mais a conclu:

. . . prohibitions against the advertising of alcoholic beverages are reasonably related to reducing the sale and consumption of those beverages and their attendant problems. The entire economy of the industries that bring these challenges is based on the belief that advertising increases sales. We therefore do not believe that it is constitutionally unreasonable for the State of Oklahoma to believe that advertising will not only increase sales of particular brands of alcoholic beverages but also of alcoholic beverages generally. The choice of the Oklahoma legislature, and its people with respect to the constitutional provision, is not unreasonable, and does directly advance Oklahoma's interest in reducing the sale, consumption, and abuse of alcoholic beverages.

This "common-sense" approach to causation was also applied in *Metromedia, Inc. v. City of San Diego*, 453 U.S. 490 (1981) (finding that a ban on highway billboards was reasonably related to highway safety despite a lack of evidence in the record demonstrating this connection); *Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Co. of Puerto Rico*, 478 U.S. 328 (1986) (finding that a ban on casino advertising was rationally connected to the government objective to reduce demand for gambling despite a lack of evidence on the record); and *Dunagin*, *supra*, (finding that a ban on alcohol advertising directly advanced the legislative goal of reducing alcohol consumption despite a lack of evidence).

Minimal Impairment

95 The next step in the proportionality analysis is to determine whether the legislative means chosen impair the right or freedom in question as little as possible. The appellants submit that Parliament has unjustifiably imposed a complete prohibition on tobacco advertising and promotion when it could have imposed a partial prohibition with equal effectiveness. They suggest that Parliament could have instituted a partial prohibition by forbidding "lifestyle" advertising (which seeks to promote an

[TRADUCTION] . . . les interdictions imposées contre la publicité des boissons alcoolisées sont raisonnablement liées à la réduction des ventes et de la consommation de ces boissons, et des problèmes qu'elles entraînent. Toute l'économie des industries qui contestent ces interdictions est fondée sur l'idée que la publicité accroît les ventes. Nous ne croyons donc pas qu'il soit déraisonnable sur le plan constitutionnel pour l'État de l'Oklahoma de penser que la publicité permettra de faire augmenter non seulement les ventes de certaines marques de boissons alcoolisées, mais aussi celles des boissons alcoolisées en général. Le choix de la législature de l'Oklahoma et des citoyens de cet État en ce qui concerne la disposition constitutionnelle n'est pas déraisonnable, et favorise directement l'intérêt de l'Oklahoma dans la réduction des ventes, de la consommation et des abus de boissons alcoolisées.

Cette façon d'aborder la question de la causalité en se fondant sur «le bon sens» a aussi été adoptée dans *Metromedia, Inc. c. City of San Diego*, 453 U.S. 490 (1981) (où on a conclu qu'une interdiction de placer des panneaux d'affichage près des autoroutes était raisonnablement liée à la sécurité routière même si le dossier ne contenait pas de preuve démontrant ce lien); dans *Posadas de Puerto Rico Associates c. Tourism Co. of Puerto Rico*, 478 U.S. 328 (1986) (où on a conclu qu'une interdiction de faire la publicité de casinos avait un lien rationnel avec l'objectif du gouvernement de réduire la demande pour les jeux de hasard, malgré le manque de preuve au dossier), et dans *Dunagin*, précité (où on a conclu qu'une interdiction de la publicité des boissons alcoolisées appuyait directement l'objectif de la législature de réduire la consommation des boissons alcoolisées et ce, malgré un manque de preuve).

L'atteinte minimale

La prochaine étape de l'analyse de la proportionnalité consiste à déterminer si les moyens choisis par le législateur portent le moins possible atteinte au droit ou à la liberté en question. Les appelantes soutiennent que le Parlement a imposé de façon injustifiée une interdiction complète de la publicité et de la promotion des produits du tabac, alors qu'une interdiction partielle se serait avérée tout aussi efficace. Elles disent que le Parlement aurait pu imposer une interdiction partielle en pro-

image by associating the consumption of the product with a particular lifestyle) or advertising directed at children, without at the same time prohibiting "brand preference" advertising (which seeks to promote one brand over another based on the colour and design of the package) or "informational" advertising (which seeks to inform the consumer about product content, taste and strength and the availability of different or new brands). According to the appellants, there is no need to prohibit brand preference or informational advertising because both are targeted solely at smokers, and serve a beneficial function by promoting consumer choice.

hibant la publicité dite de «style de vie» (qui cherche à faire la promotion d'une image par l'association de la consommation du produit avec un style de vie particulier), ou la publicité destinée aux enfants, sans pour autant interdire la publicité de «marque» (qui cherche à faire préférer une marque à une autre à partir de la couleur et de la conception de l'emballage) ou la publicité «informative» (qui cherche à informer le consommateur au sujet du contenu, du goût et de la force du produit, de même que de la disponibilité de différentes ou de nouvelles marques). Selon les appelantes, il n'y a aucune raison d'interdire la publicité de marque ou la publicité informative, parce qu'elles s'adressent toutes deux aux seuls fumeurs et qu'elles ont une fonction bénéfique, celle de promouvoir le choix du consommateur.

In my view, the appellants' argument fails for the same reasons that I have discussed throughout my s. 1 analysis. The relevance of context cannot be understated in s. 1 balancing, particularly at the minimal impairment stage. This Court has on many occasions stated that the degree of required fit between means and ends will vary depending upon both the nature of the right and the nature of the legislation. As Dickson C.J. stated in the *Prostitution Reference*, *supra*, at p. 1136:

> When a *Charter* freedom has been infringed by state action that takes the form of criminalization, the Crown bears the heavy burden of justifying that infringement. Yet, the expressive activity, as with any infringed *Charter* right, should also be analyzed in the particular context of the case.

Thus, the minimal impairment requirement does not impose an obligation on the government to employ the least intrusive measures available. Rather, it only requires it to demonstrate that the measures employed were the least intrusive, in light of both the legislative objective and the infringed right. As Sopinka J. noted in *Butler*, *supra*, at pp. 504-5:

96 À mon avis, l'argument des appelantes ne peut être retenu et ce, pour les mêmes motifs que j'ai exprimés tout au long de mon analyse fondée sur l'article premier. On ne saurait sous-estimer la pertinence du contexte dans une pondération en vertu de l'article premier, particulièrement à l'étape du critère de l'atteinte minimale. Notre Cour a maintes fois déclaré que le degré de proportionnalité entre les moyens et les fins varie en fonction tant de la nature du droit en question que de la nature de la loi. Comme le juge en chef Dickson l'a affirmé dans le *Renvoi sur la prostitution*, précité, aux pp. 1135 et 1136:

> Lorsqu'une liberté garantie par la *Charte* a été violée par une mesure prise par l'État, en l'occurrence la criminalisation, le ministère public doit s'acquitter du lourd fardeau de justifier cette violation. Néanmoins, comme dans le cas de toute violation d'un droit reconnu par la *Charte*, l'activité d'expression devrait également être analysée dans le contexte particulier de l'affaire.

Par conséquent, l'exigence de l'atteinte minimale n'impose pas l'obligation au gouvernement d'avoir recours aux mesures disponibles les moins attentatoires. Cette exigence l'oblige seulement à démontrer que les mesures prises sont les moins attentatoires compte tenu tant de l'objectif législatif que du droit violé. Comme le juge Sopinka l'a constaté dans *Butler*, précité, aux pp. 504 et 505:

In determining whether less intrusive legislation may be imagined, this Court stressed in the *Prostitution Reference*, *supra*, that it is not necessary that the legislative scheme be the "perfect" scheme, but that it be appropriately tailored in the context of the infringed right. . . . [Emphasis in original.]

97 Taking into account the legislative context, it is my view that the measures adopted under the Act satisfy the *Oakes* minimal impairment requirement. It must be kept in mind that the infringed right at issue in these cases is the right of tobacco corporations to advertise the only legal product sold in Canada which, when used precisely as directed, harms and often kills those who use it. As I discussed above, I have no doubt that Parliament could validly have employed the criminal law power to prohibit the manufacture and sale of tobacco products, and that such a prohibition would have been fully justifiable under the *Charter*. There is no right to sell harmful products in Canada, nor should there be. Thus, in choosing to prohibit solely the advertisement of tobacco products, it is clear that Parliament in fact adopted a relatively unintrusive legislative approach to the control of tobacco products. Indeed, the scope of conduct prohibited under the Act is narrow. Under the Act, tobacco companies continue to enjoy the right to manufacture and sell their products, to engage in public or private debate concerning the health effects of their products, and to publish consumer information on their product packages pertaining to the content of the products. The prohibition under this Act serves only to prevent these companies from employing sophisticated marketing and social psychology techniques to induce consumers to purchase their products. This type of expression, which is directed solely toward the pursuit of profit, is neither political nor artistic in nature, and therefore falls very far from the "core" of freedom of expression values discussed by this Court in *Keegstra*, *supra*.

98 Furthermore, there was ample evidence introduced by the Attorney General at trial demonstrating that a full prohibition of tobacco advertising is justified and necessary. In enacting this legislation,

En déterminant s'il est possible d'imaginer une loi moins attentatoire, notre Cour a fait ressortir, dans le *Renvoi sur la prostitution*, précité, que le régime législatif n'a pas à être «parfait», mais qu'il doit être bien adapté au contexte du droit qui est violé . . . [Souligné dans l'original.]

Compte tenu du contexte législatif, je suis d'avis que les mesures adoptées en vertu de la Loi satisfont à l'exigence de l'atteinte minimale énoncée dans l'arrêt *Oakes*. Il faut se rappeler que le droit violé en l'espèce est le droit des compagnies de tabac de faire la publicité du seul produit vendu légalement au Canada qui, s'il est utilisé précisément de la façon recommandée, fait du tort à ceux qui l'utilisent ou souvent les tue. Comme il ressort de l'analyse qui précède, je n'ai aucun doute que le Parlement pouvait validement se servir de sa compétence en matière de droit criminel pour interdire la fabrication et la vente des produits du tabac, et qu'une telle interdiction aurait été pleinement justifiable en vertu de la *Charte*. On n'a pas et ne devrait pas avoir le droit de vendre des produits nocifs au Canada. Par conséquent, en choisissant d'interdire seulement la publicité des produits du tabac, le Parlement a de toute évidence adopté une démarche législative relativement non attentatoire pour exercer un contrôle sur les produits du tabac. En fait, l'étendue de l'interdiction est restreinte. Sous le régime de la Loi, les compagnies de tabac continuent de bénéficier du droit de fabriquer et de vendre leurs produits, de prendre part à des débats publics ou privés sur les effets de leurs produits sur la santé et d'apposer sur les emballages des messages quant au contenu de ces produits. L'interdiction visée par la Loi ne sert qu'à empêcher ces compagnies de recourir à des techniques complexes de commercialisation et de psychologie sociale pour inciter les consommateurs à acheter leur produits. Cette forme d'expression, qui vise seulement la réalisation de profits, n'est ni politique ni artistique et est donc très loin du «cœur» des valeurs de la liberté d'expression dont notre Cour a fait l'étude dans l'arrêt *Keegstra*, précité.

Par ailleurs, le procureur général a déposé une preuve volumineuse en première instance afin d'établir qu'une interdiction totale de publicité du tabac est à la fois justifiée et nécessaire. Lorsqu'il

Parliament came to the conclusion that all advertising stimulates consumption and that a full prohibition upon advertising is therefore necessary to reduce consumption effectively. Parliament reached this conclusion only after many years of careful study and reflection. As I mentioned in my discussion of the criminal law power, the measures adopted under the Act were the product of an intensive 20-year public policy process, which involved extensive consultation with an array of national and international health groups and numerous studies, and educational and legislative programs. Over the course of this 20-year period, the government adopted an incremental legislative approach by experimenting with a variety of less intrusive measures before determining that a full prohibition on advertising was necessary. As early as 1969, the Standing Committee of Health and Welfare and Social Affairs recommended a full prohibition in its *Report of the Standing Committee on Health, Welfare and Social Affairs on Tobacco and Cigarette Smoking*, *supra*, at pp. 52-53, suggesting the following legislative solution:

One year from enactment of legislation

- Complete elimination of free distribution of cigarettes and of all coupon and premium schemes.
- No cigarette advertising on television or radio before 10 p.m.
- Warning on all cigarette packages and cartons, in all cigarette advertising and promotional materials and on all cigarette vending machines.
- Government-authorized statements of tar and nicotine levels on all cigarette packages and cartons, in all cigarette advertising and promotional materials and on all cigarette vending machines.

Two years from enactment of legislation

- Prohibition of cigarette advertising on television and radio.

a adopté cette loi, le Parlement est arrivé à la conclusion que toute publicité incite à la consommation et qu'une interdiction totale de la publicité est en conséquence nécessaire pour réduire efficacement cette consommation. Le Parlement n'est arrivé à cette conclusion qu'après de nombreuses années d'études et de réflexions attentives. Comme je l'ai mentionné dans mon analyse de la compétence en matière de droit criminel, les mesures adoptées en vertu de la Loi sont le résultat d'un processus de politique d'intérêt public qui s'est poursuivi pendant 20 ans et qui a nécessité de longues consultations auprès d'une multitude de groupes du domaine de la santé, sur les plans tant national qu'international, ainsi que de nombreuses études et maints programmes éducatifs et législatifs. Au cours de cette période de 20 ans, le gouvernement a adopté une démarche législative graduelle en essayant toute une gamme de mesures moins attentatoires avant de déterminer qu'il était nécessaire d'interdire complètement la publicité. Dès 1969, le Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales a recommandé une interdiction complète dans le *Rapport du Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales sur l'usage du tabac et de la cigarette*, *op. cit.*, aux pp. 52 et 53, où il proposait la solution législative suivante:

Un an après la mise en vigueur de la loi

- Abolition totale de toute distribution gratuite de cigarettes ainsi que des systèmes de coupons ou de primes.
- Plus d'annonces de cigarettes à la télévision ou à la radio avant 10 h le soir.
- Avertissement sur tous les paquets et cartons de cigarettes, sur tout le matériel publicitaire et sur les machines distributrices.
- Mention contrôlée par le gouvernement du degré de goudron et de nicotine sur tous les paquets et cartons de cigarettes, sur tout le matériel publicitaire et sur les machines distributrices.

Deux ans après la mise en vigueur de la loi

- Abolition de toutes les annonces de cigarettes à la télévision et à la radio.

– Prohibition of other than simple brand name advertisements in remaining media.

Four years from enactment of legislation

– Complete elimination of all cigarette promotional activities.

Although the Standing Committee recommended a full prohibition upon tobacco advertising within four years, Parliament refrained from instituting a full prohibition and chose instead to implement a variety of lesser legislative measures. Since 1969, for example, the Department of National Health and Welfare has introduced and supported many educational programmes and many research and health promotion organizations; see, e.g., Health and Welfare Canada, *National Program to Reduce Tobacco Use: Orientation Manuals & Historical Perspective*, *supra*; Health and Welfare Canada, "Directional paper of the national program to reduce tobacco use in Canada", *supra*. Parliament has also sought to combat tobacco use by preventing the sale of tobacco to young persons (*Tobacco Sales to Young Persons Act*), restricting smoking in workplaces and public places (*Non-smokers' Health Act*) and by increases in tobacco taxes. However, despite all these efforts, it was apparent by 1989 that close to one-third of Canadians continued to smoke and that the decline in the numbers of smokers in Canada since 1969 had been neither rapid nor substantial. Faced with this distressing statistic, and with the seeming ineffectiveness of the measures adopted up to that time, Parliament had more than reasonable grounds for concluding that the more robust measures adopted under the Act were both necessary and a logical next step in the policy process.

99 The reasonableness of Parliament's decision to prohibit tobacco advertising has been amply borne out by parallel developments in the international community before and after the passage of the Act. It is of great significance, in my view, that over 20 democratic nations have, in recent years, adopted complete prohibitions on tobacco advertising simi-

– Pour les autres moyens de diffusion, abolition de toute publicité à l'exception des simples annonces de marques de commerce.

Quatre ans après la mise en vigueur de la loi

– Abolition totale de toute publicité sur les cigarettes.

Même si le Comité permanent avait recommandé une abolition totale de toute publicité du tabac sur une période de quatre ans, le Parlement s'est abstenu d'imposer une interdiction totale et a plutôt choisi de mettre en œuvre toute une gamme de mesures législatives moins sévères. Par exemple, depuis 1969, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social a mis en place et appuyé de nombreux programmes éducatifs et de nombreux organismes de recherche et de promotion de la santé; voir, p. ex., Santé et Bien-être social Canada, *National Program to Reduce Tobacco Use: Orientation Manuals & Historical Perspective*, *op. cit.*; Santé et Bien-être social Canada, «Document d'orientation du programme national de lutte contre le tabagisme au Canada», *op. cit.* Le Parlement a aussi cherché à combattre l'usage du tabac en interdisant la vente de produits du tabac aux jeunes (*Loi sur la vente du tabac aux jeunes*), en restreignant l'usage du tabac sur les lieux de travail et les lieux publics (*Loi sur la santé des non-fumeurs*) et en augmentant les taxes sur le tabac. Cependant, malgré tous ces efforts, on s'est rendu compte en 1989 que près d'un tiers des Canadiens continuaient de fumer et que la réduction du nombre de fumeurs au Canada depuis 1969 n'avait été ni rapide ni importante. Face à ces statistiques troublantes et à l'inefficacité apparente des mesures adoptées jusque-là, le Parlement avait des motifs plus que raisonnables de conclure que la prise de mesures plus énergiques en vertu de la Loi était nécessaire et constituait une prochaine étape logique du processus de politique d'intérêt public.

Le caractère raisonnable de la décision du Parlement d'interdire la publicité du tabac est amplement démontré par les développements parallèles dans la communauté internationale avant et après l'adoption de la Loi. À mon avis, il est très important de faire remarquer que, au cours des dernières années, plus de 20 pays démocratiques, dont

lar to those adopted under the Act, including Australia, New Zealand, Norway, Finland and France. It is also of significance that the constitutionality of full advertising prohibitions have been upheld by the French Conseil constitutionnel (Décision No. 90-283 DC (Jan. 8, 1991) declaring the *Loi nº 91-32 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme*, which prohibits all direct and indirect tobacco advertising), to be constitutionally valid and by American courts (upholding full prohibitions on alcohol advertising and gambling advertising as a reasonable limitation on freedom of expression under the United States Constitution in *Central Hudson*, *supra*; *Oklahoma Telecasters*, *supra*; *Metromedia*, *supra*; *Posadas*, *supra*; *Dunagin*, *supra*). The decisions of the American courts, which have traditionally been jealous guardians of the right to freedom of expression, are particularly instructive in this context because they demonstrate that the adoption of a full prohibition upon tobacco advertising is perceived as neither novel nor radical in other democratic nations. Given the background of the legislation and the overwhelming acceptance by other democratic countries of this type of prohibition as a reasonable means for combatting the serious evils flowing from the sale and distribution of tobacco products, it seems difficult to argue that the impugned legislation is not a reasonable limit on the appellants' rights demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1 of the *Charter*.

Thus, in my view, there was more than enough evidence adduced at trial to justify the government's decision to institute a full prohibition on advertising and promotion. In their argument before this Court, the appellants made much of the fact that, during the course of the trial, a certificate was issued by the Clerk of the Privy Council pursuant to s. 39 of the *Canada Evidence Act*, R.S.C. 1985, c. C-5, stating that certain documents requested by the appellants, many of which were departmental memoranda sent to the Minister of Health and Welfare, constituted "confidence[s] of

l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Finlande et la France, ont adopté une interdiction complète de publicité du tabac analogue à celle adoptée en vertu de la Loi. Il est également important de préciser que la constitutionnalité d'interdictions totales de la publicité a été reconnue par le Conseil constitutionnel en France (Décision nº 90-283 DC (8 janv. 1991), qui a déclaré valide la *Loi nº 91-32 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme*, qui interdit toute publicité directe ou indirecte du tabac) et par les tribunaux américains (qui ont maintenu, dans les arrêts *Central Hudson*, *Oklahoma Telecasters*, *Metromedia*, *Posadas*, et *Dunagin*, précités, des interdictions totales de la publicité des boissons alcoolisées et des jeux de hasard parce qu'elles sont des restrictions raisonnables de la liberté d'expression garantie par la Constitution des États-Unis). Les décisions des tribunaux américains, qui ont toujours jalousement protégé le droit à la liberté d'expression, sont particulièrement intéressantes dans ce contexte parce qu'elles établissent que l'adoption d'une interdiction complète de publicité du tabac n'est considérée ni comme nouvelle ni comme radicale dans d'autres pays démocratiques. Vu l'historique de la loi et l'acceptation générale que les autres pays démocratiques donnent à ce type d'interdiction comme moyen raisonnable de lutter contre les graves problèmes découlant de la vente et de la distribution des produits du tabac, il semble difficile de soutenir que la loi attaquée ne constitue pas une limite raisonnable aux droits des appelantes, dont la justification puisse se démontrer dans une société libre et démocratique, en application de l'article premier de la *Charte*.

À mon avis, on a donc présenté en première instance plus d'éléments de preuve qu'il ne le fallait pour justifier la décision du gouvernement d'établir une interdiction complète de la publicité et de la promotion. Dans leur argumentation devant notre Cour, les appelantes ont accordé beaucoup d'importance au fait que, pendant le procès, le greffier du Conseil privé avait attesté, conformément à l'art. 39 de la *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5, que certains documents demandés par les appelantes, dont bon nombre étaient des mémoires ministériels envoyés au

the Queen's Privy Council for Canada". As a result of the objection taken by the Privy Council, all references in the requested documents to an unidentified and alternative policy option were blacked out. The appellants speculate that this mysterious policy option was less intrusive than the measures adopted under the Act and argue on this basis that a full prohibition on advertising was not the only option available to the government.

ministre de la Santé et du Bien-être social, constituaient des «renseignement[s] confidentiel[s] du Conseil privé de la Reine pour le Canada». À la suite de l'objection formulée par le Conseil privé, toute mention d'une autre option de principe non identifiée a été biffée des documents. Les appelantes estiment que cette mystérieuse option de principe était moins attentatoire que les mesures adoptées en vertu de la Loi, et soutiennent sur ce fondement qu'une interdiction complète de publicité n'était pas la seule option offerte au gouvernement.

101 Although I believe the appellants have raised a legitimate concern with respect to the effect of governmental claims to confidentiality in constitutional cases, I cannot accept that the resort by the government to Cabinet confidentiality in this context is fatal to this legislation. The appellants are right to argue that claims to confidentiality have the effect of withholding from the factual record evidence relating to available governmental options and thus compromise the ability of courts in some cases to evaluate the constitutionality of governmental actions properly. For the same reasons, the appellants are also right to argue that the exercise of this power will at times undermine attempts by the government to justify legislation under the *Charter*. The onus is on the government to establish minimal impairment and in this context it is difficult to understand why it could not make the information available. It is right to say, however, that during the course of the litigation the appellants studiously refrained from taking the steps that could have been taken to obtain the information available. It is significant that the appellants failed to challenge the Certificate issued by the Clerk of the Privy Council, as they were clearly entitled to do under s. 39 of the *Canada Evidence Act*; see, e.g., *Canadian Assn. of Regulated Importers v. Canada (Attorney General)*, [1992] 2 F.C. 130 (C.A.); *Canada (Attorney General) v. Central Cartage Co.*, [1990] 2 F.C. 641 (C.A.). That said, the responsibility was ultimately that of the government, and in acting as it did, it

Bien que, selon moi, les appelantes aient soulevé une préoccupation légitime relativement à l'effet des demandes gouvernementales en matière de confidentialité dans les affaires constitutionnelles, je ne puis accepter que le recours à la confidentialité des documents du Cabinet, revendiquée par le gouvernement dans le présent contexte, soit fatal pour la validité de la loi. Les appelantes ont raison de soutenir que les demandes de confidentialité ont pour effet de retirer du dossier des faits des éléments de preuve relatifs aux options offertes au gouvernement et, en conséquence, de nuire dans certains cas à la capacité des tribunaux de bien évaluer la constitutionnalité des mesures gouvernementales. Pour les mêmes motifs, les appelantes ont également raison de soutenir que l'exercice de ce pouvoir portera parfois atteinte aux tentatives du gouvernement de justifier une loi en vertu de la *Charte*. Il appartient au gouvernement de prouver l'atteinte minimale et dans ce contexte il est difficile de comprendre pourquoi il ne pourrait pas permettre l'accès à ces renseignements. Cependant, on a raison d'affirmer que les appelantes se sont délibérément abstenues, tout au long du litige, de prendre les mesures qui leur auraient permis d'obtenir les renseignements visés. Il importe de préciser que les appelantes ont omis de contester l'attestation donnée par le greffier du Conseil privé, comme elles avaient clairement le droit de le faire en vertu de l'art. 39 de la *Loi sur la preuve au Canada*; voir par exemple, *Canadian Assn. of Regulated Importers c. Canada (Procureur général)*, [1992] 2 C.F. 130 (C.A.), et *Canada (Procureur général) c. Central Cartage Co.*, [1990] 2 C.F. 641 (C.A.). Cela dit, la responsabilité incom-

put this Court in the difficult position of having to speculate about the contents of documents.

The real answer to the appellants' contention, however, is that such speculation cannot, in my view, displace the overwhelming evidence that the prohibition was a reasonable one. Even if it were true that the government was considering a less intrusive option prior to adopting the Act, I do not accept that this in any way undermines the Attorney General's argument that the Act minimally impairs the appellants' rights in light of the legislative objective. A partial prohibition on advertising would only have been required under the *Charter* if it had been clear to Parliament that some forms of advertising do not stimulate consumption, and that a full prohibition would accordingly be overbroad. However, the Attorney General demonstrated convincingly at trial that Parliament had a reasonable basis for believing, after 20 years of research and legislative experimentation, that all tobacco advertising stimulates tobacco consumption. As I explained in my rational connection discussion above, it is reasonable to conclude that all advertising stimulates consumption because all advertising serves to place tobacco products in the public eye and to give these products legitimacy, particularly among the young. Indeed, the appellants' emphasis in their own marketing documents on the colour and "look" of tobacco packages demonstrates that the companies themselves recognize that even purely "informational" advertising has an important effect on consumption.

Moreover, in considering the comparative advantages of partial and full advertising prohibitions, it is also significant that, in countries where governments have instituted partial prohibitions upon tobacco advertising such as those suggested by the appellants, the tobacco companies have developed ingenious tactics to circumvent the restrictions. For example, when France attempted to institute a partial prohibition on tobacco adver-

bait finalement au gouvernement, et en agissant comme il l'a fait, ce dernier place notre Cour dans une position difficile qui la force à conjecturer sur le contenu de ces documents.

Cependant, la véritable réponse à l'argument des appelantes est que cette conjecture ne peut, à mon avis, modifier la preuve accablante que l'interdiction était raisonnable. Même s'il était exact que, avant l'adoption de la Loi, le gouvernement examinait une option moins attentatoire, je n'accepte pas que ce facteur affaiblisse d'une façon quelconque l'argument du procureur général que la Loi constitue une atteinte minimale aux droits des appelantes compte tenu de l'objectif législatif. Une interdiction partielle de la publicité n'aurait été exigée en vertu de la *Charte* que s'il avait été clair dans l'esprit du législateur que certaines formes de publicité n'incitent pas à la consommation, et qu'une interdiction complète aurait donc une portée trop vaste. Cependant, le procureur général a établi de façon convaincante en première instance que le Parlement avait des motifs raisonnables de croire, après 20 ans de recherche et d'expérimentation législative, que toute publicité du tabac incite à l'usage du tabac. Comme je l'ai expliqué dans mon analyse du lien rationnel, il est raisonnable de conclure que toute publicité encourage la consommation parce que la publicité présente les produits du tabac au public et leur donne un caractère légitime, particulièrement chez les jeunes. En fait, l'importance que les appelantes accordent dans leurs propres documents de commercialisation à l'incidence sur les ventes de la couleur et de l'«aspect» des emballages des produits du tabac montre que les compagnies reconnaissent que même la publicité qui est purement «informative» a un effet important sur la consommation. 102

En outre, dans l'examen des avantages comparatifs des interdictions partielles ou complètes de la publicité, il est également révélateur que, dans les pays où les gouvernements ont imposé des interdictions partielles de la publicité du tabac comme celles proposées par les appelantes, les compagnies de tabac ont trouvé d'ingénieuses tactiques pour contourner ces restrictions. Par exemple, lorsque la France a tenté d'imposer une interdiction partielle 103

tising in the 1980s (by prohibiting "lifestyle" tobacco advertising but not informational or brand preference advertising), the tobacco companies devised techniques for associating their product with "lifestyle" images which included placing pictures on the brand name and reproducing those pictures when an advertisement showed the package, and taking out a full-page magazine advertisement and subcontracting three-quarters of the advertisement to Club Med, whose lifestyle advertisements contributed to a lifestyle association for the brand; see Luc Joossens, "Strategy of the Tobacco Industry Concerning Legislation on Tobacco Advertising in some Western European Countries" in *Proceedings of the 5th World Conference on Smoking and Health* (1983).

104 Thus, it appears that Parliament had compelling reasons for rejecting a partial prohibition on advertising and instituting a full prohibition. In this light, it would be highly artificial for this Court to decide, on a purely abstract basis, that a partial prohibition on advertising would be as effective as a full prohibition. In my view, this is precisely the type of "line drawing" that this Court has identified as being within the institutional competence of legislatures and not courts. The Court made this clear in *Irwin Toy*, *supra*, where it stated, at p. 990, that the government should be given "a margin of appreciation to form legitimate objectives based on somewhat inconclusive social science evidence". In *Irwin Toy*, this Court found ss. 248 and 249 of the *Consumer Protection Act*, R.S.Q., c. P-40.1, which prohibited the use of commercial advertising directed at persons under 13 years of age, to be an infringement of s. 2(*b*) of the *Charter*, but upheld the legislation under s. 1. The Court there observed that there was conflicting social science evidence on whether the appropriate legislative line was to be drawn at 13 years of age or a younger age and, at p. 990, observed:

> If the legislature has made a reasonable assessment as to where the line is most properly drawn, especially if that

de la publicité du tabac dans les années 80 (en interdisant la publicité du tabac de type «style de vie», mais non la publicité informative ou de marque), les compagnies de tabac ont trouvé des techniques pour associer leurs produits à des «styles de vie», par exemple, en plaçant des vignettes sur le nom de la marque et en reproduisant ces vignettes lorsqu'une annonce montrait le paquet, ou en achetant pour la publicité une pleine page d'un magazine, puis en revendant les trois-quarts de la page au Club Med, dont la publicité de style de vie contribuait à associer un style de vie à la marque; voir Luc Joossens, «Strategy of the Tobacco Industry Concerning Legislation on Tobacco Advertising in some Western European Countries» dans *Proceedings of the 5th World Conference on Smoking and Health* (1983).

Il semble donc que le Parlement avait des motifs impératifs de rejeter une interdiction partielle de la publicité et d'imposer plutôt une interdiction totale. C'est pourquoi notre Cour ferait un geste tout à fait artificiel si elle décidait, purement dans l'abstrait, qu'une interdiction partielle de la publicité serait aussi efficace qu'une interdiction totale. À mon avis, c'est précisément le type de «ligne de démarcation » que notre Cour a déclaré être du ressort des législatures et non des tribunaux. Notre Cour a été claire sur ce point dans l'arrêt *Irwin Toy*, précité, où elle a déclaré, à la p. 990, que le gouvernement devait disposer «d'une certaine latitude pour formuler des objectifs légitimes fondés sur des preuves en matière de sciences humaines qui n'étaient pas totalement concluantes». Dans cet arrêt, notre Cour a conclu que les art. 248 et 249 de la *Loi sur la protection du consommateur*, L.R.Q., ch. P-40.1, qui interdisaient la publicité commerciale destinée aux personnes de moins de 13 ans, violaient l'al. 2*b*) de la *Charte*, mais elle a maintenu la loi en vertu de l'article premier. La Cour a alors fait observer que les éléments de preuve en matière de sciences humaines étaient contradictoires quant à savoir si la ligne de démarcation que devait tracer la loi devait se situer à 13 ans ou à un âge encore plus jeune, et, à la p. 990, elle a fait observer:

> Si le législateur a fait une évaluation raisonnable quant à la place appropriée de la ligne de démarcation, surtout

assessment involves weighing conflicting scientific evidence and allocating scarce resources on this basis, it is not for the court to second guess. That would only be to substitute one estimate for another.

The Court decided that the government's choice of 13 years as the cutoff line was reasonable in light of the available evidence, and thus concluded, at p. 999:

> While evidence exists that other less intrusive options reflecting more modest objectives were available to the government, there is evidence establishing the necessity of a ban to meet the objectives the government had reasonably set. This Court will not, in the name of minimal impairment, take a restrictive approach to social science evidence and require legislatures to choose the least ambitious means to protect vulnerable groups.

This Court adopted a similar deferential approach in *Edwards Books and Art Ltd.*, *supra*, in deciding that ss. 2(1) and 3(4) of the *Retail Business Holidays Act*, R.S.O. 1980, c. 453, which prohibited retail stores with more than seven employees or more than 5,000 square feet of retail space from carrying on business on Sundays, was a justifiable infringement of freedom of religion under s. 1 of the *Charter* because it provided a mandatory day of rest for workers who would otherwise be vulnerable to pressure from employers. In that case, the appellants, a group of large retail store owners, argued that the legislature had failed to adduce sufficient evidence demonstrating that the legislation minimally impaired their rights under the *Charter*. In particular, they argued that the legislature had not adduced evidence justifying the exemption for owners of retail stores with less than eight employees. In addressing their claim, Dickson C.J. first observed, at p. 769, that the state had adduced only one Ontario Law Reform Commission report (the 1970 *Report on Sunday Observance Legislation*) in support of the distinctions drawn in the legislation, and that the Report was over 15 years old. Despite the lack of evidence on the record, however, Dickson C.J. concluded that the legislature was entitled to a degree of deference in fashioning the legislative means to accomplish that goal. While observing that other legislative

quand cette évaluation exige l'appréciation de preuves scientifiques contradictoires et la répartition de ressources limitées, il n'appartient pas aux tribunaux de se prononcer après coup. Ce serait seulement substituer une évaluation à une autre.

La Cour a décidé que le choix du gouvernement de tracer la ligne de démarcation à 13 ans était raisonnable compte tenu de la preuve disponible, et elle a conclu, à la p. 999:

> Bien que, selon la preuve, le gouvernement dispose d'autres options comportant une intrusion moindre qui répondent à des objectifs plus modestes, la preuve démontre aussi la nécessité d'interdire la publicité pour parvenir aux objectifs que le gouvernement s'est raisonnablement fixés. Cette Cour n'adoptera pas une interprétation restrictive de la preuve en matière de sciences humaines, au nom du principe de l'atteinte minimale, et n'obligera pas les législatures à choisir les moyens les moins ambitieux pour protéger des groupes vulnérables.

105 Notre Cour a adopté de façon similaire une attitude de retenue dans l'arrêt *Edwards Books*, précité, statuant que les par. 2(1) et 3(4) de la *Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail*, L.R.O. 1980, ch. 453, qui interdisaient aux magasins de détail employant plus de sept personnes ou consacraient plus de 5 000 pieds carrés au commerce de détail de faire des affaires le dimanche, étaient une atteinte justifiable à la liberté de religion en vertu de l'article premier de la *Charte*, parce qu'ils prévoyaient un jour de repos obligatoire pour les employés, qui, autrement, auraient été dans une position vulnérable face aux demandes pressantes des employeurs. Dans cette affaire, les appelants, un groupe de propriétaires de grands magasins de détail, ont allégué que la législature avait fait défaut de déposer une preuve suffisante pour démontrer que sa loi portait atteinte de façon minimale à leurs droits garantis par la *Charte*. Plus particulièrement, ils ont fait valoir que la législature n'avait pas déposé de preuve justifiant l'exemption accordée aux propriétaires de magasins de détail employant moins de huit employés. Examinant leur demande, le juge en chef Dickson a d'abord fait observer, à la p. 769, que l'État n'avait déposé qu'un rapport de la Commission de réforme du droit de l'Ontario (*Report on Sunday Observance Legislation* de 1970) à l'appui de la distinction faite par la loi, et que le rapport datait de plus de

options were conceivable, including a Sabbatarian exemption, which would have impaired the rights of retail owners to a lesser degree, Dickson C.J. stated, at p. 782, that "[t]he courts are not called upon to substitute judicial opinions for legislative ones as to the place at which to draw a precise line". He concluded, at p. 783:

> I should emphasize that it is not the role of this Court to devise legislation that is constitutionally valid, or to pass on the validity of schemes which are not directly before it, or to consider what legislation might be the most desirable.

I concurred with Dickson C.J. in that case, and stressed, at p. 795, that it was necessary, in that context, to give the legislature "room to manoeuvre" in fashioning legislation designed to mediate between different social interests and to protect vulnerable groups. My approach was later accepted by this Court in *R. v. Schwartz*, [1988] 2 S.C.R. 443, at pp. 488-89; *Andrews*, *supra*, at pp. 184-86, 197-98; and *Cotroni*, *supra*, at p. 1495.

106 In my view, the Court's approach in *Edwards Books* and *Irwin Toy* is directly applicable to the present cases. Tobacco consumption is a multifaceted problem which requires intervention from a variety of public authorities on a number of different fronts. Parliament has adopted an incremental solution by prohibiting advertising without, at the same time, prohibiting the consumption, manufacture or sale of tobacco. In so doing, it has chosen a policy approach that strives to balance the rights of tobacco smokers and manufacturers against the legitimate public health concerns arising from tobacco addiction including, most importantly, the special vulnerabilities of young Canadians. In my view, it is not the role of this Court to substitute its opinion for that of Parliament con-

15 ans. En dépit du manque de preuve au dossier, le juge en chef Dickson a toutefois conclu que la législature avait droit à une certaine retenue quant à son choix des moyens législatifs propres à atteindre l'objectif visé. Tout en faisant observer que d'autres options législatives étaient concevables, dont une exemption pour le sabbat, qui aurait porté atteinte dans une moindre mesure aux droits des propriétaires de magasins de détail, le juge en chef Dickson a affirmé, à la p. 782, que «[l]es tribunaux ne sont pas appelés à substituer des opinions judiciaires à celles du législateur quant à l'endroit où tracer une ligne de démarcation». Il a conclu, à la p. 783:

> Je tiens à souligner qu'il n'appartient pas à cette Cour de concevoir une loi qui soit constitutionnellement valide, de se prononcer sur la validité de régimes dont elle n'est pas saisie directement, ni d'examiner quelles mesures législatives pourraient être les plus souhaitables.

J'ai souscrit à l'avis du juge en chef Dickson dans cette affaire, et j'ai fait ressortir, à la p. 795, qu'il était nécessaire, dans un tel contexte, de donner à la législature une «marge de manœuvre» dans la façon d'élaborer une loi visant à faire la médiation entre des intérêts sociaux opposés et à protéger les groupes vulnérables. Mon point de vue a par la suite été accepté par notre Cour dans *R. c. Schwartz*, [1988] 2 R.C.S. 443, aux pp. 488 et 489; dans *Andrews*, précité, aux pp. 184 à 186, 197 et 198; et dans *Cotroni*, précité, à la p. 1495.

À mon avis, la démarche adoptée par la Cour dans *Edwards Books* et *Irwin Toy* est directement applicable aux présents pourvois. La consommation du tabac est un problème comportant de multiples aspects qui requiert l'intervention de nombreuses autorités publiques s'y attaquant sur différents fronts. Le Parlement a adopté une solution graduelle en interdisant la publicité sans interdire aussi l'usage, la fabrication ou la vente des produits du tabac. Ce faisant, il a choisi une démarche qui cherche à établir un équilibre entre les droits des fumeurs et des fabricants et les préoccupations légitimes en matière de santé publique que constitue la dépendance au tabac, tout particulièrement en ce qui concerne les jeunes. À mon avis, notre Cour n'a pas à substituer son

cerning the ideal legislative solution to this complex and wide-ranging social problem. As McLachlin J. observed in *Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada*, [1991] 1 S.C.R. 139, at p. 248:

> . . . some deference must be paid to the legislators and the difficulties inherent in the process of drafting rules of general application. A limit prescribed by law should not be struck out merely because the Court can conceive of an alternative which seems to it to be less restrictive.

In reaching the conclusion that the Act satisfies the *Oakes* minimal impairment criterion, I am well aware of the statements of this Court in *Ford*, *supra*, and *Rocket*, *supra*, to the effect that a complete prohibition on a type of expression will be more difficult to justify than a partial prohibition. In my view, however, these decisions are fully distinguishable from the present cases. Once again, I emphasize the importance of context in the minimal impairment analysis. In *Rocket*, this Court found that a prohibition on advertising by dentists under s. 37(39) and (40) of *Regulation 447 of the Health Disciplines Act*, R.R.O. 1980, was an infringement of s. 2(*b*) and could not be justified under s. 1. McLachlin J. began her s. 1 analysis by observing, at p. 247, that restrictions on freedom of expression may be easier to justify in some contexts than others:

> The expression limited by this regulation is that of dentists who wish to impart information to patients or potential patients. Their motive for doing so is, in most cases, primarily economic. Conversely, their loss, if prevented from doing so, is merely loss of profit, and not loss of opportunity to participate in the political process or the 'marketplace of ideas', or to realize one's spiritual or artistic self-fulfilment: see *Irwin Toy*, *supra*, at p. 976. This suggests that restrictions on expression of this kind might be easier to justify than other infringements of s. 2(*b*).

Despite her recognition of the importance of context, however, McLachlin J. struck down the legis-

opinion à celle du Parlement quant à ce que serait la solution législative idéale à ce problème social complexe et répandu. Comme le juge McLachlin l'a fait observer dans *Comité pour la République du Canada c. Canada*, [1991] 1 R.C.S. 139, à la p. 248:

> . . . il convient d'avoir de l'égard pour les législateurs et les difficultés inhérentes au processus de rédaction des règles d'application générale. Il ne faudrait pas annuler une limite prescrite par une règle de droit tout simplement parce que le tribunal peut concevoir une autre solution qui lui semble moins restrictive.

Arrivant à la conclusion que la Loi satisfait au critère de l'atteinte minimale formulé dans *Oakes*, je suis bien conscient des affirmations de notre Cour dans *Ford* et *Rocket*, précités, selon lesquelles une interdiction totale d'un type d'expression est plus difficile à justifier qu'une interdiction partielle. À mon avis, toutefois, la présente espèce se distingue tout à fait de ces arrêts. À nouveau, j'insiste sur l'importance du contexte dans l'analyse de l'atteinte minimale. Dans *Rocket*, notre Cour a conclu que l'interdiction de la publicité pour le compte des dentistes décrétée par le par. 37(39) et (40) du *Regulation 447 of the Health Disciplines Act*, R.R.O. 1980, violait l'art. 2*b*) et ne pouvait se justifier par l'article premier. Le juge McLachlin a commencé son analyse fondée sur l'article premier en faisant observer, à la p. 247, que les restrictions à la liberté d'expression peuvent être plus faciles à justifier dans certains contextes que dans d'autres: 107

> L'expression qui est restreinte par ce règlement est celle de dentistes qui désirent communiquer des renseignements à des patients réels ou éventuels. Dans la plupart des cas, leur raison d'agir ainsi est principalement d'ordre économique. À l'inverse, s'ils sont empêchés d'agir ainsi, la perte qu'ils subissent est simplement une perte de bénéfice et non une perte d'occasion de participer au processus politique ou au «marché des idées», ou de réaliser un épanouissement personnel sur le plan spirituel ou artistique: voir *Irwin Toy*, précité, à la p. 976. Cela laisse entendre qu'il se pourrait que des restrictions imposées à des expressions de ce genre soient plus faciles à justifier que d'autres atteintes à l'al. 2*b*).

En dépit du fait qu'elle ait reconnu l'importance du contexte, le juge McLachlin a cependant déclaré la

lative provision on the ground that it did not minimally impair the right to freedom of expression. She noted that the expression in question, the advertisement of dentistry services, had social value in the measure that it gave consumers access to information that would enable them to make informed health care choices. To the extent that the impugned legislative provision denied consumers such information, she observed, such an infringement could not lightly be dismissed. She stated, at p. 250:

> It is easy to think of examples of expression not falling within the exceptions which should clearly be permitted. For example, it is conceded that dentists should be able to advertise their hours of operation and the languages they speak, information which would be useful to the public and present no serious danger of misleading the public or undercutting professionalism.

She then stated, at p. 251:

> . . . the value served by free expression in the case of professional advertising is not purely the enhancement of the advertiser's opportunity to profit, as was the case in *Irwin Toy*. The public has an interest in obtaining information as to dentists' office hours, the languages they speak, and other objective facts relevant to their practice — information which s. 37(39) prohibits dentists from conveying by advertising.

disposition invalide pour le motif qu'elle ne portait pas atteinte à la liberté d'expression d'une façon minimale. Elle a fait remarquer que l'expression en question, soit la publicité de services de soins dentaires, avait une valeur sociale dans la mesure où elle donnait aux consommateurs accès à de l'information qui leur permettrait de faire des choix éclairés en matière de soins de santé. Dans la mesure où la disposition contestée nierait cette information aux consommateurs, fait-elle observer, une telle violation ne peut être écartée à la légère. Elle affirme, à la p. 250:

> Il est facile d'imaginer des exemples d'expressions qui ne s'inscrivent pas dans les exceptions et qui seraient clairement autorisées. Par exemple, on reconnaît que les dentistes devraient être en mesure d'annoncer leurs heures de bureau et les langues qu'ils parlent; ce sont des renseignements qui seraient utiles pour le public et qui ne présentent aucun danger grave d'induire le public en erreur ou de diminuer le professionnalisme.

Puis, elle ajoute à la p. 251:

> . . . la valeur appuyée par la liberté d'expression dans le cas de la publicité professionnelle n'est pas purement une augmentation de la possibilité de l'annonceur de réaliser des bénéfices comme c'était le cas dans l'arrêt *Irwin Toy*. Le public a intérêt à obtenir des renseignements sur les heures de bureau du dentiste, sur la langue qu'il parle et sur d'autres faits objectifs pertinents à son travail — des renseignements que le par. 37(39) interdit au dentiste de transmettre par la publicité.

108 It appears, then, that the contextual basis for McLachlin J.'s decision was that s. 37(39) of the *Regulation 447 of the Health Disciplines Act* operated to prohibit many aspects of advertising by dentists that serve to promote public health (i.e., advertising of hours of operation, language spoken and other aspects relating to their practice). No such argument can be made with respect to tobacco advertising. This type of expression serves to promote an activity which, in contrast to dentistry, is inherently dangerous and has no redeeming public health value. Indeed, the contrast with *Rocket* could not be more striking. Making an informed choice about dentists serves to promote

Il semble donc que le contexte sur lequel le juge McLachlin a appuyé sa décision ait été que le par. 37(39) du *Regulation 447 of the Health Disciplines Act* avait pour effet d'interdire de nombreux aspects de la publicité pour le compte des dentistes qui servent à promouvoir la santé publique (c.-à-d. la publicité portant sur les heures de bureau, la langue parlée et d'autres aspects de l'exercice de leur profession). Aucun argument de ce genre ne peut être présenté en ce qui concerne la publicité des produits du tabac. Ce type d'expression sert à promouvoir une activité qui, par contraste avec la dentisterie, est de façon inhérente dangereuse et n'a aucun effet bénéfique sur la santé publique. En

health by allowing patients to seek out the best care; making an informed choice about tobacco simply permits consumers to choose between equally dangerous products. Although the appellants argue that informational advertising allows smokers to make informed health choices by giving them information about tobacco product content, and thereby permitting them to choose tobacco products with lower tar levels, they submit no evidence that such products are actually healthier, nor logically could they, since the evidence appears to point the other direction: such products are no safer than high tar products and serve mainly to induce smokers who might otherwise quit to keep smoking "lighter" brands; see e.g. the Report of the Surgeon General of the United States, *Reducing the Health Consequences of Smoking — 25 Years of Progress — A report of the Surgeon General*, *supra*, at pp. 315-16, 664-65; Dr. Richard W. Pollay, "The Functions and Management of Cigarette Advertising", *supra*, at pp. 28-29; Report of Dr. Joel B. Cohen, "Effects of Cigarette Advertising on Consumer Behavior", *supra*, at pp. 41-42. Moreover, the appellants' argument, weak on an evidentiary level, is further undermined by the fact that consumers can still, under the Act, obtain product and health information at the point of sale and on the tobacco package (ss. 5 and 9).

A similar contrast can be drawn between the present cases and *Ford*, *supra*. In *Ford*, *supra*, this Court found that ss. 58, 69 and 205 to 208 of the Quebec *Charter of the French Language*, R.S.Q., c. C-11, which required public signs, posters and commercial advertising to be in the French language only, infringed s. 2(*b*) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* and could not be justified under s. 1. The Court based this decision

fait, le contraste avec l'arrêt *Rocket* ne pourrait pas être plus frappant. La possibilité de choisir son dentiste de façon éclairée contribue à la promotion de la santé en ce qu'elle permet aux patients de chercher à obtenir les meilleurs soins; la possibilité de faire un choix éclairé quant au tabac ne permet aux consommateurs de choisir qu'entre des produits également dangereux. Bien que les appelantes prétendent que la publicité informative permet aux fumeurs de faire des choix éclairés en ce qui concerne leur santé, parce qu'elle leur donne des renseignements sur le contenu des produits du tabac et qu'elle leur permet ainsi de choisir les produits du tabac qui ont les quantités de goudron les plus faibles, elles n'ont présenté aucune preuve établissant que ces produits sont de fait meilleurs pour la santé; elles en étaient de toute façon logiquement incapables, puisque la preuve paraît indiquer le contraire: ces produits ne sont pas plus sûrs que ceux qui contiennent de fortes quantités de goudron et ils servent principalement à inciter les fumeurs qui pourraient autrement cesser de fumer à continuer de fumer des marques plus «légères»; voir p. ex. le rapport du Surgeon General des États-Unis, *Reducing the Health Consequences of Smoking — 25 Years of Progress — A report of the Surgeon General*, *op. cit.*, aux pp. 315, 316, 664 et 665; Richard W. Pollay, «The Functions and Management of Cigarette Advertising», *op. cit.*, aux pp. 28 et 29, et le rapport de Joel B. Cohen, «Effects of Cigarette Advertising on Consumer Behavior», *op. cit.*, aux pp. 41 et 42. De plus, l'argument des appelantes, déjà faible sur le plan de la preuve, est encore davantage miné par le fait que, en vertu de la Loi, les consommateurs peuvent toujours obtenir des renseignements sur les produits et la santé au point de vente et sur l'emballage des produits du tabac (art. 5 et 9).

109 On peut constater le même contraste entre les présents pourvois et *Ford*, précité. Dans cet arrêt, notre Cour a conclu que les art. 58, 69 et 205 à 208 de *Charte de la langue française* du Québec, L.R.Q., ch. C-11, qui exigeaient que les affiches, les enseignes publiques et la publicité commerciale soient en français seulement, enfreignaient l'al. 2*b*) de la *Charte canadienne des droits et libertés* et ne pouvaient se justifier en vertu de l'article premier.

principally on the observation, at p. 780, that the prohibition was overbroad and thus did not satisfy the minimal impairment requirement:

> . . . whereas requiring the predominant display of the French language, even its marked predominance, would be proportional to the goal of promoting and maintaining a French "*visage linguistique*" in Quebec and therefore justified under the Quebec *Charter* and the Canadian *Charter*, requiring the exclusive use of French has not been so justified.

110 However, there are two crucial distinctions between *Ford* and the present cases. First, although the infringed expression in *Ford* fell, as in the present cases, within the category of commercial expression, the nature and scope of the expression in these cases are quite different. While, in these cases, the Act prohibits only tobacco advertising, in *Ford*, the law prohibited all non-French commercial expression in Quebec. It was therefore much broader in scope than the prohibition under the Act. Moreover, while the Act prohibits expression that has little or no connection with "core" freedom of expression values, the commercial expression in *Ford* was intimately connected with such core values. The impugned law in that case represented an attempt by the government of Quebec to eradicate the commercial use in public of any language other than French. Given the close historical relationship between language, culture and politics in Canada, it cannot seriously be denied that the implications of this prohibition extended well beyond the commercial sphere and impacted upon the dignity of all minority language groups in Quebec. Indeed, the Court in *Ford*, *supra*, at p. 748, recognized this fact when it quoted with approval from *Reference re Manitoba Language Rights*, [1985] 1 S.C.R. 721, at p. 744, where the Court stated:

> The importance of language rights is grounded in the essential role that language plays in human existence, development and dignity. . . . Language bridges the gap

La Cour a fondé sa décision principalement sur l'observation qu'elle fait, à la p. 780, que l'interdiction est trop large et, par conséquent, ne respecte pas le principe de l'atteinte minimale:

> Alors qu'exiger que la langue française prédomine, même nettement, sur les affiches et les enseignes serait proportionnel à l'objectif de promotion et de préservation d'un «visage linguistique» français au Québec et serait en conséquence justifié en vertu des *Chartes* québécoise et canadienne, l'obligation d'employer exclusivement le français n'a pas été justifiée.

Il y a encore deux distinctions importantes à faire entre l'arrêt *Ford* et les présents pourvois. Premièrement, bien que la liberté d'expression violée dont il était question dans *Ford* tombe, comme en l'espèce, dans la catégorie de l'expression commerciale, la nature et la portée de l'expression dans chaque cas sont très différentes. Alors que, dans les cas qui nous occupent, la Loi interdit seulement la publicité du tabac, dans *Ford*, la loi interdisait, au Québec, toute expression commerciale qui n'était pas en français. L'interdiction avait donc une portée beaucoup plus grande que celle édictée en vertu de la Loi. En outre, alors que la Loi interdit une expression qui n'a que peu ou pas de lien avec le «cœur» des valeurs de la liberté d'expression, l'expression commerciale dont il était question dans *Ford* était intimement liée à ces valeurs fondamentales. La loi contestée représentait une tentative du gouvernement du Québec d'éliminer l'utilisation commerciale en public de toute langue autre que le français. Étant donné les liens étroits dans l'histoire du Canada entre langue, culture et politique, on ne peut sérieusement nier que l'interdiction avait une incidence qui s'étendait bien au-delà du domaine commercial et qu'elle avait des répercussions sur la dignité de tous les groupes linguistiques minoritaires au Québec. En fait, la Cour, dans *Ford*, précité, à la p. 748, a souligné ce fait lorsqu'elle a repris l'extrait suivant des motifs qu'elle avait exprimés dans le *Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba*, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 744:

> L'importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l'existence, le développement et la dignité de l'être humain.

between isolation and community, allowing humans to delineate the rights and duties they hold in respect of one another, and thus to live in society.

In my view, it cannot seriously be argued that the "dignity" of the three large corporations whose rights are infringed in these cases is in any way comparable to that of minority group members dealt with in *Ford*.

A second important distinction between *Ford* and the present cases relates to the quantity of evidence adduced to satisfy the minimal impairment requirement. In *Ford*, no evidence was adduced to show why the exclusion of all languages other than French was necessary to achieve the objective of protecting the French language and reflecting the reality of Quebec society. Indeed, the Court in that case stated, at p. 779:

> The section 1 and s. 9.1 [of the Quebec *Charter*] materials do not, however, demonstrate that the requirement of the use of French only is either necessary for the achievement of the legislative objective or proportionate to it. That specific question is simply not addressed by the materials. Indeed, in his factum and oral argument the Attorney General of Quebec did not attempt to justify the requirement of the exclusive use of French. He concentrated on the reasons for the adoption of the *Charter of the French Language* and the earlier language legislation, which, as was noted above, were conceded by the respondents.

By contrast, as I discussed above, the Attorney General in the present cases submitted a substantial body of documentation, drawn from national and international sources, to demonstrate that a full prohibition is rational and can be justified in a free and democratic society. I conclude that sufficient evidence was adduced to justify the Attorney General's submission.

Proportionality Between the Effects of the Legislation and the Objective

The third part of the proportionality analysis requires a proportionality between the deleterious and the salutary effects of the measures; see

[. . .] Le langage constitue le pont entre l'isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu'ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société.

À mon avis, on ne peut sérieusement avancer que la «dignité» des trois grandes sociétés dont les droits sont violés en l'espèce est de quelque façon comparable à celle de groupes minoritaires comme dans l'arrêt *Ford*.

L'autre distinction importante entre *Ford* et les présents pourvois se rapporte à la quantité des éléments de preuve déposés à l'appui de l'exigence de l'atteinte minimale. Dans *Ford*, aucune preuve n'a été déposée pour établir que l'exclusion de toutes les langues autres que le français était nécessaire pour atteindre l'objectif de protéger la langue française et de refléter la réalité de la société québécoise. En fait, la Cour a alors dit, à la p. 779: 111

> Toutefois, les documents se rapportant à l'article premier et à l'art. 9.1 [de la *Charte* québécoise] n'établissent pas que l'exigence de l'emploi exclusif du français est nécessaire pour atteindre l'objectif législatif ni qu'elle est proportionnée à cet objectif. Cette question précise n'est même pas abordée dans les documents. En fait, dans son mémoire et dans les arguments oraux, le procureur général du Québec n'a pas tenté de justifier l'exigence de l'emploi exclusif du français. Il a plutôt insisté sur les motifs de l'adoption de la *Charte de la langue française* et de la législation antérieure en matière linguistique, motifs qui, il faut le répéter, ne sont pas contestés par les intimées.

Par contre, comme je l'ai mentionné précédemment, le procureur général a déposé en l'espèce une preuve documentaire volumineuse, tirée de sources nationales et internationales, afin d'établir qu'une interdiction totale est rationnelle et qu'elle peut se justifier dans une société libre et démocratique. Je conclus que le procureur général a déposé une preuve suffisante pour appuyer ses observations.

Proportionnalité entre les effets de la loi et l'objectif

La troisième partie de l'analyse de la proportionnalité nécessite qu'il y ait proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets béné- 112

Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp., [1994] 3 S.C.R. 835, at pp. 890-91. For the reasons I have given with respect to both the nature of the legislation and the nature of the right infringed in these cases, it is my view that the deleterious effects of this limitation, a restriction on the rights of tobacco companies to advertise products for profit that are inherently dangerous and harmful, do not outweigh the legislative objective of reducing the number of direct inducements for Canadians to consume these products.

The Unattributed Health Message Requirement

113 I now turn to the appellants' final argument, namely, that s. 9 of the Act constitutes an unjustifiable infringement of their freedom of expression by compelling them to place on tobacco packages an unattributed health message. I agree, to use Wilson J.'s phrase, that if the effect of this provision is "to put a particular message into the mouth of the plaintiff, as is metaphorically alleged to be the case here", the section runs afoul of s. 2(*b*) of the *Charter*; see *Lavigne*, *supra*, at p. 267. This view had earlier been adopted by the whole Court in *Slaight Communications Inc. v. Davidson*, [1989] 1 S.C.R. 1038. There a labour arbitrator had, *inter alia*, required an employer, by way of remedy for unjustly dismissing an employee, to provide a letter of recommendation consisting only of uncontested facts found by the arbitrator. Speaking for the Court on this point, Lamer J. (as he then was) stated, at p. 1080: "freedom of expression necessarily entails the right to say nothing or the right not to say certain things".

114 I add that I do not accept the distinction sought to be drawn by the Attorney General that here the statement is one of fact, not of opinion. Whatever merit this distinction may have in other contexts, the line here is too fine to warrant the distinction. I thus have no difficulty holding that the health mes-

fiques des mesures; voir *Dagenais c. Société Radio-Canada*, [1994] 3 R.C.S. 835, aux pp. 890 et 891. Pour les motifs que j'ai exprimés en ce qui concerne tant la nature de la loi que celle du droit violé en l'espèce, je suis d'avis que les effets préjudiciables de la limitation, soit la restriction des droits des compagnies de tabac de faire de la publicité, dans un but commercial, sur des produits qui sont en soi dangereux et dommageables, ne l'emportent pas sur l'objectif de la loi de réduire le nombre des sources directes d'incitation à consommer ces produits faite aux Canadiens.

La nécessité de mises en garde non attribuées

Je me penche maintenant sur le dernier argument des appelantes, soit que l'art. 9 de la Loi constitue une violation injustifiable de leur liberté d'expression, les forçant à placer sur les emballages de produits du tabac un message relatif à la santé non attribué. Je conviens, pour utiliser les termes du juge Wilson, que si l'effet de cette disposition est «de faire dire des choses particulières au demandeur, pour formuler métaphoriquement l'allégation faite en l'espèce», l'article est contraire à l'al. 2*b*) de la *Charte*; voir *Lavigne*, précité, à la p. 267. Ce point de vue avait déjà été adopté par l'ensemble de notre Cour dans *Slaight Communications Inc. c. Davidson*, [1989] 1 R.C.S. 1038, où un arbitre avait, entre autres, exigé d'un employeur, en réparation d'un congédiement injuste, qu'il remette une lettre de recommandation ne comprenant que les faits qui, selon l'arbitre, n'avaient pas été contestés. S'exprimant au nom de la Cour sur ce point, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a affirmé à la p. 1080: «la liberté d'expression comporte nécessairement le droit de ne rien dire ou encore le droit de ne pas dire certaines choses».

J'ajoute que je n'accepte pas de faire la distinction que tente de faire le procureur général selon qui, en l'espèce, il s'agit d'un énoncé de fait, non d'opinion. Quel que soit le mérite que cette distinction puisse avoir dans d'autres contextes, la ligne de démarcation est en l'espèce trop ténue pour permettre cette distinction. Je n'ai par conséquent aucune difficulté à statuer que la mise en

sage is expression as that term is understood in s. 2(*b*).

I have, however, more fundamental problems accepting the appellants' contention that their s. 2(*b*) right was infringed by the requirement that a prescribed health warning must be placed on tobacco packages. It must be remembered that this statement is unattributed and I have some difficulty in seeing, in the context in which it was made, that it can in any real sense be considered to be attributed to the appellants. Simply because tobacco manufacturers are required to place unattributed warnings on their products does not mean that they must endorse these messages, or that they are perceived by consumers to endorse them. In a modern state, labelling of products, and especially products for human consumption, are subject to state regulation as a matter of course. It is common knowledge amongst the public at large that such statements emanate from the government, not the tobacco manufacturers. In this respect, there is an important distinction between messages directly attributed to tobacco manufacturers, which would create the impression that the message emanates from the appellants and would violate their right to silence, and the unattributed messages at issue in these cases, which emanate from the government and create no such impression. Seen in this way, the mandatory health warnings under s. 9 are no different from unattributed labelling requirements under the *Hazardous Products Act*, under which manufacturers of hazardous products are required to place unattributed warnings, such as "DANGER" or "POISON", and hazard symbols, such as skull and crossbones on their products; see *Consumer Chemicals and Containers Regulations*, SOR/88-556. I should add that the issue has ramifications for many other spheres of activity where individuals may in certain prescribed circumstances be required to place danger signs on facilities used by the public or on construction sites, and so on. This is not really an expression of opinion by the person in control of the facility or the construction site. It is rather a requirement

garde concernant la santé est une expression dans le sens où ce terme est entendu à l'al. 2*b*).

J'ai cependant beaucoup plus de difficulté à 115
accepter la prétention des appelantes selon laquelle le droit que leur garantit l'al. 2*b*) a été violé par l'obligation d'inscrire une mise en garde particulière sur les emballages de produits du tabac. Il faut se rappeler que cet énoncé est non attribué, et je peux difficilement voir comment, dans le contexte où il a été fait, il pourrait, en réalité, être attribué aux appelantes. Le simple fait que les fabricants de produits du tabac sont tenus d'inscrire des mises en garde non attribuées sur leurs produits ne signifie pas qu'ils doivent souscrire à ces messages, ou qu'ils sont perçus par les consommateurs comme y souscrivant. Dans un État moderne, il est du cours normal des choses que l'étiquetage des produits, et particulièrement des produits destinés à la consommation humaine, soit soumis à la réglementation de l'État. Le public sait bien que ces messages émanent du gouvernement, et non des fabricants des produits du tabac. Ainsi, il y a une importante distinction à faire entre les messages directement attribués aux fabricants de produits du tabac, qui créeraient l'impression qu'ils émanent des appelantes et violeraient leur droit de garder le silence, et les messages non attribués en litige dans les présents pourvois, qui émanent du gouvernement et qui ne créent pas pareille impression. Vues de cette façon, les mises en garde exigées par l'art. 9 ne sont pas différentes des exigences en matière d'inscription de messages non attribués imposées par la *Loi sur les produits dangereux*, en vertu de laquelle les fabricants de produits dangereux sont tenus d'apposer sur leurs produits des mises en garde non attribuées, telles que «DANGER» ou «POISON», et des signaux de danger, tels qu'une tête de mort et tibias croisés; voir le *Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs*, DORS/88-556. Je crois devoir dire que la question s'étend à de nombreux autres domaines d'activités où des personnes peuvent, dans certaines circonstances particulières, avoir à placer des mises en garde dans des lieux fréquentés par le public, ou sur un chantier de construction et ainsi de suite. Il ne s'agit pas réellement d'une expression d'opinion de la part de la personne res-

imposed by the government as a condition of participating in a regulated activity.

ponsable du lieu public ou du chantier de construction. Il s'agit plutôt d'une exigence imposée par le gouvernement comme condition de la participation à une activité réglementée.

116 Even if I were of the view that there was an infringement, I am firmly convinced that it is fully justifiable under s. 1. Once again, I stress the importance of context in the s. 1 analysis. The appellants are large corporations selling a product for profit which, on the basis of overwhelming evidence, is dangerous, yet maintain the right to engage in "counterspeech" against warnings which do nothing more than bring the dangerous nature of these products to the attention of consumers. Given that the objective of the unattributed health message requirement is simply to increase the likelihood that every literate consumer of tobacco products will be made aware of the risks entailed by the use of that product, and that these warnings have no political, social or religious content, it is clear that we are a long way in this context from cases where the state seeks to coerce a lone individual to make political, social or religious statements without a right to respond. I believe a lower level of constitutional scrutiny is justified in this context. These cases seem to me to be a far more compelling situation than *Slaight*, *supra*, where a majority of the Court held the infringement there was justified under s. 1. The *Charter* was essentially enacted to protect individuals, not corporations. It may, at times it is true, be necessary to protect the rights of corporations so as to protect the rights of the individual. But I do not think this is such a case, and I again draw inspiration from the statement of Dickson C.J. in *Edwards Books*, *supra*, at p. 779, that the courts must ensure that the *Charter* not become simply an instrument "of better situated individuals to roll back legislation which has as its object the improvement of the condition of less advantaged persons".

Même si j'étais d'avis qu'il y a violation, je suis tout à fait convaincu qu'elle serait justifiable au regard de l'article premier. Une fois encore, j'insiste sur l'importance du contexte dans l'analyse fondée sur l'article premier. Les appelantes sont de grandes sociétés qui vendent un produit qui leur rapporte un bénéfice et qui est, sur la foi d'une preuve écrasante, dangereux. Elle n'en revendiquent pas moins le droit de tenir un «contre-discours» contre des mises en garde, qui ne font rien de plus que d'attirer l'attention des consommateurs sur la nature dangereuse de ces produits. Étant donné que, d'une part, l'objectif visé par l'exigence d'apposer une mise en garde non attribuée est simplement d'accroître la probabilité que tout consommateur de produits du tabac qui sait lire sera mis au courant des risques rattachés à l'usage de ces produits, et que, d'autre part, ces mises en garde n'ont aucun contenu politique, social ou religieux, il est clair que nous sommes loin, dans ce contexte, de la situation où l'État tente de forcer un particulier isolé à faire des déclarations politiques, sociales ou religieuses, sans droit de réplique. Je crois qu'en l'occurrence l'analyse constitutionnelle n'a pas à être aussi approfondie. En effet, il me semble qu'elle présente une situation bien plus convaincante que celle de l'arrêt *Slaight*, précité, où, notre Cour à la majorité a conclu que la violation en question était justifiée au regard de l'article premier. Essentiellement, la *Charte* a été adoptée pour protéger les particuliers, non les personnes morales. Il se peut qu'il faille parfois protéger les droits des personnes morales afin de protéger les droits des particuliers. Mais je ne crois pas que ce soit le cas ici et, une fois de plus, je m'inspire d'une affirmation du juge en chef Dickson dans *Edwards Books*, précité, à la p. 779, selon laquelle les tribunaux doivent s'assurer que la *Charte* ne devienne pas simplement un instrument dont se serviront «les plus favorisés pour écarter des lois dont l'objet est d'améliorer le sort des moins favorisés».

In my view, the requirement that health warnings must be unattributed is also proportional to the objective of informing consumers about the risks of tobacco use. Unattributed warnings are rationally connected to this objective because they increase the visual impact of the warning. It is not difficult to see that bold unattributed messages on a tobacco package (such as, for example, "SMOKING CAN KILL YOU") are more striking to the eye than messages cluttered by subtitles and attributions. Moreover, the attribution of the warnings also tends to dilute the factual impact of the messages. As Brossard J.A. observed, at p. 383:

> . . . it seems to me to leap to the eye that an "attributed" message can quickly become meaningless, or even ridiculous.
>
> As an example, the message that is supposed to come from the "Surgeon-General" remains a message imputed to an abstract entity or a political body which obviously cannot by simple decree make something hazardous that otherwise would not be. This, it seems to me, rationally weakens and attenuates the message.

These considerations are particularly relevant with respect to Parliament's goal of protecting children, who constitute the largest single group of new smokers every year in this country. In a report submitted at trial ("A Report on the Special Vulnerabilities of Children and Adolescents", *supra*) Dr. Michael J. Chandler observed that adolescents are apt to disregard or disobey messages from perceived authority figures. On this basis, he concluded that attributed warnings would be less effective in deterring adolescents from smoking. He stated, at p. 19:

> Adolescents are predisposed, as a function of their persistent cognitive immaturity, to view public disagreements between "experts" as evidence that everything is simply a matter of subjective opinion, and a licence to "do their own thing". A warning by Health and Welfare Canada on a publicly advertised product would provide them with just the sort of evidence they feel is required to justify doing whatever impulsive thing occurs to them at the moment.

À mon avis, l'exigence de non-attribution des mises en garde est également proportionnelle à l'objectif d'informer les consommateurs sur les risques de l'usage du tabac. Les mises en garde non attribuées ont un lien rationnel avec cet objectif en ce qu'elles accroissent l'effet visuel de la mise en garde. Il n'est pas difficile de voir que les messages directs non attribués (tels que «FUMER PEUT VOUS TUER») sont plus frappants visuellement que les messages encombrés de sous-titres et d'attributions. De plus, l'attribution des mises en garde a aussi tendance à diluer l'incidence factuelle du message. Comme l'a fait observer le juge Brossard, à la p. 437: 117

> Il me paraît [. . .] «sauter aux yeux» qu'un message «imputé» peut rapidement devenir sans signification, sinon même être tourné au ridicule.
>
> À titre d'exemple, le message que l'on veut imputer au Surgeon General demeure un message imputé à une abstraction ou à un corps politique qui ne saurait évidemment rendre dangereux, par simple décret, ce qui ne le serait pas autrement. Le message me semble alors rationnellement affaibli et atténué.

Ces considérations sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne le but du Parlement de protéger les enfants, qui constituent à eux seuls le plus grand groupe de nouveaux fumeurs chaque année au pays. Dans un rapport déposé au procès («A Report on the Special Vulnerabilities of Children and Adolescents», *op. cit.*), Michael J. Chandler, fait observer que les adolescents ont tendance à ne pas porter attention ou à désobéir aux messages émanant de ce qu'ils perçoivent comme des représentants de l'autorité. Il en conclut donc que les mises en garde attribuées seraient moins efficaces pour ce qui est de décourager les adolescents de fumer. Il affirme, à la p. 19:

> [TRADUCTION] Les adolescents sont prédisposés, en raison de leur immaturité sur le plan cognitif, à voir les divergences publiques entre «experts» comme la preuve que tout n'est qu'une question d'opinion subjective et qu'ils peuvent par conséquent «faire comme ils veulent». Une mise en garde de Santé et Bien-être social Canada apposée sur un produit faisant l'objet de publicité leur fournirait tout juste l'excuse qu'ils attendent pour se justifier de faire tout ce qui leur passe par la tête.

118 Thus, although the unattributed health warning requirement precludes large corporations from disseminating on their product packages the view that tobacco products are not harmful, I believe that any concern arising from this technical infringement of their rights is easily outweighed by the pressing health concerns raised by tobacco consumption. As noted by Dickson C.J. in *Edwards Books*, *supra*, at p. 759, the *Charter* does not require the elimination of "minuscule" constitutional burdens, and legislative action that increases the costs of exercising a right need not be prohibited if the burden is "trivial" or "insubstantial". In these cases, the only cost associated with the unattributed warning requirement is a potential reduction in profits. In my view, this is a cost that manufacturers of dangerous products can reasonably be expected to bear, given the health benefits of effective health warnings. As I stated in *Thomson Newspapers Ltd. v. Canada (Director of Investigation and Research, Restrictive Trade Practices Commission)*, [1990] 1 S.C.R. 425, at pp. 506-7:

> In a modern industrial society, it is generally accepted that many activities in which individuals can engage must nevertheless to a greater or lesser extent be regulated by the state to ensure that the individual's pursuit of his or her self-interest is compatible with the community's interest in the realization of collective goals and aspirations.

Disposition

119 I would dismiss the appeals with costs. I would answer the constitutional questions as follows:

1. Is the *Tobacco Products Control Act*, S.C. 1988, c. 20, wholly or in part within the legislative competence of the Parliament of Canada as being a law enacted for the peace, order and good government of Canada pursuant to s. 91 of the *Constitution Act, 1867*; as being enacted pursuant to the criminal law power in s. 91(27) thereof; or otherwise?

Par conséquent, bien que l'exigence des mises en garde non attribuées empêche les grandes sociétés de répandre l'idée par leurs emballages que les produits du tabac ne sont pas dangereux, je crois que toute inquiétude engendrée par cette violation de pure forme de leurs droits ne fait pas le poids devant les préoccupations pour la santé que fait surgir la consommation du tabac. Comme l'a fait remarquer le juge en chef Dickson dans *Edwards Books*, précité, à la p. 759, la *Charte* ne nécessite pas l'élimination des «infime[s]» inconvénients affectant des droits constitutionnels, et une loi qui accroît le coût de l'exercice d'un droit ne doit pas être déclarée inopérante si l'inconvénient est «négligeable» ou «insignifiant». Dans les présents pourvois, le seul coût lié à l'exigence d'une mise en garde non attribuée est une possible réduction des bénéfices. À mon avis, on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce coût soit supporté par les fabricants de produits dangereux, compte tenu des avantages pour la santé de mises en garde efficaces. Comme je l'ai affirmé dans l'arrêt *Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce)*, [1990] 1 R.C.S. 425, aux pp. 506 et 507:

> Dans une société industrielle moderne, on reconnaît généralement que de nombreuses activités auxquelles peuvent se livrer des particuliers doivent malgré tout être plus ou moins réglementées par l'État pour veiller à ce que la poursuite des intérêts des particuliers soit compatible avec les intérêts de la collectivité dans la réalisation des buts et des aspirations collectifs.

Dispositif

Je suis d'avis de rejeter les pourvois avec dépens et de donner les réponses suivantes aux questions constitutionnelles:

1. La *Loi réglementant les produits du tabac*, L.C. 1988, ch. 20, relève-t-elle, en tout ou en partie, de la compétence du Parlement du Canada de légiférer pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada en vertu de l'art. 91, ou en matière de droit criminel suivant le par. 91(27), de la *Loi constitutionnelle de 1867*, ou autrement?

Answer: The *Tobacco Products Control Act* is wholly within the legislative competence of Parliament and is validly enacted pursuant to the criminal law power in s. 91(27) of the *Constitution Act, 1867*. It is not necessary to consider whether Parliament may validly enact the Act under its power to make laws for the peace, order and good government of Canada.

Réponse: La *Loi réglementant les produits du tabac* est entièrement du ressort législatif du Parlement et elle a été validement adoptée en vertu du pouvoir de légiférer en matière de droit criminel conféré par le par. 91(27) de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Il n'y a pas lieu de déterminer si le Parlement peut validement adopter la Loi en vertu de son pouvoir de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement au Canada.

2. Is the *Tobacco Products Control Act* wholly or in part inconsistent with the right of freedom of expression as set out in s. 2(*b*) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* and, if so, does it constitute a reasonable limit on that right as can be demonstrably justified pursuant to s. 1 thereof?

2. La *Loi réglementant les produits du tabac* est-elle, en tout ou en partie, incompatible avec la liberté d'expression garantie à l'al. 2*b*) de la *Charte canadienne des droits et libertés* et, dans l'affirmative, apporte-t-elle une limite raisonnable à l'exercice de ce droit, dont la justification puisse se démontrer au sens de l'article premier de la *Charte*?

Answer: The Act is inconsistent with s. 2(*b*) of the *Charter*, but constitutes a reasonable limit to that right under s. 1 thereof.

Réponse: La Loi est incompatible avec l'al. 2*b*) de la *Charte*, mais elle apporte une limite raisonnable à l'exercice de ce droit au sens de l'article premier de la *Charte*.

The following are the reasons delivered by

Version française des motifs rendus par

SOPINKA J. — I agree with Justice Major that the impugned legislation is not validly enacted under the criminal law power. In other respects, I concur in the reasons of Justice McLachlin.

LE JUGE SOPINKA — Tout comme le juge Major, j'estime que la loi contestée n'a pas été validement adoptée dans le cadre de la compétence en matière de droit criminel. À tous autres égards, je souscris aux motifs du juge McLachlin. 120

The following are the reasons delivered by

Version française des motifs rendus par

CORY J. — Although I am in accordance with the reasons and conclusions of Justice La Forest, I am also in agreement with the reasons of Justice Iacobucci in so far as they declare a suspension of invalidity for one year.

LE JUGE CORY — Bien que je sois d'accord avec les motifs et les conclusions du juge La Forest, je suis également d'accord avec les motifs du juge Iacobucci dans la mesure où ils préconisent une suspension de l'effet de l'invalidité pour une période d'un an. 121

The following is the judgment delivered by

Version française du jugement rendu par

MCLACHLIN J. — At issue in these cases is the validity of the *Tobacco Products Control Act*, S.C. 1988, c. 20 (the "Act"), a law which imposes a ban on all advertising of tobacco products in the Canadian media and requires tobacco manufacturers to

LE JUGE MCLACHLIN — Les présents pourvois portent sur la validité de la *Loi réglementant les produits du tabac*, L.C. 1988, ch. 20 (la «Loi»), qui interdit toute publicité en faveur des produits du tabac dans les médias canadiens et exige que les 122

print unattributed health warnings on the packages of all tobacco products.

123 The first issue is whether Parliament had the power to enact the ban and warning requirements, given that advertising and promotion of particular industries generally are matters of provincial competence. I agree with my colleague, Justice La Forest, that Parliament may impose advertising bans and require health warnings on tobacco products under its criminal law power.

124 The second issue is whether the ban and warning requirements violate the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*. The *Charter* guarantees free expression, a guarantee which has been held to extend to commercial speech such as advertising: see *Ford v. Quebec (Attorney General)*, [1988] 2 S.C.R. 712; *Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927; and *Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario*, [1990] 2 S.C.R. 232. I agree with La Forest J. that the prohibition on advertising and promotion of tobacco products constitutes a violation of the right to free expression as the Attorney General conceded. Unlike La Forest J., I take the view that s. 9 of the Act, which requires tobacco manufacturers to place an unattributed health warning on tobacco packages, also infringes the right of free expression. As La Forest J. notes in para. 113, this Court has previously held that "freedom of expression necessarily entails the right to say nothing or the right not to say certain things": *Slaight Communications Inc. v. Davidson*, [1989] 1 S.C.R. 1038, at p. 1080, *per* Lamer J. (as he then was). Under s. 9(2), tobacco manufacturers are prohibited from displaying on their packages any writing other than the name, brand name, trade mark, and other information required by legislation. The combination of the unattributed health warnings and the prohibition against displaying any other information which would allow tobacco manufacturers to express their own views, constitutes an infringe-

fabricants de ces produits apposent des mises en garde non attribuées sur les emballages de tous les produits du tabac.

La première question est de savoir si le Parlement avait la compétence pour adopter cette interdiction et les exigences relatives aux mises en garde, puisque la publicité et la promotion d'industries particulières sont généralement des questions de compétence provinciale. À l'instar de mon collègue le juge La Forest, je suis d'avis que, en vertu de sa compétence en matière de droit criminel, le Parlement peut imposer des interdictions sur la publicité et exiger l'apposition de mises en garde sur les produits du tabac.

La deuxième question est de savoir si l'interdiction et les exigences relatives aux mises en garde vont à l'encontre de la *Charte canadienne des droits et libertés*. La *Charte* garantit la liberté d'expression, et cette garantie a été interprétée comme incluant le discours commercial, comme la publicité; voir *Ford c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 R.C.S. 712; *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927, et *Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario*, [1990] 2 R.C.S. 232. Je conviens avec le juge La Forest que l'interdiction imposée sur la publicité et la promotion des produits du tabac constitue une violation du droit à la liberté d'expression, comme l'a admis le procureur général. Contrairement au juge La Forest, je suis d'avis que l'art. 9 de la Loi, qui exige que les fabricants apposent sur les produits du tabac des messages non attribués relatifs à la santé, porte également atteinte au droit à la liberté d'expression. Comme le juge La Forest le souligne, au par. 113, notre Cour a déjà statué que «la liberté d'expression comporte nécessairement le droit de ne rien dire ou encore le droit de ne pas dire certaines choses»: *Slaight Communications Inc. c. Davidson*, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1080, le juge Lamer (maintenant Juge en chef). En vertu du par. 9(2), il est interdit aux fabricants de tabac d'apposer sur l'emballage d'un produit du tabac des mentions autres que la désignation, le nom et toute marque de celui-ci ainsi que les renseignements prévus par

ment of the right to free expression guaranteed by s. 2(*b*) of the *Charter*.

The only remaining question is whether these infringements of the right of free expression are saved under s. 1 of the *Charter*, as being reasonable and "demonstrably justified in a free and democratic society". Acknowledging that the evidence of justification is problematic, La Forest J. concludes that it nevertheless suffices to justify the infringement of the right of free expression, given the importance of the legislative goal, the context of the law and the need to defer to Parliament on such an important and difficult issue. With respect, I cannot agree. I share the trial judge's view that the Attorney General of Canada has failed to establish justification under s. 1 for ss. 4, 8 and 9 of the Act, those provisions which impose a total advertising ban, prohibit trade mark usage on articles other than tobacco products and mandate the use of unattributed health warnings on tobacco packaging. Because I do not believe that these provisions are severable from ss. 5 and 6 of the Act, which pertain to restrictions on promotion and trade mark usage, I find ss. 4, 5, 6, 8, and 9 to be invalid, leaving the remainder of the Act intact except in so far as it relates to the invalid provisions.

1. The Test for Justification under Section 1 of the *Charter*

(a) *The Wording of Section 1*

I agree with La Forest J. that "[t]he appropriate 'test' . . . in a s. 1 analysis is that found in s. 1 itself" (para. 62). The ultimate issue is whether the infringement is reasonable and "demonstrably justified in a free and democratic society". The jurisprudence laying down the dual considerations of importance of objective and proportionality between the good which may be achieved by the

une loi. Les mises en garde non attribuées, conjuguées à l'interdiction d'apposer tout autre renseignement qui permettrait aux fabricants de tabac d'exprimer leurs points de vue, constituent une violation de la liberté d'expression garantie par l'al. 2*b*) de la *Charte*.

La dernière question est de savoir si ces violations du droit à la liberté d'expression sont sauvegardées en vertu de l'article premier de la *Charte*, comme étant des limites raisonnables «dont la justification [peut] se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique». Reconnaissant que la preuve de la justification présente des problèmes, le juge La Forest conclut qu'elle suffit néanmoins à justifier la violation du droit à la liberté d'expression compte tenu de l'importance de l'objectif législatif, du contexte de la loi et de la nécessité d'avoir de l'égard pour le Parlement relativement à une question si importante et difficile. En toute déférence, je ne suis pas de cet avis. Tout comme le juge de première instance, j'estime que le procureur général du Canada n'a pas réussi à établir une justification en vertu de l'article premier pour les art. 4, 8 et 9 de la Loi, dispositions qui interdisent totalement la publicité, proscrivent l'utilisation de marques sur des articles autres que les produits du tabac et exigent l'apposition sur les emballages de mises en garde non attribuées. Puisque ces dispositions ne sont pas, à mon avis, dissociables des art. 5 et 6 de la Loi, qui portent sur les restrictions en matière de promotion et d'usage de marques, je conclus que les art. 4, 5, 6, 8 et 9 ne sont pas valides et que le reste de la Loi demeure inchangé, sauf dans la mesure où il se rapporte aux dispositions invalidées. 125

1. Le critère de la justification en vertu de l'article premier de la *Charte*

a) *Le libellé de l'article premier*

Je suis d'accord avec le juge La Forest pour dire que: «[l]e «critère» approprié applicable à une analyse fondée sur l'article premier se trouve dans la disposition même» (par. 62). Il s'agit en fin de compte de savoir si la violation se situe à l'intérieur de limites raisonnables «dont la justification [peut] se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique». Dans la jurisprudence por- 126

law and the infringement of rights it works, may be seen as articulating the factors which must be considered in determining whether a law that violates constitutional rights is nevertheless "reasonable" and "demonstrably justified". If the objective of a law which limits constitutional rights lacks sufficient importance, the infringement cannot be reasonable or justified. Similarly, if the good which may be achieved by the law pales beside the seriousness of the infringement of rights which it works, that law cannot be considered reasonable or justified. While sharing La Forest J.'s view that an overtechnical approach to s. 1 is to be eschewed, I find no conflict between the words of s. 1 and the jurisprudence founded upon *R. v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103. The latter complements the former.

tant sur la double considération que sont l'importance de l'objectif et le critère de la proportionnalité entre le bien que vise la loi et la violation des droits à laquelle elle donne lieu, les tribunaux formulent les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si l'atteinte qu'une loi porte aux droits garantis par la Constitution se situe néanmoins à l'intérieur de limites «raisonnables» «dont la justification [peut] se démontrer». Si l'objectif d'une loi qui restreint les droits garantis par la Constitution n'est pas suffisamment important, l'atteinte ne peut être ni raisonnable ni justifiée. De même, si le bien visé par la loi perd de son importance par rapport à la gravité de l'atteinte aux droits qui s'ensuit, on ne peut considérer que cette loi soit raisonnable ou justifiée. Je conviens avec le juge La Forest qu'il faut s'abstenir de faire une analyse trop technique fondée sur l'article premier; cependant, il n'existe pas, à mon avis, d'incompatibilité entre le libellé de l'article premier et la jurisprudence fondée sur l'arrêt *R. c. Oakes*, [1986] 1 R.C.S. 103, celle-ci venant compléter l'article premier.

127 This said, there is merit in reminding ourselves of the words chosen by those who framed and agreed upon s. 1 of the *Charter*. First, to be saved under s. 1 the party defending the law (here the Attorney General of Canada) must show that the law which violates the right or freedom guaranteed by the *Charter* is "reasonable". In other words, the infringing measure must be justifiable by the processes of reason and rationality. The question is not whether the measure is popular or accords with the current public opinion polls. The question is rather whether it can be justified by application of the processes of reason. In the legal context, reason imports the notion of inference from evidence or established truths. This is not to deny intuition its role, or to require proof to the standards required by science in every case, but it is to insist on a rational, reasoned defensibility.

Cela dit, il importe de se remémorer les termes mêmes choisis par ceux qui ont rédigé et approuvé l'article premier de la *Charte*. Premièrement, pour qu'une disposition puisse être sauvegardée en vertu de l'article premier, la partie qui défend la loi (en l'espèce le procureur général du Canada) doit établir que la loi qui porte atteinte au droit ou à la liberté garantis par la *Charte* est «raisonnable». En d'autres termes, la mesure attentatoire doit être justifiable par application de la raison et de la rationalité. La question n'est pas de savoir si la mesure est populaire ou compatible avec les sondages d'opinion publique. Elle est plutôt de savoir si cette mesure peut être justifiée par l'application du processus de la raison. Dans le contexte juridique, la raison comporte la notion d'inférence à partir de la preuve ou des faits établis. Il ne s'agit pas d'éliminer le rôle de l'intuition, ni d'exiger chaque fois une preuve répondant aux normes scientifiques, mais bien d'insister sur une défense rationnelle et raisonnée.

128 Second, to meet its burden under s. 1 of the *Charter*, the state must show that the violative law

Deuxièmement, pour s'acquitter du fardeau que lui impose l'article premier de la *Charte*, l'État

is "demonstrably justified". The choice of the word "demonstrably" is critical. The process is not one of mere intuition, nor is it one of deference to Parliament's choice. It is a process of demonstration. This reinforces the notion inherent in the word "reasonable" of rational inference from evidence or established truths.

The bottom line is this. While remaining sensitive to the social and political context of the impugned law and allowing for difficulties of proof inherent in that context, the courts must nevertheless insist that before the state can override constitutional rights, there be a reasoned demonstration of the good which the law may achieve in relation to the seriousness of the infringement. It is the task of the courts to maintain this bottom line if the rights conferred by our constitution are to have force and meaning. The task is not easily discharged, and may require the courts to confront the tide of popular public opinion. But that has always been the price of maintaining constitutional rights. No matter how important Parliament's goal may seem, if the state has not demonstrated that the means by which it seeks to achieve its goal are reasonable and proportionate to the infringement of rights, then the law must perforce fail.

(b) *The Factors to be Considered under Section 1*

The factors generally relevant to determining whether a violative law is reasonable and demonstrably justified in a free and democratic society remain those set out in *Oakes*. The first requirement is that the objective of the law limiting the *Charter* right or freedom must be of sufficient importance to warrant overriding it. The second is that the means chosen to achieve the objective must be proportional to the objective and the effect of the law — proportionate, in short, to the good which it may produce. Three matters are considered in determining proportionality: the measures chosen must be rationally connected to the objective; they must impair the guaranteed right or free-

doit établir que la violation comprise dans une loi se situe à l'intérieur de limites «dont la justification puisse se démontrer». Le choix de l'expression «puisse se démontrer» est important. Il ne s'agit pas de procéder par simple intuition, ou d'affirmer qu'il faut avoir de l'égard pour le choix du Parlement. Il s'agit d'un processus de démonstration. Cela renforce la notion propre au terme «raisonnable» selon laquelle il faut tirer une inférence rationnelle de la preuve ou des faits établis.

La démarche fondamentale est la suivante. Bien qu'ils doivent demeurer conscients du contexte socio-politique de la loi attaquée et reconnaître les difficultés qui y sont propres en matière de preuve, les tribunaux doivent néanmoins insister pour que, avant qu'il ne supprime un droit protégé par la Constitution, l'État fasse une démonstration raisonnée du bien visé par la loi par rapport à la gravité de la violation. Les tribunaux doivent respecter cette démarche fondamentale pour que les droits garantis par notre constitution soient opérants. Ce n'est pas une tâche facile, et les tribunaux devront peut-être affronter le courant d'opinion publique. Cependant, c'est depuis toujours le prix du maintien des droits constitutionnels. Si important que puisse sembler l'objectif du Parlement, si l'État n'a pas démontré que les moyens qu'il utilise pour atteindre son objectif sont raisonnables et proportionnels à la violation des droits, la loi doit alors par nécessité être déclarée non valide. 129

b) *Les facteurs à examiner sous le régime de l'article premier*

Les facteurs énoncés dans l'arrêt *Oakes* demeurent les facteurs généralement pertinents pour déterminer si une limite prévue dans une loi est une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Premièrement, l'objectif de la loi qui restreint un droit ou une liberté garantis par la *Charte* doit être suffisamment important pour justifier sa suppression. Deuxièmement, les moyens choisis pour atteindre cet objectif doivent être proportionnels à l'objectif et à l'effet de la loi — en bref, proportionnels au bien qu'elle vise. Dans la détermination de la proportionnalité, il faut tenir compte de trois points: les mesures choisies doi- 130

dom as little as reasonably possible (minimal impairment); and there must be overall proportionality between the deleterious effects of the measures and the salutary effects of the law.

(c) *Applying the Oakes Factors — Context, Deference to Parliament, Standard of Proof and the Trial Judge's Findings*

131 Having set out the criteria determinative of whether a law that infringes a guaranteed right or freedom is justified under s. 1, La Forest J. offers observations on the approach the courts should use in applying them.

132 His first point is that the *Oakes* test must be applied flexibly, having regard to the factual and social context of each case. I agree. The need to consider the context of the case has been accepted since Wilson J. propounded it in *Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General)*, [1989] 2 S.C.R. 1326. This "sensitive, case-oriented approach" was affirmed in *Rocket*, *supra*, which also concerned a law limiting advertising. There I wrote at pp. 246-47:

> While the Canadian approach does not apply special tests to restrictions on commercial expression, our method of analysis does permit a sensitive, case-oriented approach to the determination of their constitutionality. Placing the conflicting values in their factual and social context when performing the s. 1 analysis permits the courts to have regard to special features of the expression in question. As Wilson J. notes in *Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General)*, [1989] 2 S.C.R. 1326, not all expression is equally worthy of protection. Nor are all infringements of free expression equally serious.

133 That the s. 1 analysis takes into account the context in which the particular law is situate should

vent avoir un lien rationnel avec l'objectif; elles doivent restreindre aussi peu que cela est raisonnablement possible le droit ou la liberté garantis (atteinte minimale), et il doit exister une proportionnalité globale entre les effets préjudiciables des mesures et les effets salutaires de la loi.

c) *Application des facteurs de l'arrêt Oakes — Contexte, égard envers le Parlement, norme de preuve et conclusions du juge de première instance*

Après avoir formulé les critères qui servent à déterminer si une loi qui porte atteinte à un droit ou à une liberté garantis se justifie en vertu de l'article premier, le juge La Forest fait des observations sur la méthode que les tribunaux devraient utiliser lorsqu'ils les appliquent.

Il fait tout d'abord remarquer que le critère formulé dans l'arrêt *Oakes* doit être appliqué avec souplesse, compte tenu du contexte factuel et social de chaque cas particulier. Je suis d'accord. La nécessité de tenir compte du contexte de chaque cas particulier est acceptée depuis que le juge Wilson l'a proposée dans l'arrêt *Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général)*, [1989] 2 R.C.S. 1326. Cette «méthode d'analyse [. . .] avec sensibilité et en fonction de chaque cas particulier» a été confirmée dans l'arrêt *Rocket*, précité, qui portait également sur une loi restreignant la publicité. Dans cet arrêt, j'affirme, aux pp. 246 et 247:

> Bien que la méthode canadienne ne consiste pas à appliquer des critères spéciaux aux restrictions imposées à l'expression commerciale, notre méthode d'analyse permet d'aborder la détermination de leur constitutionnalité avec sensibilité et en fonction de chaque cas particulier. En situant les valeurs contradictoires dans leur contexte factuel et social au moment de procéder à l'analyse fondée sur l'article premier, les tribunaux ont la possibilité de tenir compte des caractéristiques spéciales de l'expression en question. Comme le juge Wilson le fait remarquer dans *Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général)*, [1989] 2 R.C.S. 1326, ce ne sont pas toutes les expressions qui méritent la même protection. Toutes les violations de la liberté d'expression ne sont pas également graves.

Il n'est pas vraiment étonnant que l'analyse fondée sur l'article premier tienne compte du contexte

hardly surprise us. The s. 1 inquiry is by its very nature a fact-specific inquiry. In determining whether the objective of the law is sufficiently important to be capable of overriding a guaranteed right, the court must examine the actual objective of the law. In determining proportionality, it must determine the actual connection between the objective and what the law will in fact achieve; the actual degree to which it impairs the right; and whether the actual benefit which the law is calculated to achieve outweighs the actual seriousness of the limitation of the right. In short, s. 1 is an exercise based on the facts of the law at issue and the proof offered of its justification, not on abstractions.

dans lequel se situe la loi en question. L'examen fondé sur l'article premier est, de par sa nature même, un examen spécifique des faits. Pour déterminer si l'objectif de la loi est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti, le tribunal doit examiner le véritable objectif de la loi. Dans l'examen de la proportionnalité, le tribunal doit déterminer quel est le lien qui existe entre l'objectif de la loi et ce que cette loi réussira effectivement à accomplir, dans quelle mesure la loi restreint le droit en question et, enfin, si l'avantage que la loi vise l'emporte sur la gravité de la restriction du droit. Bref, l'évaluation en vertu de l'article premier est un exercice fondé sur les faits de la loi en cause et sur la preuve de sa justification, et non sur des abstractions.

However, while the impugned law must be considered in its social and economic context, nothing in the jurisprudence suggests that the contextual approach reduces the obligation on the state to meet the burden of demonstrating that the limitation on rights imposed by the law is reasonable and justified. Context is essential in determining legislative objective and proportionality, but it cannot be carried to the extreme of treating the challenged law as a unique socio-economic phenomenon, of which Parliament is deemed the best judge. This would be to undercut the obligation on Parliament to justify limitations which it places on *Charter* rights and would be to substitute *ad hoc* judicial discretion for the reasoned demonstration contemplated by the *Charter.*

134 Cependant, bien que la loi contestée doive être examinée dans son contexte social et économique, la jurisprudence n'indique aucunement que l'analyse contextuelle diminue l'obligation qu'a l'État de démontrer que la restriction des droits est raisonnable et justifiée. Le contexte est essentiel dans la détermination de l'objectif législatif et de la proportionnalité, mais on ne peut pousser son importance à l'extrême et considérer ainsi la loi contestée comme un phénomène socio-économique unique, dont le Parlement est réputé le meilleur juge. On se trouverait ainsi à atténuer l'obligation imposée au Parlement de justifier les restrictions qu'il apporte aux droits garantis par la *Charte,* et à remplacer la démonstration raisonnée envisagée par la *Charte* par l'exercice du pouvoir discrétionnaire ad hoc d'un tribunal.

Related to context is the degree of deference which the courts should accord to Parliament. It is established that the deference accorded to Parliament or the legislatures may vary with the social context in which the limitation on rights is imposed. For example, it has been suggested that greater deference to Parliament or the Legislature may be appropriate if the law is concerned with the competing rights between different sectors of society than if it is a contest between the individual and the state: *Irwin Toy, supra,* at pp. 993-94; *Stoffman v. Vancouver General Hospital,* [1990] 3 S.C.R. 483, at p. 521. However, such distinctions

135 Relié au contexte, il y a le degré de respect dont les tribunaux doivent faire preuve envers le Parlement. Il est bien établi que le respect accordé au Parlement ou aux législatures peut varier en fonction du contexte social dans lequel est imposée la restriction aux droits. Par exemple, on a affirmé qu'il y aurait lieu de faire preuve d'un plus grand respect pour le législateur fédéral ou provincial dans le cas où une loi vise les droits contradictoires de divers secteurs de la société, que dans le cas où il s'agit d'une contestation entre le particulier et l'État: *Irwin Toy,* précité, aux pp. 993 et 994; *Stoffman c. Vancouver General Hospital,* [1990] 3

may not always be easy to apply. For example, the criminal law is generally seen as involving a contest between the state and the accused, but it also involves an allocation of priorities between the accused and the victim, actual or potential. The cases at bar provide a cogent example. We are concerned with a criminal law, which pits the state against the offender. But the social values reflected in this criminal law lead La Forest J. to conclude that "the Act is the very type of legislation to which this Court has generally accorded a high degree of deference" (para. 70). This said, I accept that the situation which the law is attempting to redress may affect the degree of deference which the court should accord to Parliament's choice. The difficulty of devising legislative solutions to social problems which may be only incompletely understood may also affect the degree of deference that the courts accord to Parliament or the Legislature. As I wrote in *Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada*, [1991] 1 S.C.R. 139, at p. 248, "some deference must be paid to the legislators and the difficulties inherent in the process of drafting rules of general application. A limit prescribed by law should not be struck out merely because the Court can conceive of an alternative which seems to it to be less restrictive".

R.C.S. 483, à la p. 521. Cependant, ces distinctions pourraient ne pas être toujours faciles d'application. Par exemple, on considère généralement que le droit criminel opposera l'État et l'accusé; cependant, il nécessitera aussi une répartition des priorités entre l'accusé et la victime, véritable ou éventuelle. Les présents pourvois offrent un exemple convaincant. Nous sommes en présence d'une loi de nature pénale, qui oppose l'État et le contrevenant. Cependant, les valeurs sociales présentes dans cette loi amènent le juge La Forest à conclure que «la Loi est précisément le type de loi envers laquelle notre Cour a généralement fait preuve d'une grande retenue» (par. 70). Cela dit, je reconnais que le problème auquel la loi tente de remédier risque d'avoir une incidence sur le degré de respect dont le tribunal devrait faire preuve à l'égard du choix du Parlement. De même, la difficulté de concevoir des solutions législatives à des problèmes sociaux qui pourraient bien n'être que partiellement compris peut aussi avoir une incidence sur le degré de respect dont les tribunaux feront preuve envers le législateur fédéral ou provincial. Comme je l'ai affirmé dans l'arrêt *Comité pour la République du Canada c. Canada*, [1991] 1 R.C.S. 139, à la p. 248: «il convient d'avoir de l'égard pour les législateurs et les difficultés inhérentes au processus de rédaction des règles d'application générale. Il ne faudrait pas annuler une limite prescrite par une règle de droit tout simplement parce que le tribunal peut concevoir une autre solution qui lui semble moins restrictive».

136 As with context, however, care must be taken not to extend the notion of deference too far. Deference must not be carried to the point of relieving the government of the burden which the *Charter* places upon it of demonstrating that the limits it has imposed on guaranteed rights are reasonable and justifiable. Parliament has its role: to choose the appropriate response to social problems within the limiting framework of the Constitution. But the courts also have a role: to determine, objectively and impartially, whether Parliament's choice falls within the limiting framework of the Constitution. The courts are no more permitted to abdicate their responsibility than is Parliament. To carry judicial deference to the point of accepting Parliament's

Cependant, comme pour le contexte, il faut prendre soin de ne pas pousser trop loin la notion du respect. Le respect porté ne doit pas aller jusqu'au point de libérer le gouvernement de l'obligation que la *Charte* lui impose de démontrer que les restrictions qu'il apporte aux droits garantis sont raisonnables et justifiables. Le Parlement a son rôle: choisir la réponse qui convient aux problèmes sociaux dans les limites prévues par la Constitution. Cependant, les tribunaux ont aussi un rôle: déterminer de façon objective et impartiale si le choix du Parlement s'inscrit dans les limites prévues par la Constitution. Les tribunaux n'ont pas plus le droit que le Parlement d'abdiquer leur responsabilité. Les tribunaux se trouveraient à dimi-

view simply on the basis that the problem is serious and the solution difficult, would be to diminish the role of the courts in the constitutional process and to weaken the structure of rights upon which our constitution and our nation is founded.

nuer leur rôle à l'intérieur du processus constitutionnel et à affaiblir la structure des droits sur lesquels notre constitution et notre nation sont fondées, s'ils portaient le respect jusqu'au point d'accepter le point de vue du Parlement simplement pour le motif que le problème est sérieux et la solution difficile.

Context and deference are related to a third concept in the s. 1 analysis: standard of proof. I agree with La Forest J. that proof to the standard required by science is not required. Nor is proof beyond a reasonable doubt on the criminal standard required. As the s. 1 jurisprudence has established, the civil standard of proof on a balance of probabilities at all stages of the proportionality analysis is more appropriate: *Oakes*, *supra*, at p. 137; *Irwin Toy*, *supra*, at p. 992. I thus disagree with La Forest J.'s conclusion (in para. 82) that in these cases "it is unnecessary . . . for the government to demonstrate a rational connection according to a civil standard of proof". Discharge of the civil standard does not require scientific demonstration; the balance of probabilities may be established by the application of common sense to what is known, even though what is known may be deficient from a scientific point of view: see *Snell v. Farrell*, [1990] 2 S.C.R. 311.

137 Dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier, les concepts de contexte et de respect sont rattachés à un troisième: celui de la norme de preuve. À l'instar du juge La Forest, j'estime que la preuve n'a pas à satisfaire à la norme requise en matière scientifique. Il ne s'agit pas non plus d'une preuve hors de tout doute raisonnable comme en matière criminelle. Comme l'établit la jurisprudence relative à l'article premier, la norme de preuve qui convient, à toutes les étapes de l'analyse de la proportionnalité, est celle qui s'applique en matière civile, c'est-à-dire la preuve selon la prépondérance des probabilités: *Oakes*, précité, à la p. 137; *Irwin Toy*, précité, à la p. 992. Je ne suis donc pas d'accord avec la conclusion du juge La Forest (au par. 82) qu'«il n'est pas nécessaire [. . .] que le gouvernement fasse la preuve d'un lien rationnel selon les règles de preuve en matière civile». Pour satisfaire à la norme de preuve en matière civile, on n'a pas à faire une démonstration scientifique; la prépondérance des probabilités s'établit par application du bon sens à ce qui est connu, même si ce qui est connu peut comporter des lacunes du point de vue scientifique: voir l'arrêt *Snell c. Farrell*, [1990] 2 R.C.S. 311.

In summary, while I agree with La Forest J. that context, deference and a flexible and realistic standard of proof are essential aspects of the s. 1 analysis, these concepts should be used as they have been used by this Court in previous cases. They must not be attenuated to the point that they relieve the state of the burden the *Charter* imposes of demonstrating that the limits imposed on our constitutional rights and freedoms are reasonable and justifiable in a free and democratic society.

138 Bref, bien que je convienne avec le juge La Forest que les concepts de contexte, de respect et d'application d'une norme de preuve souple et réaliste sont des aspects essentiels de l'analyse fondée sur l'article premier, j'estime qu'ils devraient être appliqués conformément à la jurisprudence de notre Cour. On ne doit pas en atténuer l'importance au point de libérer l'État de l'obligation que la *Charte* lui impose de démontrer que les restrictions apportées à nos droits et libertés constitutionnels sont raisonnables et justifiables dans le cadre d'une société libre et démocratique.

I come finally to a fourth general matter discussed by La Forest J. — the degree of deference

139 J'arrive finalement à la quatrième question générale examinée par le juge La Forest: le degré

which appellate courts should accord to the findings of the trial judge under s. 1 of the *Charter* analysis. The trial judge in these cases concluded that the proportionality test was not met. He based this conclusion on findings that the evidence failed to establish any of the three requirements for proportionality under s. 1.

de retenue dont une cour d'appel doit faire preuve envers les conclusions du juge de première instance dans le cadre d'une analyse fondée sur l'article premier de la *Charte*. Le juge de première instance a conclu en l'espèce que l'on n'avait pas satisfait au critère de la proportionnalité. À cette fin, il s'est fondé sur sa conclusion que la preuve n'établissait aucune des trois exigences du critère de la proportionnalité en vertu de l'article premier.

140 As a general rule, courts of appeal decline to interfere with findings of fact by a trial judge unless they are unsupported by the evidence or based on clear error. This rule is based in large part on the advantage afforded to the trial judge and denied to the appellate court of seeing and hearing the witnesses. La Forest J. concludes that this rule does not apply to the findings of the trial judge in these cases, because those findings were not "adjudicative facts" but rather were "legislative facts".

En règle générale, une cour d'appel refuse de modifier les conclusions de fait du juge de première instance, sauf si ces conclusions ne s'appuient pas sur la preuve ou sont fondées sur une erreur manifeste. Cette règle repose en grande partie sur l'avantage dont bénéficie le juge de première instance, mais non une cour d'appel, de voir et d'entendre les témoins. Le juge La Forest conclut que cette règle ne s'applique pas aux conclusions du juge de première instance, en l'espèce, parce que ces conclusions portaient non pas sur des «faits en litige», mais plutôt sur des «faits législatifs».

141 While this approach sheds some light on the matter, the distinction between legislative and adjudicative facts may be harder to maintain in practice than in theory. Suffice it to say that in the context of the s. 1 analysis, more deference may be required to findings based on evidence of a purely factual nature whereas a lesser degree of deference may be required where the trial judge has considered social science and other policy oriented evidence. As a general matter, appellate courts are not as constrained by the trial judge's findings in the context of the s. 1 analysis as they are in the course of non-constitutional litigation, since the impact of the infringement on constitutional rights must often be assessed by reference to a broad review of social, economic and political factors in addition to scientific facts. At the same time, while appellate courts are not bound by the trial judge's findings in respect of social science evidence, they should remain sensitive to the fact that the trial judge has had the advantage of hearing competing expert testimony firsthand. The trial judge's findings with respect to the credibility of certain witnesses may

Bien que cette démarche clarifie quelque peu la question, la distinction entre les faits législatifs et les faits en litige pourrait bien être plus difficile à maintenir en pratique qu'en théorie. Qu'il me suffise de dire que, dans le contexte de l'analyse fondée sur l'article premier, il pourrait bien être nécessaire de faire preuve d'une plus grande retenue à l'égard de conclusions fondées sur une preuve de nature purement factuelle, qu'à l'égard de conclusions que le juge de première instance aurait tirées après l'examen de la preuve en matière de sciences humaines et d'autres questions de principe. En règle générale, dans le contexte d'une analyse fondée sur l'article premier, une cour d'appel n'est pas liée par les conclusions du juge de première instance au même degré qu'elle l'est dans le cadre d'un litige de nature non constitutionnelle, puisque l'incidence de la violation sur les droits constitutionnels doit souvent être évaluée dans le cadre d'un vaste examen de facteurs sociaux, économiques et politiques, qui vient s'ajouter à celui de faits scientifiques. Par ailleurs, bien qu'une cour d'appel ne soit pas liée par les

be useful when the appeal court reviews the record.

Against this background, I return to the cases at bar and the factors for s. 1 justification discussed in *Oakes*.

(d) *The Objective of the Limit on Free Expression*

The question at this stage is whether the objective of the infringing measure is sufficiently important to be capable in principle of justifying a limitation on the rights and freedoms guaranteed by the constitution. Given the importance of the *Charter* guarantees, this is not easily done. To meet the test, the objective must be one of pressing and substantial importance.

Care must be taken not to overstate the objective. The objective relevant to the s. 1 analysis is the objective of the infringing measure, since it is the infringing measure and nothing else which is sought to be justified. If the objective is stated too broadly, its importance may be exaggerated and the analysis compromised. As my colleague has noted, the *Tobacco Products Control Act* is but one facet of a complex legislative and policy scheme to protect Canadians from the health risks of tobacco use. However, the objective of the impugned measures themselves is somewhat narrower than this. The objective of the advertising ban and trade mark usage restrictions must be to prevent people in Canada from being persuaded by advertising and promotion to use tobacco products. The objective of the mandatory package warning must be to discourage people who see the package from tobacco use. Both constitute important objectives, although the significance of the targeted decrease in consumption is reduced by the government's estimate that despite the ban, 65 percent of the

conclusions du juge de première instance relativement à la preuve en matière de sciences humaines, elle devrait continuer d'être consciente du fait que le juge de première instance a eu l'avantage d'entendre de première main des témoignages d'experts contradictoires. Les conclusions du juge de première instance sur la crédibilité de certains témoins peuvent être utiles lorsque la cour d'appel fait l'examen du dossier.

Sur cette toile de fond, je reviens à l'examen des présents pourvois et des facteurs de justification en vertu de l'article premier, formulés dans l'arrêt *Oakes*. 142

d) *L'objectif de la restriction de la liberté d'expression*

À cette étape, la question est de savoir si l'objectif de la mesure attentatoire est suffisamment important pour justifier en principe une restriction des droits et libertés garantis par la Constitution. Vu l'importance des garanties de la *Charte*, ce n'est pas un exercice facile à faire. Pour satisfaire à ce critère, l'objectif doit revêtir une importance urgente et réelle. 143

Il faut veiller à ne pas surestimer l'objectif. Aux fins d'une analyse fondée sur l'article premier, l'objectif pertinent est l'objectif de la mesure attentatoire puisque c'est cette dernière et rien d'autre que l'on cherche à justifier. Si l'on formule l'objectif d'une façon trop large, on risque d'en exagérer l'importance et d'en compromettre l'analyse. Comme mon collègue l'a fait remarquer, la *Loi réglementant les produits du tabac* ne constitue que l'une des facettes d'un régime complexe sur le plan de la loi et des principes destiné à protéger les Canadiens contre les méfaits de l'usage du tabac sur la santé. Cependant, l'objectif des mesures contestées est un peu plus restreint que cela. L'interdiction de publicité et les restrictions à l'usage des marques doivent viser à empêcher la population canadienne de se laisser convaincre par la publicité et la promotion de faire usage du tabac. L'objectif de la mise en garde obligatoire doit être de dissuader les gens qui voient l'emballage de faire usage du tabac. Ces deux objectifs sont importants, mais l'ampleur de la diminution de 144

Canadian magazine market will contain tobacco advertisements, given that the ban applies only to Canadian media and not to imported publications.

145 I digress at this point to note that I do not share La Forest J.'s view (para. 66) that the trial judge erred in observing (at p. 491) that "much of the expert scientific evidence relating to the effects of tobacco on health . . . was . . . irrelevant to the case and . . . served . . . to colour the debate unnecessarily". The trial judge was simply pointing out that much of the evidence focused on a larger problem than that targeted by the legislation at issue. The critical question is not the evil tobacco works generally in our society, but the evil which the legislation addresses.

146 While the limited objective of reducing tobacco-associated health risks by reducing advertising-related consumption and providing warnings of dangers is less significant than the broad objective of protecting Canadians generally from the risks associated with tobacco use, it nevertheless constitutes an objective of sufficient importance to justify overriding the right of free expression guaranteed by the *Charter*. Even a small reduction in tobacco use may work a significant benefit to the health of Canadians and justify a properly proportioned limitation of right of free expression.

(e) *Proportionality*

(i) Findings of the Trial Judge (1991), 82 D.L.R. (4th) 449

147 The trial judge held that the impairment of rights effected by the law had not been shown to be proportionate to the objective of reducing tobacco use by eliminating advertising in Canadian media and requiring unattributed health warn-

consommation visée perd de l'importance si l'on tient compte du fait que, selon une estimation gouvernementale, 65 pour 100 des magazines vendus au Canada contiendront des annonces sur les produits du tabac, puisque l'interdiction ne vise que les médias canadiens et non les publications importées.

Je m'écarte ici du sujet pour préciser que je ne suis pas d'accord avec l'opinion du juge La Forest (par. 66) selon laquelle le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a fait observer (à la p. 2293) qu'«une grande partie de cette preuve d'expertise scientifique relativement aux effets du tabac sur la santé [. . .] était [. . .] non pertinente en l'espèce et ne servait [. . .] qu'à colorer inutilement le débat». Le juge de première instance faisait simplement ressortir que la majeure partie de la preuve portait sur un problème plus vaste que celui visé par la loi en cause. La question cruciale n'est pas le mal que le tabac cause dans l'ensemble de notre société, mais bien le mal auquel s'attaque la loi.

Bien que l'objectif restreint de diminuer les méfaits du tabac sur la santé, au moyen d'une diminution de l'usage du tabac causé par la publicité et de l'inscription de mises en garde, soit moins important que l'objectif général de protéger l'ensemble de la population canadienne contre les dangers liés à l'usage du tabac, cet objectif restreint est néanmoins suffisamment important pour justifier la suppression de la liberté d'expression garantie par la *Charte*. Même une infime diminution de l'usage du tabac peut entraîner un avantage important pour la santé des Canadiens et justifier une restriction de la liberté d'expression qui respecte le critère de la proportionnalité.

e) *La proportionnalité*

(i) Les conclusions du juge de première instance, [1991] R.J.Q. 2260

Le juge de première instance a conclu que l'on n'avait pas établi que l'atteinte aux droits était proportionnelle à l'objectif de réduire l'usage du tabac par l'interdiction de la publicité dans les médias canadiens et l'inscription obligatoire de mises en

ings on tobacco packaging. In his view, none of the three requirements for proportionality under s. 1 had been established.

The first requirement is that there be a rational connection between the objective of reducing tobacco consumption and the advertising ban. Chabot J. found that the Attorney General for Canada had failed to establish on a balance of probabilities that a rational connection exists between the full prohibition on advertising and the objective of reducing tobacco consumption, describing "the connection which the state seeks to establish between health protection and tobacco advertising" as "tenuous and speculative" (p. 512). He stated (at p. 513): "[t]he virtual totality of the scientific documents in the state's possession at the time the Act was passed do not demonstrate that a ban on advertising would affect consumption".

The second requirement of proportionality is that the law impair the protected right as little as reasonably possible. In other words, the infringement on the right of free expression must go no further than reasonably required to achieve the legislative goal, in these cases the reduction of tobacco use caused by advertising and the absence of package warnings. The trial judge observed, at pp. 515-17, that the Attorney General had adduced no evidence that a complete ban would reduce tobacco consumption more than a partial ban, or that unattributed health warnings would be more effective than attributed health warnings. As a result, he found that the Attorney General had failed to meet the burden upon it of showing that the infringements of rights were carefully tailored to the legislative objective.

The third requirement is proportionality between the objective of the law and the limits it imposes on constitutionally guaranteed rights. Here too, Chabot J. ruled that the state had not discharged the onus upon it. In his view, the law constituted "social engineering" and "an extremely serious

garde non attribuées sur les emballages des produits du tabac. À son avis, on n'avait satisfait à aucune des trois exigences du critère de la proportionnalité dans le cadre de l'article premier.

148 La première exigence est qu'il y ait un lien rationnel entre l'objectif de réduire l'usage du tabac et l'interdiction de publicité. Le juge Chabot a conclu que le procureur général du Canada n'avait pas réussi à établir, suivant la prépondérance des probabilités, l'existence d'un lien rationnel entre l'interdiction totale de publicité et l'objectif de réduire l'usage du tabac, affirmant que «le lien que l'État cherche à établir entre la protection de la santé et la publicité des produits du tabac est ténu et aléatoire» (p. 2308). Il précise, à la p. 2309, que «[l]a presque totalité de la documentation scientifique en possession de l'État lors de l'adoption de la loi ne démontrait pas que le bannissement de la publicité aurait un effet sur la consommation».

149 La deuxième exigence du critère de la proportionnalité est que la loi restreigne le droit protégé aussi peu que cela est raisonnablement possible. En d'autres termes, la violation du droit à la liberté d'expression ne doit pas s'étendre au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre l'objectif législatif, en l'occurrence, la diminution de l'usage du tabac imputable à la publicité et à l'absence de mises en garde sur les emballages. Le juge de première instance a fait remarquer, aux pp. 2310 à 2312, que le procureur général n'avait pas présenté de preuve pour établir qu'une interdiction totale réduirait l'usage du tabac davantage qu'une interdiction partielle, ou que des messages non attribués relatifs à la santé seraient plus efficaces que des messages attribués. En définitive; il a conclu que le procureur général ne s'était pas acquitté du fardeau qu'il avait d'établir que la violation des droits était soigneusement adaptée à l'objectif législatif.

150 La troisième exigence est qu'il doit y avoir proportionnalité entre l'objectif de la loi et les restrictions qu'elle impose aux droits garantis par la Constitution. Le juge Chabot a également conclu que l'État ne s'était pas acquitté de la charge qu'il avait. À son avis, la loi constitue un genre «d'ingé-

impairment of the principles inherent in a free and democratic society". This effect he found (at p. 517) to be "disproportionate to the objective of the [Act]".

151 To what extent should this Court defer to the trial judge's findings? As discussed earlier, this depends on whether the findings relate to purely factual matters or whether they relate to complex social science evidence from which it is difficult to draw firm factual and scientific conclusions. In the cases at bar, the trial lasted more than one year and a massive amount of evidence was adduced through experts and through documentary evidence on which the experts were examined. I agree with La Forest J. that it would be wrong to discard completely the trial judge's findings in these cases with respect to the credibility of witnesses and with respect to the defective methodology used in compiling the data for certain reports. In my view, Chabot J. was in a stronger position than are appellate courts to make such determinations, having listened to extensive testimony from experts on both sides of the debate. On the other hand, it may be that less deference should be accorded to the trial judge's finding that the complete ban on advertising was not rationally connected to the aim of reducing advertising-induced consumption. Much of the evidence adduced on this point was social science evidence predictive of human behaviour from which it was difficult to draw firm factual conclusions. In assessing this evidence Chabot J. erred in failing to consider factors which could suggest as a matter of logic or reason that there was, on a balance of probabilities, a rational connection between the objective and the means chosen.

152 With respect to the minimal impairment element of the proportionality analysis, I accept Chabot J.'s finding that the impugned provisions mandating a complete ban and unattributed package warnings

nierie sociale» et «une atteinte extrêmement grave aux principes inhérents d'une société libre et démocratique». Il affirme, à la p. 2312, que cet effet est «incommensurable avec l'objectif de la [Loi]».

Dans quelle mesure notre Cour devrait-elle faire preuve de retenue à l'égard des conclusions du juge de première instance? Comme je l'ai déjà dit, il faut déterminer si les conclusions se rapportent à des questions purement factuelles ou à des éléments de preuve complexes en matière de sciences humaines à partir desquels il est difficile de tirer de solides conclusions factuelles et scientifiques. En l'espèce, le procès a duré plus d'un an et une preuve volumineuse a été présentée, que ce soit par témoignages d'expert ou par dépôt de documents sur lesquels les experts ont été interrogés. Tout comme le juge La Forest, j'estime qu'il serait erroné d'écarter complètement les conclusions du juge de première instance dans les présents pourvois relativement à la crédibilité des témoins et à la mauvaise méthodologie employée pour recueillir les données de certains rapports. À mon avis, le juge Chabot était mieux placé qu'une cour d'appel pour tirer ces conclusions puisqu'il avait entendu les longs témoignages des experts des deux parties. Par contre, il y a peut-être lieu de faire preuve d'une moins grande retenue à l'égard de la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'interdiction totale de publicité n'avait pas de lien rationnel avec l'objectif de diminution de la consommation provoquée par la publicité. La majeure partie de la preuve présentée sur ce point consistait en des données en matière de sciences humaines concernant le comportement humain prévisible, à partir desquelles il était difficile de tirer de solides conclusions factuelles. Dans l'appréciation de ces données, le juge Chabot a commis une erreur en omettant d'examiner des facteurs qui, logiquement ou rationnellement, aurait pu établir, suivant la prépondérance des probabilités, l'existence d'un lien rationnel entre l'objectif et les moyens choisis.

En ce qui concerne le volet atteinte minimale de l'analyse de la proportionnalité, j'accepte la conclusion du juge Chabot voulant que les dispositions attaquées qui interdisent toute publicité et

do not minimally impair the right to free expression. Under the minimal impairment analysis, Chabot J. did not rely on problematic social science data, but on the fact that the government had adduced no evidence to show that less intrusive regulation would not achieve its goals as effectively as an outright ban. Nor had the government adduced evidence to show that attributed health warnings would not be as effective as unattributed warnings on tobacco packaging.

exigent l'apposition de mises en garde non attribuées sur les emballages ne constituent pas une atteinte minimale au droit à la liberté d'expression. Dans le cadre de l'analyse de l'atteinte minimale, le juge Chabot ne s'est pas fié à des données problématiques en matière de sciences humaines mais plutôt au fait que le gouvernement n'avait pas présenté d'éléments de preuve établissant qu'un règlement moins attentatoire n'atteindrait pas ses objectifs aussi efficacement qu'une interdiction totale. Le gouvernement n'avait pas non plus présenté d'éléments de preuve pour établir que des mises en garde attribuées sur les emballages des produits du tabac ne seraient pas aussi efficaces que des mises en garde non attribuées.

(ii) Rational Connection

As a first step in the proportionality analysis, the government must demonstrate that the infringements of the right of free expression worked by the law are rationally connected to the legislative goal of reducing tobacco consumption. It must show a causal connection between the infringement and the benefit sought on the basis of reason or logic. To put it another way, the government must show that the restriction on rights serves the intended purpose. This must be demonstrated on a balance of probabilities.

(ii) Le lien rationnel

153 À la première étape de l'analyse de la proportionnalité, le gouvernement doit démontrer que l'atteinte à la liberté d'expression entraînée par la loi a un lien rationnel avec l'objectif législatif de réduire l'usage du tabac. Il doit établir un lien causal, fondé sur la raison ou la logique, entre la violation et l'avantage recherché. En d'autres termes, le gouvernement doit établir que la restriction des droits sert la fin visée. Cette preuve doit être faite suivant la prépondérance des probabilités.

The causal relationship between the infringement of rights and the benefit sought may sometimes be proved by scientific evidence showing that as a matter of repeated observation, one affects the other. Where, however, legislation is directed at changing human behaviour, as in the case of the *Tobacco Products Control Act*, the causal relationship may not be scientifically measurable. In such cases, this Court has been prepared to find a causal connection between the infringement and benefit sought on the basis of reason or logic, without insisting on direct proof of a relationship between the infringing measure and the legislative objective: *R. v. Keegstra*, [1990] 3 S.C.R. 697, at pp. 768 and 777; *R. v. Butler*, [1992] 1 S.C.R. 452, at p. 503. As Sopinka J. wrote of the causal link

154 Le lien causal entre l'atteinte aux droits et l'avantage recherché peut parfois être établi par une preuve scientifique démontrant à la suite d'une observation répétée que l'un influe sur l'autre. Par contre, dans les cas où une loi vise une modification du comportement humain, comme dans le cas de la *Loi réglementant les produits du tabac*, le lien causal pourrait bien ne pas être mesurable du point de vue scientifique. Dans ces cas, notre Cour s'est montrée disposée à reconnaître l'existence d'un lien causal entre la violation et l'avantage recherché sur le fondement de la raison ou de la logique, sans insister sur la nécessité d'une preuve directe de lien entre la mesure attentatoire et l'objectif législatif: *R. c. Keegstra*, [1990] 3 R.C.S. 697, aux pp. 768 et 777; *R. c. Butler*, [1992] 1 R.C.S. 452, à la p. 503. Voici comment le juge Sopinka envisage le lien causal entre l'obscénité et

between obscenity and harm to society in *Butler*, at p. 502:

> While a direct link between obscenity and harm to society may be difficult, if not impossible, to establish, it is reasonable to presume that exposure to images bears a causal relationship to changes in attitudes and beliefs.

155 The trial judge in the cases at bar found that the government had not established a rational connection between the advertising ban and unattributed warnings and a reduction in tobacco use in the first, scientific sense. The only direct or scientific evidence offered of the link between advertising bans and smoking reduction consisted of a report of the New Zealand Toxic Substances Board entitled *Health or Tobacco: An End to Tobacco Advertising and Promotion* (1989), which reviewed the effect of advertising restrictions in 33 countries and concluded that there was a correlation between the degree of restrictions imposed in each country and decline in tobacco use and of the evidence of Dr. Jeffrey Harris, affirming the accuracy of the New Zealand Report. The trial judge, after lengthy consideration, rejected this evidence. The report was found, at p. 513, to contain serious methodological errors which rendered it "for all intents and purposes devoid of any probative value". As for Dr. Harris, the trial judge found, at p. 514, that he used unreliable input data and a methodology which "led necessarily to the desired result". As noted above, these findings relating to the credibility of witnesses and the soundness of various methodological approaches fall within the scope of the trial judge's traditional and accepted expertise of weighing and evaluating competing expert testimony. They have not been seriously challenged. No reason has been cited for interfering with them. We may therefore take it that there was no direct evidence of a scientific nature showing a causal

le préjudice causé à la société, dans l'arrêt *Butler*, à la p. 502:

> Bien qu'il puisse être difficile, voire impossible, d'établir l'existence d'un lien direct entre l'obscénité et le préjudice causé à la société, il est raisonnable de supposer qu'il existe un lien causal entre le fait d'être exposé à des images et les changements d'attitude et de croyance.

Le juge du procès a conclu que le gouvernement n'avait pas établi de lien rationnel entre l'interdiction de publicité et les mises en garde non attribuées, d'une part, et une diminution de l'usage du tabac au sens scientifique premier, d'autre part. La seule preuve directe ou scientifique présentée quant à l'existence du lien entre l'interdiction de publicité et la diminution de l'usage du tabac était composée d'un rapport du Toxic Substances Board de la Nouvelle-Zélande, intitulé *Health or Tobacco: An End to Tobacco Advertising and Promotion* (1989), dans lequel l'organisme, après avoir examiné les effets de restrictions imposées à la publicité dans 33 pays, est arrivé à la conclusion qu'il y avait corrélation entre le degré des restrictions imposées dans chaque pays et la diminution de l'usage du tabac, ainsi que du témoignage de Jeffrey Harris, qui a confirmé l'exactitude du rapport néo-zélandais. Après un long examen, le juge de première instance a rejeté cette preuve. Il s'est dit d'avis, à la p. 2309, que ce rapport contenait des erreurs graves de méthodologie «qui le rendent à toutes fins utiles sans valeur probante». En ce qui concerne le témoignage de Harris, le juge de première instance a affirmé, à la p. 2309, qu'il s'était servi de données non fiables et que sa méthodologie «conduit nécessairement au résultat recherché». Comme je l'ai déjà fait remarquer, ces conclusions relatives à la crédibilité des témoins et à la justesse des divers processus méthodologiques relèvent de la compétence traditionnelle que l'on reconnaît au juge de première instance de faire l'appréciation de témoignages d'experts contradictoires. Ces conclusions n'ont pas été sérieusement contestées. On ne nous a donné aucune raison de les modifier. Nous pouvons en conséquence affirmer qu'il n'existait aucune preuve directe de nature scientifique de l'existence d'un lien causal

link between advertising bans and decrease in tobacco consumption.

This leaves the question of whether there is less direct evidence that suggests as a matter of "reason" or "logic" that advertising bans and package warnings lead to a reduction in tobacco use. The evidence relied upon by La Forest J. in support of rational connection falls into this category. Without duplicating his thorough review, it may be seen as consisting largely of evidence of advertising practices as well as the assumptions and conclusions of bodies concerned with reducing the health risk associated with tobacco use.

The question is whether this evidence establishes that it is reasonable or logical to conclude that there is a causal link between tobacco advertising and unattributed health warnings and tobacco use. To use the words of the Meese Commission on Pornography relied on in *Butler*, at p. 502, "would [it] be surprising . . . to find otherwise"? The government argues that it would be "surprising . . . to find otherwise". Why would tobacco companies spend great sums on advertising if not to increase the consumption of tobacco, it asks?

To this the tobacco companies reply that their advertising is directed not at increasing the size of the total market but at obtaining a larger share of the existing market. The evidence indicates that one of the thrusts of the advertising programs of tobacco companies is securing a larger market share, but there is also evidence suggesting that advertising is used to increase the total market. For example, the Court was referred to an Imperial Tobacco Ltd. ("Imperial") document, *Project Viking*, vol. I: *A Behavioural Model of Smoking*, a market research study carried out to determine an advertising strategy for the company. The report suggests that advertising should be directed to "expanding the market, or at the very least, forestalling its decline" by proactively recruiting new smokers and reassuring present smokers who

entre une interdiction de publicité et la diminution de l'usage du tabac.

156 Il reste à déterminer s'il existe une preuve moins directe qui, «rationnellement» ou «logiquement», permet d'affirmer qu'une interdiction de publicité et des mises en garde sur les emballages amènent une diminution de l'usage du tabac. Les éléments de preuve sur lesquels se fonde le juge La Forest pour conclure à l'existence d'un lien rationnel font partie de cette catégorie. Sans reprendre son examen approfondi, je constate que cette preuve se compose en grande partie de données sur les pratiques publicitaires et des hypothèses et conclusions des organismes qui se préoccupent de la diminution des méfaits de l'usage du tabac sur la santé.

157 La question est de savoir si cette preuve établit qu'il est raisonnable ou logique de conclure qu'il existe un lien causal entre la publicité en faveur du tabac et les mises en garde non attribuées, d'une part, et l'usage du tabac, d'autre part. Pour citer le rapport de la Commission Meese sur la pornographie, sur lequel notre Cour s'est appuyée dans l'arrêt *Butler*, à la p. 502, «[c]ela n'est guère étonnant. Le contraire le serait». Le gouvernement soutient que «[l]e contraire serait étonnant». Pourquoi, demande-t-il, les compagnies de tabac consacreraient-elles tant d'argent à la publicité si ce n'est pour accroître l'usage du tabac?

158 À cela, les compagnies de tabac répondent que leur publicité ne vise pas à accroître la taille du marché global, mais bien à obtenir une plus grande part du marché existant. La preuve révèle que les campagnes publicitaires des compagnies de tabac visent à leur permettre d'acquérir une plus grande part du marché, mais d'autres éléments de preuve montrent qu'elles servent aussi à accroître l'ensemble du marché. Par exemple, on a soumis à notre Cour un document de la compagnie Imperial Tobacco Ltd. («Imperial»), intitulé *Project Viking*, vol. I. *A Behavioural Model of Smoking*, une étude de marché réalisée aux fins de l'établissement d'une stratégie publicitaire pour la compagnie. Ce rapport dit que la publicité devrait viser à [TRADUCTION] «faire croître la taille du marché ou, tout au moins, à prévenir son déclin» en cherchant proacti-

might otherwise quit in response to vigorous anti-smoking publicity. Moreover, while purely informational advertising may not increase the total market, lifestyle advertising may, as a matter of common sense, be seen as having a tendency to discourage those who might otherwise cease tobacco use from doing so. Conversely, package warnings, attributed or not, may be seen as encouraging people to reduce or cease using tobacco. All this taken together with the admittedly inconclusive scientific evidence is sufficient to establish on a balance of probabilities a link based on reason between certain forms of advertising, warnings and tobacco consumption.

159 On the other hand, there does not appear to be any causal connection between the objective of decreasing tobacco consumption and the absolute prohibition on the use of a tobacco trade mark on articles other than tobacco products which is mandated by s. 8 of the Act. There is no causal connection based on direct evidence, nor is there, in my view, a causal connection based in logic or reason. It is hard to imagine how the presence of a tobacco logo on a cigarette lighter, for example, would increase consumption; yet, such use is banned. I find that s. 8 of the Act fails the rational connection test.

(iii) Minimal Impairment

160 As the second step in the proportionality analysis, the government must show that the measures at issue impair the right of free expression as little as reasonably possible in order to achieve the legislative objective. The impairment must be "minimal", that is, the law must be carefully tailored so that rights are impaired no more than necessary. The tailoring process seldom admits of perfection and the courts must accord some leeway to the legislator. If the law falls within a range of reasonable alternatives, the courts will not find it overbroad merely because they can conceive of an alternative which might better tailor objective to infringement: see *Reference re ss. 193 and 195.1(1)(c) of*

vement à intéresser de nouveaux fumeurs et en rassurant les fumeurs actuels qui seraient susceptibles d'abandonner en raison de la vigoureuse publicité contre le tabac. En outre, bien que la publicité purement informative puisse ne pas donner lieu à un accroissement du marché global, la publicité de style de vie peut logiquement être considérée comme ayant une tendance à dissuader de cesser de fumer ceux qui autrement cesseraient. En revanche, les mises en garde sur les emballages, attribuées ou non, peuvent être considérées comme une façon d'inciter les gens à diminuer ou abandonner leur usage du tabac. Ces facteurs, conjugués à la preuve scientifique considérée comme non concluante, suffisent à établir, suivant la prépondérance des probabilités, l'existence d'un lien fondé sur la raison entre certaines formes de publicité, les mises en garde et l'usage du tabac.

Par contre, il ne paraît pas y avoir de lien causal entre l'objectif de diminution de l'usage du tabac et l'interdiction absolue quant à l'usage des marques sur des articles autres que les produits du tabac, imposée par l'art. 8 de la Loi. Il n'existe ni lien causal fondé sur une preuve directe, ni d'ailleurs à mon avis, de lien causal fondé sur la logique ou la raison. Il est difficile de s'imaginer comment la présence d'un logo sur un briquet, par exemple, permettrait d'accroître l'usage du tabac mais pourtant, cette pratique est interdite. À mon avis, l'art. 8 de la Loi ne satisfait pas au critère du lien rationnel.

(iii) L'atteinte minimale

À la deuxième étape de l'analyse de la proportionnalité, le gouvernement doit établir que les mesures en cause restreignent le droit à la liberté d'expression aussi peu que cela est raisonnablement possible aux fins de la réalisation de l'objectif législatif. La restriction doit être «minimale», c'est-à-dire que la loi doit être soigneusement adaptée de façon à ce que l'atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Le processus d'adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l'intérieur d'une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu'elle a une portée trop générale simplement

the Criminal Code (Man.), [1990] 1 S.C.R. 1123, at pp. 1196-97; *R. v. Chaulk*, [1990] 3 S.C.R. 1303, at pp. 1340-41; *Ramsden v. Peterborough (City)*, [1993] 2 S.C.R. 1084, at pp. 1105-06. On the other hand, if the government fails to explain why a significantly less intrusive and equally effective measure was not chosen, the law may fail.

parce qu'ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l'objectif et à la violation; voir *Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.)*, [1990] 1 R.C.S. 1123, aux pp. 1196 et 1197; *R. c. Chaulk*, [1990] 3 R.C.S. 1303, aux pp. 1340 et 1341, et *Ramsden c. Peterborough (Ville)*, [1993] 2 R.C.S. 1084, aux pp. 1105 et 1106. Par contre, si le gouvernement omet d'expliquer pourquoi il n'a pas choisi une mesure beaucoup moins attentatoire et tout aussi efficace, la loi peut être déclarée non valide.

The trial judge, as we have seen, was troubled by the fact that the government had presented no evidence showing that a less comprehensive ban on advertising would not have been equally effective, or that an attributed warning would not have been equally effective as an unattributed one.

Comme nous l'avons vu, le juge de première instance était troublé par le fait que le gouvernement n'avait pas présenté d'éléments de preuve pour établir qu'une interdiction de publicité moins globale n'aurait pas été aussi efficace qu'une interdiction totale ou qu'une mise en garde attribuée n'aurait pas été tout aussi efficace qu'une mise en garde non attribuée. 161

I turn first to the prohibition on advertising contained in s. 4 of the Act. It is, as has been observed, complete. It bans all forms of advertising of Canadian tobacco products while explicitly exempting all foreign advertising of non-Canadian products which are sold in Canada. It extends to advertising which arguably produces benefits to the consumer while having little or no conceivable impact on consumption. Purely informational advertising, simple reminders of package appearance, advertising for new brands and advertising showing relative tar content of different brands — all these are included in the ban. Smoking is a legal activity yet consumers are deprived of an important means of learning about product availability to suit their preferences and to compare brand content with an aim to reducing the risk to their health.

J'examine tout d'abord l'interdiction de publicité prévue à l'art. 4 de la Loi. Comme on l'a fait remarquer, il s'agit d'une interdiction totale. Cette disposition interdit toutes les formes de publicité en faveur des produits du tabac canadiens et exclut explicitement toute publicité étrangère en faveur de produits non canadiens vendus au Canada. Elle vise toute publicité qui, pourrait-on soutenir, présente des avantages pour le consommateur, tout en n'ayant pratiquement aucune incidence sur l'usage. L'interdiction vise toute publicité purement informative, les simples notes quant à l'apparence de l'emballage, la publicité en faveur de nouvelles marques et la publicité indiquant le contenu relatif de goudron des différentes marques de tabac. Fumer est une activité légale; cependant, le consommateur est privé d'un important moyen de se renseigner sur l'offre de produits susceptibles de satisfaire à ses préférences et de comparer le contenu des produits de diverses marques dans le but de diminuer les méfaits du tabac pour sa santé. 162

As this Court has observed before, it will be more difficult to justify a complete ban on a form of expression than a partial ban: *Ramsden v. Peterborough (City)*, *supra*, at pp. 1105-06; *Ford v. Quebec (Attorney General)*, *supra*, at pp. 772-73.

Comme notre Cour l'a déjà fait remarquer, il sera plus difficile de justifier l'interdiction totale d'une forme d'expression que l'interdiction partielle: *Ramsden c. Peterborough (Ville)*, précité, aux pp. 1105 et 1106, et *Ford c. Québec (Procu-* 163

The distinction between a total ban on expression, as in *Ford* where the legislation at issue required commercial signs to be exclusively in French, and a partial ban such as that at issue in *Irwin Toy*, *supra*, is relevant to the margin of appreciation which may be allowed the government under the minimal impairment step of the analysis. In *Rocket*, *supra*, the law imposed a complete advertising ban on professionals seeking to advertise their services. I concluded that while the government had a pressing and substantial objective, and while that objective was rationally connected to the means chosen, the minimal impairment requirement was not met since the government had exceeded a reasonable margin of appreciation given the need for consumers to obtain useful information about the services provided. A full prohibition will only be constitutionally acceptable under the minimal impairment stage of the analysis where the government can show that only a full prohibition will enable it to achieve its objective. Where, as here, no evidence is adduced to show that a partial ban would be less effective than a total ban, the justification required by s. 1 to save the violation of free speech is not established.

164 As noted in my analysis of rational connection, while one may conclude as a matter of reason and logic that lifestyle advertising is designed to increase consumption, there is no indication that purely informational or brand preference advertising would have this effect. The government had before it a variety of less intrusive measures when it enacted the total ban on advertising, including: a partial ban which would allow information and brand preference advertising; a ban on lifestyle advertising only; measures such as those in Quebec's *Consumer Protection Act*, R.S.Q., c. P-40.1, to prohibit advertising aimed at children and adolescents; and labelling requirements only (which Health and Welfare believed would be preferable to an advertising ban: A. J. Liston's testi-

reur général), précité, aux pp. 772 et 773. La distinction entre une interdiction totale d'une forme d'expression, comme dans l'arrêt *Ford* dans lequel la loi en cause exigeait que l'affichage commercial se fasse uniquement en français, et une interdiction partielle, comme celle dont il était question dans l'arrêt *Irwin Toy*, précité, est pertinente pour ce qui est du degré de latitude dont peut bénéficier le gouvernement en vertu du critère de l'atteinte minimale de l'analyse. Dans *Rocket*, précité, la loi imposait une interdiction totale de publicité aux professionnels cherchant à annoncer leurs services. J'y ai conclu que, même si le gouvernement avait un objectif urgent et réel et si cet objectif avait un lien rationnel avec les moyens choisis, l'exigence de l'atteinte minimale n'avait pas été remplie puisque le gouvernement avait excédé la latitude raisonnable dont il disposait, vu qu'il était nécessaire que les consommateurs obtiennent des renseignements utiles sur les services offerts. Une interdiction totale ne sera acceptable, sur le plan constitutionnel, en vertu du volet atteinte minimale de l'analyse que dans le cas où le gouvernement peut établir que seule une interdiction totale lui permettra d'atteindre son objectif. Si, comme en l'espèce, aucune preuve n'a été présentée pour démontrer qu'une interdiction partielle serait moins efficace qu'une interdiction totale, on n'a pas établi la justification requise en vertu de l'article premier visant à sauvegarder la violation de la liberté d'expression.

Comme je l'ai fait remarquer dans mon analyse du lien rationnel, bien que l'on puisse conclure, de façon rationnelle et logique, que la publicité de style de vie vise à accroître la consommation, rien n'indique que la publicité purement informative ou de fidélité aux marques aurait cet effet. Au moment où il a adopté l'interdiction totale de la publicité, le gouvernement disposait de toute une gamme de mesures moins attentatoires: une interdiction partielle qui aurait permis la publicité informative et de fidélité aux marques, une interdiction de publicité de style de vie seulement, des mesures comme celles prévues dans la *Loi sur la protection du consommateur* du Québec, L.R.Q., ch. P-40.1, dans le but d'interdire la publicité destinée aux enfants et aux adolescents, et des exi-

mony). In my view, any of these alternatives would be a reasonable impairment of the right to free expression, given the important objective and the legislative context.

gences en matière d'étiquetage seulement (qui selon Santé et Bien-être social seraient préférables à une interdiction de publicité: voir le témoignage de A. J. Liston). À mon avis, chacune de ces mesures constituerait une atteinte raisonnable au droit à la liberté d'expression, étant donné l'importance de l'objectif et du contexte législatif.

These considerations suggest that the advertising ban imposed by s. 4 of the Act may be more intrusive of freedom of expression than is necessary to accomplish its goals. Indeed, Health and Welfare proposed less-intrusive regulation instead of a complete prohibition on advertising. Why then, did the government adopt such a broad ban? The record provides no answer to this question. The government presented no evidence in defence of the total ban, no evidence comparing its effects to less invasive bans.

165 Il appert de ces réflexions que l'interdiction de publicité imposée par l'art. 4 de la Loi pourrait bien porter davantage atteinte à la liberté d'expression qu'elle n'a à le faire pour que ses objectifs soient atteints. En fait, le ministère de la Santé et du Bien-être social a proposé un règlement moins attentatoire en remplacement d'une interdiction totale de la publicité. Alors, pourquoi le gouvernement a-t-il adopté une interdiction si générale? Le dossier ne renferme rien sur cette question. Le gouvernement n'a pas présenté d'éléments de preuve pour défendre l'interdiction totale ni de données établissant une comparaison entre les effets d'une interdiction totale et des interdictions moins attentatoires.

This omission is all the more glaring in view of the fact that the government carried out at least one study of alternatives to a total ban on advertising before enacting the total ban. The government has deprived the courts of the results of that study. The Attorney General of Canada refused to disclose this document and approximately 500 others demanded at the trial by invoking s. 39 of the *Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5, thereby circumventing an application by the tobacco companies for disclosure since the courts lack authority to review the documents for which privilege is claimed under s. 39. References to the study were blanked out of such documents as were produced: Reasons at Trial, at p. 516. In the face of this behaviour, one is hard-pressed not to infer that the results of the studies must undercut the government's claim that a less invasive ban would not have produced an equally salutary result.

166 Cette omission est d'autant plus flagrante que le gouvernement avait effectué au moins une étude des solutions de rechange avant d'opter pour l'interdiction totale. Le gouvernement a privé les tribunaux des résultats de cette étude. Le procureur général du Canada a refusé de divulguer ce document, de même qu'environ 500 autres dont la production avait été demandée en première instance; il a, à cette fin, invoqué l'art. 39 de la *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5, faisant ainsi échec à une demande de divulgation présentée par les compagnies de tabac puisque les tribunaux n'ont pas compétence pour examiner les documents selon lesquels un privilège est réclamé en vertu de cette disposition. Les mentions de cette étude ont été biffées des documents produits: motifs de la première instance, à la p. 2311. Face à cette attitude, il est difficile de ne pas inférer que les résultats de ces études font échec à la prétention du gouvernement qu'une interdiction moins attentatoire n'aurait pas donné lieu à un résultat tout aussi valable.

Not only did the government present no evidence justifying its choice of a total ban, it also

167 Non seulement le gouvernement n'a pas produit d'éléments de preuve pour justifier l'interdiction

presented no argument before us on the point. The appellants argued that there were undisclosed alternatives to a complete ban. The Attorney General's factum offered no response. Instead, the Attorney General contented himself with the bland statement that a complete ban is justified because Parliament "had to balance competing interests" somehow. Its response to the minimal impairment argument is not evidence, but a simple assertion that Parliament has the right to set such limits as it chooses:

> . . . Parliament was certainly entitled to conclude that nothing short of the means it designed would meet the public health objectives set out in s. 3 of the [Act]. The Act is a justified preventative health measure. Parliament has the ability to set the exact limits of this measure. [Emphasis added.]

totale qu'il a choisi d'imposer, il ne nous a non plus présenté aucun argument sur ce point. Selon les appelantes, d'autres mesures non divulguées auraient pu remplacer une interdiction totale. Le mémoire du procureur général n'a pas apporté de réponse. En fait, le procureur général s'est contenté d'affirmer d'une manière imperturbable qu'une interdiction totale est justifiée parce que le Parlement [TRADUCTION] «devait soupeser des intérêts contradictoires». La façon dont il répond à l'argument concernant l'atteinte minimale ne constitue pas une preuve, mais bien une simple affirmation que le Parlement a le droit de fixer les limites qu'il choisit:

> [TRADUCTION] . . . le Parlement avait certainement le droit de conclure que seuls les moyens qu'il avait conçus permettraient d'atteindre les objectifs en matière de santé publique, énoncés à l'art. 3 [de la Loi]. La Loi est une mesure préventive justifiée en matière de santé. Le Parlement peut en fixer les limites exactes. [Je souligne.]

168 My colleague La Forest J., while recognizing that the government's refusal to release the documents puts this Court in a difficult position given that the onus is on the government to make out minimal impairment, nonetheless concludes that the legislation is minimally impairing based on the importance of the legislative objective and the legislative context. With respect, I cannot agree. Even on difficult social issues where the stakes are high, Parliament does not have the right to determine unilaterally the limits of its intrusion on the rights and freedoms guaranteed by the *Charter*. The Constitution, as interpreted by the courts, determines those limits. Section 1 specifically stipulates that the infringement may not exceed what is reasonable and "demonstrably justified in a free and democratic society", a test which embraces the requirement of minimal impairment, and places on the government the burden of demonstrating that Parliament has respected that limit. This the government has failed to do, notwithstanding that it had at least one study on the comparative effectiveness of a partial and complete ban. In the face of this omission, the fact that full bans have been imposed in certain other countries and the fact that opinions

Néanmoins, mon collègue le juge La Forest conclut, tout en reconnaissant que le refus du gouvernement de divulguer les documents place notre Cour dans une situation difficile puisqu'il appartient au gouvernement d'établir l'atteinte minimale, que la loi crée une atteinte minimale compte tenu de l'importance de l'objectif et du contexte de la loi. En toute déférence, je ne suis pas d'accord. Même dans le cas de problèmes sociaux difficiles qui présentent des enjeux élevés, le Parlement n'a pas le droit de déterminer unilatéralement les limites qu'il peut imposer aux droits et libertés garantis par la *Charte*. C'est la Constitution, selon l'interprétation que lui donnent les tribunaux, qui détermine ces limites. L'article premier édicte expressément que la violation ne peut aller au-delà de limites qui soient «raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique», critère qui englobe l'exigence de l'atteinte minimale et impose au gouvernement le fardeau d'établir que le Parlement a respecté cette limite. C'est ce que le gouvernement a omis de faire, même s'il disposait d'au moins une étude sur l'efficacité comparative d'une interdiction partielle et d'une interdiction totale.

favouring total bans can be found, fall short of establishing minimal impairment.

Compte tenu de cette omission, le fait que des interdictions totales ont été imposées dans certains autres pays et qu'il existe des opinions favorables à une interdiction totale ne réussit pas à établir une atteinte minimale.

La Forest J. supports his conclusion that Parliament should be permitted to choose such measures as it sees fit by contrasting the importance of Parliament's objective with the low value of the expression at issue. This way of answering the minimal impairment requirement raises a number of concerns. First, to argue that the importance of the legislative objective justifies more deference to the government at the stage of evaluating minimal impairment, is to engage in the balancing between objective and deleterious effect contemplated by the third stage of the proportionality analysis in *Oakes*. While it may not be of great significance where this balancing takes place, care must be taken not to devalue the need for demonstration of minimum impairment by arguing the legislation is important and the infringement of no great moment.

169 Le juge La Forest base sa conclusion selon laquelle le Parlement devrait avoir le droit de choisir les mesures qu'il juge appropriées sur la comparaison entre l'importance de l'objectif du Parlement et la faible valeur de l'expression en cause. Cette façon de satisfaire à l'exigence de l'atteinte minimale soulève certaines préoccupations. Premièrement, soutenir que l'importance de l'objectif législatif justifie un plus grand respect envers le gouvernement à l'étape de l'évaluation de l'atteinte minimale, c'est procéder à la pondération des effets objectifs et des effets préjudiciables, prévue à la troisième étape de l'analyse de la proportionnalité dans l'arrêt *Oakes*. Le moment de cette pondération n'a peut-être pas beaucoup d'importance en soi; cependant, on doit veiller à ne pas minimiser la nécessité de démontrer l'existence d'une atteinte minimale en faisant valoir que la loi est importante mais que la violation ne l'est pas vraiment.

Second, just as care must be taken not to overvalue the legislative objective beyond its actual parameters, so care must be taken not to undervalue the expression at issue. Commercial speech, while arguably less important than some forms of speech, nevertheless should not be lightly dismissed. For example, in *Rocket, supra*, this Court struck down restrictions on dental advertising on the ground that the minimal impairment requirement had not been met. The *Health Disciplines Act*, R.S.O. 1980, c. 196, prohibited forms of advertising which far from being unprofessional, might have benefited consumers and contributed to their health. The same may be said here. Tobacco consumption has not been banned in Canada. Yet the advertising ban deprives those who lawfully choose to smoke of information relating to price, quality and even health risks associated with different brands. It is no answer to suggest, as does my colleague, (para. 108) that the tobacco companies have failed to establish the true benefits of

170 Deuxièmement, tout comme il faut prendre soin de ne pas surestimer l'objectif législatif par rapport à ses véritables paramètres, il faut veiller à ne pas sous-estimer l'importance de l'expression en cause. Quoique l'on puisse soutenir que le discours commercial est moins important que certaines formes d'expression, on ne devrait néanmoins pas l'écarter à la légère. Par exemple, dans l'arrêt *Rocket*, précité, notre Cour a annulé des restrictions imposées à la publicité des dentistes pour le motif que l'on n'avait pas satisfait à l'exigence de l'atteinte minimale. La *Loi sur les sciences de la santé*, L.R.O. 1980, ch. 196, interdisait certains types de publicité qui, loin d'être non professionnels, auraient pu présenter des avantages pour les consommateurs et contribuer à leur santé. On peut reprendre le même argument ici. L'usage du tabac n'a pas été interdit au Canada. Cependant, l'interdiction de publicité prive les fumeurs légitimes de renseignements sur le prix, la qualité, voire même les méfaits des différentes marques de tabac sur la

such information. Under s. 1 of the *Charter*, the onus rests on the government to show why restrictions on these forms of advertising are required.

171 Third, in finding that the commercial speech here at issue is entitled "to a very low degree of protection under s. 1" (para. 75) and that "an attenuated level of s. 1 justification is appropriate in these cases" (para. 77), La Forest J. places a great deal of reliance on the fact that the appellants are motivated by profit. I note that the same may be said for many business persons or corporations that challenge a law as contrary to freedom of expression. While this Court has stated that restrictions on commercial speech may be easier to justify than other infringements, no link between the claimant's motivation and the degree of protection has been recognized. Book sellers, newspaper owners, toy sellers — all are linked by their shareholders' desire to profit from the corporation's business activity, whether the expression sought to be protected is closely linked to the core values of freedom of expression or not. In my view, motivation to profit is irrelevant to the determination of whether the government has established that the law is reasonable or justified as an infringement of freedom of expression.

172 It remains to consider whether the requirement that the warning be unattributed pursuant to s. 9 of the Act fails to meet the minimum impairment requirement of proportionality. The appellant corporations contend that a warning similar to that used in the United States, which identifies the author as the Surgeon General, would be equally effective while avoiding the inference some may draw that it is the corporations themselves who are warning of the danger. They object not only to being forced to say what they do not wish to say, but also to being required to do so in a way that associates them with the opinion in question. This

santé. Il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait mon collègue (par. 108), que les compagnies de tabac n'ont pas établi les véritables avantages de ces renseignements. En vertu de l'article premier de la *Charte*, il appartient au gouvernement d'établir pourquoi il faut imposer des restrictions relativement à ces types de publicité.

Troisièmement, en affirmant que le discours commercial en cause n'a droit «qu'à une faible protection en vertu de l'article premier» (par. 75) et qu'«il convient en l'espèce de faire preuve de souplesse dans la justification au regard de l'article premier» (par. 77), le juge La Forest accorde beaucoup d'importance au fait que les appelantes sont motivées par le profit. Il en est de même de nombreux entrepreneurs ou sociétés qui contestent une loi pour le motif qu'elle contrevient à la liberté d'expression. Bien qu'elle ait affirmé que des restrictions au discours commercial puissent être plus faciles à justifier que d'autres violations, notre Cour n'a pas reconnu de lien entre la motivation d'une demanderesse et le degré de protection accordée. Les libraires, les propriétaires de journaux, les vendeurs de jouets ont tous en commun le désir des actionnaires de tirer profit de l'activité commerciale de la compagnie, que l'expression que l'on veut protéger soit ou non étroitement liée aux valeurs fondamentales de la liberté d'expression. À mon avis, la volonté de faire un profit ne constitue pas une considération pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si le gouvernement a établi que la loi est raisonnable ou justifiée en tant qu'atteinte à la liberté d'expression.

Il reste à établir si l'exigence de la non-attribution des mises en garde, prévue à l'art. 9 de la Loi, ne satisfait pas à l'exigence de l'atteinte minimale du critère de la proportionnalité. Selon les appelantes, une mise en garde semblable à celle utilisée aux États-Unis, émanant du Surgeon General, serait tout aussi efficace, et empêcherait certains d'inférer que ce sont les compagnies qui font la mise en garde. Les compagnies s'opposent non seulement à ce qu'on leur attribue des propos qu'elles n'ont pas l'intention de tenir, mais aussi à se voir obligées de le faire d'une façon qui les associe au message en question. À leur avis, cela

impairs their freedom of expression, they contend, more than required to achieve the legislative goal.

The government is clearly justified in requiring the appellants to place warnings on tobacco packaging. The question is whether it was necessary to prohibit the appellants from attributing the message to the government and whether it was necessary to prevent the appellants from placing on their packaging any information other than that allowed by the regulations.

As with the advertising ban, it was for the government to show that the unattributed warning, as opposed to an attributed warning, was required to achieve its objective of reducing tobacco consumption among those who might read the warning. Similarly, it was for the government to show why permitting tobacco companies to place additional information on tobacco packaging, such as a statement announcing lower tar levels, would defeat the government's objective. This it has failed to do. Again, my colleague La Forest J. responds (para. 116) with the belief that "a lower level of constitutional scrutiny is justified in this context". For the reasons given with respect to the advertising ban, I respectfully disagree.

(iv) Proportionality Between the Effects of the Legislation and the Objective

Having found the requirement of minimum impairment is not satisfied for ss. 4 and 9 of the Act, it is unnecessary to proceed to the final stage of the proportionality analysis under s. 1 — balancing the negative effects of the infringement of rights against the positive benefits associated with the legislative goal. A finding that the law impairs the right more than required contradicts the assertion that the infringement is proportionate. Neither the fact that commercial expression may be entitled to a lesser degree of protection than certain other forms of expression, nor the importance of reducing tobacco consumption, even to a small extent, negate this proposition. Freedom of expression, even commercial expression, is an important

porte atteinte à leur liberté d'expression plus qu'il n'est nécessaire de le faire pour atteindre l'objectif de la loi.

173 Le gouvernement est clairement justifié d'exiger des appelantes qu'elles apposent des mises en garde sur les emballages des produits du tabac. La question est de savoir s'il était nécessaire d'interdire aux appelantes d'attribuer le message au gouvernement et s'il était nécessaire de les empêcher d'apposer sur leur emballage des renseignements autres que ceux autorisés par règlement.

174 Comme pour l'interdiction de publicité, il appartenait au gouvernement d'établir que la mise en garde non attribuée, par opposition à une mise en garde attribuée, était nécessaire pour atteindre l'objectif visé de réduire la consommation du tabac chez les personnes susceptibles de la lire. De même, le gouvernement devait établir pourquoi l'inscription de renseignements additionnels sur les emballages par les compagnies de tabac, comme un message sur la faible teneur en goudron, irait à l'encontre de son objectif. Il n'a pas réussi à le faire. De nouveau, mon collègue le juge La Forest affirme (par. 116) que, selon lui, «en l'occurrence l'analyse constitutionnelle n'a pas à être aussi approfondie». Avec égards, pour les motifs exposés relativement à l'interdiction de publicité, je ne suis pas d'accord.

(iv) La proportionnalité entre les effets de la loi et son objectif

175 Puisque j'ai conclu que l'on n'a pas satisfait à l'exigence de l'atteinte minimale relativement aux art. 4 et 9 de la Loi, j'estime inutile de procéder à l'examen de la dernière étape du critère de la proportionnalité dans la cadre de l'article premier: soupeser les effets négatifs de la violation des droits par rapport aux avantages positifs liés à l'objectif législatif. Conclure que la loi porte atteinte au droit en question plus qu'il n'est nécessaire contredit l'affirmation que la violation satisfait au critère de la proportionnalité. Ni le fait que l'expression commerciale peut bénéficier d'une protection moindre que certaines autres formes d'expression, ni l'importance de réduire la consommation du tabac, même légèrement, ne viennent repousser

and fundamental tenet of a free and democratic society. If Parliament wishes to infringe this freedom, it must be prepared to offer good and sufficient justification for the infringement and its ambit. This it has not done.

2. Remedy

176 I have found ss. 4, 8 and 9 of the *Tobacco Products Control Act* constitute unjustified infringements on free expression. These provisions spearhead the scheme under the Act and cannot be severed cleanly from other provisions dealing with promotion and trade mark usage, ss. 5 and 6. I would consequently hold that ss. 4, 5, 6, 8, and 9 are inconsistent with the *Charter* and hence are of no force or effect by reason of s. 52 of the *Constitution Act, 1982.*

177 Section 7 of the Act prohibits the free distribution of any tobacco product in any form, a provision which is closely connected to the law's objective. In my view, this provision should stand, together with the remaining provisions of the Act which deal with reporting, enforcement, regulations and offences and punishment, in so far as these sections operate in relation to provisions other than those declared invalid.

178 This leaves the question of costs. The appellant Imperial has been successful in these appeals. The appellant RJR-MacDonald has been substantially successful. Having requested that the whole of the *Tobacco Products Control Act* be struck down, it has succeeded in having a significant portion of it struck down. I would allow the appeals with costs to both appellants.

The following are the reasons delivered by

179 IACOBUCCI J. — These appeals concern the constitutional legitimacy of the *Tobacco Products Control Act*, S.C. 1988, c. 20 (the "Act"), a federal statute which effectively establishes a total ban on cigarette advertising in Canada.

cette affirmation. La liberté d'expression, même l'expression commerciale, constitue un précepte important et fondamental d'une société libre et démocratique. Si le Parlement a l'intention de porter atteinte à cette liberté, il doit être disposé à justifier l'étendue de cette atteinte de façon adéquate et suffisante. Il ne l'a pas fait.

2. La réparation

J'ai conclu que les art. 4, 8 et 9 de la *Loi réglementant les produits du tabac* constituent des atteintes injustifiées à la liberté d'expression. Ces dispositions sont le fer de lance de l'économie de la Loi et ne peuvent être nettement dissociées des autres qui traitent de promotion et d'usage des marques, les art. 5 et 6. Je conclus donc que les art. 4, 5, 6, 8 et 9 sont incompatibles avec la *Charte* et sont de ce fait inopérants en application de l'art. 52 de la *Loi constitutionnelle de 1982.*

L'article 7 de la Loi interdit la distribution à titre gratuit des produits du tabac, sous quelque forme que ce soit, disposition qui se rattache étroitement à l'objectif de la Loi. À mon avis, cette disposition devrait être déclarée valide, de même que les autres dispositions de la Loi relatives aux rapports, à la mise en œuvre, aux règlements, aux infractions et aux peines, dans la mesure où elles s'appliquent aux dispositions autres que celles qui ont été déclarées non valides.

Il reste à trancher la question des dépens. L'appelante Imperial a eu gain de cause en l'espèce. L'appelante RJR-MacDonald a elle aussi eu essentiellement gain de cause. Elle avait demandé l'annulation intégrale de la *Loi réglementant les produits du tabac* et a réussi à en faire annuler une bonne partie. Je suis d'avis d'accueillir les pourvois avec dépens aux deux appelantes.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE IACOBUCCI — Les présents pourvois portent sur la constitutionnalité de la *Loi réglementant les produits du tabac*, L.C. 1988, ch. 20 (la «Loi»), loi fédérale qui établit en fait une interdiction totale de la publicité en faveur de la cigarette au Canada.

The appellants submit that there are two alternative grounds that support the constitutional invalidity of the Act: (1) that it is *ultra vires* the powers accorded to Parliament by s. 91 of the *Constitution Act, 1867*; and (2) that it infringes the appellants' right to freedom of expression in a manner that does not constitute a reasonable limit under s. 1 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*.

Les appelantes soutiennent que deux motifs subsidiaires viennent étayer l'inconstitutionnalité de la Loi: (1) elle excède les pouvoirs conférés au Parlement par l'art. 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, et (2) elle porte atteinte à la liberté d'expression des appelantes d'une façon qui ne constitue pas une limite raisonnable en vertu de l'article premier de la *Charte canadienne des droits et libertés*. 180

My colleague Justice La Forest details at length the reasons why the Act is properly enacted pursuant to the federal power over criminal law (s. 91(27)). I find myself in full agreement with him in this regard. I also agree with his approach to appellate court intervention on legislative or social facts as found by a trial judge.

Mon collègue le juge La Forest expose en détail les motifs pour lesquels il s'agit d'une loi validement adoptée conformément à la compétence fédérale en matière de droit criminel (par. 91(27)). Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Je suis également d'accord avec la démarche qu'il adopte relativement à l'intervention des tribunaux d'appel quant aux faits législatifs ou sociaux constatés par le juge de première instance. 181

I diverge, however, with La Forest J. on the *Charter* issue; specifically, I do not believe that the Act minimally impairs the appellants' s. 2(*b*) *Charter* rights. More broadly, I also have reservations about the somewhat attenuated minimal impairment analysis propounded by La Forest J. As I noted in my reasons in *Egan v. Canada*, [1995] 2 S.C.R. 513, unduly diluting the s. 1 principles from their original form cast in *R. v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103, and related cases causes me concern in so far as it creates a risk that *Charter* violations will be too readily justified and, as a result, *Charter* values too easily undercut. In this respect, I find myself generally attracted to Justice McLachlin's reasons and disposition in this appeal. Nevertheless, although I concur with many of her general conclusions, I differ somewhat with her s. 1 analysis and proposed remedy and therefore prefer to express my own reasons.

Cependant, je ne partage pas l'opinion du juge La Forest sur la question de la *Charte* et, plus précisément, je ne crois pas que la Loi constitue une atteinte minimale aux droits garantis aux appelantes par l'al. 2*b*) de la *Charte*. D'une façon plus générale, j'ai aussi des réserves sur l'analyse quelque peu assouplie de l'atteinte minimale que propose le juge La Forest. Comme je l'ai fait remarquer dans mes motifs de l'arrêt *Egan c. Canada*, [1995] 2 R.C.S. 513, je crains un trop grand assouplissement des principes d'application de l'article premier par rapport à leur formulation initiale dans l'arrêt *R. c. Oakes*, [1986] 1 R.C.S. 103, et les arrêts connexes, car cela crée un risque que les violations de la *Charte* ne soient trop facilement justifiées et, de ce fait, que les valeurs protégées par la *Charte* ne soient trop facilement contrecarrées. À cet égard, je trouve généralement intéressants les motifs et le dispositif du juge McLachlin en l'espèce. Néanmoins, bien que je souscrive à nombre de ses conclusions générales, j'ai une opinion quelque peu différente quant à son analyse de l'article premier et à la réparation proposée et je préfère donc formuler mes propres motifs. 182

The two principal issues underlying the *Charter* analysis in these appeals are: (1) whether the Act is rationally connected to its goal of protecting Canadians from the health risks associated with

Les deux principales questions en litige qui sous-tendent l'analyse fondée sur la *Charte* dans les présents pourvois sont de savoir (1) si la Loi a un lien rationnel avec son objectif de protéger les 183

tobacco use and, if so, (2) whether the legislation attains this rationally connected goal in a manner that minimally impairs the appellants' infringed *Charter* rights.

184 Rational connection is to be established, upon a civil standard, through reason, logic or simply common sense. The existence of scientific proof is simply of probative value in demonstrating this reason, logic or common sense. It is by no means dispositive or determinative.

185 Clarifying the standard upon which rational connection analysis ought to proceed is of great importance in appeals such as these, in which there is extremely lengthy yet generally inconclusive scientific evidence. In short, Chabot J. found much of the scientific evidence to be suspect and was of the mind that the Act was "social engineering". With respect, this latter proposition is one which I cannot accept. Consequently, I am reluctant to associate the reasons of this Court with those of Chabot J. and agree with La Forest J. in this respect in concluding that the trial judge's determination that the Act is not rationally connected to its legislative goal ought to be overturned. I should now like to turn to minimal impairment aspects.

186 Minimal impairment analysis requires this Court to consider whether the legislature turned its mind to alternative and less rights-impairing means to promote the legislative goal in question. In these appeals, I am concerned by the fact that the Attorney General of Canada chose to withhold from the factual record evidence related to the options it had considered as alternatives to the total ban it chose to put in place. It is no answer to this conduct to suggest, as my colleague La Forest J. does, that part of the responsibility for this incomplete factual record lies with the appellants, purportedly owing to the fact that their counsel did not pursue every conceivable legal avenue in order to attempt to secure the publication of the undisclosed documents. I am reluctant to permit the justification of a conceded constitutional violation because of the inability of a party to the litigation to have pursued all possible avenues to obtain the non-disclosed

Canadiens contre les méfaits de l'usage du tabac sur la santé et, dans l'affirmative, (2) si la Loi atteint cet objectif d'une façon qui porte le moins possible atteinte aux droits que la *Charte* garantit aux appelantes.

Le lien rationnel doit être établi, selon la norme de preuve en matière civile, par la raison, la logique ou le simple bon sens. L'existence d'une preuve scientifique n'a une valeur probante que lorsqu'il s'agit d'établir la raison, la logique ou le bon sens. Elle n'est en aucune façon déterminante.

Dans des pourvois comme en l'espèce, dans lesquels il existe une preuve scientifique extrêmement volumineuse, mais généralement non concluante, il est fort important de clarifier la norme sur laquelle doit se fonder l'analyse du lien rationnel. En résumé, le juge Chabot a conclu qu'une grande partie de la preuve scientifique était douteuse et que la Loi était une forme «d'ingénierie sociale». En toute déférence, je ne puis accepter cette dernière conclusion. C'est pourquoi j'hésite à associer les motifs de notre Cour à ceux du juge Chabot et je suis d'accord avec le juge La Forest pour conclure que la décision du juge de première instance portant que la Loi n'a pas de lien rationnel avec son objectif législatif devrait être infirmée. Je traiterai maintenant des aspects de l'atteinte minimale.

Lorsqu'elle analyse l'atteinte minimale, notre Cour doit déterminer si le législateur a examiné d'autres mesures moins attentatoires pour atteindre l'objectif législatif en question. Dans les présents pourvois, je suis préoccupé par le fait que le procureur général du Canada a choisi de ne pas dévoiler la preuve factuelle au dossier concernant les options envisagées comme solutions de rechange à l'interdiction totale que le législateur a choisi de mettre en place. On ne saurait expliquer cette conduite, comme le fait mon collègue le juge La Forest, en affirmant que les appelantes sont en partie responsables de l'existence de ce dossier factuel incomplet, présumément parce que leurs avocats n'ont pas épuisé tous les moyens juridiques possibles pour tenter d'obtenir la publication des documents non divulgués. J'hésite à permettre la justification d'une violation admise de la Constitution parce qu'une partie au litige n'a pas

information. These cases are of wide public interest constitutional litigation in which the government should remain non-adversarial and make full disclosure. Without this requirement, courts will be constrained to decide the constitutionality of legislation without full information. In any event, the burden of proof at the s. 1 stage lies solely with the government.

épuisé tous les moyens possibles pour obtenir les renseignements non divulgués. Il s'agit en l'espèce d'un litige d'un grand intérêt public en matière constitutionnelle, dans lequel le gouvernement ne devrait pas s'en tenir à un débat contradictoire et devrait faire une pleine divulgation. Sinon, les tribunaux seront forcés de trancher la constitutionnalité d'une loi sans avoir tous les renseignements. Quoi qu'il en soit, à l'étape de l'article premier, c'est au gouvernement seul qu'incombe la charge de la preuve.

I underscore that the rights violation in these cases does not involve the prohibition of the sale or consumption of tobacco. It involves the total ban on the advertising of tobacco products. I do not believe that the jurisprudence supports La Forest J.'s conclusion that the impugned *Charter* right, in these cases s. 2(*b*), is minimally impaired because the government chose not to pursue a course of conduct (i.e., prohibiting tobacco products) which bears no relevance to s. 2(*b*), especially when it is clear that this alternative was never, by the government's own admission, feasible or viable.

187 Je tiens à faire ressortir que la violation des droits en l'espèce ne découle pas d'une interdiction de la vente ou de l'usage du tabac, mais plutôt d'une interdiction totale de la publicité en faveur des produits du tabac. Je ne crois pas que la jurisprudence appuie la conclusion du juge La Forest qu'il y a atteinte minimale au droit garanti par la *Charte*, en l'espèce à l'al. 2*b*), parce que le gouvernement a choisi de ne pas opter pour une ligne de conduite (l'interdiction des produits du tabac) qui n'a aucun rapport avec l'al. 2*b*), particulièrement lorsqu'il est évident que cette solution de rechange n'a jamais été, de l'aveu même du gouvernement, possible ou viable.

In my opinion, the question in these appeals is not whether a partial prohibition (the lesser rights-impairing approach) would be acceptable only if there were information establishing that some forms of advertising do not stimulate consumption. On the contrary, it is the total prohibition (the full rights-impairing option) that is only constitutionally acceptable if information is provided that such a total prohibition is necessary in order for the legislation to achieve a pressing and substantial goal. When, as in the case at bar, the evidence is unclear whether a partial prohibition is as effective as a full prohibition, the *Charter* requires that the legislature enact the partial denial of the implicated *Charter* right. In the absence of the discharge of this evidentiary burden (which is to be wholly borne by the government), the least rights-impairing option is to be preferred. Although tobacco advertising as a whole certainly affects consumption, the evidence is unclear whether all types of tobacco ads affect consumption. I believe that some attention

188 À mon avis, la question en l'espèce n'est pas de savoir si une interdiction partielle (la mesure moins attentatoire aux droits) ne serait acceptable que s'il existait des données établissant que certaines formes de publicité n'encouragent pas la consommation. Au contraire, c'est l'interdiction totale (l'option pleinement attentatoire aux droits) qui n'est acceptable du point de vue constitutionnel que s'il existe des renseignements établissant qu'une telle interdiction est nécessaire pour qu'un objectif urgent et réel de la loi soit atteint. Si, comme en l'espèce, la preuve ne permet pas d'établir clairement si une interdiction partielle est aussi efficace qu'une interdiction totale, la *Charte* exige que le législateur opte pour la mesure qui constitue une atteinte partielle au droit garanti par la *Charte*. Lorsque cette preuve n'a pas été établie (dont le fardeau de présentation incombe en totalité au gouvernement), il faut préférer l'option la moins attentatoire. Bien que la publicité du tabac dans son ensemble influe certainement sur la consomma-

must be paid to whether the legislature endeavoured to differentiate the harmful advertising from the benign advertising before it decided to ban all advertising or sought to identify whether, as claimed by the appellants, informational and brand-name advertising do not have the effects that the Act seeks to curb.

189 I agree with La Forest J. that a contextual approach must be taken to s. 1 analysis, and, when reduced to its essence, the impugned right in this case amounts to the ability of tobacco companies to advertise — solely for the purposes of financial profit — a product with known deleterious effects to public health. To this end, the amount of legislative tailoring required to sustain minimal impairment analysis would not be very significant. However, context does not eliminate the need for any tailoring at all. In this appeal, the government chose not to do any tailoring and, ultimately, this constitutes the lynch-pin of the Act's unconstitutionality. I note that the partialness of bans on commercial expression has often been key to their constitutional validity: *Ford v. Quebec (Attorney General)*, [1988] 2 S.C.R. 712; *Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario*, [1990] 2 S.C.R. 232; *Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927.

190 Section 9 of the Act (obliging the placing of unattributed health messages on cigarette packages) raises similar concerns. I find that this provision trenches upon s. 2(*b*) and is unjustifiable under s. 1 and I agree with McLachlin J. in this respect. The question here is whether the reduction of tobacco consumption can be equally advanced by adopting the less intrusive remedy of governmentally attributed warnings or whether such a method would only yield results more modest than the full rights-impairing approach presently adopted by s. 9. Given the evidence before this

tion, la preuve n'établit pas clairement si tous les types de publicité influent sur la consommation. À mon avis, il faut examiner si le législateur s'est efforcé de distinguer la publicité néfaste de la publicité bénigne avant de décider d'imposer une interdiction totale de la publicité ou s'il a cherché à déterminer si, comme le soutiennent les appelantes, la publicité informative et la publicité de marques n'entraînent pas les effets contre lesquels la Loi cherche à lutter.

Je suis d'accord avec le juge La Forest pour dire qu'il faut adopter une analyse contextuelle relativement à l'article premier et que, ramené à sa plus simple expression, le droit attaqué en l'espèce est celui des compagnies de tabac de faire la publicité — strictement à des fins de profits — d'un produit ayant des effets néfastes connus sur la santé publique. À cette fin, le législateur n'aurait pas à faire de très importantes adaptations pour satisfaire à l'analyse de l'atteinte minimale. Cependant, le contexte n'élimine pas la nécessité de toute adaptation. Dans le cadre des présents pourvois, le gouvernement a choisi de ne pas faire d'adaptations et, en fin de compte, c'est là le motif clé pour lequel la Loi est inconstitutionnelle. Je constate que le caractère partiel des interdictions imposées à l'expression commerciale a souvent été la clé de leur constitutionnalité: *Ford c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 R.C.S. 712; *Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario*, [1990] 2 R.C.S. 232; *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927.

L'article 9 de la Loi (qui exige l'apposition de messages non attribués sur les emballages de cigarettes) soulève des préoccupations similaires. À mon avis, cette disposition empiète sur l'al. 2*b*) et ne peut se justifier en vertu de l'article premier, et je suis d'accord avec le juge McLachlin sur ce point. En l'espèce, la question est de savoir si la diminution de l'usage du tabac peut également être encouragée par la mesure moins attentatoire que constituent des messages attribués au gouvernement ou si cette mesure ne donnerait lieu qu'à des résultats plus modestes que la disposition pleinement attentatoire aux droits que constitue l'art. 9. Vu la preuve présentée à notre Cour, j'ai tendance

Court, I am inclined to opt for the lesser rights-impairing approach.

At this juncture, I should like to offer some indication of what sorts of measures would, in my mind, have survived *Charter* scrutiny. As I have already mentioned, it is clear that health warnings can and should be placed on the packages, but the strictures of the *Charter* necessitate that they be attributed to their author, in all likelihood Health and Welfare Canada. Regarding the advertising ban, it is clear to me that an effort could have been made to regulate tobacco advertising along the lines of alcohol advertising. Given that the tobacco companies had agreed as early as 1972 (through the *Voluntary Code*) to refrain from advertising on television and radio, these regulations would only involve advertising in the print media anyway. Alternatively, as evidenced in some of the testimony at trial, partial bans in the order of prohibitions on lifestyle advertising only and limitations on advertising aimed at adolescents could have been given more constructive attention. The main point I wish to make is that in this case we are faced with a total and absolute ban on advertising without a justifiable basis for it. Perhaps proof exists for such a ban, but in my view the record does not establish it.

In the end, I would allow these appeals, with costs throughout to the appellants. For the reasons set out above, ss. 4, 5, 6, 8, and 9 of the Act should be struck. However, I am of the mind, for the reasons I advanced in *Egan*, *supra*, that this, too, is the appropriate case for a suspensive declaration of invalidity of one year. I thus disagree with McLachlin J. in terms of the remedy. Immediately striking down the legislation would permit the tobacco companies the untrammelled ability to advertise until minimally impairing legislation is drafted; the suspensive veto would permit the government to design such legislation while the *status quo* remains in force. In my view, that is warranted in light of the deleterious effects of tobacco prod-

à opter pour la démarche moins attentatoire aux droits.

191 À cette étape, j'aimerais donner des précisions sur les mesures qui, à mon avis, auraient résisté à un examen fondé sur la *Charte*. Comme je l'ai déjà mentionné, il est évident que des messages relatifs à la santé peuvent et doivent être apposés sur les emballages, mais les contraintes de la *Charte* exigent qu'ils soient attribuées à un auteur, en toute vraisemblance Santé et Bien-être social Canada. En ce qui concerne l'interdiction de publicité, il est, à mon avis, clair que l'on aurait pu s'efforcer de réglementer la publicité du tabac de la même façon que celle de l'alcool. Puisque les compagnies de tabac avaient convenu dès 1972 (le *Voluntary Code*) de s'abstenir de faire de la publicité à la télévision et à la radio, ce règlement ne porterait de toute façon que sur la publicité dans la presse écrite. Par ailleurs, comme l'indiquent certains témoignages au procès, on aurait pu s'intéresser de manière plus constructive à une interdiction partielle, sous forme d'interdiction de la publicité de style de vie seulement et de restrictions sur la publicité relative aux adolescents. Je tiens à souligner principalement qu'il s'agit, en l'espèce, d'une interdiction de la publicité totale et absolue, qui n'est pas justifiée. Il existe peut-être une preuve appuyant une telle interdiction mais, à mon avis, elle ne ressort pas du dossier.

192 En définitive, je suis d'avis d'accueillir les pourvois, avec dépens dans toutes les cours en faveur des appelantes. Pour les motifs qui précèdent, les art. 4, 5, 6, 8 et 9 de la Loi devraient être annulés. Cependant, pour les motifs formulés dans l'arrêt *Egan*, précité, je suis d'avis qu'il est également approprié en l'espèce d'ordonner une suspension de l'effet de la déclaration d'invalidité pour une période d'un an. Je ne partage donc pas l'opinion du juge McLachlin quant à la réparation. L'annulation immédiate de la loi aurait pour effet de permettre aux compagnies de tabac de mener librement des campagnes publicitaires jusqu'à l'établissement d'une loi satisfaisant au critère de l'atteinte minimale; par contre, le veto suspensif permettrait au gouvernement de procéder à l'élaboration d'une telle loi et au statu quo de demeurer

ucts on those who use them and on society generally.

The following are the reasons delivered by

193 MAJOR J. — I agree with Justice McLachlin's disposition of these appeals but disagree that Parliament may impose an advertising ban on tobacco products, trade marks, and brand names under its criminal law power.

194 I agree with Justice La Forest that Parliament could prohibit the sale of tobacco products without printed health warnings under its criminal law power but that is not the issue in these appeals.

195 It is undisputed that Parliament may legislate with respect to hazardous, unsanitary, adulterated and otherwise dangerous foods and drugs pursuant to its power to legislate in the field of criminal law.

196 It follows that Parliament can require manufacturers to place warnings on tobacco products which are known to have harmful effects on health. Manufacturers of tobacco products are under a duty to disclose and warn of the dangers inherent in the consumption of tobacco products. Failure to place warnings on tobacco products can validly constitute a crime, a "public wrong" which merits proscription and punishment and ought to be suppressed as "socially undesirable conduct" (*R. v. Morgentaler*, [1993] 3 S.C.R. 463, at p. 488). Section 9 of the *Tobacco Products Control Act*, S.C. 1988, c. 20 ("the Act"), falls within Parliament's power under s. 91(27) of the *Constitution Act, 1867*.

197 However, I do not agree that Parliament under its criminal law power is entitled to prohibit all advertising and promotion of tobacco products and restrict the use of tobacco trademarks as provided for in ss. 4, 5, 6, 8 and 9 of the Act. In *Labatt Breweries of Canada Ltd. v. Attorney General of*

en vigueur. À mon avis, cette mesure se justifie par les effets néfastes des produits du tabac sur ceux qui les utilisent et sur la société en général.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE MAJOR — Je souscris au dispositif proposé par le juge McLachlin en l'espèce, mais je ne puis convenir que le Parlement peut, en vertu de sa compétence en matière de droit criminel, imposer une interdiction sur la publicité en faveur des produits du tabac, de leurs marques et de leurs noms.

À l'instar du juge La Forest, je suis d'avis que le Parlement peut, en vertu de sa compétence en matière de droit criminel, interdire la vente des produits du tabac sur lesquels aucune mise en garde n'a été apposée, mais là n'est pas la question en litige en l'espèce.

Il est incontesté que, conformément à sa compétence en matière de droit criminel, le Parlement peut légiférer relativement aux aliments et drogues dangereux, insalubres ou altérés, ou présentant autrement un danger.

Le Parlement peut par conséquent obliger les fabricants à apposer des mises en garde sur les produits du tabac qui sont reconnus comme nocifs pour la santé. Les fabricants de produits du tabac ont l'obligation de mettre la population en garde contre les dangers inhérents à la consommation des produits du tabac. L'omission d'apposer des mises en garde sur ces produits peut validement constituer un crime, un «méfait public» qui justifie interdiction et sanctions et qui doit être enrayé puisqu'il constitue un «acte socialement indésirable» (*R. c. Morgentaler*, [1993] 3 R.C.S. 463, à la p. 488). L'article 9 de la *Loi réglementant les produits du tabac*, L.C. 1988, ch. 20 (la «Loi»), relève de la compétence du Parlement en vertu du par. 91(27) de la *Loi constitutionnelle de 1867*.

Par contre, je ne crois pas qu'en vertu de sa compétence en matière de droit criminel, le Parlement puisse interdire toute publicité et promotion en faveur des produits du tabac et restreindre l'utilisation des marques de tabac comme le prévoient les art. 4, 5, 6, 8 et 9 de la Loi. Dans l'arrêt *Brasse-*

Canada, [1980] 1 S.C.R. 914, the test should be one of substance, not form, and excludes from the criminal jurisdiction legislative activity not having the prescribed characteristics of criminal law. It is not always easy to determine whether legislation comes within the purview of Parliament's criminal law power. Cory J. described this difficulty in *Knox Contracting Ltd. v. Canada*, [1990] 2 S.C.R. 338, at p. 347:

> As a point of commencement, it may be helpful to consider what constitutes criminal law. While, like a work of art, it is something that may be easier to recognize than define, some guidelines have been established.

Cory J., at p. 348, then referred to the reasons of Rand J. in *Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act*, [1949] S.C.R. 1 (the *Margarine Reference*), which he found to be a "very helpful definition of criminal law" and referred with approval to the dissenting reasons in *R. v. Hauser*, [1979] 1 S.C.R. 984, *per* Dickson J. (as he then was) at p. 1026:

> Head 27 of s. 91 of the *British North America Act* empowers Parliament to make substantive laws prohibiting, with penal consequences, acts or omissions considered to be harmful to the State, or to persons or property within the State.

The approach taken by this Court in *Knox Contracting*, *supra*, provides a solid foundation for defining the scope of Parliament's criminal law power.

In discussing the *Margarine Reference*, Professor Hogg notes that legislation which merely contains a prohibition and a consequent penalty cannot be upheld as a valid exercise of Parliament's criminal law power unless the legislation also addresses a "typically criminal public purpose" (*Constitutional Law of Canada* (3rd ed. 1992), at p. 18-5). The "typically criminal public purpose" can be determined in part by considering whether the act or omission is sufficiently harmful to the state, or

ries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914, le critère applicable devrait s'intéresser au fond et non à la forme, et il exclut de la compétence en matière de droit criminel toute activité législative qui ne revêt pas les caractéristiques requises du droit criminel. Il n'est pas toujours aisé de déterminer si un texte de loi s'inscrit dans le cadre de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. Le juge Cory a exposé ainsi la difficulté dans l'arrêt *Knox Contracting Ltd. c. Canada*, [1990] 2 R.C.S. 338, à la p. 347:

> Tout d'abord, il peut être utile d'examiner en quoi consiste le droit criminel. Bien que, comme une œuvre d'art, il s'agisse de quelque chose qui peut être plus facile à reconnaître qu'à définir, certaines lignes directrices ont été établies.

Le juge Cory cite ensuite, à la p. 348, un passage des motifs prononcés par le juge Rand dans *Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act*, [1949] R.C.S. 1 (le *Renvoi sur la margarine*), où l'on trouve à son avis une «définition très utile du droit criminel», puis il renvoie en les approuvant aux motifs du juge Dickson (plus tard Juge en chef), dissident dans l'arrêt *R. c. Hauser*, [1979] 1 R.C.S. 984, à la p. 1026:

> Le paragraphe 27 de l'art. 91 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique* habilite le Parlement à édicter des lois qui interdisent, sous peine de sanctions pénales, des actes ou omissions jugés préjudiciables à l'État, à des personnes ou à des biens y situés.

La position adoptée par notre Cour dans l'arrêt *Knox Contracting*, précité, fournit une assise solide aux fins de cerner l'étendue de la compétence du Parlement en matière de droit criminel.

198 Dans son analyse du *Renvoi sur la margarine*, le professeur Hogg remarque que la loi qui ne contient qu'une simple interdiction à laquelle est assortie une sanction pénale ne peut être considérée comme un exercice valide de la compétence du Parlement en matière de droit criminel que si cette loi vise également un [TRADUCTION] «objectif public habituellement reconnu du droit criminel» (*Constitutional Law of Canada* (3e éd. 1992), à la p. 18-5). On pourra établir en partie ce qu'est un

to persons or property within the state to warrant the exercise of Parliament's criminal law power.

199 In *Boggs v. The Queen*, [1981] 1 S.C.R. 49, it was held to be beyond Parliament's criminal power to impose criminal sanctions for infractions of a variety of provincial regulations such as failure to pay insurance premiums, civil judgments, taxes and licence fees. Licence suspensions are not related to the owner's ability to drive or to public safety on the highways, and hence criminal penalties flowing from their breach are *ultra vires* Parliament. Although Parliament's power to legislate in the field of criminal law is broad, it is subject to constitutional limits.

200 A definitive and all-encompassing test to determine what constitutes a "criminal offence" remains elusive but the activity which Parliament wishes to suppress through criminal sanction must pose a significant, grave and serious risk of harm to public health, morality, safety or security before it can fall within the purview of the criminal law power. While there is a range of conduct between the most and less serious, not every harm or risk to society is sufficiently grave or serious to warrant the application of the criminal law.

201 The heart of criminal law is the prohibition of conduct which interferes with the proper functioning of society or which undermines the safety and security of society as a whole. *Reference re Alberta Statutes*, [1938] S.C.R. 100, held that a crime is a public wrong involving a violation of the public rights and duties to the whole community, considered as a community, in its social aggregate capacity. Matters which pose a significant and serious risk of harm or which cause significant and serious

«objectif public habituellement reconnu du droit criminel» en déterminant si l'acte ou l'omission est suffisamment préjudiciable à l'État, à des personnes ou à des biens y situés, pour justifier l'exercice par le Parlement de sa compétence en matière de droit criminel.

Dans l'arrêt *Boggs c. La Reine*, [1981] 1 R.C.S. 49, on a conclu que la compétence du Parlement en matière criminelle ne lui permettait pas d'imposer des sanctions pénales relativement à des infractions commises contre divers règlements provinciaux, comme l'omission de payer des primes d'assurance, un montant alloué par un jugement civil, une taxe ou un droit de délivrance d'un permis. Les suspensions de permis n'ont pas de rapport avec la capacité de conduire ou la sécurité du public sur les routes, de sorte que les sanctions pénales assorties à leur non-respect excèdent les pouvoirs du Parlement. Bien que le pouvoir de ce dernier de légiférer en matière criminelle soit vaste, il est assujetti à certaines limites constitutionnelles.

Il demeure impossible d'établir un critère définitif et exhaustif qui permette de déterminer ce qui constitue une «infraction criminelle» mais, pour qu'elle puisse tomber sous le coup de la compétence en matière de droit criminel, l'activité que le Parlement souhaite réprimer à l'aide d'une sanction pénale doit présenter un risque de préjudice grave et important pour la santé du public, sa moralité ou sa sécurité. S'il existe une gamme de comportements entre celui qui est le plus grave et celui qui l'est le moins, ce ne sont pas tous les préjudices ou dangers pour la société qui sont suffisamment graves et importants pour justifier l'application du droit criminel.

Au cœur du droit criminel se situe l'interdiction du comportement qui entrave le bon fonctionnement de la société ou qui compromet la sécurité de la société considérée dans son ensemble. Dans *Reference re Alberta Statutes*, [1938] R.C.S. 100, la Cour a conclu qu'un crime est un méfait public qui implique la violation des droits et des devoirs publics envers la collectivité tout entière, considérée comme telle, dans sa capacité d'agir en tant que collectivité. Tout ce qui pose un risque de pré-

harm to public health, safety or security can be proscribed by Parliament as criminal.

Consequently, lesser threats to society and its functioning do not fall within the criminal law, but are addressed through non-criminal regulation, either by Parliament or provincial legislatures, depending on the subject matter of the regulation.

The regulation of manipulative children's advertising was upheld as *intra vires* the province in *Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927, even though the impugned legislation contained sanctions that included fines and possible imprisonment. While manipulative children's advertising exposes society to some harms, those harms are not sufficient to attract the sanction of the criminal law. In the same way, we must consider whether the ban on tobacco advertising is essentially a regulatory matter within provincial competence, or whether tobacco advertising truly constitutes criminal conduct, a public wrong which Parliament is entitled to punish as harmful, socially undesirable conduct violative of public rights and duties.

Sopinka J. in *Morgentaler*, *supra*, stated that to find a valid exercise of Parliament's criminal law power, the presence of a criminal public purpose or object is pivotal. I agree that criminal law is not frozen in time. Parliament can decriminalize what once was thought criminal, and can also criminalize conduct which was not part of the criminal law at the time of Confederation. I disagree that affinity with a traditional criminal law concern has no part to play in the analysis, whether the conduct proscribed by Parliament has an affinity with a traditional criminal law concern is a starting point in determining whether a particular matter comes within federal criminal competence. Cases such as *Morgentaler*, *supra*, and *Knox Construction*, *supra*, demonstrate that courts will often look for

judice grave et important ou qui entraîne pour la sécurité et la santé du public un préjudice grave ou important peut être interdit par le Parlement comme relevant du droit criminel.

202 Par conséquent, les menaces moins graves pour la société et son fonctionnement ne relèvent pas du droit criminel; elles sont toutefois ciblées dans les régimes de réglementation qui ne relèvent pas du droit criminel, soit par le Parlement, soit par les législatures provinciales, selon le sujet que vise le règlement.

203 Dans l'arrêt *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927, la Cour a jugé que le règlement relatif à la publicité manipulatrice destinée aux enfants relevait de la compétence de la province même s'il prévoit des sanctions telles des amendes et le risque d'emprisonnement. Si la publicité manipulatrice destinée aux enfants expose la société à certains préjudices, ceux-ci ne sont pas suffisamment graves pour que l'on fasse appel au droit criminel. De la même façon, il nous faut considérer si l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac est dans son essence un sujet de réglementation qui relève de la compétence provinciale ou si la publicité en faveur des produits du tabac est véritablement un acte criminel, un méfait public que le Parlement a le droit de punir parce qu'il constitue un comportement préjudiciable, socialement indésirable et contraire aux droits et aux devoirs publics.

204 Dans l'arrêt *Morgentaler*, précité, le juge Sopinka a indiqué que, pour qu'un exercice par le Parlement de sa compétence en matière de droit criminel soit valide, l'existence d'un objectif public touchant le droit criminel est primordiale. Je conviens que le droit criminel n'est pas immuable. Le Parlement peut décriminaliser ce qui autrefois était jugé criminel et peut d'autre part criminaliser un comportement qui ne ressortissait pas au droit criminel à l'époque de la Confédération. Je ne peux convenir que l'existence d'une affinité avec une préoccupation traditionnelle du droit criminel ne joue aucun rôle dans l'analyse, puisque la question de savoir si le comportement interdit par le Parlement a une affinité avec une préoccupation traditionnelle du droit criminel est le point de

an affinity with a traditional criminal law concern, or affinity with activities historically recognized as criminal, to determine whether a certain exercise of legislative power falls within the field of criminal law.

205 In *Devine v. Quebec (Attorney General)*, [1988] 2 S.C.R. 790, at p. 811, the Court noted that the prohibition on the use of language in and of itself did not have an affinity with some traditional criminal law concern such as morality or public order.

206 Parliament has the power to make certain kinds of speech criminal, such as sedition and obscenity. These types of speech have an affinity with traditional criminal law concerns. These two examples are not determinative, but demonstrate the presence of a typically criminal public purpose where the speech in question causes serious harm or a serious risk of harm to society. In contrast, it is difficult to see how tobacco advertising causes the same type of harm.

207 In his reasons, La Forest J. states that the "evil targeted by Parliament is the detrimental health effects caused by tobacco consumption" (para. 30). McLachlin J. writes that "[c]are must be taken not to overstate the objective" (para. 144). I endorse her conclusion that, if the objective is stated too broadly, its importance may be exaggerated and the analysis compromised.

208 The objective of the advertising ban and trade mark usage restrictions, as stated by McLachlin J., is to prevent Canadians from being persuaded by advertising and promotion to use tobacco products.

départ de l'analyse visant à déterminer si un sujet donné relève de la compétence du Parlement en matière criminelle. Des arrêts comme *Morgentaler* et *Knox Construction*, précités, démontrent que, pour déterminer si un exercice donné du pouvoir de légiférer s'inscrit dans le domaine du droit criminel, les tribunaux chercheront souvent une affinité avec une préoccupation traditionnelle du droit criminel ou une affinité avec des activités qui, dans le passé, ont été reconnues comme étant criminelles.

Dans l'arrêt *Devine c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 R.C.S. 790, à la p. 811, la Cour a signalé que l'interdiction relative à l'utilisation en soi d'une langue n'a aucune affinité en soi avec un sujet traditionnel du droit criminel comme la moralité ou l'ordre public.

Le Parlement a le pouvoir de qualifier de criminelles certaines formes d'expression, comme la sédition et l'obscénité. Ces formes d'expression ont des affinités avec des préoccupations traditionnelles du droit criminel. Si ces deux exemples ne sont pas déterminants, ils démontrent toutefois l'existence d'un objectif public habituellement reconnu du droit criminel, où l'expression en cause entraîne un préjudice grave ou un risque grave de préjudice à la société. Par contre, il est difficile de voir comment la publicité en faveur des produits du tabac peut causer pareil préjudice.

Dans ses motifs, le juge La Forest indique que «le mal visé par le Parlement est l'effet nocif de l'usage du tabac sur la santé» (par. 30). Le juge McLachlin écrit pour sa part qu'«[i]l faut veiller à ne pas surestimer l'objectif» (par. 144). Je partage son avis lorsqu'elle conclut que, si l'on formule l'objectif d'une façon trop large, on risque d'en exagérer l'importance et d'en compromettre l'analyse.

L'objectif de l'interdiction de publicité et des restrictions à l'usage des marques, ainsi que l'écrit le juge McLachlin, est d'empêcher la population canadienne de se laisser convaincre par la publicité et la promotion de faire usage du tabac. En toute déférence, je ne puis convenir avec le juge

I respectfully disagree with La Forest J. that this type of persuasion constitutes criminal conduct.

Tobacco advertising and promotion may encourage some people to start or to continue to smoke. For that reason, it is viewed by many as an undesirable form of commercial expression. I do not disagree that it may be an undesirable form of expression, but is this undesirability sufficient to make such expression criminal? Does tobacco advertising pose a significant, grave and serious danger to public health? Or does it simply encourage people to consume a legal but harmful product? I cannot agree that the commercial speech at issue poses such a significant, grave and serious danger to public health to fall within the purview of the federal criminal law power. In my opinion, the Act is too far removed from the injurious or undesirable effects of tobacco use to constitute a valid exercise of Parliament's criminal law power. Legislation prohibiting all advertising of a product which is both legal and licensed for sale throughout Canada lacks a typically criminal public purpose and is *ultra vires* Parliament under s. 91(27) of the *Constitution Act, 1867*. Such advertising can hardly be considered to be a public wrong involving a violation of public rights and duties to the whole community, the type of conduct that Parliament is entitled to proscribe and punish as harmful and socially undesirable under its criminal law power.

Parliament could have criminalized tobacco use, but has chosen not do so for a variety of reasons. The Act does not directly address the injurious or undesirable effects of tobacco use. La Forest J., in response to this concern, notes that in some circumstances Parliament has criminalized ancillary activities without criminalizing the core activity itself, and that this Court has upheld such measures as a valid exercise of the criminal law power. With respect, the cases cited by La Forest J. — *Reference re ss. 193 and 195.1(1)(c) of the Criminal Code (Man.)*, [1990] 1 S.C.R. 1123 (solicitation

La Forest que ce genre de persuasion constitue un comportement criminel.

209 Il se peut que la publicité et la promotion en faveur du tabac incitent certaines personnes à commencer ou à continuer à fumer. Pour cette raison, plusieurs considèrent qu'il s'agit là d'une forme indésirable d'expression commerciale. J'admets qu'il puisse s'agir d'une forme indésirable d'expression, mais est-ce suffisant pour la rendre criminelle? La publicité en faveur du tabac présente-t-elle un risque grave et important pour la santé publique? Ou encourage-t-elle simplement les gens à consommer un produit légal, mais nocif? Je ne peux convenir que le discours commercial en question présente un risque grave et important pour la santé publique au point qu'il est assujetti à la compétence fédérale en matière de droit criminel. À mon avis, la Loi est trop éloignée des effets nocifs ou indésirables de l'utilisation du tabac pour constituer un exercice valide de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. Une loi qui interdit toute publicité en faveur d'un produit légal dont la vente est réglementée partout au Canada est dénuée d'un objectif public habituellement reconnu du droit criminel et excède les pouvoirs du Parlement sous le régime du par. 91(27) de la *Loi constitutionnelle de 1867*. On peut difficilement considérer cette publicité comme un méfait public impliquant la violation des droits et des devoirs publics envers la collectivité tout entière, le genre de comportement que le Parlement peut interdire et punir, conformément à sa compétence en matière de droit criminel, parce qu'il est socialement préjudiciable et indésirable.

210 Le Parlement aurait pu criminaliser l'usage du tabac, mais il a choisi de ne pas le faire pour de multiples raisons. La Loi ne vise pas directement les effets nocifs ou indésirables de l'usage du tabac. En réponse à cet argument, le juge La Forest fait remarquer que, dans certaines circonstances, le Parlement a criminalisé des activités secondaires sans criminaliser l'activité principale même, et que notre Cour a confirmé que l'adoption de telles mesures était un exercice valide de la compétence en matière de droit criminel. Avec égards, les arrêts cités par le juge La Forest — *Renvoi relatif à*

for the purposes of prostitution and the operation of bawdy houses) and *Rodriguez v. British Columbia (Attorney General)*, [1993] 3 S.C.R. 519 (prohibition on assisted suicide) — concern matters which have traditionally been subject to criminal sanctions. Moreover, the "ancillary" activities proscribed in the above two examples pose significant and serious dangers in and of themselves.

211 It is well known that crime often follows in the wake of prostitution and its related activities. It is also well known that assisted suicide can engender all manner of evils, not the least of which is involuntary euthanasia. Hence the criminalization of solicitation of prostitution where prostitution itself is legal, or the criminalization of assisted suicide where suicide itself is legal does not provide a useful analogy to the criminalization of tobacco advertising where tobacco consumption is legal. The fact that the "ancillary" activities in the *Prostitution Reference* and in *Rodriguez* of themselves pose serious risks of harm to society makes the analogy less than compelling.

212 Since Parliament has chosen not to criminalize tobacco use, it is difficult to understand how tobacco advertising can somehow take on the character of criminal activity. The Act does not deal in any way with the regulation or prohibition of dangerous products or drugs. The underlying "evil" of tobacco use which the Act is designed to combat remains perfectly legal. Tobacco advertising is in itself not sufficiently dangerous or harmful to justify criminal sanctions. In my view, it is beyond Parliament's competence to criminalize this type of speech where Parliament has declined to criminalize the underlying activity of tobacco use.

213 On a final note, La Forest J. addressed the exemptions contained within the Act, most notably the exemption for foreign periodicals. He concluded that notwithstanding the exemptions,

l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 (sollicitation à des fins de prostitution et tenue d'une maison de débauche), et *Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)*, [1993] 3 R.C.S. 519 (prohibition de l'aide au suicide) — portent tous deux sur des sujets qui ont toujours fait l'objet de sanctions pénales. En outre, les activités «secondaires» interdites dans les deux exemples qui précèdent comportent en elles-mêmes des dangers graves et importants.

Il est bien connu que la prostitution et les activités qui y sont liées entraînent souvent dans leur sillage une certaine criminalité. Il est également bien connu que l'aide au suicide peut engendrer toutes sortes de maux, dont l'euthanasie involontaire n'est pas le moindre. La criminalisation de la sollicitation à des fins de prostitution lorsque la prostitution même est légale, ou la criminalisation de l'aide au suicide lorsque le suicide même est légal, n'offre donc aucune analogie utile quant à la criminalisation de la publicité en faveur du tabac alors que la consommation du tabac est légale. Le fait que les activités «secondaires» dans le *Renvoi sur la prostitution* et dans l'arrêt *Rodriguez* posent en elles-mêmes des risques graves de préjudice à la société rend l'analogie moins que convaincante.

Puisque le Parlement a choisi de ne pas criminaliser l'usage du tabac, il est difficile de comprendre comment la publicité en faveur du tabac peut d'une quelconque façon revêtir le caractère d'une activité criminelle. La Loi ne porte pas du tout sur la réglementation ou l'interdiction de produits dangereux ou de drogues. Le «mal» sous-jacent à l'usage du tabac que la Loi vise à combattre demeure parfaitement légal. La publicité en faveur du tabac en elle-même n'est pas suffisamment dangereuse ou préjudiciable pour justifier l'existence de sanctions pénales. À mon avis, il ne relève pas de la compétence du Parlement de criminaliser cette forme de discours lorsqu'il a refusé de criminaliser l'activité principale, soit l'usage du tabac.

Enfin, le juge La Forest s'est penché sur les exemptions prévues dans la Loi, plus particulièrement l'exemption concernant les publications étrangères. Il conclut que, nonobstant ces exemp-

tobacco advertising still constitutes criminal law. I disagree. La Forest J. cites a number of cases, such as *Morgentaler v. The Queen*, [1976] 1 S.C.R. 616, and *R. v. Furtney*, [1991] 3 S.C.R. 89, for the proposition that exemptions in criminal legislation do not take away from the legislation's criminal character. While exemptions do not necessarily take a statute out of criminal law, broadly based exemptions are a factor which may lead a court to conclude that the proscribed conduct is not truly criminal. Both *Morgentaler* (dealing with abortion) and *Furtney* (dealing with gambling) involved conduct which has traditionally been viewed as criminal. The exemptions could not be described as "broadly based". For example, the *Criminal Code* only allowed abortions to be performed in limited circumstances and under strict conditions and guidelines. While the legislation may not have been applied uniformly at hospitals throughout the country, Parliament could still validly decide that abortion in general was criminal and could only be performed in hospitals in accordance with statutory requirements.

tions, la publicité en faveur du tabac demeure une matière qui relève du droit criminel. Je ne suis pas d'accord. Le juge La Forest cite certains arrêts, dont *Morgentaler c. La Reine*, [1976] 1 R.C.S. 616, et *R. c. Furtney*, [1991] 3 R.C.S. 89, pour soutenir que les exemptions prévues dans une loi en matière criminelle ne retirent pas à la loi son caractère criminel. Si les exemptions ne retirent pas nécessairement une loi du cadre criminel, l'existence d'exemptions générales est un facteur qui peut mener un tribunal à conclure que le comportement interdit n'est pas véritablement criminel. Aussi bien l'arrêt *Morgentaler* (concernant l'avortement) que l'arrêt *Furtney* (concernant le jeu) portaient sur un comportement qui a toujours été considéré comme criminel. Les exemptions ne pouvaient être qualifiées de «générales». Ainsi, le *Code criminel* n'autorisait les avortements que s'ils étaient pratiqués dans certaines circonstances et suivant des conditions et des directives strictes. Bien que la loi puisse ne pas avoir été appliquée de façon uniforme dans les hôpitaux du pays, le Parlement pouvait quand même validement décider que l'avortement en général était criminel et ne pouvait être pratiqué que dans les hôpitaux conformément aux exigences prescrites dans la loi.

In *Furtney*, unrestricted and unregulated gambling could be seen as engaging a typically criminal public purpose because of the harm to society that often flows from gambling and its related activities. The fact that properly licensed and regulated gambling, such as bingo, could be exempted from the criminal law did not take away from the criminal public purpose engaged by the general prohibition on gambling. The exemptions discussed in the above two cases are limited in nature and the scope of activities that remained criminalized still engaged a typically criminal public purpose.

214 Dans *Furtney*, on a considéré qu'on pouvait envisager que le jeu non restreint et non réglementé engage un objectif public reconnu du droit criminel en raison du préjudice que le jeu et les activités qui s'y rattachent causent fréquemment à la société. Le fait qu'un jeu valablement réglementé et assujetti à l'obtention d'un permis, par exemple le bingo, puisse être exempté de l'application du droit criminel, ne diminue en rien l'objectif public de droit criminel qui sous-tend l'interdiction générale visant le jeu. Les exemptions analysées dans les deux affaires précitées sont limitées en nature et la portée des activités qui demeurent criminalisées engage toujours un objectif public reconnu du droit criminel.

In these appeals, McLachlin J. notes that despite the advertising ban, 65 percent of the Canadian magazine market will contain tobacco advertisements, given that the ban applies only to Canadian media and not to imported publications. The

215 Dans les présents pourvois, le juge McLachlin signale qu'en dépit de l'interdiction de publicité, 65 pour 100 du marché des revues au Canada contiendra de la publicité en faveur du tabac puisque l'interdiction ne s'applique qu'aux médias cana-

exemptions for advertising cannot be seen as being limited in nature because most Canadians will be exposed to advertising for tobacco products in newspapers, magazines and so forth. It is hard to understand how the respondent on the one hand claims that nothing short of a total ban will accomplish the goal of reducing tobacco consumption while at the same time the Act allows a very significant amount of advertising to enter the country. It is difficult to imagine how tobacco advertising produced by the United States or other countries and distributed in Canada through publications somehow becomes criminal when produced and distributed by Canadians. The broadly based exemptions contained in the Act, combined with the fact that the Act does not engage a typically criminal public purpose, leads to the conclusion that the prohibitions on advertising cannot be upheld as a valid exercise of Parliament's criminal law power.

diens et non aux publications importées au Canada. Les exemptions quant à la publicité ne peuvent être considérées comme étant limitées puisque la plupart des Canadiens seront exposés à la publicité en faveur des produits du tabac dans des journaux, des revues et le reste. Il est difficile de comprendre comment l'intimé peut soutenir d'une part, qu'il faut une interdiction générale, rien de moins, pour réaliser l'objectif qui consiste à réduire la consommation du tabac alors que, d'autre part, la Loi permet qu'une quantité considérable de publicité soit introduite au pays. On peut difficilement imaginer comment la publicité en faveur du tabac produite par les États-Unis ou d'autres pays et distribuée au Canada par voie de publications devient en quelque sorte criminelle lorsqu'elle est produite et distribuée par des Canadiens. L'existence d'exemptions générales prévues dans la Loi, combinée au fait qu'elle ne relève pas d'un objectif public habituellement reconnu du droit criminel, porte à conclure que les interdictions sur la publicité ne peuvent être maintenues à titre d'exercice valide de la compétence du Parlement en matière de droit criminel.

216 The Act, except for s. 9 and its associated provisions relating to mandatory health warnings on tobacco packaging, cannot be upheld as valid criminal legislation. The Act is a regulatory measure aimed at decreasing tobacco consumption. While Parliament's desire to limit tobacco advertising may be desirable, its power to do so cannot be found in s. 91(27) of the *Constitution Act, 1867*.

La Loi, à l'exception de l'art. 9 et de ses dispositions accessoires relatives aux mises en garde obligatoires sur les emballages, ne peut être maintenue comme étant une loi valide en matière criminelle. La Loi est une mesure de réglementation qui vise à diminuer la consommation du tabac. Bien que la volonté du Parlement de restreindre la publicité en faveur du tabac puisse être souhaitable, le par. 91(27) de la *Loi constitutionnelle de 1867* ne lui confère pas le pouvoir de le faire.

217 In the Court of Appeal ((1993), 102 D.L.R. (4th) 289), Brossard J.A. held at p. 352 that the Act fell within the federal parliament's power to legislate for the "peace, order and good government" of Canada as the Act met national dimensions. I agree. Inasmuch as the legislations fails in any event for the reasons of McLachlin J., it is unnecessary to come to any conclusion on this point.

Le juge Brossard de la Cour d'appel ([1993] R.J.Q. 375) a conclu, à la p. 416, que la Loi relevait de la compétence du Parlement de légiférer pour la «paix, l'ordre et le bon gouvernement» du Canada puisqu'elle revêt des dimensions nationales. Toutefois, je suis d'accord que, puisque les dispositions législatives sont de toute façon invalides pour les motifs formulés par le juge McLachlin, il est inutile de tirer quelque conclusion à cet égard.

Appeals allowed, LA FOREST, L'HEUREUX-DUBÉ, GONTHIER *and* CORY JJ. *dissenting. The first*

Pourvois accueillis, les juges LA FOREST, L'HEUREUX-DUBÉ, GONTHIER *et* CORY *sont dissi-*

constitutional question dealing with the legislative competence of Parliament to enact the legislation under the criminal law power or for the peace, order and good government of Canada should be answered in the positive. With respect to the second constitutional question, ss. 4 (re advertising), 8 (re trade mark use) and 9 (re unattributed health warnings) of the Act are inconsistent with the right of freedom of expression as set out in s. 2(b) of the Charter and do not constitute a reasonable limit on that right as can be demonstrably justified pursuant to s. 1 thereof. La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier and Cory JJ. would find that they constitute a reasonable limit. Given that ss. 5 (re retail displays) and 6 (re sponsorships) could not be cleanly severed from ss. 4, 8 and 9, all are of no force or effect pursuant to s. 52 of the Constitution Act, 1982.

Solicitors for the appellant RJR-MacDonald Inc.: Mackenzie, Gervais, Montreal.

Solicitors for the appellant Imperial Tobacco Ltd.: Ogilvy, Renault, Montreal.

Solicitors for the respondent the Attorney General of Canada: Côté & Ouellet, Montreal.

Solicitor for the mis-en-cause the Attorney General of Quebec: The Attorney General of Quebec, Ste-Foy.

Solicitor for the intervener the Attorney General for Ontario: The Attorney General for Ontario, Toronto.

Solicitors for the intervener the Heart and Stroke Foundation of Canada: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.

Solicitors for the intervener the Canadian Cancer Society: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.

Solicitors for the intervener the Canadian Council on Smoking and Health: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.

dents. La première question constitutionnelle sur la compétence du Parlement de légiférer en matière de droit criminel ou pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada reçoit une réponse positive. Pour ce qui est de la seconde question constitutionnelle, les art. 4 (la publicité), 8 (les marques) et 9 (les messages non attribués relatifs à la santé) de la Loi sont incompatibles avec le droit à la liberté d'expression garanti à l'al. 2b) de la Charte et n'apportent pas une limite raisonnable à l'exercice de ce droit, dont la justification puisse se démontrer au sens de l'article premier. Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory sont d'avis qu'ils apportent une limite raisonnable. Vu que les art. 5 (commerce au détail) et 6 (parrainage) ne peuvent pas nettement être distingués des art. 4, 8 et 9, ils sont tous inopérants aux termes de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Procureurs de l'appelante RJR-MacDonald Inc.: Mackenzie, Gervais, Montréal.

Procureurs de l'appelante Imperial Tobacco Ltd.: Ogilvy, Renault, Montréal.

Procureurs de l'intimé le procureur général du Canada: Côté & Ouellet, Montréal.

Procureur du mis en cause le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste-Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureurs de l'intervenante la Fondation des maladies du cœur du Canada: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.

Procureurs de l'intervenante la Société canadienne du cancer: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.

Procureurs de l'intervenant le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.

Solicitors for the intervener the Canadian Medical Association: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.

Solicitors for the intervener the Canadian Lung Association: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.

Procureurs de l'intervenante l'Association médicale canadienne: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.

Procureur de l'intervenante l'Association pulmonaire du Canada: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.